TEORIA DE LA LEY[1]

Sumario:
1.- Origen de la palabra ley. 2.- Definición de ley. 2.1. Definición de ley del Código Civil. 2.2. Definiciones doctrinarias. 3.- Requisitos externos e internos de la ley. 3.1. Requisitos externos. 3.2. Requisitos internos. 4.- Características de la ley. 5.- Clasificación de las leyes. 5.1. Leyes prohibitivas e imperativas. 5.2. Leyes dispositivas. 5.3. Leyes materiales y formales. 5.4. Leyes perfectas, más que perfectas, menos perfectas e imperfectas. 6.- Jerarquía de las normas jurídicas. 6.1. Escala jerárquica de las normas. 6.2. Factores en virtud de los cuales se jerarquizan las normas. 7.- Constitucionalidad de la ley. 7.1. Constitucionalidad de fondo y forma. 7.2. Efectos de las leyes inconstitucionales. 7.3. El control de la constitucionalidad en Chile. 8.- La potestad reglamentaria. 8.1. Concepto. 8.2. Limitaciones en el ejercicio de la potestad reglamentaria. 8.3. Autoridades administrativas con potestad reglamentaria. 8.4. Amplitud de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. 8.5. Decretos en general y decretos supremos. 8.6. Reglamentos y simples decretos. 8.7. Clases de decretos supremos, de conformidad a la función que desempeñan. 8.8. Firmas que deben llevar los decretos. 8.9. Control de constitucionalidad y de legalidad de los decretos supremos y resoluciones. 8.10. Semejanzas y diferencias entre la ley y el decreto. 8.11. Las resoluciones, instrucciones o circulares. 8.12. Las ordenanzas. 9.- Decretos con fuerza de ley y decretos leyes. 9.1. Decretos con fuerza de ley. 9.2. Decretos leyes. 10.- Interpretación de la ley. 10.1. Generalidades. 10.2. Normas de interpertación en el Código Civil. 10.3. Hermenéutica legal y sistemas de interpretación. 10.4. Diversas clases de interpretación. 10.5. Elementos de interpretación. 10.6. Especies de interpretación. 10.7. Métodos de interpretación. 10.8. Interpretación pública o por vía de autoridad. 10.9. Elementos de interpretación de las leyes establecidos en el Código Civil. 11.- Integración de la ley. 11.1. Cuando debe "integrarse" la ley. 11.2. Normas que ordenan integrar la ley. 11.3. Cómo debe integrarse la ley. 12.- Efectos de la ley. 12.1. Efectos de la ley en cuanto al tiempo. 12.2. Efectos de la ley en cuanto al territorio. Bibliografía. Cuestionario.

1.- Origen de la palabra ley.

La palabra "ley" deriva del latín *lex*. Tiene su origen la última en la raíz indoeuropea *leg*, que expresa dos ideas:
i.- Por una parte, expresa la idea de *legere*, en cuanto a *elegir* o *escoger*. Como expresa Claro Solar, "En su etimología la palabra ley viene de *legere*, elegir, porque el legislador elige entre las reglas de conducta aquéllas que considera mejores al bienestar común de la sociedad".[2]
ii.- Por otra parte, denota la palabra *lex* la idea de *leer*. Es decir, la fórmula previamente elegida, era después escriturada, para que todos (teóricamente) pudieran leerla, entenderla y acatarla.

En su origen, la palabra *lex* era un vocablo religioso y se refería a las fórmulas elegidas para llevar a cabo un rito. Más tarde, pasó al ámbito jurídico, para denotar *aquello que se lee*, es decir, el precepto fijado por medio de la escritura, en contraposición a *mores*, la costumbre, es decir, el precepto que no ha sido escrito. En las lenguas semíticas, ley es lo mismo que escritura. La palabra griega equivalente a

[1] Fecha de última modificación: 12 de febrero de 2026.
[2] Claro Solar, Luis (1898), *Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, De las Personas*, Tomo Primero, Santiago de Chile, Establecimiento Poligráfico Roma, Nº 45, p. 29.

ley es *nomos*, que deriva de *nomo*, atribuir, adjudicar, en el sentido de ley como forma de justicia que distribuye o retribuye.

Es sugerente el origen religioso de la palabra, que confirma que, en los tiempos primitivos, el Derecho y la ley se establecían por los sacerdotes. Ellos eran, por lo demás, los que tenían una mayor instrucción y sabían leer y escribir, a diferencia de la gran mayoría de la población. Los sacerdotes, de esta manera, recitaban los preceptos jurídicos, que el pueblo memorizaba desde la niñez.

La palabra ley, de esta manera, en el ámbito jurídico, envuelve en su origen la idea de un precepto escrito destinado a un fin justo.

De *lex* deriva el genitivo *legis*. Quien crea la ley es el *legislador*, de *legis* y *lator*, palabra ésta última que alude "al que lleva". El legislador, por ende, es quien lleva la ley, quien la crea para que se instaure en la sociedad.

2.- Definición de ley.

1.1. Definición de ley del Código Civil.

Art. 1: "La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite".

La definición sugiere las siguientes observaciones:

a) Se trata de una declaración: no hay ley, sino en la medida en que se formule una exposición, que por cierto ha de ser escrita y como se verá, debidamente comunicada a la nación.

b) La declaración debe ser hecha por quienes representan la voluntad soberana: según veremos, el pueblo delega la soberanía que en él reside en el Poder Legislativo. A éste le corresponde por tanto formular la declaración que se convertirá en ley.

c) Dicha declaración, formulada por el aludido Poder, debe ser hecha ateniéndose a un determinado procedimiento: aquél establecido en la Constitución Política.

d) La declaración, formulada por el citado Poder y conforme al aludido procedimiento, tiene una triple finalidad: mandar, prohibir o permitir algo.

Tal como señala el precepto, la ley es "*una*" declaración de la voluntad soberana y no "*la*" declaración, pues no es la única de esta especie. En efecto, son también declaraciones de la voluntad soberana, por ejemplo, las sentencias judiciales y las decisiones adoptadas por la ciudadanía convocada a un plebiscito.

Se han formulado críticas de fondo y de forma a la definición de ley del Código Civil:

a) *Crítica de fondo* (*o sustancial*): se critica a la definición, debido a que no da una idea clara del objeto de la ley (es decir de su finalidad), ni de lo que esta es, en sí misma.[3] En realidad, la definición de ley del Código es más bien formal, no contiene elementos sustantivos, más allá de la forma que puede asumir el mandato en ella contenido.

Jaime Williams señala por su parte que la objeción se relativiza, si conjugamos la definición con varias normas de la Constitución Política, que, a diferencia de lo que ocurría con la Constitución de 1925, le confieren al artículo 1 la sustancia que le falta: "Actualmente la Constitución Política de 1980 consagra ciertas disposiciones de cuyo contexto fluye tanto explícita como implícitamente lo que entendemos por ley en un sentido técnico (…). Los aspectos doctrinales de la ley que no se encontraban en textos positivos anteriores a esta Carta, hoy aparecen en sus disposiciones. Así, el art. 63 N° 20 consagra en forma expresa el carácter general y obligatorio que debe tener la ley. Implícitamente reconoce su carácter abstracto al exigir que sea general, pues no va a

[3] Vodanovic H., Antonio (1990), *Derecho Civil. Parte Preliminar y Parte General, Explicaciones basadas en las versiones de clases de los profesores de la Universidad de Chile Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U., redactadas, ampliadas y actualizadas por Antonio Vodanovic H.*, Santiago de Chile, Ediar Conosur Ltda., Tomo 1º, 5ª edición, N° 152, p. 105. En adelante, citaremos esta obra aludiendo sólo a su redactor.

prever casos concretos, sino que 'situaciones tipo', lo que se reafirma en la parte final del art. 63 N° 20, que exige a la norma establecer las bases esenciales de un ordenamiento jurídico (…). En lo referido al objeto, finalidad o elemento material de la ley, nuestra Constitución actual, a diferencia de la del año 1925, consagra expresamente las bases esenciales de la institucionalidad en su capítulo I, el que contiene los valores y principios fundamentales que inspiran todo nuestro sistema jurídico. Ahora bien, en su art. 1° inciso 4° se señala: 'El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es *promover el bien común*, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. De acuerdo a lo anterior, y si consideramos que el poder legislativo es un componente del Estado, debemos concluir que debe también perseguir como finalidad última el *bien común*. Es por ello que nuestra Constitución, en un contexto general, determina el contenido de los actos del *poder legislativo*: deben encaminarse a servir al ser humano y el bien común".[4]

De esta manera, siguiendo los postulados de Jaime Williams, se puede concluir que la definición de ley del art. 1 del Código Civil debe ser *complementada* por los arts. 1 y 63 de la Constitución Política, de los que puede desprenderse que se incorporan a la aludida definición los siguientes elementos:

i.- La ley debe propender al bien común, como en general debe ocurrir con los actos realizados por el Estado.

ii.- La ley tiene carácter general.

iii.- La ley es abstracta.

iv.- La ley es obligatoria.

b) *Crítica de forma*: se critica porque tal como esta redactada parece decir que manda, prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita en la Constitución, y no por ser una declaración de la voluntad soberana, aspecto obviamente más relevante que el primero, de carácter instrumental. Por lo demás, no puede haber alguna declaración de la voluntad soberana que no importara un mandato.[5]

2.2. Definiciones doctrinarias.

a) Aristóteles: sostiene que ley es el común consentimiento de la ciudad. Sin embargo, no basta con que la ley se origine en el consentimiento "de la ciudad", es decir de la *polis*. La ley también debe ser justa. Afirma que "Las leyes (*nomoi*) hablan de todas las cosas y tratan de realizar lo que conviene a todos". Aristóteles "parte del supuesto de que la legalidad implica la justicia, pues las leyes introducen un orden (*kosmos*) que hace posible no sólo la convivencia, sino también la aspiración de alcanzar una vida buena. Aunque el conjunto de normas imperantes en una sociedad concreta no cumplan plenamente con las exigencias de la justicia, su mera eficacia ya implica un mayor grado de justicia en comparación con aquellas sociedades en donde no existe una legalidad definida o donde ésta no se respeta. Para Aristóteles el concepto de legalidad presupone no sólo una regularidad en las conductas, sino también una referencia a la justicia. Porque la ley (en su sentido normativo) contiene el mandato de vivir conforme a la virtud y la prohibición de comportarse de manera viciosa".[6]

b) Marco Tulio Cicerón: la ley es la suma razón, ínsita en la naturaleza, que manda lo que ha de hacerse y prohíbe lo contrario.

c) Gayo: ley es lo que el pueblo manda y establece.

---

[4] Williams Benavente, Jaime (1999), *Lecciones de Introducción al Derecho*, Santiago de Chile, Ediciones Fundación de Ciencias Humanas, 3ª edición, actualizada., pp. 143 y 144.

[5] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 152, p. 105.

[6] Serrano, Enrique, "La Teoría Aristotélica de la Justicia", en *Isonomía* Nº 22/Abril 2005, México, p. 127.

d) Santo Tomás de Aquino: es una orden de la razón destinada al bien común debidamente promulgada por el que cuida la comunidad. En su formulación original: "*quaedam rationis ordinatio ad bonum commune al eo, qui curam communitatis habet, promulgata*". En esta definición, "se comprenden todos los requisitos que ha de tener un precepto para constituir ley; a saber: emanar de competente autoridad, ajustarse a razón, enderezarse al bien común y estar suficientemente promulgado".[7]
e) Francisco Suárez: precepto común, justo, estable y suficientemente promulgado.
f) Armand Dalloz: es una regla de conducta impuesta por una autoridad a la que se debe obediencia.
g) Marcel Planiol: es una regla social obligatoria establecida con carácter general y permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza.
h) Henry Capitant: disposición jurídica reconocida como necesaria elaborada por un organismo especial llamado poder legislativo.
i) Jean-Étienne Portalis: es una declaración solemne de la voluntad del soberano sobre un objeto de interés común. Como expresa Borja, "Esta definición es, a no dudarlo, la aceptada en el Código de la Luisiana y modificada en el proyecto de D. Andrés Bello".[8] En realidad, la definición del art. 1 del Código Civil chileno también se basa en el Digesto y en la siguiente definición, de Napoleón Víctor Marcadé (1810-1854).
j) Napoleón Víctor Marcadé: regla establecida por la autoridad que de acuerdo con la Constitución Política, tiene el poder de mandar, prohibir o permitir en toda la extensión del Estado.[9]
k) Giorgio del Vecchio: pensamiento jurídico deliberado y consciente expresado por órganos adecuados que representan la voluntad preponderante en una multitud asociada.
l) F. K. von Savigny: el derecho positivo expresado por el idioma en caracteres exteriores, y revestido de autoridad absoluta, se llama ley.[10]
m) Nicolás Coviello: "Ley, en sentido estricto, no es otra cosa que la norma jurídica establecida por aquella autoridad del Estado que, según la constitución fundamental, está destinada para desempeñar tal oficio".[11]
n) Papiniano: precepto común, decreto de hombres prudentes, corrección de los delitos que por voluntad o ignorancia se cometen, y pacto común de la República (Digesto, 1.3.1).

Como puede observarse, la mayor parte de estas definiciones son más bien formales, mientras que algunas incluyen elementos sustantivos, como la razón, el bien común, la justicia o el interés común.

3.- Requisitos externos e internos de la ley.

De la definición del Código Civil, se desprende que los requisitos de la ley son externos e internos.

3.1. Requisitos externos.

Permiten a la población en general cerciorarse si la norma es en realidad ley. Son dos los requisitos externos:

---

[7] Fernández Concha, Rafael (1877), *Filosofía del Derecho o Derecho Natural*, Santiago de Chile, Imprenta de "El Correo", de R. Varela, pp. 99 y 100.
[8] Borja, Luis F. (1899), *Estudios sobre el Código Civil Chileno*, Tomo Primero, Quito, Tip. De la Escuela de Artes y Oficios, p. 2.
[9] Aftalión, Enrique R. (1956), García Olano, Fernando y Vilanova, José, *Introducción al Derecho*, 7ª edición, Buenos Aires, Editorial "La Ley", p. 169.
[10] Citado por Borja, Luis F. (1899), p. 3.
[11] Coviello, Nicolás (2007), *Doctrina General del Derecho Civil*, Buenos Aires, Valletta Ediciones, p. 42.

a) *Declaración de la voluntad soberana*: la soberanía reside en la Nación que delega su ejercicio en lo que al legislar se refiere, en el Congreso Nacional y en el Presidente de la República. Ambos son colegisladores.

No son leyes por faltar este primer requisito, los simples decretos del Presidente de la República, aunque sean de efectos generales y permanentes.

b) *Manifestada en la forma prescrita por la Constitución*: (artículos 65 al 75 de la C. P. de la R.). La Constitución Política dispone que "Las leyes pueden tener su origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por *mensaje* que dirija el Presidente de la República o por *moción* de cualquiera de sus miembros" (art. 65). "Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen pasará inmediatamente a la otra para su discusión" (art. 69). "Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley" (art. 72).

El quórum para aprobar, modificar o derogar las leyes es el siguiente, conforme a los artículos 66 y 127 de la Constitución Política de la República:

a) *Leyes que interpretan preceptos constitucionales*: conforme al art. 66, inc. 1° de la Constitución Política de la República, requieren para su aprobación, modificación o derogación, de 4/7 de diputados y senadores en ejercicio (es decir, de un 57,14% de los parlamentarios en ejercicio).

b) *Leyes que reformen la Constitución*: de acuerdo con el art. 127 de la Constitución Política de la República, se exige 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio.

Aprobado el proyecto por ambas Cámaras, pasará al Presidente de la República.

En cualquiera de los dos casos anteriores, si el Presidente de la República rechaza totalmente un proyecto de reforma, éstas podrán insistir en su totalidad por 2/3 de sus miembros, en cuyo caso el Presidente:

i) Deberá promulgar dicho proyecto; o,

ii) Consultar a la ciudadanía mediante plebiscito.

Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el art. 127, y se devolverá al Presidente para su promulgación.

Si las Cámaras no aprueban todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo (art. 128).

La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso. El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por ambas Cámaras y vetado totalmente por el Presidente de la República, o las únicas cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito. El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser

promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación. Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta (art. 129).
c) *Leyes orgánicas constitucionales*: de acuerdo con el art. 66, inc. 2°, exigen para su aprobación, modificación o derogación, de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
d) *Leyes de quórum calificado*: de acuerdo con el art. 66, inc. 2°, exigen para su aprobación, modificación o derogación, de la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Sin embargo, en un caso, se requiere de un quórum mayor, ascendente a dos terceras partes de diputados y senadores en ejercicio: las leyes que concedan indultos generales y amnistía tratándose de delitos contemplados en el art. 9 de la Constitución, esto es, delitos terroristas (art. 63, N° 16 de la Constitución).
e) *Leyes de quórum simple*: de acuerdo con el art. 66, inc. 3°, exigen para su aprobación, modificación o derogación, mayoría de los miembros presentes en cada cámara, o las mayorías que sean aplicables conforme a los arts. 68 y siguientes de la Carta Fundamental.

La ley, en consecuencia, debe formarse conforme al procedimiento específico que contempla la Constitución Política. De tal forma, no será ley, por ejemplo, la declaración de voluntad de todos los miembros del Congreso Nacional y del Presidente de la República manifestada por medio de una escritura pública.

El quórum requerido para cada ley, conforme a lo expresado, debe calcularse atendiendo al número de diputados y de senadores. Actualmente, son 155 los diputados (que duran cuatro años en el cargo) y 50 los senadores (que duran ocho años en el cargo). Para entrar en sesión y adoptar acuerdos, se requiere de la asistencia de la tercera parte de los diputados y senadores en ejercicio (art. 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y art. 54 del Reglamento del Senado). Por lo tanto, se requiere la concurrencia de al menos 52 diputados y de 17 senadores, si se trata de aprobar, modificar o derogar una ley de quórum simple.

Las leyes se numeran en Chile a partir del 11 de enero de 1893. La Ley N° 1, versa sobre la prórroga de la prohibición de adquirir terrenos indígenas, hecha a los particulares por una Ley de 4 de agosto de 1874, ampliada por otra de 20 de enero de 1883.

En rigor, después de la proclamación de nuestra independencia, bien podríamos entender que la primera ley de la República es la de 3 de junio de 1818, que sustituye la denominación de "español" por la de "chileno", atendido a que "Después de la gloriosa proclamación de nuestra Independencia sostenida por la sangre de sus defensores, sería vergonzoso permitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial". Lleva la firma de O'Higgins e Irizarri.

3.2. Requisitos internos.

Miran al contenido de la norma, si es *imperativa*, *prohibitiva* o *permisiva*. Toda ley, por el hecho de ser tal, implica un mandato, por ser una declaración de la voluntad soberana a la cual debemos obediencia. Pero las leyes contienen mandatos de diversas especies: algunos imperativos, otros prohibitivos y otros permisivos. De ahí que existan leyes imperativas, prohibitivas y permisivas.

a) *Leyes imperativas*: son las que mandan hacer algo, o cumplir con una serie de requisitos para que un acto o contrato tenga eficacia jurídica. Conforme a lo anterior, se distinguen dos clases de normas imperativas:
a.1) *Leyes imperativas propiamente tales*: son aquellas que simplemente ordenan algo, como, por ejemplo:

i.- Art. 86, en las normas de la muerte presunta: obligación de hacer inventario que pesa sobre los herederos presuntivos, para recibir la posesión provisoria de los bienes del desaparecido.
ii.- Art. 89, también en la muerte presunta: obligación de prestar caución, que deben cumplir los mismos herederos presuntivos.
iii.- Art. 321, en materia de alimentos: obligación que tienen ciertas personas, de proporcionar alimentos.
iv.- Art. 907, en las normas de las prestaciones mutuas: el poseedor condenado a restituir la cosa a su dueño, deberá además restituir los frutos naturales y civiles de la cosa.
v.- Art. 908, también en las normas de las prestaciones mutuas: el dueño que recupera la posesión de la cosa, deberá abonar al poseedor lo que éste haya invertido por concepto de expensas necesarias.
vi.- Art. 1847, en la compraventa: la ley le impone al vendedor una serie de prestaciones, con las cuales indemnizar al comprador, si éste hubiere sufrido evicción de la cosa comprada.
vii.- Art. 2329, en las normas de la responsabilidad extracontractual: obligación de reparar los daños causados a otro.
a.2) *Leyes imperativas de requisito*: son aquellas que permiten ejecutar o celebrar un determinado acto jurídico, *pero previo cumplimiento de ciertos requisitos*, como, por ejemplo:
i.- Art. 88, en la muerte presunta: para que los poseedores provisorios puedan vender o hipotecar bienes del desaparecido, deben cumplirse los requisitos previstos en la norma.
ii.- Art. 124, en los impedimentos para contraer nuevo matrimonio: obligación de hacer inventario solemne de los bienes que les pertenezcan a sus hijos menores de edad o a sus pupilos.
iii.- Art. 254, respecto de la administración de los bienes de los hijos menores de edad: para gravar o enajenar ciertos bienes del hijo, se requiere autorización judicial.
iv.- Arts. 393 y 394, en materia de administración de los bienes por el tutor o curador: para gravar o enajenar ciertos bienes del pupilo, debe previamente obtenerse autorización judicial; la venta de esos bienes, deberá hacerse por pública subasta.
v.- Art. 402 inc. 2º, también en materia de administración de los bienes por el tutor o curador: para donar dinero u otros bienes muebles del pupilo, se requiere autorización judicial.
vi.- Art. 412, inc. 1º, en materia de administración de los bienes por el tutor o curador: para que el tutor o curador pueda comprar para sí bienes del pupilo, debe ser autorizado por los otros guardadores o a falta de éstos por el juez.
vii.- Art. 1464 números 3 y 4, en los casos de objeto ilícito: para enajenar bienes actualmente embargados, se requiere autorización del juez o consentimiento del acreedor; para enajenar bienes cuya propiedad se litiga, es necesario que así lo permita el juez que conoce del litigio.
viii.- Art. 1554, respecto del contrato de promesa: la promesa de celebrar un contrato no producirá obligación alguna, de cumplirse con los cuatro requisitos exigidos por este precepto.
ix.- Art. 2144, en las normas del mandato: para que el mandatario pueda "autocontratar", debe contar con la aprobación expresa de su mandante.

Estas normas suelen tener, en principio, apariencia de prohibitivas, pero como en la práctica permiten ejecutar o celebrar un acto jurídico previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley, no son prohibitivas sino sólo imperativas de requisito.

b) *Leyes prohibitivas*: son las que mandan no hacer algo, que impiden una determinada conducta *bajo todo respecto o consideración* (no queda ninguna

posibilidad para intentar llevar a cabo determinado hecho, la ley lo prohíbe en términos categóricos, absolutos). Las leyes penales tienen carácter prohibitivo. Señalamos a continuación algunos ejemplos en el Código Civil:
i.- Art. 402 inc. 1°: prohíbe la ley donar bienes inmuebles del pupilo.
ii.- Art. 412, inc. 2º: prohíbe la ley al tutor o curador comprar o arrendar para sí, bienes inmuebles del pupilo.
iii.- Art. 1464 números 1 y 2: prohíbe la ley enajenar cosas que están fuera del comercio o derechos personalísimos.
iv.- Art. 1463: prohíbe la ley los pactos sobre una sucesión futura.
v.- Art. 1465: prohíbe la ley condonar el dolo futuro.
vi.- Art. 1796: prohíbe la ley celebrar compraventa entre cónyuges no separados judicialmente o entre el padre o la madre y el hijo no emancipado.
vii.- Art. 2450: prohíbe la ley transigir sobre el estado civil de las personas.

c) *Leyes permisivas*: son las que permiten realizar algún acto o reconocen a un sujeto determinada facultad. Son leyes permisivas, por ejemplo:
i.- Todas aquellas que regulan el ejercicio de un derecho (como el de propiedad o el derecho para reconocer un hijo); o
ii.- Todas aquellas que posibilitan celebrar un contrato.

La ley permisiva entraña un mandato a todas las personas en el sentido de que respeten el derecho que ella reconoce al titular del derecho. Por ejemplo: ante el derecho de propiedad que ejercita el propietario, el resto de la población tiene un deber de abstención. Los terceros no pueden perturbar el legítimo ejercicio del derecho, por parte de su titular.

Las leyes permisivas no deben confundirse con las imperativas de requisito: así, por ejemplo, el marido casado en sociedad conyugal puede enajenar los muebles de aquella, sin restricciones (ley permisiva); pero si pretende enajenar un inmueble social, necesita obtener autorización de la mujer o de la justicia en subsidio, conforme al art. 1749 del Código Civil (ley imperativa de requisito).

d) Sanción ante la infracción de las distintas clases de leyes.

d.1) *Leyes imperativas*: no tienen una *sanción determinada*, esta podrá ser la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la inoponibilidad o incluso ninguna sanción. Para determinar lo anterior habrá que examinar el texto de la ley respectiva.

Carlos Ducci, al respecto, señala que, para determinar la sanción, debemos distinguir si la norma es de *interés público o general*, o si por el contrario, sólo es de *interés particular o privado*:
i.- Si es de *interés público* o general (lo que acontecerá cuando la disposición legal dice relación con el orden público y las buenas costumbres), la sanción podrá ser la nulidad absoluta o la nulidad relativa.

Habrá nulidad absoluta, si el acto que contravenga la ley adolece de objeto o causa ilícitos o implica la omisión de una formalidad exigida por la ley en atención a la naturaleza del acto o contrato (o sea, una solemnidad propiamente tal).

Habrá nulidad relativa, si los requisitos que se omiten, habían sido exigidos por la ley en atención a la calidad de las personas que ejecutan o celebran el acto o contrato (o sea, una formalidad habilitante).

Agrega este autor que podrá señalar la ley una *sanción especial*, para el caso de incumplimiento.

Admite también que podría ocurrir que *la ley no prevea ninguna sanción, para el evento de su contravención*. Así, por ejemplo, art. 1026, en relación con los artículos 1016, 1023 inciso 5º y 1024 inciso 2º, todos concernientes al otorgamiento del testamento: aunque se omitan en el testamento algunas de las menciones que exige la

ley –ciudad de nacimiento del testador, por ejemplo-, ello no traerá consigo la nulidad de aquél, "siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo". Veremos que las normas legales cuya contravención no tiene asociada una sanción, se denominan *imperfectas* por la doctrina.
ii.- La sanción de las leyes imperativas de *interés particular* será, en caso de contravención, la responsabilidad, como norma general (o sea, la indemnización de perjuicios), o incluso, como sanción adicional, dejar sin efecto el acto o contrato a través de su resolución o terminación[12].

d.2) *Leyes prohibitivas*: la sanción aplicable por su infracción es la *nulidad absoluta*, lo que se desprende de los artículos 10, 1466 (parte final) y 1682 del Código Civil. Del artículo 10, se desprende que la sanción será la *nulidad*. Del artículo 1466 parte final, que los actos que prohíbe la ley adolecen de *objeto ilícito*; y del artículo 1682, que *el objeto ilícito es una causal de nulidad absoluta*. De esta forma, de la interpretación armónica de los tres artículos, concluimos que la sanción ante la infracción de una ley prohibitiva, será la nulidad absoluta.

Lo anterior, salvo si la ley contempla otra sanción. Así, por ejemplo:
i.- En el caso de los fideicomisos sucesivos y usufructos sucesivos y alternativos, artículos 745 y 769, respectivamente, hipótesis en las cuales la sanción es la *caducidad*. Es decir, habiendo operado el primer fideicomiso o el primer usufructo, los siguientes que se hubieren constituido, caducan, consolidándose el derecho en el fideicomisario o en el primer usufructuario. Cabe notar que, respecto al usufructo, la ley alude también a los usufructos "alternativos". Sería tal, aquél en que Juan es nudo propietario y Pedro usufructuario, por dos años, al cabo de los cuales se alternan en sus calidades, pasando Juan a ser usufructuario y Pedro nudo propietario o si uno es usufructuario por 5 años y el otro por los siguientes 5 años y así alternativamente. Tal figura, también está proscrita por la ley, pues atenta contra el principio de la propiedad privada y la libre circulación de la riqueza.
ii.- En el caso previsto en el art. 2206 del Código Civil, en los intereses pactados en un contrato de mutuo: si dichos intereses excedieren del "interés máximo convencional", la sanción consistirá en reducirlos al "interés corriente". Por ende, el contrato de mutuo no será nulo, pero el acreedor no podrá exigir todos los intereses estipulados, sino una suma menor.

d.3) *Leyes permisivas*: por lo general su infracción permite demandar *indemnización de perjuicios*, sin perjuicio de que la persona afectada, interponga las acciones que le permitan el ejercicio del derecho o facultad que le reconoce la ley, removiendo el obstáculo o dejando sin efecto el hecho del tercero que así lo impida.

4.- Características de la ley.

Atendiendo a su contenido, es decir en cuanto principio normativo, Ducci señala las siguientes características de la ley:
a) Es una regla social, es decir, una norma de conducta exterior. La ley no regula el fuero interno de las personas (donde opera la norma moral), sino sus actos, y no los aislados, sino aquellos que se relacionan con la vida social.

[12] Ducci Claro, Carlos (1984), *Derecho Civil. Parte general*, 2ª edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, pp. 54-57.

b) Emana de la autoridad pública, del organismo al que la comunidad ha investido del poder de dictarla. En el caso de Chile, detentan la potestad legislativa el Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.[13]

c) Debe ser cumplida, no es facultativo para los individuos acatarla o no.

d) Es sancionada con la fuerza. La sanción de las leyes de Derecho público toma distintas formas, desde las medidas de prevención hasta las penas. En materia civil, también reviste distinto aspecto.

e) Es general. Se aplica a todas las personas concernidas en la situación descrita por la ley. Ellas pueden ser todas las que habitan el territorio del Estado o ciertos grupos o categorías de sujetos, pero no un individuo particularmente individualizado.[14] Lo anterior, sin perjuicio de la existencia de leyes "particulares" (como aquella que otorga la nacionalidad chilena), que, según se verá, son leyes sólo en lo "formal", más no en lo "material".

f) Es abstracta. Establece una hipótesis susceptible de ser aplicada en cada uno de los casos concretos en que ella se presente.

g) Es permanente. Dura indefinidamente, desde su promulgación hasta que se produzca su derogación. Ello no impide que existan leyes temporales, dictadas para tener vigencia durante un cierto tiempo, y leyes transitorias, que, generalmente, regulan el paso de una legislación antigua a una nueva.

h) Es cierta. No necesita ser probada. Una vez que entra en vigencia, se presume por todos conocida. De acuerdo al art. 8 del Código Civil, nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.[15]

i) Rige para el futuro. Tal es la regla general. Sólo excepcionalmente podrá tener efectos retroactivos, [16]y con las limitaciones que se expondrán a tratar de los efectos de la ley en el tiempo.

5.- Clasificación de las leyes.

Como lo señalamos al tratar de las clasificaciones de las normas jurídicas ("El Derecho y el ordenamiento jurídico"), optamos por dejar para la clasificación de las leyes sólo algunas categorías, que efectivamente son privativas de las leyes, aunque todas las que se expusieron en aquella materia, también podrían aplicarse para aludir a los diversos tipos de leyes.

5.1. Leyes prohibitivas e imperativas.

Se imponen a la voluntad de los particulares, lo cuales no pueden eludir su aplicación. La doctrina ha señalado que las causas que determina al legislador a dictar estas normas son de dos especies:

---

[13] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), *Explicaciones de Derecho Civil. Parte general y acto jurídico*, Tomo I, Santiago de Chile, AbeledoPerrot Legal Publishing Chile, p. 45.
[14] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., p. 45.
[15] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 35, p. 40.
[16] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., p. 45.

i.- Asegurar el mantenimiento del orden público. Se trata de aquellas normas que se dictan para posibilitar el mantenimiento del equilibrio social, la moral pública y la armonía económica.[17]
ii.- Proteger a las personas que, por su edad, sexo o condición física o psíquica, son incapaces de defender por sí mismas, sus derechos. De no mediar esta protección, las aludidas personas podrían ser víctimas de su debilidad o inexperiencia.[18] Así, por ejemplo, arts. 254 (protección al hijo no emancipado); 393 y 394 (protección a las personas que están bajo guarda); 1019 (protección al ciego o al sordo o sordomudo que conozca el lenguaje de señas, cuando otorgan testamento).

5.2. Leyes dispositivas.

Son aquellas en que el legislador dicta una norma para resolver conflictos de interés que se presentan entre personas que no han contratado entre sí. En estos casos, el legislador compara y pesa los intereses controvertidos y se pronuncia dando la primacía a aquél que le parece más digno de protección.[19] Así, por ejemplo:
i.- Puede ocurrir que un individuo venda a otro una cosa ajena. Entre el dueño de la cosa y el que la ha comprado surge un conflicto de intereses que la voluntad de ninguno de los dos ha contribuido a crear. La norma del art. 1815 del Código Civil, dispositiva, regula la situación. De acuerdo a este artículo, la venta de cosa ajena es válida, pero ello se entiende sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa.
ii.- Igual acontece en el caso de que se venda una misma cosa, separadamente, a dos o más personas. El art. 1817 establece las reglas en virtud de las cuales se resuelve cuál de los compradores podrá retener la cosa.
iii.- Una norma similar encontramos en el art. 1922 del Código Civil, esta vez en el contrato de arrendamiento de cosa, cuando ésta se ha arrendado separadamente a dos o más personas.
iv.- Por su parte, los arts. 1490 y 1491 resuelven el conflicto que pueda surgir entre el acreedor y reivindicante de una cosa y los terceros adquirentes de la misma, cuando el primero obtiene la resolución del contrato por el cual se la había enajenado al deudor, persona ésta de la que tales terceros adquirieron dicha cosa.
v.- El art. 1135, resuelve el conflicto que puede surgir entre un legatario y, por ejemplo, el comprador de la cosa legada, si el testador, después de otorgar su testamento e instituir en él el legado, resuelve vender y enajenar la cosa legada, a otra persona. En tal caso, la ley entiende tácitamente revocado el legado, favoreciendo al comprador por sobre el legatario.

5.3. Leyes materiales y formales.

Este distingo –refiere María de la Luz Mijangos Borja- tiene su origen en el conflicto surgido entre la corona prusiana y la cámara de Diputados, entre los años 1861 y 1866, cuando la segunda, dominada por los liberales e invocando la Constitución prusiana de 1850, niega la aprobación del presupuesto que el Rey Guillermo I había presentado, en el que se incluían las partidas necesarias para una importante reforma militar, que irrogaría ingentes gastos. El monarca procedió a disolver el Landtag y convocó a nuevas elecciones, en las que los liberales tuvieron un triunfo arrollador. El conflicto, por tanto, parecía no tener salida. El rey nombró en 1862 como canciller a Otto von Bismarck, quien se comprometió en sacar adelante la reforma militar. El canciller obtuvo el apoyo de la cámara alta –Herrenhaus- y logró de

[17] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 160, p. 109.
[18] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 160, p. 109.
[19] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 161, p. 109.

manera inconstitucional la aprobación del presupuesto. Lo mismo ocurrió en los años siguientes, hasta que la victoria sobre Austria en Sadowa, en 1865, otorgó a Bismark un éxito político indudable que implícitamente justificó la reforma y el gasto militar, no quedándole a los liberales más remedio que aprobar de manera retroactiva los gastos hechos en los años anteriores. En 1870, el triunfo prusiano sobre Francia, posibilitará la unidad alemana y la creación del imperio alemán bajo el liderazgo de Prusia. En este contexto, Paul Laband (1838-1918), catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Estrasburgo, escribirá en 1871 su obra "Das Budgetrecht nach den Preussischen Verfassungs"[20], en la que formula su teoría dualista –favorable a la Corona y con el propósito de que el conflicto no pudiere ocurrir nuevamente-, afirmando que existen dos tipos de leyes: *leyes en sentido material*, que contienen una norma jurídica, una regla de derecho, emanada del Poder Legislativo, que afecta a la esfera de los derechos individuales de los gobernados, bien en sus relaciones recíprocas, bien en sus relaciones con el Estado y sus órganos o funcionarios, creando a su beneficio o a su cargo nuevos derechos y obligaciones, y *leyes en sentido formal*, que únicamente expresan la constatación o el requisito de un acuerdo entre el rey y las dos cámaras del Parlamento, pero que materialmente no contienen ninguna manifestación de la voluntad del Estado de establecer o declarar una regla de derecho, una norma jurídica. Es decir, éstas últimas no afectan la esfera de los derechos individuales, sino que interesan exclusivamente al funcionamiento interno del aparato administrativo. Así las cosas, Laband sostiene que la ley que aprueba el presupuesto es una ley formal, que tan solo implica la participación de las cámaras parlamentarias en su aprobación. El resultado de esta argumentación fue sostener que el Parlamento no podía enmendar o modificar el proyecto de presupuesto elaborado por el gobierno, reduciéndose su función a la aprobación, a una vacía formalidad. Ello, pues las funciones del Poder Legislativo eran mínimas respecto a la elaboración del presupuesto, a diferencia de lo que ocurría con una ley ordinaria. El presupuesto era un acto administrativo, que no contenía normas jurídicas en sentido material. Por lo tanto, la ley que lo aprobara si bien lo era en lo formal, no lo era en lo material.[21]

De esta manera, la "teoría dualista" de Laband "considera que la ley está compuesta de dos elementos, el 'formal' y el 'material'. Lo formal atiende a que para la elaboración de la ley se sigan los pasos establecidos por el órgano competente, legislativo. El elemento material requiere de un contenido jurídico como es la permanencia, generalidad y abstracción. Llenado el primer requisito tenemos la 'ley en sentido formal' y, con el segundo, una 'ley en sentido material'. Si únicamente se cumple con el primer requisito se trata de un acto de autoridad legislativa, administrativa o judicial, pero no de una ley. De Buen dice: 'Sólo la conjunción de los dos sentidos, mejor diríamos de los dos elementos, el material y el formal, determinan el concepto propio de ley como norma jurídica caracterizada en relación a los demás'".[22]

Las verdaderas leyes, se afirma entonces, por ser generales, abstractas e hipotéticas, se denominan "leyes materiales". En efecto, "La ley debe estar destinada a regir una clase indeterminada de casos o de situaciones".[23]

Excepcionalmente, en cambio, encontramos leyes particulares, tales como las que conceden pensiones de gracia o la nacionalidad por gracia a individuos

---

[20] "La Ley Presupuestaria de acuerdo a las disposiciones de la Constitución prusiana".

[21] Mijangos Borja, María de la Luz (1995), "La naturaleza jurídica del presupuesto", en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Nº 82, pp. 205-228.

[22] Barillas, José, (1967), "Las fuentes formales del ordenamiento jurídico", tesis doctoral, Universidad de El Salvador, Corte Suprema de Justicia, Biblioteca Judicial "Dr. Ricardo Gallardo", disponible en www.csj.gob.sv.; quien cita a su vez a Bascuñán Valdés, Antonio (1964), *Introducción al estudio de las ciencias jurídicas y sociales*, 2ª edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, p. 170.

[23] Corral Talciani, Hernán (2018), *Curso de Derecho civil. Parte General*, Santiago de Chile, Thomson Reuters, p. 50.

determinados. Estas últimas han sido calificadas como "leyes formales", con lo que quiere significarse que no serían verdaderas leyes, para contraponerlas a las verdaderas leyes. Se trata de "normas que, si bien se aprueban con los trámites de una ley, reciben el mismo ropaje exterior de la ley, disponen sobre situaciones o casos individuales y no generales. (…) Estas leyes no son materialmente leyes, pero sí lo son formalmente (pueden considerarse decretos supremos, pero para cuya aprobación se exige el trámite y quórum de una ley)".[24]

5.4. Leyes perfectas, más que perfectas, menos perfectas e imperfectas.

Se formula esta clasificación atendiendo a la sanción que debe operar, de haberla, para el evento de infringirse la ley:
i.- Leyes perfectas (*perfectae*): "son aquellas en que la sanción es la nulidad del acto; por ejemplo, son nulos los actos jurídicos otorgados por personas absolutamente incapaces por dependencia de una representación necesaria".[25]
ii.- Leyes más que perfectas (*plus quam perfectae*): son aquellas en que la sanción consiste no sólo en la nulidad del acto, sino también en una pena civil o administrativa adicional: por ejemplo, la falta de testigos en el otorgamiento de un testamento causa su nulidad y también da lugar a graves sanciones contra el notario; las nulidades de los actos jurídicos, basadas en dolo de una de las partes, acarrean, además, la indemnización de los daños y perjuicios, aplicándose las reglas de la responsabilidad extracontractual.[26]
iii.- Leyes menos perfectas (*minus quam perfectae*): "son aquellas en que la sanción no consiste en la nulidad del acto, sino en una pena que podemos llamar menos importante; por ejemplo, el que ha incurrido en dolo incidente debe pagar los daños ocasionados, pero el acto mantiene su validez".[27]
iv.- Leyes imperfectas (*imperfectae*): "son las que carecen de sanción; asumen la forma de *consejo* o indicación general, pero su violación no trae aparejada ninguna consecuencia legal. Estrictamente, estas leyes sólo lo son desde el punto de vista formal, puesto que han sido sancionadas por el legislador; pero no lo son desde el punto de vista material o de fondo, ya que uno de los elementos esenciales de la norma jurídica es precisamente la sanción".[28]

6.- Jerarquía de las normas jurídicas

6.1. Escala jerárquica de las normas.

Se entiende por tal la escala de graduación de las normas. Tal escala jerárquica es la siguiente:
Primer escalón: es el ordenamiento constitucional integrado por la Constitución Política de 1980 y sus modificaciones.
Segundo escalón: formado por las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las leyes de quórum simple, los Decretos con Fuerza de Ley, los Decretos Ley y los Tratados Internacionales firmados y ratificados.

Sin embargo, en relación con los tratados internacionales, es necesario formular algunas precisiones, dados los términos del inc. 2° del art. 5 de la Constitución Política: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los

---

[24] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 50.
[25] Borda, Guillermo A. (2007), *Tratado de Derecho Civil. Parte General*, Tomo I, 12ª edición actualizada, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Nº 43, p. 62.
[26] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., Nº 43, p. 63.
[27] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., Nº 43, p. 63.
[28] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., Nº 43, p. 63.

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Ha surgido una controversia en cuanto al rango que tienen los tratados internacionales, cuando consagran derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Tres opiniones se han formulado:

i.- Para una primera opinión, estos tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución. Por lo tanto, si el Estado chileno los suscribe y ratifica, se debe entender modificada nuestra Constitución Política, por un mecanismo extraordinario, diverso al previsto en la misma Carta Fundamental.

ii.- Una segunda opinión plantea que los tratados, de cualquier naturaleza, tienen rango legal, de manera que una ley posterior podría derogarlos.

iii.- Para una tercera opinión, intermedia, habría que formular el siguiente distingo: por regla general, los tratados internacionales tienen el valor de una ley; pero si se trata de tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, tienen mayor valor que una ley, aunque inferior a la Constitución Política de la República.[29]

Tercer escalón: los Decretos Supremos, sean éstos reglamentarios (de ejecución y autónomos) o simples.

Cuarto escalón: los Decretos.

Quinto escalón: las ordenanzas e instrucciones y otras normas similares.

Sexto escalón: actos jurídicos y sentencias judiciales

En esta escala jerárquica operan dos controles: un *control de la Constitucionalidad* y otro *de la Legalidad*.

Las normas que integran el segundo al sexto escalón, ambos inclusive, están sujetas al control de la constitucionalidad.

Las normas que integran el tercero al sexto escalón, ambos inclusive, están sujetas al control de la legalidad.

Estos controles pueden operar *a priori* o *a posteriori*. El control a priori opera antes de que la norma entre en vigencia. El control a posteriori opera después que la norma ha entrado en vigencia.

El *control de la constitucionalidad*, se ejerce por el Tribunal Constitucional, órgano que vela para que las normas de rango legal del segundo escalón se ajusten a las normas de rango constitucional de superior jerarquía. Asimismo, cautela que las normas reglamentarias de inferior jerarquía guarden respeto y armonía con el ordenamiento constitucional. Se encuentra regulado este órgano en los artículos 92 a 94 de la Constitución Política (Capítulo VIII de la Constitución) y en la Ley N° 17.997, "Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional", publicada en el Diario Oficial de fecha 19 de mayo de 1981. Según se verá, este control puede operar tanto a priori como a posteriori.

El *control de la legalidad*, se verifica por la Contraloría General de la República, órgano que se ocupa de revisar la legalidad –y necesariamente también la constitucionalidad-, de las normas reglamentarias de rango inferior al legal. Su regulación se encuentra contemplada en los artículos 98 a 100 de la Constitución Política (Capítulo X de la Constitución) y en la "Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República", cuyo texto está aprobado por el Decreto Supremo N° 2.421, publicado el 10 de julio de 1964. Este control opera a priori y a posteriori:

i.- A priori, revisando la legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones que se envían, para el trámite de "*toma de razón*" –si el instrumento enviado se ajusta al ordenamiento jurídico- o para "*representar*", en caso contrario. El art. 10 de la citada

[29] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., pp. 57 y 58.

Ley, dispone en su inc. 1°: "El Contralor General tomará razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría, representará la inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer, dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de su recepción, que el Contralor podrá prorrogar hasta por otros quince días, si existiesen motivos graves y calificados, mediante resolución fundada".
ii.- A posteriori, cuando un funcionario público o un particular, solicita pronunciamiento de la Contraloría, acerca de la legalidad de un decreto o de una resolución. En esta función, el Contralor emite "*dictámenes*", que contienen un análisis jurídico fundado, en el que se emiten conclusiones acerca de la legalidad del decreto y sus alcances. Dichos dictámenes van generando jurisprudencia administrativa y son obligatorios para el funcionario público al que se le notifique. El Contralor, sin embargo, deberá abstenerse de emitir dictámenes, cuando se trate de asuntos que por su naturaleza sean litigiosos o estén siendo conocidos por un tribunal de justicia.

También debe considerarse el control que se ejerce por *los tribunales de justicia*. Este es un *control integral*, que comprende todo el espectro jerárquico del ordenamiento jurídico, incluyendo velar por el pleno acatamiento a las normas constitucionales. En efecto, no obstante que el control de la constitucionalidad está entregado exclusivamente al Tribunal Constitucional, *en la práctica* los tribunales también ejercen una suerte de control de la constitucionalidad. Esto ocurre en dos sentidos:
i.- *Por todo Juez de la República*, por aplicación del principio de la *aplicación directa de la Constitución*, consagrado en el art. 6, inc. 2º de la Carta Fundamental: "Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo". En consecuencia, el juez, en su sentencia, deberá velar por el pleno respeto a las normas constitucionales.
ii.- *Por las Cortes de Apelaciones y por la Corte Suprema*, cuando conocen de la acción o recurso de protección, consagrada en el art. 20 de la Carta Fundamental. Como ha expresado la Corte Suprema, "el recurso de protección de garantías establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio".[30]

Por cierto, el control que ejercen los tribunales de justicia sólo opera a posteriori.

6.2. Factores en virtud de los cuales se jerarquizan las normas.

Las normas jurídicas se jerarquizan atendiendo a diversos factores:
i.- *En cuanto a su contenido*: las normas constitucionales, consagran los grandes principios jurídicos; las normas legales y las reglamentarias, detallan o pormenorizan dichos principios generales, fijan la forma de llevarlos a la práctica;
ii.- *En cuanto a su origen*: las normas constitucionales emanan del Poder Constituyente; las legales del Poder Legislativo y las reglamentarias de la Potestad Reglamentaria;
iii.- *En cuanto a su validez*: La Ley tiene una fuerza menor que la Constitución ya que está limitada o comprimida por la Constitución a la cual debe respetar y adaptarse a la norma superior, so pena de no ser aplicada en un caso concreto por

[30] Sentencia de la Corte Suprema de fecha 26 de octubre de 2012, autos Rol Nº 4.755/2012, citada por Navarro Beltrán, Enrique (2018), *Las acciones constitucionales económicas ante los tribunales de justicia*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Finis Terrae, pp. 38 y 39.

inconstitucionalidad. A su vez, los decretos supremos y demás normas de inferior jerarquía, deben subordinarse a la ley y con mayor razón a la Constitución. En el mismo sentido, el orden jerárquico de las normas implica que la creación de aquellas de inferior grado está subordinada en cuanto a su validez a las de grado superior de manera que las primeras (las de menor rango) representan una aplicación de las últimas (de las de grado superior).

Las normas van de lo más general a lo más detallado, de manera que se deben estudiar conjuntamente las normas constitucionales, las leyes y sus correspondientes reglamentos, cuando corresponda.

Como conclusión, las normas jurídicas, están jerarquizadas en cuanto a su contenido, es decir, a lo que expresan; como en lo que respecta a su origen, es decir en cuanto a la forma como se generan; y a su validez, esto es, en lo concerniente a su eficacia, la que dependerá de su sujeción a la norma de rango superior.

7.- Constitucionalidad de la ley.

La Constitución es la ley de las leyes, la súper ley, a la cual deben subordinarse todas las demás. Cuando éstas guardan conformidad con la Constitución, se dice que son constitucionales.

7.1. Constitucionalidad de fondo y de forma.

La constitucionalidad abarca dos aspectos:
i.- *De fondo*: se cumple cuando el contenido de la ley respeta todo derecho garantido o consagrado por la Constitución.
ii.- *De forma*: se cumple cuando la ley es dictada por los órganos competentes y con las formalidades que para su generación y promulgación establece la Constitución.

En consecuencia, la inconstitucionalidad, es la negación de uno de los dos aspectos o de ambos a la vez.

Ejemplos de leyes inconstitucionales *en el fondo*:
i.- Cualquier ley que prohibiera el derecho de asociarse sin permiso previo, pues se vulneraría el derecho reconocido a todo habitante de la república en el artículo 19 número 15 de la Constitución;
ii.- Una ley, que estableciera la expropiación de bienes sin indemnización a sus dueños, ya que se burlaría el derecho garantido en la Constitución en el artículo 19 número 24.
iii.- Cierta ley penal, que ordenara que determinados hechos ya ocurridos al promulgarse sean juzgados de acuerdo con sus preceptos, pues en tal caso habrá infracción al derecho que la Constitución reconoce a toda persona a ser juzgada en conformidad a una ley promulgada con anterioridad al hecho sobre el que recae el juicio, artículo 19 número 3 de la Constitución.

Ejemplos, de la inconstitucionalidad *en la forma*:
i.- Cualquier ley, que pueda ser dictada con prescindencia de uno de los órganos constitutivos del poder legislativo (Cámara de Diputadas y Diputados, Senado y Presidente de la República).
ii.- Una ley, que apareciera en el Diario oficial, con un texto diverso del aprobado por los órganos que integran el poder legislativo (sin perjuicio de la facultad conferida al Presidente de la República por el artículo 64, inciso 5º, de la Constitución Política, que le permite, al fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de una ley, introducirles "los cambios de forma que sean indispensables", aunque sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance).
iii.- Cierta ley de quórum calificado, que regule una materia que, conforme a la Constitución, debía reglamentar una ley orgánica constitucional o a la inversa, una ley orgánica constitucional que regule una materia que debe ser reglamentada por una ley

de quórum calificado, o una ley de quórum simple que regulare una materia propia de una ley orgánica constitucional o de una ley de quorum calificado.

7.2. Efectos de las leyes inconstitucionales.

Cabe preguntarse si producen efectos las leyes inconstitucionales, si deben o no ser obedecidas por los poderes públicos y la comunidad en general. En principio, la respuesta es afirmativa, pero las legislaciones de los distintos países establecen medidas tendientes a obtener que no se apliquen tales leyes, ya sea en general o en el caso concreto en el cual pretenden hacerse valer. En la mayoría de los países, incluso en Chile, los efectos de la resolución que declara la *inaplicabilidad* por inconstitucionalidad de una ley no son generales, se limitan a declarar "inaplicable" dicha ley para el caso concreto de que se trate, de manera que la ley sigue rigiendo y todas las contiendas y juicios deben resolverse conforme a ella, si los interesados no solicitan la inaplicabilidad. Es necesario, por tanto, en cada ocasión, solicitar la declaración de inconstitucionalidad para que la ley no se aplique. Lo anterior, a menos que el Tribunal Constitucional declare la *inconstitucionalidad* de un precepto legal, según veremos. Esta sentencia, a diferencia de la primera, sí tendrá efectos generales.

7.3. El control de la constitucionalidad en Chile.

La determinación de la constitucionalidad de las leyes en nuestro ordenamiento jurídico corresponde, hoy día, exclusivamente, al Tribunal Constitucional.

Dicho órgano ejerce este control, tanto en forma preventiva como a posteriori.

Entre sus atribuciones está:

i.- Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales, antes de su promulgación, de las leyes que interpretan algún precepto de la Constitución Política y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales.

ii.- Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autoacordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones.

iii.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad, que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional o de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.

iv.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un Decreto con Fuerza de Ley.

v.- Controlar la constitucionalidad de las normas legales, después que estas han entrado en vigencia, conociendo de la *acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad*. Para ello, el art. 93 de la Constitución Política faculta al Tribunal para resolver, con el voto favorable de la *mayoría de sus miembros en ejercicio*, la *inaplicabilidad* de un precepto legal cuya aplicación, en cualquier gestión seguida ante un tribunal, resultare contraria a la Constitución (art. 93, N° 6). En este caso, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. El recurso será declarado admisible, siempre que haya una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial y se pruebe que la aplicación del precepto legal puede resultar decisiva en la resolución del asunto. El Tribunal Constitucional podrá resolver la suspensión del procedimiento respectivo. Además, el Tribunal Constitucional podrá declarar, por la *mayoría de 4/5 de sus integrantes en ejercicio*, la *inconstitucionalidad* de un precepto legal que hubiere declarado inaplicable (art. 93, N° 7). Para tal efecto, la Constitución confiere acción pública, sin perjuicio que pueda declararse de oficio tal inconstitucionalidad.

Nótese que la circunstancia de que el Tribunal Constitucional declare en una sentencia la *inaplicabilidad* de un determinado precepto legal a un caso concreto, no

significa que dicha norma, *per se*, o en condiciones abstractas y generales, sea contraria a la Constitución Política de la República, sino que sólo para dicho asunto. Así, por ejemplo, por sentencia de 27 de enero de 2015, autos Rol N° 2.688-14, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable por inconstitucionalidad el art. 5, inc. 3 de la Ley N° 19.537, antigua Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria, que autorizaba la suspensión del suministro eléctrico a una unidad (departamento, oficina, casa, etc., acogido a dicho régimen inmobiliario), cuando se adeudaren tres o más cuotas continuas o discontinuas de gastos comunes. En el caso, se estimó que la norma era contraria al párrafo 1° del N° 3 del art. 19 de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, toda vez que el contexto fáctico en que se da la interrupción del servicio eléctrico domiciliario a la recurrente de protección priva a ésta de la posibilidad de hacerse oír por un órgano jurisdiccional competente y exponer ante él la defensa de su derecho (en este caso, no se había enviado un aviso pormenorizando de la deuda ni tampoco se había demandado judicialmente el pago de los gastos comunes).

Pero si comienzan a reiterarse sentencias que declaren la *inaplicabilidad* de una determinada norma, puede ocurrir que en definitiva el Tribunal Constitucional resuelva su *inconstitucionalidad*, de manera que la norma se expulse del ordenamiento jurídico.

Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional, no procede recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido (art. 94, inc. 1º).

Las disposiciones que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales, no podrán convertirse en ley o Decreto con Fuerza de Ley en el proyecto respectivo (art. 94, inc. 2º).

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un Decreto con Fuerza de Ley, de un Decreto Supremo o de un Auto Acordado, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación (art. 94, inc. 4º).

En todo caso, cabe considerar que el efecto de la declaración de inconstitucionalidad no será el mismo para un decreto supremo, para un auto acordado, para un Decreto con Fuerza de Ley o una ley. El decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, se entiende no haber surtido efecto alguno. En cambio, el auto acordado, el Decreto con Fuerza de Ley o la ley declarados inconstitucionales, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo (artículo 94, inciso 3°).

Conforme a lo expuesto, podemos concluir que el tribunal Constitucional ejerce un control de la constitucionalidad tanto *a posteriori*, como asimismo un control *previo*. En el primer caso, la ley o Decreto con Fuerza de Ley ya existen, pero son inconstitucionales; en el segundo caso, la ley o Decreto con Fuerza de Ley no llegan a existir, se quedan en un mero proyecto.

De lo expresado en los párrafos precedentes, cabe destacar las siguientes diferencias entre la acción de inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad:

i.- *En cuanto al presupuesto de cada una*:

a) Inaplicabilidad: que el precepto legal impugnado se pretenda aplicar en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial.

b) Inconstitucionalidad: que un precepto legal se haya declarado inaplicable por una sentencia previa.

ii.- *En cuanto a quiénes pueden interponerla*:

a) Inaplicabilidad: cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto.

b) Inconstitucionalidad: acción pública, es decir, por cualquiera persona.

iii.- *En cuanto al quórum para acogerlas*:

a) Inaplicabilidad: mayoría de los miembros del Tribunal en ejercicio.

b) Inconstitucionalidad: mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio.
iv.- *En cuanto a la posibilidad de actuar de oficio el Tribunal Constitucional*:
a) Inaplicabilidad: no es posible.
b) Inconstitucionalidad: puede declararse de oficio.
v.- *En cuanto a sus efectos*:
a) Inaplicabilidad: efecto relativo, circunscrito a la gestión judicial de que se trate.
b) Inconstitucionalidad: efecto absoluto, quedando derogado el precepto legal.
vi.- *En cuanto a la publicidad de la sentencia*:
a) Inaplicabilidad: se notificará a las partes.
b) Inconstitucionalidad: se notificará a los interesados y además se publicará en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.

Todos están de acuerdo que el recurso procede contra las leyes inconstitucionales en el fondo, pero la unanimidad de criterios desaparece tratándose de leyes inconstitucionales en la forma. Dos razones se esgrimían en Chile para no pronunciarse acerca de la supuesta inconstitucionalidad en la forma que afectare a ciertas leyes:
i.- Se afirmaba que, contra éstas, no cabía el recurso, ya que si se promulgaba una ley infringiendo las normas que regían su generación, sencillamente a juicio de esta doctrina no había ley y por lo tanto, el juez debía prescindir de la misma y acudir directamente a una ley que rigiera el caso y que estuviere conforme con la Constitución y en su defecto a los *principios de la equidad*.
ii.- Adicionalmente, y a pesar de que el texto de la Constitución Política de 1925 no hacía ningún distingo ni limitaba por ende la procedencia de la inaplicabilidad respecto de la inconstitucionalidad de forma, la Corte Suprema entendía que sus atribuciones sólo le permitían controlar la constitucionalidad de fondo, pues, en caso contrario, estimaba que estaba invadiendo las atribuciones del legislador.[31]

Hoy en día, sin embargo, la mayoría opina que, contra las leyes inconstitucionales en la forma, también procede el recurso, dado que la Constitución Política no distingue entre ambas clases de inconstitucionalidad.[32]

8.- La potestad reglamentaria.

8.1. Concepto.

Existen potestades de diversa índole: potestad *constituyente*, potestad *legislativa*, potestad *social o consuetudinaria* (para generar usos y costumbres), potestad *jurisdiccional*, potestas *administrativa* y potestad *privada o negocial* (para originar actos y contratos). Revisaremos ahora, a grandes rasgos, la "potestad *reglamentaria*", cuyo estudio más exhaustivo corresponde al Derecho administrativo. A nuestro juicio, según se expondrá, la potestad reglamentaria es una especie que forma parte de una categoría más amplia: la *potestad administrativa*.

Se entiende por potestades del ordenamiento jurídico "a la determinación de quién es la persona o el órgano con aptitud para, en general, crear el Derecho, o más precisamente, para generar normas jurídicas con poder suficiente para ser aplicadas a sus destinatarios bajo sanción para el caso de violación".[33]

La llamada potestad reglamentaria, como está dicho, integra una potestad de mayor alcance, que se denomina *potestad administrativa*.

---

[31] "Historia del Tribunal Constitucional", en www.tribunalconstitucional.cl
[32] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 40, p. 46.
[33] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., p. 13.

Carlos Ducci define la potestad reglamentaria como "la facultad de ciertas autoridades administrativas para dictar reglas obligatorias, más o menos generales, para el cumplimiento de la ley o el establecimiento de normas administrativas".[34]

Hernán Corral expresa a su vez que "Se llama potestad reglamentaria a la atribución que tiene el Presidente de la República y demás autoridades de la Administración del Estado, para dictar normas necesarias para la ejecución de las leyes y de la Constitución".[35]

Vodanovic, por su parte, distingue entre la potestad reglamentaria en sentido propio y estricto y en sentido amplio. En su sentido propio y estricto, la potestad reglamentaria, es la facultad o poder de que están dotadas las autoridades administrativas para dictar normas jurídicas, es decir mandatos de alcance general e impersonal.[36] En un sentido amplio abarca, además, la facultad de emitir resoluciones o mandatos que se refieren a una persona o situación determinada.[37] En realidad, aquello que Vodanovic denomina potestad reglamentaria "en sentido amplio" no es propiamente potestad reglamentaria, sino que constituye la manifestación de los actos administrativos en los otros ámbitos en que se desenvuelve la potestad administrativa.

En efecto, el distingo de Vodanovic tiene relevancia, pues en el ámbito del Derecho administrativo, se distingue entre los actos que consisten en el ejercicio de la potestad reglamentaria y los restantes actos de la Administración, llamados "actos administrativos". Refiriéndose a los últimos, Jorge Bermúdez señala que "Resulta fundamental dentro del concepto de acto administrativo el carácter de decisión o resolutivo que éste tiene. Ello quiere decir que a través del acto administrativo lo que hace la Administración del Estado es tomar una decisión de aplicación del ordenamiento jurídico a un caso concreto en una determinada forma. En efecto, lo que hace el ente público a través del acto es resolver una determinada manera de aplicar o ejecutar el ordenamiento jurídico público a un caso en particular que puede afectar o favorecer a una persona, un grupo de personas o incluso a la comunidad en su conjunto".[38]

El "acto administrativo", está definido por el art. 3 de la Ley Nº 19.880, que "Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado", de la siguiente manera: "Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. / Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. / Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones. El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro "Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su competencia. / Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. / Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente. / Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa,

---

[34] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 38, p. 43.
[35] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 58.
[36] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 170, p. 114.
[37] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 170, p. 114.
[38] Bermúdez Soto, Jorge (2010), "Estado actual del control de legalidad de los actos administrativos. ¿Qué queda de la nulidad de derecho público?", en *Revista de Derecho*, Vol. XXIII, Nº 1 – Julio 2010, p. 106.

salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional".

Considerando lo expuesto, podríamos distinguir, dentro de la *potestad administrativa*, entre la *potestad reglamentaria*, por una parte, y las demás potestades administrativas, a saber, la *potestad administrativa de ejecución*, la *potestad administrativa de revisión de oficio o de revocación o invalidación de los actos administrativos por la propia Administración* y la *potestad administrativa sancionatoria*. La primera, genera efectivamente *reglamentos* (que son, al mismo tiempo, fruto de actos administrativos). Las otras tres, *sólo actos administrativos*. Pero lo cierto es que una y otras potestades, generan normas jurídicas. La primera, de alcance general. Las otras tres, particulares. A todas estas especies de potestades se refiere la definición de acto administrativo del art. 3 citado. De esta manera, la relación entre potestad administrativa y potestad reglamentaria es una de género a especie. El género es la potestad administrativa y una de sus especies la potestad reglamentaria. Pero cualquiera que sea la potestad administrativa, siempre se ejercerá mediante un acto administrativo, aunque diverso será su alcance según se ejercite en uno u otro de los mencionados ámbitos. Por ende, no todo acto administrativo supone el ejercicio de la potestad reglamentaria, pero cada vez que se ejerce ésta, ello debe ocurrir mediante un acto administrativo. A su vez, dentro de la *potestad administrativa de ejecución*, es posible formular un último distingo, según si se trata de actos administrativos *resolutivos*, actos administrativos *no resolutivos* (actos de mero trámite o que contienen informes, etc.) y actos constitutivos de *contratos administrativos*. Estos últimos se rigen, en lo formal, por el Derecho administrativo, pero en lo sustancial, por el Derecho civil.

Considerada en toda su extensión, incluyendo por ende tanto a la potestad reglamentaria propiamente tal como a los actos administrativos que en estricto rigor no constituyen un ejercicio de la misma, la potestad de la Administración Pública se manifiesta por medios de Decretos Reglamentarios, Decretos Simples, Resoluciones, Ordenanzas, Instrucciones, Circulares, etc.

Todos estos actos emanan de los órganos y de las personas que integran la "Administración del Estado". El art. 1, inc. 2º de la Ley Nº 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado", establece quiénes la conforman: "La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias,[39] las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley".

8.2. Limitaciones en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Los funcionarios públicos que ejerzan las facultades que les confiere la potestad reglamentaria o que en general dictan actos administrativos, tienen dos limitaciones:
a) Limitaciones sustantivas.

Estas limitaciones deben entenderse en dos sentidos:
i.- Los actos que realicen, deben encuadrarse estrictamente en las atribuciones que el ordenamiento jurídico les otorga, conforme al principio en virtud del cual en Derecho público sólo puede hacerse aquello que está expresamente permitido.

[39] Los intendentes fueron reemplazados por los delegados presidenciales regionales (art. 115 bis de la Constitución Política) y por los delegados presidenciales provinciales (art. 116 de la Constitución Política).

ii.- Al ejercitar dichas atribuciones, ciertamente que sus actos no pueden infringir normas constitucionales ni legales, es decir, las de rango superior a las que se configuren en virtud de la potestad reglamentaria.
b) Limitaciones formales.

El acto administrativo debe generarse conforme al procedimiento establecido por la ley. Para ello, debe darse cumplimiento a las normas de la citada Ley Nº 19.880. En tal sentido, el art. 4 de este cuerpo legal señala los principios a los que debe someterse un procedimiento administrativo: escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad. Los arts. 5 a 16 de la misma Ley, se refieren a cada uno de estos principios.

Estas limitaciones se desprenden de los arts 7 de la Constitución Política y 2 de la Ley Nº 18.575. Dispone el art. 7 de la Constitución: "Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. / Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. / Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale". Establece el art. 2 de la Ley Nº 18.575: "Artículo 2°.- Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes".

8.3. Autoridades administrativas con potestad reglamentaria.

Son múltiples las autoridades administrativas que tienen potestad reglamentaria: desde el Presidente de la República (art. 32, Nº 6 de la Constitución Política), sus Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, los Gobernadores, los Alcaldes (reglamentos municipales, art. 12 de la Ley Nº 18.695) y otros funcionarios públicos como los Jefes de Servicios, etc.[40]

8.4. Amplitud de la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

Esta se encuentra establecida en la Constitución Política en su art. 32 Nº 6, que dispone: "Son atribuciones especiales del Presidente de la República: (…) 6º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes".

De esta disposición se deduce que la Potestad Reglamentaria del Presidente de la República, comprende lo siguiente:
a) La facultad de dictar mandatos generales y especiales encaminados a la ejecución de las leyes. Es la que se denomina "Potestad reglamentaria de ejecución".
b) La facultad de dictar normas o resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones propias para Gobernar y Administrar el Estado, supuesto, naturalmente, que se respeten los principios constitucionales y que no exista una ley expresa en contrario. Es la que se llama "Potestad reglamentaria autónoma".[41]

---

[40] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 171, p. 115.
[41] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 172, p. 115.

De la distinción anterior, se pueden clasificar a los reglamentos que dicta el Presidente en reglamentos *de ejecución* y reglamentos *autónomos*.

Los *reglamentos de ejecución*, son aquellos cuya finalidad es asegurar la aplicación de una ley, sus normas tienden a poner en marcha a las normas más generales de la ley. Las normas del reglamento, como expresa Vodanovic, deben encuadrarse dentro de la pauta fijada por la norma legal y en caso alguno pueden contrariar sus preceptos, modificarlos, restringirlos o ampliarlos. El Reglamento de Ejecución, es siervo de la ley, que detalla, como quiera que su razón de ser es desenvolver las reglas generales, explicar las consecuencias de los principios que ellas contienen, determinando la manera de cumplirlas, según las circunstancias que pueden presentarse. En la jerarquía de las normas jurídicas, el Reglamento de Ejecución, está debajo de las leyes, en especial de aquella ley cuya aplicación tiende a llevar a cabo. En consecuencia, este reglamento no puede, sin caer en la tacha de ilegalidad, contrariar preceptos de la ley y menos de la Constitución Política.[42] En el mismo sentido, afirma Ducci, "en las materias que deben ser objeto de ley [el Presidente de la República] sólo podrá dictar las normas necesarias para el cumplimiento de dichas leyes, sin poder sustituir sustantivamente sobre la materia".[43]

Ejemplos de Reglamentos de Ejecución son:

i.- El Reglamento del Registro de Prendas sin Desplazamiento de la Ley Nº 20.190 (Decreto Supremo Nº 722 de fecha 8 de septiembre de 2010, que se publicó en el Diario Oficial de fecha 23 de octubre de 2010).

ii.- El Reglamento del Decreto con Fuerza de Ley N° 164, concerniente a concesión a privados de Obras Públicas (Decreto Supremo Nº 956, publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de octubre de 1997).

iii.- El Reglamento de la Ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas (Decreto Supremo Nº 702, publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de julio de 2012).

iv.- El Reglamento de la Ley Nº 21.442, sobre Copropiedad Inmobiliaria (Decreto Supremo Nº 7, publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de enero de 2025).

v.- El reglamento de la Ley Nº 20.830, sobre Acuerdo de Unión Civil (Decreto Supremo N° 510, publicado en el Diario Oficial con fecha 16 de septiembre de 2015).

Los *reglamentos autónomos* son los que no se relacionan con una ley determinada y reglan materias que no están normadas por una ley ni declaradas de la exclusiva incumbencia de una ley por la Constitución. Estos Reglamentos, se dictan por la autoridad administrativa en ejercicio de sus propias atribuciones o de los poderes discrecionales que se le reconocen.[44] Ducci previene que "Como la Constitución ha señalado tal número de materias que deben ser objeto de ley, la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República es extremadamente reducida. En realidad, prácticamente sólo tendrá cabida en aquellas leyes (…) en las cuales el legislador sólo fija las bases esenciales de una institución. Es indudable que, respetando esas bases, la materia puede ser regulada sustancialmente en forma reglamentaria. En resumen en aquellas materias que la Constitución ha reservado expresamente a la ley, ésta constituye lo que se ha denominado norma de clausura, inhibiendo la competencia reglamentaria para estatuir sobre la materia. En las materias no reservadas a la ley, la norma de clausura va a ser el reglamento, que podrá reemplazar a la ley, igualmente en las materias objeto de una ley de base en las que, respetando dichas bases, podrá complementarlas sustantivamente".[45]

8.5. Decretos en general y decretos supremos.

---

[42] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 175, p. 116.
[43] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 38, p. 43.
[44] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 175, p. 117.
[45] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., N° 38, pp. 43 y 44.

En general, Decreto, es todo mandato escrito y revestido de las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico, dictado unilateralmente por la autoridad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones. Cuando es emitido por el Presidente de la República, recibe el nombre de *Decreto Supremo*. [46] Como expresa el art. 3 de la Ley Nº 19.880, "El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro "Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su competencia".

Entre otras materias, debe dictarse un decreto supremo, por ejemplo:

i.- Para promulgar una ley.
ii.- Para promulgar el reglamento de una ley.
iii.- Para nombrar Ministros, subsecretarios, Jefes de Servicio, etc.
iv.- Para privar de la nacionalidad en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados (art. 11, N° 2 de la Constitución).
v.- Para fijar los requisitos y las condiciones de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, para la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias minerales o fósiles no susceptibles de concesión (art. 19, N° 24 de la Constitución).
vi.- Para fijar los requisitos y las condiciones de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, para la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional (art. 19, N° 24 de la Constitución).
vii.- Para los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros (art. 105 de la Constitución).
viii.- Para convocar a plebiscito, cuando el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma a la Constitución aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara (art. 129 de la Constitución).
ix.- Para indultar a una persona condenada por sentencia ejecutoriada.

8.6. Reglamentos y simples decretos.

Los decretos se pueden clasificar en *Reglamentos* y *Simples decretos*.

Reglamento o *decreto reglamentario*, es un Decreto de alcance general e impersonal, concierne a una generalidad abstracta de personas o situaciones, como el reglamento que señala los detalles de ejecución de una ley. Ducci define los reglamentos como "la colección ordenada y metódica de disposiciones para asegurar el cumplimiento de una ley".[47] Los dicta el Presidente de la República y contienen normas aplicables a un número indeterminado de personas o para una situación indeterminada. Son por tanto generales, como una ley.[48]

Simple decreto o *decreto individual*, es el que se refiere a una persona o situación determinada como el que nombra a un funcionario público en determinado cargo de la administración del Estado o aquél que otorga un indulto particular, o por el cual se nombra un embajador, etc. No son por tanto generales, como los reglamentos.[49]

8.7. Clases de decretos supremos, de conformidad a la función que desempeñan.

---

[46] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 173, p. 115.
[47] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., N° 38, p. 44.
[48] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., p. 98.
[49] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 174, p. 116; Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., p. 98.

De acuerdo al rol que desempeñan, los decretos supremos pueden ser de cuatro clases, según refiere Jaime Williams:
a) Decreto supremo *ordinario*: "es aquel que recae sobre asuntos que conforman la administración ordinaria del Estado y se sujeta a las formalidades generales" (art. 32, Nº 6 de la Constitución Política).
b) Decreto supremo de *insistencia*: "es aquel que dicta el Presidente con la firma de todos sus ministros ordenando al Contralor dar curso a un decreto representado por ilegalidad" (art. 99, inc. 1º de la Constitución Política).
c) Decreto supremo de *emergencia*: "es aquel que dicta el Presidente con la firma de todos sus ministros para ordenar gastos no autorizados por la ley con cargo al 2% constitucional" (art. 32, Nº 20 de la Constitución Política).
d) Decreto supremo *promulgatorio*: "es aquel que dicta el Presidente como órgano colegislador para sancionar la existencia de una ley y dejar constancia de su texto definitivo"[50] (art. 32, Nº 1 de la Constitución Política).

8.8. Firmas que deben llevar los decretos.

De acuerdo al art. 35 de la Constitución Política, todos los Decretos, sean Simples o Reglamentarios, deben llevar la firma del Presidente de la República y del Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Sin embargo, algunos Decretos, pueden expedirse por la sola firma del Ministro respectivo pero con la frase "por orden del Presidente de la República".[51]

8.9. Control de constitucionalidad y de legalidad de los decretos supremos y resoluciones.

Atendida su jerarquía, los decretos supremos, simples decretos, resoluciones y demás actos administrativos, están subordinado tanto a las normas del ordenamiento constitucional como a las de rango legal. Revisemos seguidamente cómo opera el control en cada uno de estos niveles.
a) Control de constitucionalidad.

El control de la constitucionalidad de los decretos supremos le corresponde al Tribunal Constitucional, de conformidad a lo previsto en el art. 93 de la Carta Fundamental. Dispone en su Nº 16: "Son atribuciones del Tribunal Constitucional (…) 16º.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63". La expresión "cualquiera sea el vicio invocado", denota que puede tratarse de un vicio formal o de fondo. Asimismo, puede tratarse de un decreto supremo de ejecución o autónomo. El mismo art. 93, más adelante, señala quiénes tienen legitimación activa para requerir la intervención del Tribunal Constitucional: "En el caso del número 16º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento". La frase "a requerimiento de cualquiera de las Cámaras", significa que el presentación debe ser hecho por la respectiva Cámara como corporación, representada por su Presidente y

[50] Williams Benavente, Jaime (1999), ob. cit., p. 160.
[51] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 176, p. 117.

previo acuerdo en tal sentido de la mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado. Tal podrá ocurrir con decretos supremos reglamentarios *autónomos*. En cambio, si se trata de decretos supremos reglamentarios *de ejecución*, basta para presentar el requerimiento una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la respectiva Cámara. De conformidad al inc. 3º, primera parte, del art. 94 de la Constitución Política, "En el caso del Nº 16º del artículo 93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo". El inc. 4º del art. 94, establece que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de un decreto supremo, se publicará en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.

b) Control de legalidad.

En el ejercicio de la función de control de legalidad, y de conformidad a lo dispuesto en los arts. 98 y 99 de la Constitución Política de la República, el Contralor General de la República, tomará razón de los Decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que pueden adolecer; pero deberá darles curso, cuando a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos Decretos a la Cámara de Diputados.

8.10. Semejanzas y diferencias entre la ley y el decreto.

a) Semejanzas:

i.- Ambas normas emanan de organismos públicos.

ii.- Ambas son igualmente obligatorias, para la ciudadanía y autoridades.

iii.- Sus normas y mandatos deben subordinarse a la Constitución.

b) Diferencias**:**

En nuestro derecho, la nota distintiva no se encuentra en el *objeto* o *contenido*, porque no hay una norma taxativa de las materias propias del Decreto y de la Ley. Si bien existen asuntos de la exclusiva competencia de la ley (art. 63 de la Constitución), hay otros asuntos que no son privativos del poder legislativo y por ende pueden ser objeto de la ley o del Reglamento Autónomo.

Tampoco la *generalidad e impersonalidad* de las normas es característica exclusiva de la ley, porque, por una parte, hay leyes que se refieren a situaciones individuales (por ejemplo, leyes de gracia) y por otra parte existen Decretos, como los Reglamentarios, que tratan situaciones generales.

La Ley y el Decreto Simple o Reglamentario, se distinguen esencialmente:

i.- Por el *órgano* que los crea. La ley emana del Poder legislativo y el decreto del Poder Ejecutivo o la autoridad administrativa. La primera emana de la potestad legislativa, mientras que el segundo se origina en la potestad administrativa en general y de la potestad reglamentaria en particular.

ii.- Otra característica diferenciadora, es la *superioridad jerárquica* de la ley sobre el decreto; por lo tanto, todo decreto, sea éste individual o sea que corresponda a un reglamento de ejecución o autónomo, no puede contrariar ni modificar las leyes.

iii.- El *proceso de gestación* hasta alcanzar la formación y el efecto de obligatoriedad es distinto para la ley y el decreto.[52]

iv.- Los *recursos constitucionales* son diversos, cuando la ley o el decreto afectan derechos garantidos por la Carta Fundamental: en el caso de una ley, ella se podrá atacar ante el Tribunal Constitucional mediante la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad. En el caso de un decreto, se

[52] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 177, p. 118.

podrá impugnar ante la Corte de Apelaciones competente a través de un recurso de protección.[53]

8.11. Las resoluciones, instrucciones o circulares.

De acuerdo al citado art. 3 de la Ley Nº 19.880, "Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza [a la de los decretos supremos] que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión".

Distinguimos por su parte dos tipos de instrucciones o circulares:

a) Las que se dirigen a todos los ciudadanos: por ejemplo, las que dicta la Comisión de Mercado Financiero, o los dictámenes emanados de la Dirección del Trabajo, o las circulares dictadas por el Director del Servicio de Impuestos Internos, etc.

b) Las que se dirigen a los funcionarios del respectivo servicio: son comunicaciones que los funcionarios públicos superiores dirigen a sus subordinados indicándoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposición jurídica o las medidas que deben tomar para un mejor funcionamiento de un servicio público. Tienen por objeto, ilustrar el criterio del funcionario, para el más conveniente ejercicio de las funciones que le corresponden o el desarrollo de la actividad pública que se le ha encomendado. Las instrucciones del Presidente de la República, son enviadas por los Ministros respectivos. Cuando las Instrucciones van dirigidas a un gran número de funcionarios se envían por medio de *circulares* y si se expiden a un número reducido de funcionarios se denominan *oficios*.[54] El art. 12 de la Ley Nº 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", expresa que "Las instrucciones serán directivas impartidas a los subalternos".

8.12. Las ordenanzas.

Hay dos clases de disposiciones que reciben el nombre de Ordenanzas: unas son dictadas por las Municipalidades y otras son dictadas por el Presidente de la República.

i.- *Dictadas por las municipalidades*, son reglas de aplicación general, dictadas por estos órganos, relativas a la autoridad comunal y ante cuya inobservancia se impone la pena de *multa*. La obligatoriedad de las Ordenanzas Municipales es local, circunscrita al territorio jurisdiccional de la Municipalidad que las dicta.

El art. 12 de la Ley Nº 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", define las ordenanzas municipales en los siguientes términos: "Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de cinco unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes".

La misma Ley alude a la "ordenanza ambiental" (art. 25, letra f), a la ordenanza que regule expendio de bebidas alcohólicas (art. 65, letra o), a la ordenanza que regule el cierre y establezca medidas de control en calles y pasajes (art. 65, letra q), y a la ordenanza para la participación ciudadana (art. 93).

ii.- *Dictadas por el Presidente de la República*, son verdaderos reglamentos que contienen entre sus disposiciones, algunas que son materia de ley y que se caracterizan por tener sanciones penales (multas). Estas ordenanzas se dictan por expresa autorización del Congreso. Por ejemplo: Ordenanza de aduanas y Ordenanza General de Construcción y Urbanización, etc.[55]

---

[53] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., p. 104.
[54] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 178, p. 119.
[55] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 179, p. 119.

9.- Decretos con fuerza de ley y decretos leyes.

9.1. Decretos con fuerza de ley.

a) *Concepto*: son aquellos Decretos, que por expresa autorización del Congreso a través de una ley, dicta el Presidente de la República, sobre materias que según la Constitución Política, son propias de ley. El nombre se explica, porque una vez dictadas adquieren fuerza de ley.

b) *Constitucionalidad*: en la Doctrina, en general, se ha discutido la constitucionalidad de los Decretos con Fuerza de Ley. Estiman algunos, que ellos vulneran el principio de la división de poderes públicos ya que, mediante su dictación, el ejecutivo agrega a sus funciones, otras inherentes a los del Poder Legislativo. Por otra parte se dice que *el Congreso tiene un poder por delegación del pueblo y no puede en consecuencia delegarlo*, de acuerdo con el principio universalmente aceptado, acerca que, "*la potestad delegada no se puede delegar a su vez*".

c) *Los Decretos con Fuerza de Ley en nuestro ordenamiento jurídico*: aparecen recién consagrados con la reforma, que la Ley N° 17.284 del 23 de enero de 1970 introdujo a la Constitución de 1925, sin perjuicio de su existencia fáctica en los años precedentes. La Constitución de 1980 regula la materia en su artículo 64. Tal precepto declara que una Ley puede autorizar al Presidente de la República, para dictar Decretos con Fuerza de Ley, sobre determinadas materias, durante un plazo no superior a un año. En consecuencia, tienen dos limitaciones:
i.- En cuanto a la materia en la que recae la delegación.
ii.- En cuanto al plazo dentro del cual el Presidente de la República debe dictar el decreto con fuerza de ley.

d) *La Constitución Política, prohíbe extender la autorización a diversas materias*: tales como la Nacionalidad, la Ciudadanía, las Elecciones, el Plebiscito y materias comprendidas en las Garantías Constitucionales o que deben ser objeto de Leyes Orgánicas Constitucionales o de Quórum Calificado. La Autorización tampoco podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de las funciones del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República.

La Ley que otorga la referida autorización, señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer determinadas limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.

A la Contraloría General de la República, corresponderá tomar razón de los Decretos con Fuerza de Ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la citada autorización (Ley Delegatoria de Facultades) o cuando sean contrarios a la Constitución Política. Ante la representación de la Contraloría General de la República, el Presidente de la República, no tendrá la facultad de insistir y en caso de no conformarse el Presidente de la República con la representación, deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional, dentro del plazo de 10 días, a fin de que este resuelva la controversia (artículo 99, incisos 2º y 3º de la Constitución Política). Lo anterior, también puede acaecer, tratándose de:
i.- UN DECRETO PROMULGATORIO de una ley o de una Reforma Constitucional, por apartarse del texto aprobado.
ii.- DE UN DECRETO o RESOLUCION, contrario a la Constitución Política.

En todos los casos anteriores, el Presidente de la República, carece de la facultad de insistencia. Si el Tribunal Constitucional, confirma la inconstitucionalidad representada

por la Contraloría General de la República, no se podrá convertir en ley el proyecto o Decreto con Fuerza de Ley de que se trate.

En caso de tratarse de un Decreto Supremo, este queda sin efecto de pleno derecho con el solo mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Los Decretos con Fuerza de Ley, están sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para una ley cualquiera.

9.2. Los decretos leyes.

a) *Concepto*: son aquellos Decretos, que, sin autorización alguna del Congreso, dicta el Poder Ejecutivo, sobre materias que según la Constitución Política son propias de ley, en situaciones de emergencia o grave crisis institucional.

b) *Constitucionalidad de los Decretos Leyes*: si bien no se encontraban regulados en la Constitución Política de 1925 y tampoco en la de 1833, la jurisprudencia terminó por aceptarlos, atendiendo para ello al *principio de la seguridad jurídica*, pues fueron numerosas e importantes las materias reguladas por estas normas, especialmente las relativas a la organización estatal y normas laborales, de previsión y social.

c) *Períodos en que se han dictado*: en tres períodos de nuestra historia del siglo XX, se han dictado Decretos Ley: 816 entre el 1924 y 1925; 669 entre 1931 y 1932; y 3.660 entre el 1973 y 1980.

La numeración de los Decretos Ley, no es progresiva, a diferencia de las leyes. La última ley promulgada antes del 11 de septiembre de 1973 fue la Nº 17.982 y al entrar en vigencia la Constitución Política de 1980 se continuó con la Nº 17.983.

Los Decretos Ley, en consecuencia, tienen la misma fuerza obligatoria de una ley y solo pueden ser modificados o derogados por una disposición de jerarquía legal

10.- Interpretación de la ley.

10.1. Generalidades.

a) Acepciones de la palabra "interpretación".

La palabra interpretación admite varias acepciones:

i.- *Interpretación meramente cognoscitiva*: como afán de conocimiento, que no trasciende más allá de la mente del intérprete, no existe intención de trasmitir lo interpretado. Por ejemplo, la lectura personal.

ii.- *Interpretación reproductiva o representativa*: su finalidad es comunicar a otros el conocimiento que se obtiene; distinguimos acá la siguiente relación: una forma original → interprete → forma expresada, la que no será necesariamente igual a la forma original. Por ejemplo, la interpretacion musical o dramática.

iii.- *Interpretación normativa*, persigue una doble finalidad:

i) Dar a conocer la forma original, lo que implica un conocimiento adecuado de esa forma.

ii) Regular las conductas de las personas, que deben ceñirse al precepto interpretado. El ejemplo clásico, es la interpretacion jurídica o legal.

b) Concepto de interpretación jurídica.

La *interpretación jurídica*, consiste en la determinación del verdadero significado y alcance de la ley, el sentido o valor de la ley en general, frente a situaciones jurídicas concretas a que dicha ley debe aplicarse. Mediante la interpretación jurídica se adapta

la norma legal a la práctica, a la realidad. Como expresa Ducci, en la interpretación jurídica concurren dos elementos, uno abstracto y otro concreto. El abstracto, que corresponde a la interpretación propiamente tal, cuyo fin es fijar el sentido de la ley, y el concreto, que corresponde a la aplicación, "y significa adaptar la ley al hecho concreto".[56]

Cabe deternerse en la frase "determinación del verdadero significado y alcance de la ley". El *significado*, como se comprenderá, implica determinar qué es lo que expresa la ley. Es decir, cuál es la hipótesis en ella formulada. El *alcance*, a su vez, consiste en determinar a qué situaciones debe aplicarse tal hipótesis. Se trata de dos operaciones intelectuales sucesivas y concatenadas. La tercera operación, consistirá en aplicar dicha ley al caso concreto. De esta forma, aislada la hipótesis y fijado su alcance, ella terminará empleándose para la solución del problema jurídico planteado al intérprete.

c) Cuándo se interpreta la ley.

Como bien sostiene Ruggiero, no solo se interpretan las normas obscuras o ambiguas, sino también las que presentan una redacción clara en su apariencia. La interpretacion no presupone una dificultad en la inteligencia de la ley. Equivocadamente, se piensa que un texto legal no requiere de una interpretacion cuando su sentido se capta rapidamente. Sin embargo, toda aplicación de una norma por transparente que esta sea implica una labor intelectual necesaria para resolver el caso particular y concreto con la fórmula general y abstracta dada por el legislador. Por ende, resulta evidente que no es posible aplicar la norma sin su previa interpretación.[57]

Por lo demás, la claridad u obscuridad de una ley es un concepto relativo que además puede variar con el tiempo, en especial al promulgarse normas posteriores que regulan la misma materia.

d) Razonamiento jurídico necesario para interpetrar.

Ahora bien, en el proceso intelectual tendiente a determinar cuál es el verdadero sentido y alcance de una ley, tiene fundamental importancia el tipo de *razonamiento jurídico* que emplee el intérprete. Se alude por la doctrina a un razonamiento *lógico*, *tópico* y *retórico*. El razonamiento *lógico*, es el que tradicionalmente se había postulado para la labor interpretiva. Conforme a él, "El juez no debía crear ni interpretar, sino aplicar la ley del mismo modo que se resuelve un silogismo, en el que la norma constituye la premisa mayor, la descripción del caso la premisa menor, y la sentencia la conclusión. Así: Premisa mayor (la norma): La ley dice que es nula la enajenación de derechos que no son transferibles. Premisa menor (el caso): Juan enajenó a Pedro su derecho real de habitación, que es un derecho intransferible. Conclusión (la sentencia): La enajenación de Juan a Pedro es nula. Este es el llamado método de la absorción o de la subsunción: basta identificar bien el caso para 'incluirlo' en la normativa general de la norma".[58]

Pero este razonamiento, como advierte Corral, ha suscitado críticas en las últimas décadas: "La actual teoría jurídica ha desmentido que este modelo reproduzca fielmente el método que usa el juez para aplicar la norma. De partida, se reconoce que muchas veces ocurre lo inverso, es decir que primero el juez concibe la inclusión y después busca las premisas en las que fundará su sentencia. Además, tanto para la construcción de la premisa mayor como para la menor es necesario efectuar un

[56] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 73, p. 75.
[57] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 224, p. 159.
[58] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., pp. 160 y 161.

proceso interpretativo que no es estrictamente lógico, sino que emplea criterios de mayor plausibilidad, fuerza persuasiva, valoración moral o de mayor o menor justicia, criterios de la experiencia o de los resultados sociales, etc. La misma calificación jurídica de los hechos es una tarea que no está exenta de valoraciones y apreciaciones que son superadas por el esquematismo lógico (…) De allí que se hayan formulado otras teorías acerca de la estructura del razonamiento jurídico y de su método. Se habla de razonamiento dialéctico, en el que se reconoce la probabilidad de las premisas (no su verdad absoluta), en el cual tiene importancia especial el método tópico descrito por Teodoro Viehweg (1907-1988), en su *Tópica y Jurisprudencia*. Según este autor, los jueces y los juristas para resolver casos no usan el esquema del silogismo lógico. Su trabajo es más bien tópico, porque usa puntos de vista preestablecidos (*topoi*) que sirven de base al razonamiento. Es el método que originó el Derecho privado en la discusión de los juristas romanos. De allí que fueran muy casuísticos y enemigos de los conceptos o definiciones abstractas y generales. Otros autores han puesto de relieve que el razonamiento jurídico es de tipo dialéctico o retórico-argumentativo. No se trata de demostrar la verdad lógica de una proposición, sino de lograr persuadir que una determinada solución jurídica es más prudente, mejor argumentada, de mayor peso, más justa, que otra. Y esto se logra sobre la base de una confrontación de pros y contras, de argumentos y refutaciones".[59]

Sin embargo, Corral previene que la lógica no puede dejarse de lado en la solución de un problema jurídico: "Con todo, no debemos desdeñar tampoco el papel de la lógica, porque los métodos tópicos o retóricos tampoco pueden dar lugar a resultados que sean lógicamente absurdos. Se trata más bien de no aplicar un tipo de lógica formal o matemática a una ciencia humana y social como el Derecho. Se hará necesario pensar en una lógica prudencial y deontológica (que no orienta las proposiciones descripctivas: del mundo del ser, sino las prescriptivas: del mundo del deber ser). Además, la lógica juega un papel importante en la sistematización de los resultados de la tópica y la argumentación. Las soluciones de los casos deben ser ordenadas de manera lógica, en un sistema que procure garantizar que casos que sean iguales en sus elementos relevantes, tengan la misma respuesta jurídica".[60]

Por nuestra parte, también consideramos que la lógica es insoslayable en el procedimiento interpretativo. En este sentido, consideramos útil tener presente el antiguo método, descrito por Jacques Paul, que aplicaban en la *lectio* los maestros y los discípulos, en el estudio –y por ende en su interpretación- de los textos clásicos y de los autores medievales, mediante el *accesus ad auctores*: "La enseñanza consiste principalmente en comentar y explicar los *auctores*, es decir, los escritores que se tenían como autoridad en el tema. Este método no hace nada más que trasladar a las escuelas la consideración hacia los textos, sagrados o no, de los romanos del Bajo Imperio y de los cristianos. En este marco, la gramática y la retórica de las escuelas romanas proporcionan los primeros elementos de explicación. El término *lectio* designa el comentario de texto y el curso mismo. Leer, *legere*, es el equivalente de enseñar. La *lectio* es un ejercicio que tiene sus reglas. Comienza con un análisis gramatical del texto que se toma al pie de la letra, es decir, cuya corrección se examina y se le extrae su sentido más corriente. En este estadio, conviene precisar el sentido de los términos y evocar sus múltiples significados posibles. El ejercicio prosigue con un análisis lógico o dialéctico que sopesa con cuidado el valor de cada enunciado. Se expone el pensamiento del autor, *sensus*. Después viene una discusión más general del pensamiento expresado, de lo que significa en relación con un conjunto de doctrinas.

[59] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., pp. 161 y 162.
[60] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 162.

El comentarista puede deslizar aquí fines y sutiles reservas o desarrollar puntos de vista nuevos. Esto es la *sententia*, la enseñanza que se puede extraer del texto".[61]

Llamamos la atención acerca de la semejanza de este método de enseñanza y aprendizaje medieval, con los elementos de interpretación de la ley planteados por Savigny y recogidos en nuestro Código Civil, según revisaremos. Primero, el elemento gramatical, precisar el significado de las palabras empleadas por el legislador. Luego, la finalidad de la norma y la coherencia entre las distintas partes de la ley (elemento lógico) y su relación con las demás normas jurídicas (elemento sistemático). Y todo esto, considerando el contexto en que la ley nació, las razones que llevaron al legislador a crearla, el pensamiento del autor (elemento histórico).

En síntesis, la interpretación supone a nuestro juicio un proceso compuesto por tres fases fundamentales: *comprensión* (del texto y de los fines de la norma) → *relación* (entre las diversas partes de la norma y con las demás normas del ordenamiento) → *conclusión* (que en el caso del juez, corresponde a la sentencia).

10.2. Normas de interpretación en el Código Civil.

Diversas normas del Codigo Civil regulan lo concerniente a la interpretación, tanto de la ley, como de los testamentos y de los contratos:

i.- Artículos 3, 9 inc. 2º y 19 al 24, en relación a la interpretación de la ley.
ii.- Artículos 4 y 13, al consagrar el principio de la especialidad.
iii.- Artículos 25 al 51, que definen varias palabras de uso frecuente en las leyes.
iv.- Artículos 1560 al 1566, relativos a la interpretación de los contratos.
v.- Artículos 1056 al 1069, respecto de la interpretación de las disposiciones testamentarias.

Fuera de estas normas agrupadas por el Código Civil de manera sistemática, existen en él otros preceptos que también cumplen una función interpretativa, como ocurre, por ejemplo, con los arts. 574 (en materia de bienes), 1119 a 1126 (en las reglas de los legados), 1830 (en la compraventa)o 2420 (en la hipoteca).

Por ahora, sólo nos referiremos a las normas que regulan la interpretación de la ley. Las concernientes a la interpretación de los contratos, se revisarán en la Teoría General del Contrato. Las que dicen relación con la interpretación del testamento, se revisarán al estudiar la sucesión testada, en el Derecho Sucesorio. Los preceptos particulares, al tratar de la respectiva materia.

10.3. Hermenéutica legal y sistemas de interpretación.

La Interpretacion Jurídica, que se denomina hermenéutica[62] legal, no se realiza arbitrariamente sino de acuerdo a ciertos principios o líneas directivas. Cuando estas se encuentran determinadas por el legislador, tenemos un sistema de interpretacion "*reglado*". De lo contrario, uno "*no reglado*".

Los Codigos Civiles Chileno e Italiano, adoptan el primer sistema; en cambio, el Código Francés y el Alemán adoptan el segundo.

Ambos tienen sus ventajas e inconvenientes. El sistema reglado evita la arbitrariedad, pero amarra al juez en cuanto a los medios para indagar el sentido y alcance de la ley. El sistema no reglado, proporciona al juez un campo más amplio para realizar su investigación, permitiéndole amoldar la ley con mayor facilidad al momento que se vive, pero puede, como contrapartida, prestarse en mayor grado a la

---

[61] Paul, Jacques (2003), *Historia intelectual del occidente medieval*, España, Ediciones Cátedra, citado por Gómez Moreno, Ángel, y otros (2012), *Antología comentada de la literatura española. Edad Media*, dirigida por Andrés Amorós, Barcelona, Castalia Ediciones, p. 104.

[62] Del griego "hermeneutikos", que se descompone en "hermeneuo"=yo descifro, y "tekhné"=arte, es decir, el arte de descifrar o comprender un texto.

arbitrariedad. Frente a esta objección, se argumenta que es difícil que tal abuso se produzca, ya que existen recursos para reclamar de los agravios.[63]

Siendo el sistema consagrado en nuestro Código Civil uno "*reglado*", las normas que lo integran son imperativas para el juez. Si éste las desatiende, su sentencia podrá impugnarse, incluso ante la Corte Suprema, mediante el recurso de casación en el fondo. En tal caso, como frecuentemente lo ha señalado ésta Corte, el recurrente debe precisar qué precetos legales no se han interpretado en la forma que establece la ley. Debe relacionarse la norma *de interpretación* vulnerada con la norma *sustantiva* incorrectamente interpretada.

Pero el sistema de interpretación sólo obliga al juez y no al legislador, pues el primero tiene rango legal y no constitucional. Así las cosas, el legislador, al dictar una ley interpretativa, puede separarse de las reglas de interpretación previstas en el Código Civil. En otras palabras, la interpretación auténtica, es decir la que hace el propio legislador, es una interpretación "no reglada".[64]

En cuanto a la interpretación doctrinaria o privada, aunque ella no es vinculante como la judicial (para los intervinientes en el proceso) o la que hace el legislador (para todos), debe atenerse a las reglas que señala el Código Civil, porque su propósito es facilitar al juez el análisis de los hechos y de las normas que debieran aplicarse a los primeros. Si el destinatario final de la interpretación doctrinaria es el juez, entonces ella debe ajustarse a las reglas del Código Civil, pues también tendrá que hacerlo el juez.

Una cuestión debatida, se refiere a la interpretación de las normas constitucionales. Se sostuvo que no existiendo en la Constitución normas que reglen la interpretación, el intérprete puede interpretar libremente, sin sujeción a reglas predeterminadas. Esta conclusión se fundaba en que el Código Civil recoge las ideas de la Exégesis y la primacía absoluta del tenor literal sobre los demás elementos de interpretación. Sin embargo, como expresa Hernán Corral, "si se aclara la confusión que ha llevado a identificar los arts. 19 a 24 con lo más extremo de la Escuela francesa de la Exégesis, se deshace el peligro de que su aplicación pueda desnaturalizar textos de naturaleza más axiológica y declarativa de principios como las normas constitucionales y los tratados internacionales. Y, por el contrario, se obtendría una interpretación más uniforme e igualitaria de los textos normativos. En efecto, no se ve por qué una ley interpretativa de la Constitución deba ser interpretada de acuerdo al estatuto hermenéutico del Código Civil (ya que es formalmente una ley) y no debe serlo la Constitución misma que es interpretada por ella. Lo mismo puede señalarse respecto de las Leyes Orgánico-constitucionales. En todo caso, los tribunales suelen acudir a estas reglas, aunque a veces las invoquen más como criterios de autoridad, que como preceptos vinculantes. Esta práctica también se observa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".[65]

Respecto de la interpretación de las normas constitucionales, el lector puede revisar los planteamientos que sobre dicho particular se expresan un poco más adelante al tratar del método positivo teleológico o finalista de interpretación, así como también en la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de agosto de 2017, Rol Nº 3729-2017.

10.4. Diversas clases de interpretación.

Según de quien emane, la interpretación es "doctrinal" o "privada" y "por vía de autoridad" o "pública".

---

[63] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 225, p. 160.
[64] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 174.
[65] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., pp. 174 y 175.

La primera, *doctrinal* o *privada*, es producto de los particulares, es la que hacen todas las personas, abogados o ciudadanos en general. No tiene fuerza obligatoria, descansando su autoridad en la solidez o fuerza del raciocinio y en el prestigio del intérprete.

Se refiere a ella el Codigo de Procedimiento Civil, en el recurso de apelación (art. 228: "Los tribunales podrán mandar, a petición de parte, informar en derecho"; art. 229: "El término para informar en derecho será el que señale el tribunal y no podrá exceder de sesenta días, salvo acuerdo de las partes"; art. 230: "Los informes en derecho, con las firmas del abogado y de la parte o de su procurador, y el certificado a que se refiere el número 6º del artículo 372 del Código Orgánico de Tribunales se agregarán a la carpeta electrónica para conocimiento de los ministros") y en el recurso de casación en el fondo (art. 805: "Tratándose de un recurso de casación en el fondo, cada parte podrá presentar por escrito, y aun impreso, un informe en derecho hasta el momento de la vista de la causa"), al facultarse a las partes para recabar informes en Derecho, los que si bien no obligan a la Corte pueden influir en la decisión de la misma según el mérito de sus argumentos y el prestigio del autor. Por otra parte, el art. 342 del Código Procesal Penal, dispone en su letra d) que la sentencia deberá contener "Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo". Por su parte, el art. 66 de la Ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, establece en su N° 5 que las sentencias definitivas deberán también contener "Las razones legales y doctrinarias que sirvieren para fundar el fallo".

La interpretación *por vía de autoridad* o *pública*, emana de aquellas personas investidas por la ley con la facultad interpretativa. Es obligatoria y se divide en *interpretación judicial* e *interpretación legal* o *auténtica***.**

La *interpretación judicial* es aquellas que realizan los Tribunales de Justicia y se manifiesta en las sentencias que dictan.

La *interpretación legal* o *auténtica* es la que realiza el legislador mediante leyes interpretativas.

Ambas son obligatorias, pero la judicial sólo lo es respecto a la causa en que se pronuncia la sentencia (art 3, inc. 2º del Código Civil). La legal, en cambio, es "generalmente obligatoria" (art 3, inc. 1º del del Código Civil).

Si queremos difundir la Interpretación Judicial habrá que referirse al precedente por la vía doctrinal, sin que obligue al Tribunal.

Dispone el art. 3 citado: "Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. / Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren".

A las anteriores clases de interpretación por vía de autoridad, se suma la *interpretación administrativa*, es decir aquella realizada por ciertos Jefes de Servicio a quienes la ley otorga una facultad interpretativa: por ejemplo, el Director del Servicio de Impuestos Internos, quien dicta circulares que fijan el alcance de una ley; también el Director del Trabajo, a través de sus dictámenes sobre materias laborales y previsionales; de igual forma, las Circulares u oficios de la Comisión de Mercado Financiero (Bancos e Instituciones Financieras) o de la "Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento".

Debemos advertir que la interpretación administrativa sólo obliga a los funcionarios encargados de aplicar las normas sobre las cuales aquella recae. Sin embargo, como dichos funcionarios aplicarán el precepto legal de que se trate en la forma interpretada por la autoridad administrativa, en la práctica los particulares también se verán afectados. Con todo, éstos podrán recurrir a la justicia ordinaria, si disienten de la interpretación del ente administrativo, pues la última palabra la tendrán los jueces.[66]

---

[66] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 199.

10.5. Elementos de interpretación.

F. K. von Savigny, distingue elementos de interpretación para leyes "en su estado normal", y otros elementos de interpretación para leyes "defectuosas".

Para las leyes "en su estado normal", plantea cuatro elementos de interpretación: *gramatical*, *lógico*, *histórico* y *sistemático*. No se trata de cuatro clases de interpretación, sino de cuatro operaciones diversas, pero que actúan conjuntamente.[67] En efecto, "El estudio de estos cuatro elementos comprende todo el contenido de la ley. No son cuatro clases de interpretación, entre las cuales pueda elegirse, sino cuatro operaciones distintas, indispensables para interpretar la ley. Sin duda, uno o más de estos elementos pueden prevalecer; y basta no dejar ninguno desapercibido".[68]

a) Elemento gramatical.

Tiene por objeto la palabra. La interpretación de las palabras de la ley, debe tener lugar según las reglas del lenguaje[69]: "El *elemento gramatical* de la interpretación comprende las palabras empleadas por el legislador para enunciar el pensamiento, esto es, el lenguaje de las leyes".[70]

b) Elemento lógico.

Este elemento "conduce a la descomposición del pensamiento, o las relaciones lógicas que ligan sus diferentes partes".[71] Se trata de indagar acerca de "la intención o espíritu de la ley o las relaciones lógicas que unen sus diversas partes".[72]

La "descomposición del pensamiento", es una cuestión de fondo. Las "relaciones lógicas", una de forma.

Tiene por ende este elemento una doble finalidad:

i.- Por una parte, busca desentrañar la intención o espíritu de las leyes para lo cual investiga la "*ratio legis*", es decir el propósito perseguido por la ley, la razón que la justifica y también la "*ocassio legis*", es decir las circunstancias particulares del *momento* histórico que determinaron su dictación. En esta investigación la *ratio legis* es la más importante, hasta tal punto que se ha sostenido que, si cesa la razón de la ley, cesa la ley misma. También se señala que puede cambiar con el tiempo concibiéndola como "una fuerza viviente y móvil"; en tal punto de vista se basa la interpretación histórico-evolutiva.[73]

ii.- Por otra parte, el elemento lógico busca determinar la armonía y cohesión interna de una ley, las relaciones lógicas que unen las diversas partes de una ley. Esta es una cuestión de carácter formal. Puede ocurrir que un artículo o inciso sea claro si lo consideramos en forma aislada, pero luego, al contrastarlo con otro artículo o inciso de la misma ley, se oscurece su sentido, de manera que el intérprete debe arribar a una conclusión que le permita superar esta antinomia. O a la inversa, un precepto podría ser confuso, pero luego su alcance se aclara, a la luz de lo dispuesto en otra norma de la misma ley.

---

[67] Vodanovic H., Antonio, ob. cit., Nº 227, pp. 160 y 161.
[68] Savigny, F. K., citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 356.
[69] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 227, p. 161.
[70] Savigny, F. K., citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 356.
[71] Savigny, F. K., citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 356.
[72] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 223, p. 124.
[73] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 227, p. 161.

c) Elemento histórico.

Se "refiere al estado del derecho relativo a la materia cuando la ley fue expedida. Tal estado determina los efectos de la ley: esos efectos y el cambio motivado por la ley es lo que el elemento histórico debe declarar".[74]

Su objeto es indagar el estado del derecho existente sobre la materia al elaborarse o promulgarse la ley y el estudio de los antecedentes que tomó en cuenta el legislador antes de dictar la ley que se trata de interpretar. El conocimiento de los antecedentes o de la historia fidedigna del establecimiento de la ley que resulta del estudio de los proyectos, actas de las Comisiones Legislativas, debates en las Cámaras, exposición de motivos con que se acompañaron los proyectos, mensajes, etc., tiene un apreciable valor porque trasunta el pensamiento del legislador.[75]

En realidad, el elemento histórico comprende dos cosas: los antecedentes reunidos durante la presentación, discusión y aprobación del respectivo proyecto de ley, y las transformaciones que ha experimentado a lo largo del tiempo la materia regulada en el precepto legal que se interpreta. En el primer caso, se busca determinar cuál fue la voluntad del legislador al momento en que se creó la ley. En el segundo caso, las mutaciones que exhibe la materia, permiten determinar el actual sentido del precepto legal que se interpreta. En el primer caso, se habla de interpretación psicológica. En el segundo caso, se habla de interpretación histórica propiamente tal. Algunos pretenden que la interpretación basada en el elemento histórico sólo comprende uno u otro de estos aspectos. Refiere al respecto Javier Ezquiaga: "Las posturas doctrinales en relación con el fundamento de la interpretación histórica tampoco son unánimes. Dicho de otro modo, se discrepa abiertamente acerca de cuál debe ser el objeto de la indagación histórica: si la voluntad del legislador histórico que redactó el texto objeto de interpretación o la evolución de la regulación efectuada por el texto objeto de la interpretación. Para quienes mantienen la primera posición, el elemento fundamental de análisis histórico son los trabajos preparatorios del documento normativo, mientras que para la segunda opinión el objeto de estudio es la regulación histórica de la materia de que se trate. Veamos ambas posturas. La que considera como finalidad de la interpretación histórica *determinar la voluntad del legislador*, postura que podría denominarse "clásica", ya que tradicionalmente los autores que han estudiado la argumentación jurídica o los medios de interpretación, incluyen dentro del criterio histórico los trabajos preparatorios como el elemento fundamental para determinar la voluntad del legislador que históricamente redactó el texto objeto de interpretación. En todos los autores que incluyen los trabajos preparatorios dentro del elemento histórico se observa, por un lado, que están influidos por la cuatripartición de los elementos de la interpretación hecha por Savigny (gramatical, lógico, histórico y sistemático); y, por otro, que consideran como única (o al menos preferente) finalidad del método histórico el descubrimiento de la voluntad del legislador. Frente a esta tendencia, se sitúan otros autores que prefieren separar la interpretación histórica del argumento psicológico, reservando para este último la indagación de la voluntad del legislador histórico. Es la postura que parece más adecuada por una razón fundamental: ambos tipos de interpretación tienen un fundamento diferente: la interpretación histórica presupone la existencia de un legislador conservador y, en consecuencia, de una continuidad en la legislación, mientras que el argumento psicológico pretende dar con la voluntad del legislador, pero del legislador histórico concreto que elaboró el documento objeto de interpretación. La diferencia entre ambos es, por consiguiente, clara: mientras que el argumento psicológico intenta reconstruir la voluntad de las personas que física e

[74] Savigny, F. K., citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 356.
[75] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 227, p. 161.

históricamente elaboraron el documento, la interpretación histórica sirve para otorgar a un documento que plantea dudas interpretativas aquel significado que sea acorde con la forma en que los distintos legisladores a lo largo de la historia han regulado la institución jurídica que el enunciado objeto de interpretación regula. En definitiva, el argumento histórico será aquél por el que 'dado un enunciado normativo, en ausencia de indicaciones contrarias expresas, se le debe atribuir el mismo significado normativo que tradicionalmente era atribuido al enunciado normativo precedente y preexistente que regulaba la misma materia en la misma organización jurídica' (Tarello). O, con otras palabras, '*argumento histórico*, sería más propiamente, todo argumento proporcionado por la *historia del Instituto* que la norma *interpretada* contribuye a regular (Lazzaro)".[76]

En nuestra opinión, no debe plantearse tal antinomia, pues los dos aspectos mencionados, el psicológico y el propiamente histórico, deben ser incluidos en la labor interpretativa.

Hernán Corral denomina a estos aspectos del elemento histórico como "historia próxima" e "historia remota" del establecimiento de la ley: "La próxima es aquella que da cuenta del proceso de discusión, aprobación y promulgación de la ley por medio de los órganos legislativos competentes (…) Pero no siempre es suficiente analizar la historia próxima de una disposición legal para conocer su finalidad y muchas veces es necesario recurrir a su historia remota, es decir, a la historia de la institución jurídica, ya sea en el ordenamiento jurídico de la República, o incluso retrocediendo más atrás hasta buscar el origen más antiguo de la figura legal o disposición. Por ejemplo, respecto del Código Civil es muy frecuente que deba rastrearse el origen de una disposición pasando por el Código Civil francés, las Partidas, el Derecho medieval y llegando a los juristas romanos. El Derecho es un producto histórico, por lo que sus soluciones sólo se comprenden bien si se tiene en cuenta su tradición o trayectoria a través de las distintas sociedades y culturas".[77]

Como una última cuestión que concierne al elemento histórico de interpretación, cabe también indicar que, mediante él, el juez puede arribar a dos posibles conclusiones: que la norma que se interpreta es el resultado de la continuidad en la regulación de una institución jurídica, o, por el contrario, que se aparta de la regulación tradicional y supone por ende una ruptura con dicha regulación pretérita. Para arribar a una u otra conclusión, el elemento histórico desempeñará un rol esencial. En el primer caso, se habla de un "uso estático" de la interpretación histórica. En el segundo caso, de un "uso dinámico" del argumento histórico: "a) *Uso estático de la interpretación histórica*: Esta variante es la forma tradicional de entender el modo de funcionamiento de este argumento: se presume que el legislador es conservador y, por eso, aunque elabore leyes nuevas, su intención es no apartarse del 'espíritu' que tradicionalmente ha informado la 'naturaleza' de la institución jurídica que actualmente ha regulado de nuevo. Es decir, ante una duda acerca del significado de un enunciado, el juez justifica su solución alegando que ésta es la forma en que tradicionalmente se ha entendido la regulación sobre esa materia (…) b) *Uso dinámico del argumento histórico*: Esta invocación de la historia consiste en tomarla como una tendencia hacia el futuro, como un proceso de cambio continuo, o como un proceso irregular, con rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas".[78]

d) Elemento sistemático.

---

[76] Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier (2006), *La argumentación interpretativa de la justicia electoral mexicana*, México D.F., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 147 y 148.
[77] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 184.
[78] Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier (2006), ob. cit., p. 150.

Este elemento "se refiere al vínculo íntimo que liga las instituciones y las reglas de derecho en una vasta unidad. El legislador conocía este conjunto, así como los hechos históricos, y para comprender bien su pensamiento debemos explicarnos claramente la influencia de la ley en el sistema general del Derecho y el lugar que en él le corresponde".[79]

Se basa en la conexión que enlaza a todas las instituciones jurídicas y normas en una gran entidad. Se trata de ver la relación que hay entre la ley interpretada y el conjunto del ordenamiento jurídico.[80] Podríamos decir que se asemeja al elemento lógico en cuanto a establecer la armonía y coherencia de la ley, pero ahora no entre sus diversas partes sino en su relación con todo el ordenamiento jurídico, y en especial con aquellas leyes que versan sobre la misma materia o sobre asuntos semejantes.

Se ha entendido que estos cuatro elementos se consagran en nuestro Código Civil en los siguientes preceptos:
i.- Elemento gramatical: en los arts. 19 inc. 1º, 20 y 21.
ii.- Elemento lógico: arts. 19 inc. 2º, 22 inc. 1º, y 23.
iii.- Elemento histórico: art. 19, inc. 2º.
iv.- Elemento sistemático: arts. 22 inc. 2º y 24.

Nuestra doctrina tradicional, sostuvo que el intérprete debía recurrir a estos elementos conforme al siguiente orden de prelación:
i.- Elemento gramatical: si éste es claro, no debe recurrirse a los demás elementos.
ii.- Elemento lógico y elemento histórico: cuando el tenor literal de la ley sea oscuro.
iii.- Elemento sistemático.

Se agrega por dicha doctrina tradicional que finalmente, cuando no fuere posible aplicar los elementos anteriores, se podría recurrir al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.

Según veremos, la doctrina actual postula que todos estos elementos deben conjugarse, aplicarse en forma colectiva, y no conforme a un orden de prelación.

La doctrina más reciente, también ha apuntado "que los cuatro elementos son mencionados por Savigny como criterios para entender leyes que él llama 'saludables', mientras que para las 'leyes defectuosas', ya sea porque están redactadas de un modo indeterminado o porque llegan a resultados incorrectos, y que son las que realmente necesitan una interpretación, recomienda otros criterios: el lingüístico, el contexto y el resultado".[81]

10.6. Especies de interpretación.

Debemos distinguir entre la interpretación *declarativa*, interpretación *restrictiva* e interpretación *extensiva*, según el resultado al que conduzcan. En efecto, si el proceso interpretativo consiste en la investigación de la voluntad del legislador, expresada en una fórmula que puede ser adecuada o inadecuada, el resultado será disímil.[82]

a) *Interpretación declarativa*.

Mediante ella se reconoce o constata que la fórmula o los términos literales utilizados por la ley, coinciden exactamente con la intención del legislador, vale decir,

---

[79] Savigny, F. K., citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 356.
[80] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 227, p. 161.
[81] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 176, quien cita a su vez a Bascuñán Rodríguez, Antonio (2013), "El mito de Domat", en Fernando Atria y otros (Editores), *Una vida en la Universidad de Chile. Celebrando al profesor Antonio Bascuñán Valdés*, Thomson Reuters, pp. 293 y ss.
[82] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 229, p. 162.

las palabras de la ley expresan con fidelidad o acierto dicha intención legislativa, dicha *ratio legis*. Por lo tanto, la interpretación se denomina "declarativa" pues no tiene más que manifestar o declarar lo que dice la ley. Esta interpretación es la que normalmente opera. En estos casos, el intérprete no puede ni extender ni restringir el alcance de la ley, pues él claramente lo señala.[83]
Así, por ejemplo:
i.- Cuando el art. 1896 del Código Civil señala que la acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años contados desde la fecha del contrato.
ii.- Al establecer el art. 1682 del Código Civil, en sus dos primeros incisos, las causales de nulidad absoluta.
iii.- Al disponer el art. 1796 del Código Civil que no es válida la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente.

b) *Interpretación extensiva*.

Puede ocurrir que las palabras utilizadas en la ley, no reflejen exactamente la intención del legislador, en términos tales que su tenor literal restrinja dicha voluntad legislativa en condiciones no queridas o deseadas al promulgar la ley. En otras palabras, la ley dice menos o parece abarcar menos de lo que quiso decir o abarcar el legislador. Frente a ello, es necesario interpretar la ley extendiendo su alcance. Revisemos algunos ejemplos:
i.- Tratándose del inc. 1° del art. 1464 del Código Civil, respecto de la palabra "enajenación", la que se ha entendido en un sentido amplio, que abarca tanto la transferencia del dominio de una cosa como la constitución de un gravamen sobre ella, como una hipoteca.
ii.- En el N° 3 del mismo art. 1464, respecto a la voz "embargadas", interpretada en sentido extensivo, abarcando no sólo el embargo, propio del juicio ejecutivo, sino también, por ejemplo, las medidas precautorias, que se decretan en los juicios ordinarios.
iii.- En el art. 138 bis del Código Civil, respecto del cual se ha criticado que se refiera sólo a la partición de bienes "hereditarios", sin que haya resuelto la situación de otras comunidades en las que participe la mujer. Por una interpretación extensiva, debiera propiciarse la misma solución, máxime si el art. 2313 somete la división de toda comunidad a las reglas de la partición de la herencia.
iv.- En el art. 2205 del Código Civil, en las normas del mutuo, se establece que "Se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles". Se ha entendido que esta norma no sólo permite pactar intereses en contratos de mutuos, sino que también en otros contratos, como por ejemplo si quedare un saldo de precio en un contrato de compraventa.[84]
v.- En el art. 1841 del Código Civil, en las normas de la compraventa. Conforme al tenor literal de la ley, sólo se podría citar de evicción al último y al antepenúltimo de los vendedores. Sin embargo, se ha concluido por la doctrina y por la jurisprudencia, que es posible citar de evicción a otros vendedores, situados más atrás en la secuencia de vendedores.

c) *Interpretación restrictiva*.

A la inversa del caso anterior, puede ocurrir que las palabras utilizadas en la ley no reflejen con exactitud la intención del legislador en términos tales que su tenor literal extiende en demasía dicha voluntad legislativa. Es decir, la ley dice más de lo

---

[83] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 229, p. 162.
[84] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., N° 229, pp. 163.

que pretendió decir el legislador, pareciera invadir zonas que el legislador no pretendió tocar o regular. Ante tal conclusión, es necesario interpretar la ley en forma restrictiva. Consignamos seguidamente algunos ejemplos:
i.- En el art. 1490 del Código Civil, la voz "enajena" se ha interpretado en su acepción restrictiva o estricta, referida sólo a transferir el dominio a una persona, y no al acto por el cual sin que opere tal transferencia, el dueño constituya una prenda sobre la cosa mueble, caso este último de enajenación en su acepción amplia.
ii.- En el art. 1781 del Código Civil, al facultar a los herederos de la mujer a renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal, debemos excluir entre aquellos al viudo, a pesar de que también es heredero de la mujer.
iii.- En el art. 1796 del Código Civil, se establece que es nulo el contrato de compraventa celebrado entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. En principio, como la norma no distingue, pareciera que debe aplicarse a toda compraventa celebrada entre las personas recién señaladas. Sin embargo, Alessandri sostenía que el precepto no incluye la compraventa celebrada entre el padre o madre y el hijo que a pesar de ser menor de edad, fuere titular de un patrimonio especial, obtenido con su trabajo, denominado peculio profesional o industrial (que tiene su antecedente en el peculio castrense del Derecho romano). Incluso, en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 15 de marzo de 2018, autos Rol N° 4.080-2017, se concluye que la hipótesis del art. 1796 no se aplica en el caso que el padre –que no tenía la patria potestad de su hijo-, vendiere un inmueble a dicho hijo (que actuó representado legalmente por su madre). Sin embargo, la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo, que fue acogido, anulándose la sentencia impugnada, por fallo de la Corte Suprema de 23 de agosto de 2019, Rol Nº 12.971-2018.

Se ha sostenido que, en ciertos tipos de leyes, siempre debiera preferirse una interpretación restrictiva. Tales serían: las leyes de excepción, las leyes que imponen sanciones, las leyes que declaran la invalidez de ciertos actos, las leyes que establecen incapacidades o inhabilidades, las leyes que exigen el cumplimiento de ciertas formalidades, las leyes que establecen limitaciones a las libertades o derechos constitucionales, y las leyes que establecen cargas públicas.[85] En nuestra opinión, en tales casos coincidimos que jamás debiera dárseles una especie de interpretación extensiva, pero por regla general la especie que debiera operar sería la declarativa, y en algunos casos, una especie de interpretación restrictiva (como en el ejemplo recién citado del art. 1796 del Código Civil, respecto de la compraventa entre el padre o la madre y el hijo no emancipado, en lo referido al peculio profesional o industrial del menor).

Cabe señalar también que por expreso mandato de la ley, "Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes", según reza el artículo 23 del Código Civil.

Este artículo tiene un fundamento histórico, ya que, en la Edad Media, en el ámbito del Derecho canónico, se estableció el principio "*Odia restringi et favores convenit ampliari*", es decir, al interpretar la ley, lo odioso se restringía y lo favorable se ampliaba. Andrés Bello alude a esta fórmula: "En caso de duda, si se trata de cosas favorables, es más seguro ampliar la significación; y si se trata de cosas odiosas, es más seguro restringirla".[86]

---

[85] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 159 y pp. 191 y 192.
[86] Bello, Andrés (1981), *Principios de Derecho Internacional*, p. 180, en *Obras Completas*, Caracas, La Casa de Bello, citado por Guzmán Brito, Alejandro (2007), *Las Reglas del "Código Civil" de Chile sobre interpretación de las leyes*, Santiago de Chile, LexisNexis, p. 192.

El propio Bello, proporciona ejemplos de cosas odiosas y favorables: 1° Todo lo que sin causar un gravamen notable a persona alguna cede en beneficio general de la especie humana, es favorable y lo contrario es odioso; 2° Todo lo que atiende a la utilidad común y a la igualdad de las partes, es favorable, y lo contrario es odioso; 3° Todo lo que va a mudar el estado presente haciendo consistir la ganancia de los unos en la pérdida de los otros, es odioso; 4° Todo lo que contiene una pena es odioso; 5° Todo lo que propende a inutilizar un pacto y hacerlo ilusorio es odioso; 6° En las cosas que participan de lo favorable y de lo odioso, debe compararse el bien con el mal, y mirarse como favorable aquello en que prepondera el bien, y como odioso lo contrario.[87]

Como señala Guzmán Brito, "En la formulación clásica del antiguo derecho, el principio *odiosa restringenda favorabilia amplianda sunt* recibía aplicación en todo caso, hubiera duda o no la hubiera, de modo que funcionaba como regla material de restricción o extensión".[88]

Como esto se prestaba para abusos, el legislador consideró conveniente abolir, en forma expresa, tal fórmula.

Con todo, si correspondiere aplicar el art. 24 del Código Civil, y específicamente en el marco del mismo la equidad natural, podría ocurrir que en alguna materia, se pronuncie una sentencia que permita restringir lo odioso o ampliar lo favorable. Ello se explica por la ubicación del art. 23, y porque al recurrir a la equidad, no es posible aplicar "las reglas de interpretación precedentes" y no hay norma que resuelva la materia, de manera que no se presenta el riesgo de desnaturalizar su "genuino sentido".[89]

10.7. Métodos de interpretación.

Por "método" se entiende un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un fin o resultado determinado. En el campo del Derecho, se han propuesto a lo largo del tiempo, a partir de la codificación moderna, diversos métodos que pretenden establecer la mejor forma de interpretar la ley y fijar su verdadero sentido y alcance, con el propósito de solucionar el caso concreto. Se suele distinguir, por una parte, entre el método lógico tradicional y por otra parte, los métodos nuevos o modernos de interpretación.

a) *Método lógico tradicional*.

Este método pretende sobre todo indagar acerca de la voluntad del legislador al momento de ser redactada y promulgada la ley.[90]

Es propio del positivismo jurídico en boga en el siglo XIX, del cual nace la escuela Exegética, que postula un fuerte apego al texto, un culto al tenor literal de la ley. Se sostiene por esta escuela que en los códigos está todo el Derecho, aun cuando hayan cambiado las circunstancias que motivaron la promulgación de estos.

La interpretación se realiza a través de procedimientos fundamentalmente lógicos, sin que se permita el arbitrio judicial, vale decir, se excluye la posibilidad que el juez adecue las normas en el tiempo.

De esta manera, siguiendo a Vodanovic, los medios que propone este método son los siguientes:

---

[87] Bello, Andrés (1981), ob. cit., pp. 180 y 181, citado por Guzmán Brito, Alejandro (2007), ob. cit., p. 180.
[88] Guzmán Brito, Alejandro (2007), ob. cit., p. 181.
[89] Guzmán Brito, Alejandro (2007), ob. cit., pp. 181 y 182; Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., N° 251, pp. 179 y 180.
[90] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 231, p. 164.

i.- La exégesis, fundada en la explicación gramatical (estructura formal de las oraciones) y semántica (significado de los vocablos).
ii.- Los trabajos preparatorios que originaron el proyecto de ley y su discusión hasta su aprobación.
iii.- La conjetura, es decir un juicio acerca de la intención del legislador, que se construye a partir del espíritu de la ley, es decir, la determinación de su finalidad esencial.
iv.- Razonamiento lógico, considerando que el legislador da soluciones racionales, descartando por ende conclusiones absurdas a que pueda llevar la interpretación.
v.- Otros procedimientos lógicos, que corresponden a las reglas prácticas de interpretación (analogía, a fortiori, a contrario sensu, la no distinción, etc.).[91]

Se distingue en este método entre interpretar y aplicar la ley. La interpretación corresponde principalmente al legislador y secundariamente al juez, quien por lo demás deberá hacerlo a partir de normas fijas. En verdad, más que la interpretación, lo que corresponde al juez es la aplicación de la ley. Para este último, ésta es su misión prioritaria. Prevalece por ende la voluntad del legislador, su intención, lo que trae como consecuencia la omnipotencia de la ley. Los artículos 3 y 5 del Código Civil, son una manifestación de los principios anteriores.

Se funda esta teoría en el principio de separación de poderes, que se formula a fines del Siglo XVIII. Es por ende el legislador quien dicta e interpreta la ley. A su vez, el Ejecutivo y el Poder Judicial sólo deben aplicarla, no comentarla ni tampoco interpretarla.[92] Se supone que el legislador es sabio, que redacta en forma clara y precisa las normas legales, de manera que el juez debe limitar su tarea a aplicarlas al caso concreto de que esté conociendo. Es el pueblo quien, a través del Poder Legislativo, dicta las leyes. El juez debe aplicarlas sin desconocer el tenor literal de aquellas. Si lo hiciere, atentaría contra los fundamentos mismos de la democracia representativa.

De esta manera, "… el juez debe simplemente ser el aplicador de la decisión soberana del poder político, que se refleja en la ley. Por ello, el juez debe aplicar la ley clara, aunque personalmente le parezca injusta. Y si la ley es oscura, debe buscar la intención del legislador en su texto, analizando las palabras empleadas (método exegético) o indagando en las actas de los órganos políticos en que se discutió el texto legal".[93]

Esta era la teoría en boga en Francia, a la época en que entra en vigencia el Código Civil francés. De ahí que los grandes comentaristas del mismo –como Duranton, Aubry y Rau, Demolombe, Troplong, Laurent, etc.-, adscribirán a esta escuela exegética. Para ellos, el legislador es omnipotente e infalible, y la ley ha de ser la única fuente de las decisiones jurídicas. En síntesis, interpretar consiste en buscar cuál es la voluntad del legislador, manifestada en el tenor literal de la ley.[94]

En efecto, el auge de la Escuela Exegética fue una consecuencia del Código Napoleón. Como refiere Brebbia, "La sanción del Código Civil francés ejerció una gran influencia sobre el moderno planteamiento del tema en razón de haberse creado una situación histórica inédita proveniente de dos circunstancias: 1. La existencia de un solo *corpus juris*; 2. La aparición de un legislador viviente, que se tradujeron en el monopolio acordado a la ley como fuente y en la valoración de la voluntad del legislador como contenido de la ley. La atmósfera mística en que se sancionó el Código hizo perder pie a la interpretación austera, objetiva que se hacía de los textos romanos: ahora la interpretación quedaba conclusa cuando se podía saber lo que quiso decir el legislador concreto que la había redactado. La constelación de las ideas de la

[91] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 231, p. 164.
[92] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., p. 121.
[93] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 170.
[94] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., pp. 121 y 122.

Exégesis gira alrededor de estas cuatro premisas, estrechamente vinculadas entre sí: 1. La codificación estabilizó el Derecho. 2. Existencia de un monopolio interpretativo por parte del legislador; 3. La codificación creó una cesura histórica que canceló y borró el pasado; 4. No hay más derecho que el codificado: la ley es la única fuente de cognición del Derecho".[95]

Debe reconocerse, sin embargo, que la opinión de los redactores del Código francés no era tan tajante al respecto. Como indica Carlos Ramos Núñez, "En realidad, el napoleónico no cerraba del todo las puertas a la costumbre. Los redactores del Código civil admitían la fuerza obligatoria de la costumbre, en cierta medida; en el proyecto definitivo, el título preliminar comprendía disposiciones formales en ese sentido, disposiciones que si desaparecieron después fue ante todo por su carácter demasiado filosófico, incongruente con el tecnicismo que el Código buscaba. En el curso de los trabajos preparatorios Portalis se expresó en términos exentos de ambigüedad y que conviene recordar: 'Nosotros estamos igualmente preservados de la peligrosa ambición de querer regularlo todo y preverlo todo. Hágase lo que se haga, las leyes positivas no podrían reemplazar jamás el uso de la razón natural en los negocios de la vida … Un Código, por completo que pueda parecer, apenas terminado no basta para resolver los mil problemas inesperados que se presentan al magistrado. Porque las leyes una vez redactadas, continúan permaneciendo en los términos en que lo fueron. Pero los hombres por el contrario, jamás descansan; obran siempre, y ese movimiento, que no tiene fin y cuyos efectos son diversamente modificados por las circunstancias, produce a cada instante alguna nueva combinación … En defecto de un texto preciso sobre cada materia, un uso antiguo, constante y bien establecido, una serie no interrumpida de decisiones semejantes, una opinión o una máxima aceptada, hace a veces de ley'".[96]

Pero estas ideas de Portalis finalmente no se admitirán, al menos en forma explícita. De ahí que "La escuela de la exégesis, a diferencia del discurso del codificador Portalis, mira con pavor tanto a la costumbre como a la actividad hermenéutica de los jueces. Al sacralizar la actividad legislativa, llega a considerar imposible la modificación de las reglas legales dictadas por el poder político. Lo que piensa el legislador, debe aplicarlo exactamente el juez. La discordia supone un acto subversivo. Cuánta tranquilidad les habrá dispensado a los partidarios de la supremacía plena de la ley sobre la costumbre, la lectura de uno de los exégetas más conocidos, Duranton, en la advertencia de su *Cours de droit français, suivant le Code Civil*, donde recomienda hacer comentarios en la medida que se produzcan reformas legislativas, o lo dicho por otro afamado exponente de esta tendencia, el profesor belga Laurent, quien consideraba que cuando los códigos 'no dejan nada al arbitrio del intérprete, éste no tiene por misión crear Derecho, el Derecho está hecho'. Cuando 'el legislador habla –agrega Laurent- no queda a los intérpretes más que obedecer'. Demolombe, otro exponente clásico del movimiento, declara: 'Mi divisa, mi profesión de fe: los textos antes que todo'. Proudhom expresaría la misma concepción: 'Los textos antes que otra cosa deben ser la divisa del jurista'. Mourlon dirá, a su vez: 'Para el jurisconsulto, para el abogado, para el juez, existe un único Derecho: el Derecho positivo'. Aubry y Rau insistirían siempre: 'La ley, pero nada más que la ley'. La filosofía, la historia y la costumbre perdían así todo interés para el jurista. Estos dos últimos, profesores de la Universidad de Estrasburgo, procurarían explicar con lucidez la hegemonía moderna de la ley. Sostienen que antes de la codificación la costumbre

---

[95] Brebbia, Roberto H. (2000), *Instituciones de Derecho Civil*, I, Rosario, Editorial Juris, p. 30.

[96] Ramos Núñez, Carlos (2009), "Consideración de la costumbre en la doctrina jurídica virreinal. De la valoración clásica a su impugnación moderna", en *La tradición clásica en el Perú Virreinal*, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, p. 294; Portalis, Jean-Etienn Marie, "Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de la commission du gouvernement", en Fenet, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil*, t. I, p. 469.

estaba generalmente admitida, porque era compatible con el sistema político absolutista, pero, bajo la democracia republicana, devino incompatible con un ordenamiento fundado sobre el principio de la separación de los poderes".[97]

Considerando lo precedentemente transcrito, se explica que la principal crítica a este método lógico tradicional, diga relación a que "impide toda evolución y progreso del Derecho. Impide que el Derecho, a través de una interpretación progresiva, pueda adaptarse a la evolución de los tiempos y a los cambios sociales".[98] El método "… conduce a la petrificación del Derecho, porque, mientras la vida se renueva constantemente, deja a las normas jurídicas estáticas en la época de su nacimiento y, por ende, sin aptitud para moldear en forma adecuada las realidades nuevas";[99] "El aplicar un criterio exegético impide toda evolución y progreso del derecho a través de la interpretación jurídica. Impide que éste, a través de una interpretación progresiva, pueda adaptarse a la evolución y cambios del medio social y condena al mundo actual a la aplicación estricta de fórmulas dictadas tomando en consideración un estado social a veces anterior en siglos al momento presente".[100]

Nos parece que estas críticas deben matizarse. Aunque en algunos casos es razonable e incluso imperativo que el juez adecúe el sentido de la ley a las exigencias del presente, no se puede desconocer que el método lógico tradicional, tiene sin duda un aspecto a favor: al proclamar un irrestricto respeto al tenor de la ley, limita al intérprete, en especial cuando éste intenta arribar a conclusiones forzadas o a veces derechamente antojadizas. El método es funcional por ende a la seguridad jurídica, e impide lo que en nuestros días se ha llamado "activismo judicial", es decir, aquella práctica en virtud de la cual el juez, apartándose del tenor de la ley, construye soluciones que considera más justas y adecuadas al tiempo actual. Por loable que esto pudiera ser, lo cierto es que constituye un atentado al principio de separación de poderes y al principio fundamental por el cual es el legislador el que debe crear el Derecho, y el juez aplicarlo en el caso concreto. Adicionalmente, la adecuación del Derecho a los cambios que experimenta la sociedad, no es una tarea que corresponda a los jueces, sino que al propio legislador. Es éste quien debe estar atento, para introducir las modificaciones que el ordenamiento jurídico requiere, para dar una adecuada respuesta a las transformaciones que ocurran en la comunidad nacional. Así las cosas, los Cortes, conforme al art. 5 del Código Civil, pueden señalar al Presidente de la República, las dudas, dificultades o vacíos que se presenten en la interpretación y aplicación de las leyes, para que aquél, como colegislador, reaccione y presente los proyectos de ley tendientes a resolver los problemas relevados por la judicatura.

Pero lo cierto es que, ya a principios del siglo XX, como constata Brebbia, "Los postulados sobre los que se había cimentado la doctrina de la Exégesis: a) la ley es la única fuente de derecho y expresa la voluntad de un legislador concreto; b) la interpretación debe hacerse según el momento en que la ley fue sancionada y constituye un proceso puramente mecánico, cayeron en franca derrota".[101]

En efecto, esta reacción contra la Escuela de la Exégesis, "tuvo caracteres violentos pudiendo señalarse como jalones de los ataques las obras de Geny (1893), Lambert Aubri (1903), Kantorowicz (1906), Cruet (1908), Ganelin (1910) y Morin (1911). Resulta extremadamente difícil efectuar una síntesis de las críticas de estos autores pero puede afirmarse que, en general tales tendencias afirman: a) la negación de los principios y de la dogmática; b) atacan la majestad de la ley; c) están imbuidas

[97] Ramos Núñez, Carlos (2009), ob. cit., pp. 294 y 295.
[98] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., p. 122.
[99] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 231, p. 164.
[100] Ducci Claro, Carlos (1984), Nº 75, p. 76.
[101] Brebbia, Roberto H. (2000), ob. cit., p. 28.

de un voluntarismo y emocionalismo irracionalistas; d) consideran la interpretación como un acto creador (Kelsen)".[102]

Los postulados que enfrentan por una parte al método tradicional con los nuevos métodos de interpretación, se recogen también al distinguir entre la interpretación literalista, finalista y sociologista. Como refiere Corral, la interpretación literalista "asume que el factor decisivo, sino único, para conocer el sentido de la norma es el significado gramatical de las palabras de que se compone. El texto es el único vehículo para conocer el sentido de la norma y no se atiende ni a la finalidad ni a la realidad sociológica de su aplicación. A esta forma de interpretación a veces se le llama también 'mosaica' (porque era la que los maestros judíos preferían para interpretar la legislación de Moisés prevista en el Pentateuco); también se le suele denominar "exegética" (por el nombre de la Escuela de la Exégesis francesa que se apoyaba sobre todo en la literalidad de los textos del Código Civil). Por oposición a interpretación literalista, puede hablarse de interpretación finalista, para designar aquella interpretación que intenta superar o corregir el texto de la ley para buscar su sentido recurriendo a su finalidad o espíritu. Otros preferirán dar primacía a la realidad social a la que debe aplicarse la norma, y se podrá aludir entonces a una interpretación sociologista".[103]

b) *Método de la "Escuela Histórica del Derecho"*.

En el marco de esta corriente, fundada como se ha referido en los postulados de von Savigny, el argumento histórico desempeña un rol fundamental en la tarea de interpretación jurídica. Refiere Javier Ezquiaga: "Sintéticamente, los dos puntos principales propuestos por el *método de la escuela histórica* para la interpretación jurídica son los siguientes: a) la interpretación no está vinculada solamente a los casos de oscuridad de la ley, sino a toda aplicación de ésta a la vida real; y b) junto a los elementos gramatical y lógico se da entrada en la interpretación al histórico y al sistemático; además, esos cuatro elementos no constituyen cuatro clases de interpretación, sino que son medios que han de utilizarse combinadamente. La Escuela histórica encuentra su justificación en que al igual que no es posible ninguna existencia humana completamente individual, cada período de la historia de un pueblo es continuación y desarrollo de las edades pasadas. En definitiva, el Derecho sería fruto de una ininterrumpida tradición. En virtud de ello, Bobbio señala como características de la Escuela histórica: el 'amor al pasado', el 'sentido de la tradición' (que revalorizó la costumbre como su expresión), la individualidad y variedad del hombre (no hay un Derecho único intemporal, sino que es fruto de la historia), la irracionalidad de las fuerzas históricas (el Derecho no es un fruto de un cálculo racional sino que brota del sentimiento de justicia que todo hombre tiene esculpido en el corazón), y el pesimismo antropológico (se desconfía de las reformas de las nuevas instituciones)".[104]

Como indica Hernán Corral, La "Escuela Histórica del Derecho", como ya habíamos señalado, abogaba por evitar que se codificara el Derecho, "puesto que sostenía que el Derecho es el resultado de una tradición histórica, que se refleja en el espíritu del pueblo, más que en una creación de textos por los cuerpos legislativos. El Derecho es como la lengua, las costumbres, que se van moldeando a lo largo de la evolución de los pueblos. La interpretación, por consiguiente, no debe atenerse a las palabras de los textos legales, ni tampoco a la historia inmediata de la decisión del órgano legislativo, sino que debe profundizar en la conformación histórica de las

[102] Brebbia, Roberto H. (2000), ob. cit., p. 30.
[103] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., pp. 159 y 160.
[104] Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier (2006), ob. cit., p. 146.

instituciones jurídicas y en las necesidades del espíritu del pueblo a las que ellas responden".[105]

c) *Método histórico evolutivo*.

Como expresa Javier Ezquiaga, "Como reacción a la Escuela de la exégesis, y por considerar el método de ésta excesivamente petrificador de la legislación, surge la propuesta del método histórico evolutivo para interpretar las leyes, cuya característica general sería la de concebir la interpretación como un trabajo de adaptación de los preceptos positivos a las variaciones históricas de la vida. El método histórico-evolutivo sería, por tanto, un método elástico y dinámico que pretende adaptar la legislación y los conceptos jurídicos a las necesidades actuales de la vida, basándose en que una ley una vez dictada se objetiviza. Por ello la labor del intérprete no consiste en indagar la voluntad del legislador en el momento de elaborar la ley, sino en analizar históricamente la evolución jurídica y armonizarla con la evolución social".[106]

Cabe señalar que el método histórico-evolutivo no debe confundirse con los postulados de la "Escuela Histórica" del Derecho. En efecto, como subraya Ezquiaga, "en estas propuestas metodológicas subyacen dos concepciones completamente distintas del papel que la historia debe desempeñar en la interpretación jurídica: una estática y otra dinámica. A la primera se adscribiría la Escuela Histórica, que propugna como criterio para interpretar la legislación la tradición; a la segunda, el método histórico-evolutivo, que propugna como criterio para interpretar la legislación, la realidad social existente en el momento de aplicarla. Se aprecian, en definitiva, dos propuestas diferentes sobre el papel que la historia debe desempeñar en la interpretación: o bien como un instrumento conservador y continuista al servicio de la seguridad jurídica y del respeto a la voluntad del legislador; o bien como instrumento para la adaptación del Derecho a los cambios de la vida social, al entenderse la historia como un proceso de cambio continuo".[107]

Adicionalmente, como explicamos al referirnos a la "Escuela Histórica", el intérprete debe determinar el sentido y el alcance del *Derecho* que rija en el momento en que se plantea el conflicto, y no sólo de *la ley* o de *las leyes vigentes*, considerando que también debe incluirse la costumbre como elemento a interpretar, así como también las leyes que hayan existido acerca de la misma materia, aunque no se encuentren actualmente vigentes, porque tales leyes reflejan la tradición jurídica que debe respetarse por quien interprete.

Según este método histórico-evolutivo, la ley no debe concebirse como la voluntad de su autor. Una vez dictada, se independiza de quien la creó, adquiere existencia autónoma y comienza a vivir su propia vida, cuyo destino es satisfacer un presente en constante renovación. El intérprete, está llamado a hacer cumplir ese destino, vale decir, respetando la letra de la ley, puede atribuirle un significado diverso del originario, que responda a las nuevas necesidades sociales. El principio es el siguiente: debe darse a la ley, no el sentido que tuvo al tiempo de dictarse, sino el que pueda tener al momento de ser aplicada.[108]

Se suele criticar el método histórico-evolutivo, indicándose que no señala una pauta para ajustar el sentido de la ley a los tiempos nuevos, al presente, pudiendo degenerar la operación en la arbitrariedad. Además, como el sentido de la ley queda sujeto a los cambios de cada época y a las influencias del ambiente, la certidumbre de

---

[105] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 170.
[106] Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier (2006), ob. cit., pp. 146 y 147.
[107] Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier (2006), ob. cit., p. 147.
[108] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 233, a), p. 165.

la ley desaparece y por ende la seguridad de los particulares para realizar sus negocios jurídicos.[109]

En rigor, el hecho mismo de "adaptar" la ley al presente y al caso, ha sido cuestionado. En efecto, siguiendo a Brebbia, dicha adaptación no es admisible, cuando ella suponga deformar la ley o despojarla del monopolio del Derecho: "La deformación de la ley se obtiene acordando efectos jurídicos a hechos irrelevantes o negando efectos jurídicos a una circunstancia a la que la ley se los acuerda. Reconocer la existencia de la ley y admitir la libertad de deformarla puede causar más mal que la Escuela de Derecho Libre".[110]

d) *Método de la libre investigación científica*.

Se formuló por el jurista francés Francois Geny, en 1899, en su obra "Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo". Este método hace entrar en juego la interpretación, solo cuando hay dudas acerca del sentido de la norma. Tal sentido se determina de acuerdo con la intención del legislador que revelan las circunstancias dominantes a la época de la dictación de la ley y no a la época de su aplicación.

El intérprete debe reconstituir el pensamiento del poder legislativo considerando el que habría tenido el legislador en su época, si hubiera conocido las dificultades que hoy se presentan. Hasta aquí, hay coincidencia con el método lógico tradicional. La discrepancia comienza frente a las obscuridades insalvables y los vacíos o lagunas de la ley. En tales casos, inútil resulta buscar una intención legislativa que no va a existir. El intérprete debe entonces crear la solución adecuada al caso. La investigación que realiza es "Libre" y "Científica". Libre, porque la investigación se encuentra sustraída a la autoridad positiva de las fuentes formales del Derecho, como son la ley y la costumbre. Científica, porque se apoya en elementos objetivos que sólo la ciencia puede revelar (la historia, la sociología, la psicología, la economía, etc.). De tal forma, el plano científico estaría representado por las fuentes materiales o reales del derecho, mientras que las fuentes formales, corresponderían a un plano técnico. En consecuencia, las fuentes materiales, deben prevalecer sobre las fuentes formales, en caso de oscuridad o ausencia de la ley, como la ciencia prevalece sobre la técnica.[111]

"Esta doctrina –refiere Ducci- preconiza un método libre para llegar no sólo a las fuentes formales de las reglas de derecho que son la costumbre y la ley, sino a las fuentes reales de dichas normas. Estas fuentes reales están constituidas por un elemento racional que es la noción de derecho y un elemento experimental que es la aspiración a la armonía colectiva que existe en el medio social. Según ella la interpretación procede cuando hay dudas sobre el sentido de la ley y del texto. En ella se consideran el precepto y el fin social de la ley, siempre que junto al texto –fuente formal de la ley- esté la ciencia del derecho, fuente real de la ley".[112]

e) *Método positivo teleológico o finalista*.

La teleología es la ciencia que se aboca al estudio de los fines o propósitos de un ser, objeto o materia.

Este método fue propuesto por la doctrina alemana -Rudolph von Ihering (1818-1892), Philipp Heck (1858-1943) y su "jurisprudencia de intereses"-, entre otros.

---

[109] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 233, a), p. 165.
[110] Brebbia, Roberto H. (2000), ob. cit., p. 37.
[111] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 234, b), p. 166.
[112] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 75, p. 76.

Según este método, las normas jurídicas tienen un fin práctico y este es el que debe indagar el intérprete y no la voluntad o intención del legislador, que es subjetiva y puede no coincidir con aquel fin.[113]

Se afirma que del tenor literal de una norma puede deducirse el elemento finalista como el criterio interpretativo por antonomasia. Dicho elemento sería el único desde el que puede desentrañarse el auténtico sentido de un precepto legal. Todos los demás elementos serían complementarios a este, pues cobran sentido en la medida que coadyuvan con él. La finalidad de la norma corresponde a la *ratio legis*, es decir, la determinación del motivo por el cual la norma fue dictada y la finalidad que ella pretende alcanzar. Dicha *ratio legis* trasciende cualquier coyuntura histórica, otorgando estabilidad a la tarea interpretativa, pues no se circunscribe a la realidad histórica del momento de su promulgación (que la doctrina denomina *occasio legis*), ni se ve condicionada por el criterio sociológico, que determina que las normas deben interpretarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que deben aplicarse. Al concretar la finalidad de la norma, debe diferenciarse también la *ratio legis* de la *voluntas legislatoris*, pues ésta última no pasa de ser un hecho circunstancial histórico, y por ello efímero. La *ratio legis*, en cambio, presenta un carácter más estable. La interpretación finalista, además, debe tener en cuenta los valores y principios que han inspirado su aprobación.[114]

En la tesis de Philipp Heck, la decisión judicial debe lograrse a partir de la determinación de los intereses que el legislador quiso proteger. A partir de la identificación de estos intereses, podrá luego determinase la finalidad de la ley.

Dos críticas fundamentales se hacen a este método:

i.- Se sostiene que el defecto de este método, consiste en suponer que cada ley tiene un fin práctico, propio, único, cuando en realidad tanto la norma legal como la conducta por ella regulada supone una cadena de múltiples fines sucesivamente articulados.

ii.- Los fines pueden entenderse de manera contradictoria y su apreciación llevar a la arbitrariedad.[115]

Cabe destacar que el Tribunal Constitucional ha sostenido que en la interpretación constitucional debe prevalecer el contenido teleológico de la Constitución. Refiere sobre el particular Rodrigo Andreucci: "Otro tema relevante que se debe destacar, es que no existe ni una sola sentencia emanada de la Corte Suprema que indique si en la interpretación de las normas constitucionales se deben aplicar los artículos 19 a 24 del Código Civil. Sin embargo, fallando asuntos de índole constitucional, en sede de protección, amparo, queja y de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, la Corte Suprema ha aplicado permanentemente los artículos 19 a 24 del Código Civil; en consecuencia existe una declaración indirecta de aplicación de estas normas, y se da por supuesta su aplicabilidad en sede constitucional. El Tribunal Constitucional de la República de Chile, a diferencia de esta omisión de la Corte Suprema, ha sostenido que la interpretación en su sede es diferente a la interpretación de las leyes no constitucionales; así se lee por ejemplo en el considerando Nº 6 del fallo dictado en la causa rol Nº 325 de fecha 26 de junio de 2001 (…): 'En la interpretación constitucional debe siempre prevalecer el contenido teleológico de la Constitución, que si es instrumento de gobierno, también y principalmente es restricción de poderes en amparo de la libertad individual. La finalidad suprema y última de la norma constitucional es la protección y la garantía de la libertad y la dignidad del hombre. Por consecuencia, la interpretación de la ley fundamental debe orientarse siempre hacia aquella suprema meta. Y en el caso de aparente conflicto

---

[113] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 235, c), p. 167.

[114] www.expansiom.com/diccionario-juridico/interpretacion-teleologica-o-finalista (consultado el 19 de diciembre de 2020).

[115] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 235, c), pp. 167 y 168.

entre la libertad y el interés del gobierno, aquella debe primar siempre sobre este último, porque no se concibe que la acción estatal manifestada a través de los cauces constitucionales pueda resultar incompatible con la libertad, que es el fin último del Estado". Lo expuesto en este considerando, corresponde a las ideas del profesor Segundo Linares Quintana, en su texto "Tratado de la Ciencia Constitucional". En los considerandos 12º y 13º de este fallo, se agrega: "12º Que, es una norma de lógica interpretación constitucional muy aconsejable de seguir en situaciones como la que enfrentamos, aquella que nos previene que en los casos en que las palabras o las expresiones de un precepto puedan tener un significado o un alcance distinto, siempre debe preferirse aquel que mejor se aviene con la finalidad perseguida por la norma … 13º Que, una interpretación literal o basada en el principio de la especialidad o en el aforismo jurídico de que donde la ley no distingue no es lícito al intérprete hacerlo, establecidas o reconocidas en el Código Civil para la interpretación de las leyes no reciben aplicación en el presente caso, atendida la naturaleza especial del problema que se analiza y del texto que se interpreta".[116]

f) *Escuela del Derecho Libre*.

Sus planteamientos fueron elaborados por Germán Kantorowicz. Sostiene este autor que frente al Derecho estatal, manifestado en la ley, existe un Derecho libre, que puede o no ser coincidente con el primero. La jurisprudencia no puede basarse exclusivamente en el Derecho estatal. La ciencia del Derecho posee fuerza creadora, de manera que la jurisprudencia no será nunca mera servidora de la ley.

Para esta doctrina, las primeras fuentes del Derecho no son las del Estado u oficiales, llamadas fuentes formales (ley y costumbre), sino las reales, constituidas por hechos que se generan en la realidad social, sea en toda ésta o en aquellos grupos en que la sociedad se divide.[117]

A diferencia del juez subordinado a la ley, como se observa de los postulados del método exegético, en la escuela del Derecho libre, el juez deviene protagonista. Su función no sólo es interpretar y aplicar, sino en definitiva crear Derecho.

De esta manera, el juez debe prescindir de la ley en dos casos: cuando su texto no es claro, y cuando adquiere la convicción de que el legislador no habría resuelto el actual conflicto en el sentido que formula la ley. Ante estas situaciones, el juez debe gozar de toda la libertad posible para formular una solución al problema de que conoce.

Pero dentro de esta corriente, hay dos posiciones, cuando el sentido de la ley es claro:

i.- Para algunos, el juez está autorizado para desentenderse de la ley, cuando las fuentes reales –subsuelo de las fuentes formales-, llevan a una solución distinta de aquella contemplada en la ley.

ii.- Para otros, el juez debe respetar la letra de la ley, acomodando a ella el sentido que fluye de la equidad, de la realidad social, del sentimiento jurídico general o personal.[118]

g) *Teoría de la interpretación de Rodríguez Grez*.

Expuesta en su obra *Teoría de la interpretación Jurídica*,[119] la denomina "Creacionista". Para este autor, es el intérprete el que va creando y recreando las

---

[116] Andreucci Aguilera, Rodrigo (2008), "Los conceptos de la Corte Suprema sobre interpretación de la ley a través de sus sentencias", *Nomos*, Universidad de Viña del Mar, Nº 1 (2008), pp. 16 y 17.
[117] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., p. 77.
[118] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 237, e), p. 169.
[119] Cfr. Rodríguez Grez, Pablo (1990), *Teoría de la interpretación jurídica*, Santiago de Chile, edición privada.

reglas de conducta que organizan la vida civil en una trama constante e ininterrumpida a lo largo del tiempo. La norma jurídica -general y abstracta- no es más que la fuente de la cual surge "el derecho que nos afecta".

En cuanto la norma jurídica no se realiza espontáneamente, ella deviene en la generación de una regla particular forjada por el juez, la autoridad administrativa o los particulares, a través del proceso de aplicación del derecho, que se traduce en la interpretación (formal y sustancial) de las normas jurídicas. De este modo, las normas generales y abstractas se extienden, gracias a la tarea creativa del intérprete, mediante el forjamiento de "reglas particulares" que nacen en el marco de aquéllas y que hacen posible que la regulación jurídica cubra todo el complejo tejido social.

Explicando el distingo que plantea entre interpretación formal y sustancial, expresa el autor que "La ciencia jurídica ha puesto acento en lo que nosotros llamamos 'interpretación formal', que consiste en desentrañar el verdadero significado y alcance de la norma. Esta fase del proceso interpretativo está reglada en el Código Civil (artículos 19 a 24), debiendo recurrirse, en primer lugar, al tenor literal de la misma (incluyéndose el significado que debe darse a las palabras empleadas por el legislador), y sólo ante la imposibilidad de alcanzar por este medio una conclusión, a otros elementos también definidos en la ley (histórico, lógico y sistemático). Para el evento de que no se logre una solución, se instituye una instancia de clausura que permite al intérprete invocar el espíritu general de la legislación (principios generales del derecho) y, finalmente, como último recurso, la equidad natural. Agotada la fase formal, lo que implica precisar el significado y alcance del mandato normativo (en otras palabras, descubrir lo que la ley manda, prohíbe o permite), se inicia una fase de 'interpretación sustancial', en la cual el intérprete debe construir una regla particular y concreta (sentencia judicial, resolución administrativa, acto o contrato) que resuelva el caso a que ha sido convocado sobre la base de transmitir a su creación los elementos que extrae de la norma, puesto que de ello dependerá la validez jurídica de su obra. He aquí una de las grandezas del derecho, que permite al intérprete, acatando la ley, generar reglas particulares e incorporar a ellas elementos que actualizan su contenido. De su capacidad creativa y del respeto a lo ordenado en la norma dependerá la calidad y buen funcionamiento del Estado de Derecho".[120]

Como es natural, en esta concepción la norma jurídica tiene vida, voluntad y sentidos propios, independientemente del legislador (de quien la creó), de suerte que el intérprete puede, al aplicarla, extraer conclusiones muy diversas, atendidos los valores y preferencias que gravitan en cada época.

De lo que se trata es adecuar el Derecho a las necesidades y principios morales que imperan en la sociedad contemporánea, aún a costa de sacrificar "la letra de ley", especie de deidad, a la cual muchos juristas rindieron constante acatamiento.

La norma jurídica no puede asentarse sino en los valores éticos que constituyen en el fondo, la base de todo mandamiento normativo.

10.8. Interpretación pública o por vía de autoridad.

a) *Interpretación judicial*.

a.1) Quién la realiza.

Es la que emana de las sentencias de los Tribunales. Su fuerza obligatoria sólo alcanza a los litigantes o a los intervinientes en una gestión no contenciosa y ni siquiera obliga a futuro al juez que dictó el fallo, quien podrá, en casos análogos, resolver en forma diversa.

---

[120] Rodríguez Grez, Pablo, "Sobre la interpretación jurídica", en *El Mercurio*, cuerpo A, edición del 27 de enero de 2013.

a.2) Fases que la integran.

El juez tiene un doble rol: *interpretar* y *aplicar* la ley. Para llevarlo a cabo en cada caso concreto debe:

i.- Primero: interpretar, fase que a su vez se descompone en dos etapas:

i) Conoce, vale decir, a partir de los hechos, selecciona la ley aplicable al caso concreto.

ii) Juzga, o sea desentraña el verdadero sentido y alcance de la ley, combina o conjuga la hipótesis general y concreta, extrayendo de ella las pertinentes consecuencias jurídicas.

ii.- Segundo: aplicar la ley, fase que se traduce en la dictación de las sentencias.

Se trata de un proceso complejo, en el cual el juez sigue un conjunto de pasos lógicos. En relación a los elementos *abstracto* y *concreto* que menciona Ducci, "En la interpretación judicial ambos procesos constituyen un todo unitario. La ley es una formulación general de situaciones pensadas como posibles. En la sentencia, o sea, en la individualización jurisdiccional del derecho, esta generalidad de la ley debe armonizarse con las características y circunstancias específicas del caso concreto. La norma jurídica debe tener idéntico sentido que la situación real para que puedan recíprocamente ser puestas en correspondencia".[121]

a.3) Elementos que integran la interpretación judicial.

En dicho proceso interpretativo deben concurrir copulativa y armónicamente un conjunto de normas y elementos:

i.- Todos los elementos de interpretación (gramatical, lógico, histórico y sistemático);

ii.- El Principio de la especialidad (arts. 4 y 13 del Código Civil).

iii.- Determinación de la especie de interpretación aplicable: declarativa, extensiva o restrictiva.

iv.- Aplicación de diversas reglas prácticas de interpretación, por ejemplo, a fortiori, *a contrario sensu*, de distinción, etc.

v.- Recurrir al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. El espíritu general corresponde a los fines de la ley. Ahora bien, para alcanzar dichos fines, la sentencia debe fundarse en los principios fundamentales que informan el Código Civil u otro cuerpo legal, en los que se expresan tales fines, a los cuales ya hicimos referencia. Nos referiremos a la equidad más adelante.

b) *Interpretación legal o auténtica*.

b.1) Concepto.

Es la realizada por medio de una ley. Es el propio legislador quien señala el sentido en que debe entenderse una ley y el alcance con que debe aplicarse. Las leyes interpretativas contienen entonces una declaración acerca del sentido y alcance de una ley cuya interpretación se presta a dudas.

Al decir cómo debe entenderse y aplicarse la ley interpretada, el legislador se limita a reiterar su voluntad original o primitiva, sin hacer una nueva declaración de voluntad. En otras palabras, para que una ley pueda calificarse realmente de interpretativa, debe limitarse a declarar el sentido y alcance de otra ley precedente, pues si contiene normas nuevas, no se le puede atribuir tal naturaleza. Poco importa en todo caso, que la ley interpretativa declare explícitamente su carácter interpretativo, aunque lo normal será que así se haga.

Por una ficción legal se supone que la ley interpretativa forma "un solo cuerpo con la ley interpretada"; se entiende incorporada en ésta (art. 9 del Código Civil). Esto significa que la ley interpretativa debe aplicarse desde la fecha en que entró en

[121] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 73, p. 75.

vigencia la ley interpretada. Para todos los efectos, se considera que la ley interpretativa es una sola con la ley interpretada.

Veamos algunos ejemplos de leyes interpretativas:

i.- En el proceso de la "Reforma Agraria" impulsado en Chile en los años 60 y 70 del siglo pasado, los asignatarios favorecidos con inmuebles expropiados, recibían dos predios: la *parcela o huerto*, destinada a cultivarse, por una parte, y *el sitio y casa*, destinado a la habitación del asignatario y su familia. Adicionalmente, los asignatarios adquirían también derechos sobre ciertos "bienes comunes" (silos, tranques, canchas de fútbol, etc.). Estos inmuebles y derechos quedaban sujetos a la regulación de los Decretos Leyes N° 3.262 y 3.516, ambos del año 1980. Ahora bien, se desprendía de estos cuerpos de rango legal que los asignatarios –cumpliéndose ciertos requisitos-, podían enajenar los predios que habían recibido en dominio. Sin embargo, lo que no resultaba claro era si podían enajenarlos *por separado*, es decir, sólo la parcela o huerto, o sólo el sitio y casa, y si era también posible enajenar los derechos sobre los bienes comunes. A su vez, si la respuesta fuere afirmativa, tampoco aclaraban estos cuerpos legales quién debería continuar con la "deuda fiscal" originada por la asignación de los predios, si el dueño de la parcela o huerto, o si el dueño del sitio y casa. La cuestión se resolvió mediante la Ley N° 18.658, de 30 de septiembre de 1987, que dispuso en su art. 5°: "Declárase, interpretando lo dispuesto en el artículo 5° del decreto ley N° 3.516, de 1980, que los adquirentes de aquellos predios a que se refiere el decreto ley N° 3.262, de 1980, han podido y pueden enajenar independientemente de la parcela o huerto el sitio y casa comprendidos en la asignación original, siempre que éstos no formen un todo físico con dichos inmuebles y figuren separadamente, con deslindes especiales, en el acta de asignación. Asimismo, estos adquirentes podrán enajenar sus derechos sobre los bienes comunes incluidos en la asignación. / En tales casos no se aplicará lo preceptuado en el artículo 1° del decreto ley N° 3.262, de 1980, y toda la deuda fiscal gravará exclusivamente la parcela o huerto".

ii.- El inc. 4° del art. 1 del Código del Trabajo, establece que "Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código". Se originaron dudas, sin embargo, en cuanto a si lo declarado por dicho inciso implicaba que se les aplicaba a dichos trabajadores todas las normas del aludido Código o sólo algunas de ellas. La cuestión fue aclarada por el art. 2 de la Ley N° 19.945, publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de mayo de 2004, que dispone: "Declárase interpretando el inciso cuarto del artículo 1° del Código del Trabajo en el siguiente sentido: El inciso cuarto del artículo 1° del Código del Trabajo en cuanto señala que "Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código", debe interpretarse y aplicarse de forma tal que la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones y expresiones, que emana del Código del Trabajo y leyes complementarias, resulte aplicable a los trabajadores que laboran en los oficios de notarías, archiveros o conservadores".

iii.- La Ley Nº 21.199, publicada en el Diario Oficial el 23 de enero de 2020, interpretando el art. 56 de la Ley Nº 21.109, publicada en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2018, que "Establece un estatuto de los asistentes de la educación pública", incluyó entre los "asistentes de la educación" a las personas que indica. Reza el texto de la primera: "Artículo único.- Declárase interpretando el artículo 56 de la ley Nº 21.109, que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, que los artículos 38, 39, 40 y 41 del referido texto antes citado, benefician en cuanto a sus efectos a los asistentes de la educación, entendidos como tales quienes colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y la correcta prestación del servicio educacional, a través de funciones de carácter profesional distintas de aquellas establecidas en el artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº 1,

del Ministerio de Educación, promulgado el año 1996 y publicado el año 1997; sean del estamento técnico, administrativo o auxiliar, realicen sus tareas en aula o fuera de ellas y que presten servicios en educación parvularia, básica y media, en establecimientos que reciban subvención por parte del Estado, cualquiera sea su forma de organización, conforme al decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998".

b.2) Iniciativa de la interpretación auténtica.

El legislador puede dictar una ley interpretativa, cuando lo estime conveniente, por iniciativa propia, a insinuación de los particulares o de los Tribunales. En este último caso, aplicando el mecanismo contemplado en el art. 5 del Código Civil y en el art. 102 del Código Orgánico de Tribunales. Esta facultad y obligación no se ha ejercido con la frecuencia deseable.

Los particulares, por su parte, pueden pedir la promulgación de una ley interpretativa con arreglo al derecho de petición consagrado en el art. 19 Nº 14 de la Constitución Política. En todo caso el legislador es soberano para atender o no a estas insinuaciones o peticiones.

b.3) Alcance de la interpretación legal.

La interpretación auténtica es la que tiene un alcance más amplio, como acontece con los efectos generales de toda ley (art. 3 Código Civil). En este aspecto, se diferencian del alcance relativo de la interpretación judicial, restringido al litigio o asunto no contencioso en el cual se dicta la sentencia.

b.4) La retroactividad y las leyes interpretativas.

En el Derecho Chileno, se dice que las leyes interpretativas no pueden estimarse retroactivas. En efecto, para que el problema de la retroactividad surja, es necesario que existan dos leyes, de diferentes fechas, que regulan lo mismo. Tratándose de leyes interpretativas, esto no ocurre, porque de acuerdo al art. 9 inc. 2 del Código Civil, se entienden incorporadas en la ley interpretada, formando con ésta una sola ley.

En la práctica, sin embargo, la ley interpretativa, desde el momento que se aplica a situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad a su promulgación, tiene efectos retroactivos.

b.5) Limitaciones de la ley interpretativa.

La ficción que supone que la ley interpretativa forma un solo todo con la ley interpretada, tiene límites, sin embargo. Ellos son:

i.- La Ley Interpretativa no puede afectar en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio (art. 9, inc. 2º del Código Civil) Cabe precisar que si en el momento de dictarse la ley interpretativa, el litigio se encuentra pendiente, se fallará conforme a las disposiciones de la ley interpretativa, porque la excepción sólo rige tratándose de sentencias ejecutoriadas, es decir aquellas contra las cuales ya no proceden recursos y cuyo efecto es producir la cosa juzgada.

ii.- Las leyes interpretativas tampoco pueden afectar las transacciones celebradas en el tiempo intermedio que va desde la ley interpretada a la ley interpretativa, pues estos contratos se equiparan en sus efectos a las sentencias (art. 2460 del Código Civil).

iii.- La última limitación dice relación, con el efecto retroactivo de las leyes interpretativas que en los hechos se produce, como ya se indicó. Al respecto, esta retroactividad no puede afectar las garantías constitucionales. En materia civil una ley interpretativa no puede transgredir la garantía constitucional del Derecho de propiedad contenida en el art. 19, Nº 24 de la Constitución Política. En materia penal, la limitación proviene del art. 19, Nº 3, inc. 8º, de la Constitución, que establece el principio de la legalidad, consagrado en los siguientes términos: "ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado".

b.6) Interpretación auténtica realizada por la autoridad administrativa, por el juez o por los contratantes.

Puede ocurrir que el intérprete sea la autoridad administrativa, que a través de un decreto o de una resolución, interpreta o aclara lo expresado en un instrumento dictado por la misma autoridad. En este caso, obviamente no cabe referirse a una interpretación *legal*, pero sí a una interpretación *auténtica*, pues la realiza el mismo que había creado el precepto que ahora se interpreta. Por cierto, esta interpretación debe circunscribirse a la esfera de competencia de quien la realiza. La autoridad administrativa –por ejemplo el Presidente de la República que mediante un decreto supremo interpreta lo expresado en un decreto supremo previo-, no podría pretender interpretar un precepto que tenga rango legal. De ocurrir lo anterior, nos encontraríamos ante una vulneración al principio de juridicidad (arts. 6 y 7 de la Constitución Política de la República) y por ende ante un acto que adolecería de nulidad de Derecho público.

El juez puede también aclarar la sentencia que haya pronunciado en un caso determinado. Para tal fin, las partes disponen del llamado recurso de rectificación, aclaración o enmienda, previsto en el art. 182 del Código de Procedimiento Civil, que reza en sus dos primeros incisos: "Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. / Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia".

En otro plano, las partes que han celebrado un contrato pueden también interpretar las cláusulas de la convención que han acordado, mediante una aclaración de las mismas. Usualmente lo harán suscribiendo un instrumento que aclara y complemente el contrato. También se trataría de otra especie de interpretación auténtica, circunscrita en este caso sólo a los efectos del contrato que vinculan a quienes lo han celebrado.

De esta forma, en realidad no toda interpretación *auténtica* es al mismo tiempo *legal*, pues ella también puede incidir en un acto administrativo, en una sentencia o en un contrato.

10.9. Elementos de interpretación de las leyes establecidos en el Código Civil.

Tradicionalmente, nuestra doctrina y jurisprudencia han entendido que los elementos de interpretación de la ley consagrados en el Código Civil provienen de los planteamientos de von Savigny, a los que hicimos referencia, expresados en la obra "Sistema de derecho romano actual", publicada entre 1840 y 1849. Adicionalmente, se suele afirmar que de estos elementos, debe aplicarse en primer lugar el elemento gramatical, y sólo cuando el sentido de la ley no se aclara con dicho elemento, se recurre por el intérprete a los restantes elementos. Sin embargo, como acertadamente afirma Rodrigo Andreucci, ambas premisas no son verdaderas o al menos deben ser matizadas: los elementos no provienen en realidad de von Savigny, sino que de Domat (vía Código de La Luisiana) y no es correcto sostener que primero se recurre al elemento gramatical, pues todos los elementos deben conjugarse. Adicionalmente, el "sentido de la ley" no debe confundirse con su tenor literal. Afirma Andreucci que el equívoco "surge a partir de una errada lectura que hacen los autores de estos artículos 19 a 24 del Código Civil, comenzando en el año 1882 con la publicación de unas 'Explicaciones de Código Civil destinadas a los estudiantes del ramo en la Universidad de Chile', efectuada por don Paulino ALFONSO a partir de las clases de los profesores Enrique COOD y José Clemente FABRES, en las cuales se sostenía que 'El primer inciso de este artículo (19) prescribe la interpretación literal, mosaica o judaica …'. En el año 1906, con la aparición de la obra 'Explicaciones de Derecho Civil' basadas en las clases

del profesor Luis CLARO SOLAR, se introduce tanto en la doctrina como en la jurisprudencia la tesis que estos artículos 19 a 24 del Código Civil, contienen la teoría de interpretación de SAVIGNY, a saber, los cuatro elementos de la interpretación. CLARO SOLAR pretendía superar la manera literalista de interpretar la ley que regía desde la publicación de la obra de Paulino ALFONSO, pero en la práctica, los tribunales siguieron efectuando esa forma de interpretación".[122]

Nos referiremos seguidamente a cada uno de estos elementos.

a) *Elemento gramatical*.

Dispone el art. 19, inc. 1 del Código Civil: "Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu".

En una primera lectura y de acuerdo a los postulados de la Escuela Exegética, prevalece por sobre cualquiera otra consideración el tenor literal de la ley. Así lo entendió nuestra jurisprudencia, especialmente durante la primera mitad del siglo XX, señalándose incluso que en tal caso, más que interpretar, lo que debe hacer el juez es aplicar la ley, empleando dicha máxima propia del siglo XIX: "Si la ley no contiene precepto oscuro alguno, debe aplicarse de acuerdo con su tenor literal, y no se puede recurrir para ese fin a su historia, intención o espíritu. No cabe interpretar la ley perfectamente clara, pues toda interpretación presupone cierta oscuridad" (Corte Suprema, sentencias de 26 de septiembre de 1908, 22 de octubre de 1922, 11 de noviembre de 1925, 12 de enero de 1928, 3 de julio de 1934, 12 de junio de 1936, 1 de diciembre de 1949).[123]

El propio Bello, consigna en una nota puesta al art. 19 del Proyecto Inédito: "Nosotros creemos que lo más seguro es atenerse a la letra de la ley; que no debemos ampliarla o restringirla, sino cuando de ella resulten evidentes absurdos o contradicciones y que todo otro sistema abre ancha puerta a la arbitrariedad y destruye el imperio de la ley".[124]

De esta manera, se ha dicho que "Cuando el tenor de la ley es claro resulta inoficioso averiguar si su contenido guarda o no armonía con los principios generales, puesto que la misión del tribunal consiste en aplicar la ley escrita, cualesquiera que sean sus consecuencias o las circunstancias especiales del caso fallado" (Corte Suprema, 3 de enero de 1936 y 12 de diciembre de 1941); "Frente al claro tenor literal de una ley, es inútil e ilegal tratar de interpretar, definir o comparar los términos empleados en ella, trayendo a discusión textos de otras legislaciones extranjeras o estudios de carácter doctrinario" (Corte de Valparaíso, 16 de octubre de 1935).[125]

Cabe observar, sin embargo, que el solo hecho de leer una norma, y determinar su sentido, es un acto de interpretación. No estamos de acuerdo, por ende, con la frase transcrita en orden a que "toda interpretación presupone cierta oscuridad". Adicionalmente, la cuestión no se reduce al solo tenor literal: la norma citada exige que el *sentido de la ley sea claro,* como presupuesto para atenerse al tenor literal de la misma. Así lo expresan los ministros Labarca y Fernández, en un voto de disidencia, a la sentencia de 17 de abril de 1930 de la Corte de Valparaíso: "el artículo 19 del Código Civil dice que cuando el *sentido* –no el *tenor*- de la ley es claro, no ha de recurrirse a consultar su espíritu, desentendiéndose de sus términos literales; y *sentido* equivale a significado, alcance o interpretación. De manera que el significado

---

[122] Andreucci Aguilera, Rodrigo (2008), ob. cit., pp. 13 y 14.

[123] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, tomo I, p. 126.

[124] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 126.

[125] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 127.

de los términos puede ser claro, pero no su alcance o extensión y, en tal caso, el sentido de la ley tampoco lo es".[126]

Habría que determinar entonces cuál es el sentido de la ley, antes de recurrir al tenor literal, aunque este parezca inequívoco. Esta idea se reafirma en el art. 22, inc. 1º y en el art. 23 del Código Civil, preceptos en los cuales también el legislador se refiere al sentido de la ley.

Veamos algunos ejemplos en los que pudiendo estimarse que el tenor literal de la ley es claro, el sentido sin embargo no lo es, y por ello ha suscitado interpretaciones contradictorias:

i.- El art. 2503, inc. 1º del Código Civil, en las normas de la prescripción adquisitiva, dispone que "Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor". Como primer punto, aclaremos que la expresión "todo recurso judicial" alude a la interposición de una acción, como es la reivindicatoria. En este caso, el dueño pretende recuperar la posesión de la cosa de la que es dueño, y evitar con ello que el poseedor, una vez que complete el plazo de prescripción, pueda transformarse en el nuevo dueño. Por su parte, el art. 2518, en las normas de la prescripción extintiva, dice que "La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente (…) Se interrumpe civilmente por la demanda judicial". Ahora bien, la discusión que se ha planteado consiste en lo siguiente: ¿se interrumpe la prescripción con la sola *interposición de la demanda*, o este efecto sólo se producirá *una vez notificada dicha demanda*? Esta es una cuestión que ha suscitado, como se dijo, interpretaciones en uno y otro sentido. Si nos atuviéramos al tenor literal, pareciera que bastaría ingresar la demanda en el tribunal respectivo, para entender que se ha interrumpido la prescripción, sea esta adquisitiva o extintiva. Pero tal conclusión podría considerarse que pugna con la lógica jurídica, pues podría ocurrir que la demanda no sea notificada y el tribunal ordene archivar los antecedentes. Todo esto, sin que el demandado –que en rigor aún no es tal-, ni siquiera se entere.

ii.- En las normas de la compraventa, el art. 1841 dispone: "Aquel a quien se demanda una cosa comprada podrá intentar contra el tercero de quien su vendedor la hubiere adquirido, la acción de saneamiento que contra dicho tercero competería al vendedor, si éste hubiese permanecido en posesión de la cosa". Del tenor literal de la norma, se desprende que el comprador demandado por un tercero (por ejemplo por una acción reivindicatoria), podrá citar de evicción a su directo vendedor o a quien vendió la cosa a su vendedor. Pero a partir de la opinión de Manuel Somarriva, la Corte Suprema varió su criterio inicial, apegado al tenor literal de la norma, y ha concluido que conforme al sentido de la norma, el último comprador ha reunido en su patrimonio el derecho que tenían todos sus antecesores para citar de evicción a quienes les antecedieron en la posesión. Por lo tanto, no hay límites en cuanto a citar de evicción a cualquiera de los poseedores anteriores.

iii.- En las normas de la responsabilidad extracontractual, establece el art. 2332: "Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto". De acuerdo al tenor literal de la norma, los cuatro años para hacer efectiva una responsabilidad extracontractual deben computarse desde que se perpetra el acto ilícito, lo que podría entenderse como "desde que se ejecuta el acto". Sin embargo, en no pocos casos el daño que experimenta la víctima no se manifiesta de inmediato, sino que después de un tiempo (por ejemplo, por *mala praxis* médica). En tal caso, la doctrina más reciente, al igual que la jurisprudencia, entienden que los cuatro años deben computarse desde que el daño se manifiesta y no desde la ejecución del acto culpable o doloso. Ello, porque el sentido de la norma

---

[126] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 126.

permite concluir que siendo el daño uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual, el acto ilícito sólo termina de "perpetrarse" cuando tal daño se le hace manifiesto a la víctima.

Rebatiendo los principios de la Escuela Exegética, Carlos Ducci sostiene por su parte que el sentido debe entenderse como la correspondencia o armonía entre la norma general que se trata de aplicar y las condiciones concretas del caso particular, de modo que se obtenga una solución de equidad, es decir lo que llama "justicia concreta".[127] Se reafirma lo anterior, teniendo presente que los tribunales son de justicia y no puramente de Derecho.

Por otra parte, incluso quienes siguen la Escuela Exegética, admiten que para estimar claro el sentido de la ley no basta que la parte consultada de esa ley esté redactada en términos que no provoquen dudas; también es menester que *no exista otro precepto que lo contradiga*, sea en el mismo cuerpo de leyes o en otro referido a la misma materia, porque de haberlo el sentido de la ley no será claro, ya que este debe resultar del conjunto de las disposiciones que tratan de la misma materia y no de una ley o disposición de una ley considerada aisladamente. Primará en cambio el tenor literal, cuando sea armónico con la interpretación considerada globalmente (Corte Suprema, fallos de 9 de octubre de 1946 y 3 de mayo de 1950).[128]

Por tanto, el sentido de la ley es claro cuando el alcance de la disposición legal se entiende por su sola lectura:

i.- Sea porque al aplicarse al caso concreto produce un efecto racional y justo, una "solución de equidad".

ii.- Sea porque considerada aisladamente de las demás leyes no origina dudas.

iii.- Sea porque relacionada con ellas no denota discordancias.

Por lo demás, la claridad de la ley puede ser un concepto relativo. Una norma que no provoca dudas al tiempo de promulgarse puede originarlos después por diversas circunstancias. De igual forma, las leyes que parecen claras en su texto abstracto, pueden tornarse obscuras al confrontarlas con hechos reales.

Ahora bien, el sentido de la ley será diverso, según las palabras utilizadas por el legislador. Al respecto, se debe distinguir entre el *sentido natural y obvio*, el *sentido legal* y el *sentido técnico*.

i.- *Sentido natural y obvio*.

Dispone el art. 20, primera parte: "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras".

Se trata del sentido que corresponde al *uso general de las palabras*. Consiste en la regla general, la forma más usual para interpretar una palabra. Sentido natural y obvio, ha dicho la jurisprudencia, es aquél que da a las palabras el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se interpretan según su sentido natural y obvio todas aquellas palabras que sin entenderse como técnicas, el legislador tampoco las ha definido. Algunos autores, siguiendo postulados más modernos, sostienen que para buscar el sentido natural y obvio de las palabras, más que atenerse al diccionario citado, hay que atender al uso general que le da a una palabra la comunidad, considerando las mudanzas o mutaciones que experimenta el lenguaje.

En realidad, no existe antinomia entre una y otra noción. En principio, el intérprete debe recurrir al significado que tenga la palabra según el mencionado Diccionario. Pero bien podría ocurrir que en un contrato, por ejemplo, las partes hayan empleado un vocablo con un significado *vulgar* (que incluso puede suponer una corrupción del lenguaje) y siendo así, ha de prevalecer el último, pues el art. 1560 del Código Civil advierte que "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe

---

[127] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 80, p. 80.

[128] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 127.

estarse a ella más que a lo literal de las palabras". Lo mismo podría ocurrir con la interpretación de un testamento, respecto del cual señala el art. 1069, inc. 2º: "Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido". En cambio, es de suponer que el legislador es culto y emplea con propiedad el lenguaje, de manera que los términos de que se vale debieran guardar perfecta consonancia con el significado que tengan conforme a lo que expresa la Academia de la Lengua castellana.

ii.- *Sentido legal*.

Establece el art. 20, segunda parte: "pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal".

Se interpretan en tal sentido las palabras, cuando el legislador las ha definido. Así, por ejemplo, en los arts. 25 al 51 del Código Civil, "Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes". Otro tanto ocurre con todas las instituciones definidas por el legislador, como ocurre por ejemplo, en el caso del Derecho civil, con el dominio, la tradición, la posesión, la prescripción, y con todos los contratos regulados en este cuerpo legal.

El sentido legal debe prevalecer sobre el sentido natural y obvio y también sobre el sentido técnico.

iii.- *Sentido técnico*.

Expresa el art. 21: "Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso".

Se refiere este sentido a las palabras técnicas de toda ciencia o arte. El significado auténtico de los vocablos de una ciencia o arte solo lo pueden dar las personas que se consagran a esas disciplinas. Por eso es lógico presumir que el mismo significado y alcance les ha dado el legislador. Con todo, una palabra técnica puede ser empleada impropiamente en una ley o con un sentido diverso al estrictamente técnico; por ejemplo, la palabra "demente", en el art. 1447, la que no está utilizada en su sentido técnico, pues en psiquiatría se denomina así al que sufre un proceso de pérdida de sus facultades psíquicas, especialmente la inteligencia, por causas sobrevenidas en el curso de su vida. La expresión no comprende por ende, en su sentido técnico, a los que sufren perturbaciones mentales congénitas. No cabe duda sin embargo, que la ley pretende comprenderlos bajo el vocablo demente, así como a cualquiera que padece trastornos mentales graves y permanentes (para el Diccionario de la Rae, "loco o falto de juicio", y "loco" es el que "ha perdido la razón"). Cuando tal ocurre, debemos interpretar la expresión en un sentido natural y obvio o en un sentido legal, según corresponda.

En resumen, los sentidos recién enunciados deben preferir entre sí conforme al siguiente orden:

i.- En primer lugar, el sentido legal.

ii.- En segundo lugar, a falta de definición legal, se aplicará el sentido técnico, si la palabra lo tuviere.

iii.- Finalmente, a falta de los dos anteriores, se recurrirá al sentido natural y obvio.

b) *Elemento lógico*.

Está contemplado en el art. 19, inc. 2 y en el art. 22, inc. 1, del Código Civil. Dichas normas corresponden a los dos aspectos de este elemento. Uno, dice relación al espíritu de la ley, a su finalidad; el otro, a la coherencia interna de la norma.

Dispone el art. 19, inc. 2, que se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma. Se atiende por tanto a la finalidad perseguida por el legislador, o sea la *ratio legis*.

Por su parte, el art. 22, inc. 1, establece que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Se refiere por ende esta norma, a la lógica correlación formal y de fondo que debe existir en toda ley.

c) *Elemento histórico*.

Dispone el art. 19, inc. 2, que se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a la historia fidedigna de su establecimiento. La investigación se retrotrae a las circunstancias coetáneas, a la tramitación de la ley, atendiendo tanto a las circunstancias "extrajurídicas" (fuentes materiales) como a los trámites constitucionales necesarios para su aprobación y promulgación (iniciativa, discusión, indicación, etc., de todo lo cual queda constancia en las actas respectivas).

De igual manera, conforme a lo expresado en esta obra, el elemento histórico también dice relación con la historia de una institución, es decir, cómo se originó y qué vicisitudes o mutaciones ha experimentado a lo largo del tiempo, que permiten entender su regulación actual.

d) *Elemento sistemático*.

Alude a este elemento el art. 22, inc. 2, que dispone: "Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto".

Se deben cumplir aquí los siguientes presupuestos:

i.- Debe existir un precepto legal destinado a interpretarse.

ii.- Dicho precepto legal debe contener "pasajes obscuros".

iii.- Debe existir otra ley u otras leyes, que versen sobre el mismo asunto.

iv.- Los pasajes obscuros de la primera, se salvarán aplicando la solución contenida en las otras leyes.

Se trata de la proyección del elemento lógico, pero ahora más allá de una ley. Es la correspondencia y armonía *entre las leyes* y no sólo entre las disposiciones de una misma ley.

La ley, será interpretada recurriendo al sentido de otras leyes, que contengan elementos semejantes, desde el momento que versan sobre la misma materia. La ley obscura y las otras leyes a las que se recurre para interpretar la primera, deben responder a un mismo principio informador, orientador.

Como puede observarse, la analogía como elemento de interpretación de una ley, está permitida en el citado art. 22, inc. 2°.

La analogía, según veremos, también puede emplearse cuando no hay ley que se refiera a cierta materia o determinado asunto. En este último caso, operará encuadrada en la equidad natural.

La diferencia entre un caso y el otro en que se recurre a la analogía, es que en el primero, ésta cumple efectivamente una función *interpretativa*, mientras que en el segundo, su función es más bien *integradora*.

Como expresa Hernán Corral, "Como se trata del uso de la analogía para interpretar una ley, se habla de *analogía legis*, que se distingue de la *analogía iuris*, empleada para buscar reglas que colmen las lagunas del ordenamiento jurídico como un todo…".[129]

Cabe advertir que, en ocasiones, se aprecia cierta confusión en el empleo de estos términos. En efecto, se afirma por Agustín Squella que "Tratándose de la analogía jurídica, se distingue entre *analogía legis* y *analogía iuris*. Por *analogía legis*

[129] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 183.

se entiende un procedimiento para llenar lagunas legales que consiste en extender la solución dada por la ley a un caso a otro no previsto por la ley, pero que es parecido o similar al que sí se encuentra previsto. Por su parte, la *analogía iuris* es también un procedimiento para llenar lagunas, aunque no a partir de una ley, esto es, no valiéndose de una determinada norma legal que contemple y resuelve un caso parecido a aquel que no se encuentra regulado por ley alguna, sino recurriendo a los principios generales del derecho. Por tanto, puede decirse que la analogía jurídica propiamente tal –vista como un método o procedimiento de integración de la ley- es la *analogía legis*, puesto que la *analogía iuris* remite a un método o procedimiento de integración de la ley distinto de la analogía, a saber, los principios generales del derecho".[130]

Me permito disentir del profesor Squella en la primera parte de esta aseveración, y adherir en cambio a la última parte de su argumentación. En efecto, creemos que la *analogía legis* opera para interpretar un precepto legal, mientras que la *analogía iuris* opera para integrar una laguna legal. En el primer caso, se recurre a una norma legal semejante a la que estamos interpretando, para fijar con el auxilio de la primera el sentido y alcance de la segunda (*analogía legis*). En el segundo caso, el asunto no está regulado por norma alguna, pero se recurre a otra norma legal, que regula una materia semejante, para colmar o integrar dicha laguna legal (*analogía iuris*). En el primer caso, hay dos normas: una, cuyo sentido y alcance no es claro, y otra, que empleamos para interpretar la primera. En el segundo caso, no hay norma que resuelva la materia, pero se recurre a otra que regula asuntos semejantes a dicha materia, para llenar el vacío legal. En cambio, cuando no hay norma alguna –no hay una que resuelva la materia ni otra que regule otra materia semejante-, no puede hablarse de analogía (como admite el profesor Squella), de manera que la laguna legal se integrará en virtud de la equidad natural, pro no en virtud de la analogía, sino que fundada en el espíritu general de la legislación y en los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. En otras palabras, habría que distinguir tres situaciones:
i.- *Analogía legis*: cuando para interpretar una ley, recurrimos a otra ley.
ii.- *Analogía iuris*: cuando a falta de ley que regule una materia, recurrimos a una ley para integrar esta laguna legal.
iii.- Equidad natural fundada en el espíritu general de la legislación y en los principios fundamentales del ordenamiento jurídico: cuando no hay ley que resuelva una materia, ni de manera directa ni tampoco por analogía.

e) *Espíritu general de la legislación*.

Alude el Código Civil a este "espíritu general de la legislación" en el art. 24, que dispone: "En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural".

Conforme al enunciado inicial del precepto, el juez debe recurrir al "espíritu general de la legislación" siempre que se den los siguientes presupuestos:
i.- Cuando no puedan aplicarse las reglas de interpretación contempladas en los arts. 19 a 23.
ii.- Cuando el precepto legal que debe interpretarse, tenga pasajes obscuros o contradictorios.

Considerando el primer presupuesto, se trataría por ende de un elemento de interpretación aparentemente supletorio. Así se entendió por nuestra doctrina más

[130] Squella Narducci, Agustín (2004), *Introducción al Derecho*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, p. 487.

antigua. La doctrina más reciente, sin embargo, ha rebatido esta aplicación meramente subsidiaria.

En efecto, Carlos Ducci afirma que la frase inicial del precepto "no significa que se trate sólo de elementos supletorios de interpretación", aunque no da mayores razones para fundar su aserto.[131]

Hernán Corral, por su parte, señala dos argumentos para concluir que se trata de una subsidiariedad "relativa", y no "absoluta":

i.- La labor hermenéutica debe ser integral. No parece que sea posible –agrega-, realizar el análisis de la *ratio* de la norma sin considerar si ella conduce a un resultado de abierta inequidad o contrario a los principios generales de la legislación.

ii.- Además, este autor interpreta la frase "… en los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes…", en el sentido de que se trata de una subsidiariedad relativa, en cuanto la ley no permite interpretar una ley sólo mediante la equidad y el espíritu general de la legislación, prescindiendo de las demás reglas de interpretación. Entendemos entonces este argumento, en el sentido de que si dichas reglas de interpretación contenidas en los arts. 19 a 23 no permiten determinar el sentido de la ley, se podrán complementar con la equidad natural y el espíritu general de la legislación.[132]

Dicho "espíritu general de la legislación", corresponde a los fines más esenciales que la ley persigue. A diferencia de lo expresado respecto del elemento lógico, ahora ya no se trata de la razón y de la finalidad específica o particular de una ley, sino que se trata de identificar los fines generales de la legislación.

Ahora bien, todo el sistema jurídico, está basado en principios generales o fundamentales, que son comunes, que como un todo trasuntan el espíritu general de la legislación. Así, por ejemplo: la autonomía de la voluntad, la propiedad, la buena fe, la igualdad ante la ley, la sanción al enriquecimiento sin causa, la responsabilidad, etc.

Como señala Corral, "El art. 24 del Código Civil no se refiere expresamente a los principios jurídicos, sino al 'espíritu general de la legislación', pero los autores y la jurisprudencia han entendido que en esa expresión quedan perfectamente identificados, tanto los llamados principios intrasistémicos (que se derivan de las normas legisladas) como los extrasistémicos (que informan desde fuera ese espíritu y lo hacen general)".[133]

De esta manera, los fines generales de la legislación, las razones que han llevado al legislador a dictar las leyes, se pueden a su vez sistematizar en los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico civil. Luego, en un tercer nivel, estos principios, en su derivación más concreta, se manifiestan en ciertas normas jurídicas.

Por ende, la relación sería:

i.- Fines generales o razones generales de la legislación, que corresponden a su "espíritu general".[134]

ii.- Principios fundamentales en que es posible sistematizar tales fines generales. Aludimos aquí a los llamados principios *intrasistémicos*, que dimanan del espíritu general de la legislación.

iii.- Normas jurídicas en las que se manifiestan dichos principios fundamentales.

No se trata de sostener que el "espíritu general" de la legislación sea uno mismo con los "principios fundamentales" de carácter "intrasistémicos". Creemos que el primero es fuente de los segundos.[135]

---

[131] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., p. 85.

[132] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 190.

[133] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 79.

[134] Que, a su vez, como ya explicamos, dimana de los *valores* más importantes que la comunidad nacional reconoce para su subsistencia.

[135] Expresa al efecto Alejandro Guzmán Brito: "Se tendrá presente que no es posible identificar sin más el 'espíritu general' con los 'principios generales del Derecho', que siguen siendo objetivos y no razones o

Hernán Corral explica este distingo entre los principios *intrasistémicos* y *extrasistémicos*: "Los intrasistémicos son aquellos que pertenecen a un determinado ordenamiento jurídico, y que se extraen por un proceso de inducción de las normas particulares que existen en ese sistema legal. En el fondo son como súper reglas que se derivan de la existencia de normas positivas presentes y vigentes en el sistema que, sin enunciar el principio, lo manifiestan mediante aplicaciones particulares. Estos principios pueden variar de un derecho a otro". A su vez, "son extrasistemáticos los principios que no se deducen de las normas internas, sino que actúan desde fuera del sistema, como criterios normativos que informan, organizan y legitiman las normas positivas del sistema. Por ejemplo, el principio de la dignidad humana o de la igualdad ante la ley, no son principios que deban su existencia a la presencia de normas que los manifiesten en el sistema, sino que son necesarios para que el sistema jurídico subsista como tal y cumpla su misión propia".[136]

Hernán Corral vincula seguidamente los principios extrasistémicos con la tradición del Derecho natural, aunque aclara que no son coincidentes. Agrega que "Los principios jurídicos han sido ya de alguna manera positivizados (por la doctrina, la jurisprudencia, la cultura jurídica universal) y, dependen en su aplicación, de una red de relaciones internas. Sólo algunas más fundamentales, los que tienen que ver con derechos absolutos del hombre deben ser considerados insoslayables".[137]

Por nuestra parte, creemos que aún aquellos principios que se han llamado extrasistémicos, se encuentran manifestados en normas positivas. Desde ya, a propósito de los dos ejemplos proporcionados por Corral, valga señalar que ambos están consagrados en las normas de nuestra Constitución Política (arts. 1 y 5, inc. 2°, por lo pronto).

Sí concordamos en que no todos los principios jurídicos tienen la misma jerarquía. Ciertamente, los hay que perfectamente pueden mutar y no por ello se comprometerán derechos esenciales. Pero los hay otros, como los dos mencionados en el ejemplo, que son inherentes a la naturaleza humana, y que jamás podría desconocer un ordenamiento jurídico. Por ello, postulamos la siguiente conclusión: los llamados principios extrasistémicos, están por sobre el eventual y contingente espíritu general de la legislación. Este no puede contrariar los primeros, pues derivan de la propia naturaleza humana y de sus derechos más esenciales. En cambio, los llamados principios intrasistémicos, derivan del espíritu general de la legislación. El legislador nacional, en cada caso, puede ir moldeándolos y sustituyéndolos, sin que en este caso se encuentre subordinado por principios de rango superior. Nos parece que el inc. 2° del art. 5 de la Constitución Política, ya citado, responde a este distingo fundamental.

Este distingo, se funda además en la noción a estas alturas indubitada, en orden a que el Derecho nacional está limitado por un Derecho supranacional, que tiene su origen en el Derecho natural y que hoy se encuentra consagrado en los más importantes instrumentos internacionales que reconocen y amparan los derechos más esenciales, inherentes a toda persona.

f) *La equidad natural*.

Se refiere a ella el art. 24, ya citado. De igual manera, el art. 170 Nº 5, del Código de Procedimiento Civil, del siguiente tenor: "Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte

---

finalidades adoptadas. No bien que en ciertos casos el espíritu de la ley pueda consistir en insertar un principio general, y que, en otro, a partir de las razones de la legislación se pueda construir un principio, debe, con todo, mantenerse rigurosamente la distinción conceptual entre ambas nociones": Guzmán Brito, Alejandro (2007), ob. cit., p. 192.

[136] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 78.

[137] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 78.

dispositiva las de otros tribunales, contendrán: (…) 5°. La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo".

Como bien ha destacado el profesor Alejandro Guzmán, la "equidad natural" y "los principios de equidad" pueden desempeñar un doble rol: en el art. 24 del Código Civil la equidad natural es un elemento de *interpretación* de la ley. En cambio, en el art. 170 Nº 5, los principios de equidad operan como un elemento para la *integración* de la ley. En el primer caso, se recurre a la equidad natural para interpretar los pasajes obscuros o contradictorios de una ley. En el segundo caso, se funda la sentencia en los principios de equidad a falta de ley que resuelva la contienda judicial.

Refiere Alejandro Guzmán, aludiendo al art. 24 del Código Civil, que "Este artículo remitente a la equidad natural discurre (…) dentro del campo de la interpretación de la ley, con lo cual quiero decir que él no se refiere al caso de una laguna legal, para colmar la cual debe recurrirse a la equidad natural. En otras palabras, se supone ahí la existencia de una ley, si bien obscura o contradictoria, sin que hubiera sido posible superar tales vicios mediante las reglas de interpretación señaladas en los artículos 19 a 23 CC.; en tal caso, el artículo 24 manda que los pasajes oscuros o contradictorios de esa ley se interpreten '*del modo que más conforme parezca a la equidad natural*'. Esta es, en consecuencia, en nuestro artículo un criterio de interpretación de la ley existente, no de integración de ley incompleta".[138]

En cambio, según se dirá, el art. 170 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil permite recurrir a los principios de equidad para llenar las lagunas o vacíos que presente el ordenamiento legal. Este artículo, como refiere Alejandro Guzmán, tiene como antecedente una Ley promulgada el 12 de septiembre de 1851 (art. 3, Nº 3), que se originó a partir de un proyecto presentado por Antonio Varas en 1847, sobre el modo de acordar y fundar las sentencias. En 1850, en el contexto de la discusión de esta iniciativa, Andrés Bello propuso incorporar en el Proyecto una frase en virtud de la cual se estableciere que a falta de ley y de costumbre en la que se fundare la sentencia, ésta podría fundarse en "las razones de equidad natural"[139]: "La enmienda propuesta por Bello fue aceptada unánimemente (…). Con ello, a partir de 1851, la equidad natural, como fuente supletoria de ley (y costumbre) inexistente, quedó incorporada en el derecho propiamente chileno".[140]

Además de estos dos roles, veremos que en algunos casos la equidad natural debe operar para *aplicar* la ley, cuando así lo ordena ésta.

Ni el Código Civil ni el Código de Procedimiento Civil contienen una definición de "equidad" o "equidad natural" o de "principios de equidad".

Se ha entendido por equidad, "el sentimiento seguro y espontáneo de lo justo y lo injusto que deriva de la sola naturaleza humana, con prescindencia del Derecho Positivo".[141]

El Diccionario de la Lengua Española, define la equidad como la "Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley". Asimismo, como la "Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva". O

---

[138] Guzmán Brito Alejandro, "El significado histórico de las expresiones 'equidad natural' y 'principios de equidad' en el Derecho Chileno", ob. cit., p. 13.

[139] En realidad, como señala Alejandro Guzmán, Bello ya había planteado la función integradora de la equidad en un artículo publicado el 1 de noviembre de 1839 en *El Araucano*, titulado "Necesidad de fundar las sentencias": Guzmán Brito Alejandro (2005), "El significado histórico de las expresiones 'equidad natural' y 'principios de equidad' en el Derecho Chileno", en *Estudios dogmáticos de derecho civil*, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 17 y 18.

[140] Guzmán Brito Alejandro (2005), ob. cit., p. 18.

[141] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., N° 249, p. 177.

también como la "Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece" (segunda, tercera y quinta entrada de la palabra "equidad").

La palabra "equidad" se relaciona con los vocablos "prudencia" y "equitativo"[142]. El Diccionario de la Lengua Española define al segundo en los siguientes términos: "Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. II 2. Templanza, cautela, moderación. II 3. Sensatez, buen juicio". A su vez, se entiende por el tercero aquello "que tiene equidad".

La relación entre estas tres palabras es importante, pues veremos que, en algunos casos, la ley faculta al juez o las personas concernidas en el tipo legal para actuar "prudencialmente" o para emitir un pronunciamiento "equitativo". Con ello, entendemos que también quiere referirse el legislador a la equidad.

Couture, por su parte, señala las siguientes acepciones a la palabra "equidad": 1) En general imparcialidad, ecuanimidad, espíritu de justicia; 2) Como orden supletorio: conjunto de valores al cual puede acudir el juez, en casos particulares que no tienen solución prevista en el texto legal. 3) Por oposición a Derecho estricto: dícese del sistema jurídico en el cual los jueces, cuando los faculta para ello la ley, pueden apartarse prudentemente del Derecho positivo que estimen injusto en el caso particular, acudiendo a los dictados de su leal saber y entender.[143]

Por cierto, desde ya debe advertirse que en nuestro Derecho, no es admisible la tercera de estas acepciones.

De lo expuesto hasta aquí, cuando nos referimos a la equidad, se trata de aquella entendida en su acepción de justicia natural.

La equidad referida a un caso determinado se define como "la justicia del caso concreto", pues busca para este, la justicia adecuada, incluso, en algunos casos, para una doctrina extrema, desentendiéndose de la norma general y abstracta, cuando su aplicación repugna a la justicia natural. En este sentido la equidad se opondría al Derecho rígido y estricto.[144] Con todo, esto no es posible en el Derecho nacional, por muy inicua que pudiere parecernos la norma positiva. Si ella existe, y no es obscura o contradictoria, el juez deberá fallar conforme a la misma, y no podrá sustituirla por la equidad natural.

Por cierto, la equidad natural debe además emplearse conforme a un criterio *objetivo*, y no puramente subjetivo. La objetividad de la misma, se obtiene entendiendo que "La equidad es una forma de prudencia razonada y debe ser adecuadamente fundada".[145] En la construcción de su solución en virtud de la equidad, el juez debe desplegar entonces una labor intelectual fundada en la racionalidad y en la lógica, tanto general, cuanto específicamente jurídica. Por ello, se afirma que "La equidad debe ser una equidad culta e informada de los criterios y reglas de la ciencia y el arte del Derecho. Debe ser una equidad jurídicamente sustentada, una equidad culta".[146]

Por lo demás, el propio Andrés Bello dejó en claro los límites que tiene el juez al recurrir a la equidad, expresando: "'A pretexto de equidad' no deben los jueces de los comerciantes (y lo mismo se aplica a todos los otros jueces) apartarse de las leyes y

---

[142] Cabe advertir, sin embargo, que, en algunos casos, la palabra "equitativo" no se emplea en el Código Civil como aquello que resulta de actuar conforme a la equidad, sino que más bien como equivalente al precio justo de una cosa. Así ocurre en los arts. 1106 y 1997 del Código Civil.

[143] Couture, Eduardo (1960), *Vocabulario Jurídico*, Montevideo, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La República, citado a su vez por Pedrals García de Cortázar, Antonio (2010), en su trabajo "Sobre la 'abstracta y difusa' noción de equidad natural", publicado en *Estudios de Derecho Civil V*, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Concepción, 2009, AbeledoPerrot-LegalPublishing, p. 4.

[144] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., p. 177.

[145] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 75.

[146] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 75.

reglamentos. Se les manda solamente no detenerse en las sutilezas del derecho y en lo que se llama *summum jus summa injuria*. Si la ley es clara y precisa, no le es permitido violarla, por dura que les parezca (…) La conciencia de la ley vale más que la del hombre (…) Debe el juez seguir la equidad de la ley, no la de su propia cabeza (Dumoulin). Las jueces dan sentencias inicuas cuando se imaginan ser árbitros y maestros de la equidad (Stracca). Ellos deben tener continuamente a la vista lo que decía M. Pussort, cuando se redactó la ordenanza de 1667[147]: Todos saben que el juez no hace el derecho, sino solamente lo declara. Es su dispensador, no su dueño. El poder y la soberanía están en la ley, no en él. Y si el juez pudiera impunemente contravenir a la ley, sería por consecuencia infalible dueño de las haciendas, honras y vidas de los ciudadanos, pues sin temor de pena alguna podría disponer de ellas como quisiese, a pesar de la ley".[148]

En otras palabras, la equidad deberá fundarse en razones jurídicas, deberá aplicarse por el juez en armonía con el espíritu general de la legislación y con los principios fundamentales del Derecho. Ello explica, además, que el legislador aluda en un mismo artículo a dicho espíritu general y a la equidad natural, es decir, insinuando que la segunda debe fundarse en el primero.

Como expresa Hernán Corral, "La equidad y los principios jurídicos están muy ligados entre sí, ya que muchas veces la solución equitativa de un caso pasa por la aplicación a él de un principio general. Es decir, la equidad puede fundamentarse, y ordinariamente así sucederá, en uno o más principios jurídicos".[149] Más adelante, agrega que "Por su parte, el art. 170 N° 5 del Código de Procedimiento Civil alude a 'los principios de equidad', con lo que parece hacer una mención conjunta a los principios jurídicos y a la equidad que, como hemos dicho, frecuentemente van enlazados".[150]

En palabras de Guzmán Brito: "… para Bello, la equidad natural era una categoría objetiva y verificable, de la cual se puede dar cuenta argumentativa y razonada, y que no se agota en la mera afirmación de ser algo equitativo o de parecerle tal cosa equitativa a alguien. Debemos, pues, evitar pensar que la equidad natural a que alude el artículo 24 del Código sea una puerta abierta a la subjetiva opinión individual, al sentimiento y a la imaginación, que excusa tener que razonar sobre la base de premisas objetivas, ciertas y justificables, probadas por la ciencia y aprobadas por la más autorizada doctrina".[151]

Por otra parte, la doctrina también ha destacado el carácter "general" que debe contener aquella interpretación fundada en la equidad natural. Es decir, la solución a la que llegue el juez, debe ser tal, que podría servir para otros casos que presenten elementos semejantes. Se expresa al efecto: "Por otro lado, hemos de advertir que la particularidad de la equidad, es decir, su adecuación al caso singular que se pretende resolver, no debe descuidar la vocación de generalidad que toda solución jurídica debe tener si pretende ser realmente justa. Es decir, el juez al diseñar su sentencia basada en la equidad debe ser capaz de enunciar una regla que debiera servir no sólo para dar respuesta al caso particular que se está juzgando (y que ha caído fuera de la generalidad de la ley), sino una que potencialmente sea adecuada para resolver en el futuro otros casos que presenten las mismas características especiales".[152]

---

[147] Alude Bello a las "Ordenanzas de justicia", que por mandato de Luis XIV redactó Pussort. Elogiando su trabajo, Foucault dijo de Pussort: "Este grande hombre, se aplicó con tal cuidado y exactitud a esta tarea, que en su trabajo se observa tanta penetración, tan inviolable adhesión por la justicia, que todos reconocen en él unánimemente las más excelentes y sublimes cualidades".

[148] Bello, Andrés, "Necesidad de fundar las sentencias", en *Obras Completas*, VII, Opúsculos jurídicos, p. 344, citado a su vez por Guzmán Brito, Alejandro (2007), ob. cit., pp. 202 y 203.

[149] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 78.

[150] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 79.

[151] Guzmán Brito, Alejandro (2007), ob. cit., p. 203.

[152] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 75.

Ahora bien, ¿Dónde encontrar los fundamentos jurídicos que permitan al sentenciador fallar conforme a la equidad? Antonio Pedrals alude a cuatro doctrinas que, "… de algún modo, aspiran a *concretizar* y *precisar* el concepto". Tales son: i) La que postula que el juez debe remitirse al Derecho natural, y fallar conforme a él; ii) La que postula que el juez debe remitirse al Derecho romano, y fallar conforme a él; iii) La que postula que el juez debe remitirse a los principios de justicia reconocidos socialmente, y fallar conforme a ellos; y iv) La que postula que el juez debe remitirse a su personal sentido de la justicia, y fallar conforme a éste.[153]

En nuestro concepto, los tres primeros son criterios atendibles y razonables, a partir de los cuales construir una solución justa, racional, jurídicamente fundada y con pretensión general. El cuarto debiera rechazarse, por su carácter arbitrario y subjetivo.

Para Alejandro Guzmán, los principios jurídicos a partir de los cuales el juez pueda fallar conforme a la equidad natural, deben buscarse en el Derecho romano. Fundamenta esta aseveración en los siguientes argumentos:

i.- El Título preliminar del Proyecto de Código Civil de 1853, contenía un art. 4, del siguiente tenor: "En materias civiles, a falta de ley escrita o de costumbre que tenga fuerza de ley, fallará el juez conforme a lo que dispongan las leyes para casos análogos y, a falta de éstas, conforme a los principios generales de derecho y de equidad natural". Asimismo, se incluía el art. 23, que corresponde al actual art. 24. La equidad natural, de esta manera, cumplía una doble función: en el art. 4, para integrar la ley o la costumbre; en el art. 23, para interpretar la ley.

ii.- El art. 4 fue eliminado en el Proyecto definitivo, redistribuyéndose sus ideas en otros preceptos del mismo Título preliminar, según indicaremos. En lo que respecta a la equidad natural como criterio para integrar la ley, se consideró que era una norma más propia del Código de Enjuiciamiento. Por lo demás, ello ya se contemplaba en el art. 3, Nº 3 de la Ley de septiembre de 1851, a la que aludimos, de carácter efectivamente procesal (y en la que se incorporó la equidad natural como criterio de integración de la ley a propuesta de Andrés Bello, según vimos).

iii.- Ahora bien, ¿cuál era la fuente del art. 4 del Proyecto y por ende de la idea de equidad natural que en él proponía Bello, misma idea por lo demás que se incorporó en la ley procesal de 1851? Bello anotó dos referencias: Código de la Luisiana y el *Curso de Derecho Civil* de Delvincourt (publicada en París en 1834), tomo 1, página 8. Guzmán agrega que el art. 23 del Proyecto de 1853, actual art. 24, tiene la misma fuente.

iv.- El art. 21 del Código de la Luisiana, tiene a su vez por fuente la obra de Toullier *Le droit civile français suivant l'ordre du Code*, publicada en París en 1819. En ella, afirma Toullier: "Por lo que respecta a la equidad, se ha dicho en todos los tiempos que ella era el suplemento de las leyes; y nada es más justo ni verdadero, con tal que la equidad sea dirigida por la ciencia sin la cual el magistrado debe temblar antes de sentarse en el templo de la justicia, y sin la cual el espíritu no hará más que vagar en la búsqueda de un fantasma de equidad puramente imaginario. Sobre todo es en los escritos de los jurisconsultos romanos en donde él encontrara guías seguros y reglas de decisión infalibles. Este solo libro [se refiere al Corpus iuris civilis], como lo observa D'Aguesseau, desenvuelve sin tropiezos los primeros principios y las últimas consecuencias del derecho natural. Desdichado sea el magistrado –dice él- que no tema preferir su sola razón a aquélla de tantos grandes hombres, y que sin otra guía que la audacia de su genio, se lisonjee de descubrir con una simple mirada y de percibir con el primer golpe de vista la vasta extensión del derecho".

v.- Delvincourt, por su parte, en su obra, para ilustrar el concepto de equidad natural, recurre a un caso de laguna en el *Code Napoléon*, en cuanto señala en su art. 1426 que los actos ejecutados por la mujer casada sin autorización de su marido, no obligan

[153] Pedrals García de Cortázar, Antonio (2010), ob. cit., pp. 8 y 9.

a la sociedad conyugal. Pero Delvincourt se pone en el caso que el acto reportare beneficio a la sociedad conyugal. Siendo así, ¿se aplicará estrictamente el tenor literal del art. 1426? ¿Podrá excusarse el marido de cumplir la obligación contraída por la mujer? Para Delvincourt (que estima que el precepto sólo se refiere al caso en que el acto de la mujer no reporta beneficio al marido o a la sociedad conyugal), aunque el caso no esté previsto en la ley, el juez debe declarar a la comunidad sujeta a la obligación y condenar en consecuencia al marido al cumplimiento de la misma, conforme al principio *nemo debet locupletior fieri cum alterius detrimento* (nadie debe hacerse más rico en detrimento de otro). El principio que considera Delvincourt se encuentra de modo textual en dos pasajes del Digesto. En consecuencia, concluye Guzmán, "cuando Delvincourt glosa la expresión '*équité naturelle*', ilustrándola a través de un ejemplo concreto, no sabe sino que invocar textos nada menos que del Digesto de Justiniano, esto es, de un libro histórico que, además, ha sido considerado como portador de derecho vigente en Europa desde el siglo XII. La equidad natural para Delvincourt, en este caso al menos, aparece expresada en el derecho romano".
vi.- Así las cosas, el texto de Toullier sobre la equidad, "nos muestra de inmediato la comunidad existente entre sus ideas y las de Delvincourt. En síntesis, aquél había dicho: el juez puede recurrir a la equidad para colmar la ley insuficiente; pero la equidad a que él debe recurrir es aquella dirigida por la ciencia; en el entendido de que esta dirección a la equidad se encuentra sobre todo en los libros del derecho romano, o sea, en el *Corpus iuris civilis*. De modo analítico, esto es lo mismo que a través de un ejemplo dijo (…) Delvincourt, cuando, en la necesidad de colmar una laguna por él vista en el artículo 1426 del *Code Civil*, a través de un recurso a la equidad, acude él precisamente al derecho romano, a un texto del Corpus iuris civilis".
vii.- Cita Alejandro Guzmán varios autores de los siglos XVI, XVII y XVIII, para quienes el Derecho romano debía ser la fuente para llegar a una solución equitativa, a falta de ley y de costumbre. Entre ellos, François le Duaren (1509-1559), François Dumoulin (1500-1566), Carondas le Caron (1536-1617), Jean Domat (1625-1696) y François de Boutaric (1672-1733). Domat, el más célebre, dirá que "los libros del derecho romano son el depósito de las reglas naturales de la equidad"; "las reglas que se sacan de las decisiones incorporadas en el derecho romano (…) tienen el carácter de ley natural por los principios de equidad natural de donde ellas han sido extraídas". "Para Domat, tal es el motivo por el cual debe acatarse el derecho romano, pues él tiene entonces 'la misma autoridad que tienen la justicia y la equidad sobre nuestra razón'".
viii.- Concluye Alejandro Guzmán que, "cuando, en defecto de ley o para interpretarla, se hace necesario recurrir a la equidad, a lo que debe recurrirse es al derecho romano, trasunto de aquélla". Se pregunta más adelante: "¿Cómo controlar al juez cuando, por falta de ley, o ante una ley oscura, se ve en la necesidad de aplicar los artículos 170 Nº 5 CPC. y 24 CC.? A mi modo de ver, no cabe otra solución, o sea, otro control, que exigirle la exhibición de un texto autorizado de doctrina jurídica en que se encuentre la solución que busca. Para el derecho civil no hay ni ha habido, ni quizá habrá en la historia otro texto más autorizado que el *Corpus iuris civilis*, el cual en definitiva ha sido directa o indirectamente fuente de nuestro Código Civil; y como de acuerdo con los resultados del presente estudio, '*equidad natural*' y '*principios de equidad*' en los códigos civil y de procedimiento civil significan finalmente '*Corpus iuris civilis*', he allí, pues, el texto doctrinal al cual el juez deberá acudir en su búsqueda de soluciones equitativas para el caso de ley oscura o defectuosa. Si no se encuentra ahí una solución, el juez puede recurrir a los intérpretes del derecho romano, teniendo presente que los civilistas modernos en la medida en que trabajan con códigos romanistas son legítimos sucesores de los antiguos intérpretes directos del *Corpus iuris civilis*".[154]

---

[154] Guzmán Brito, Alejandro (2005), ob. cit., pp. 11-32.

Nuestro ordenamiento jurídico, como ya se anticipó, no permite sin embargo usar la equidad para corregir la injusticia que en un caso dado puede resultar de la aplicación de la norma general y abstracta. Encuentra preferible sacrificar la justicia al "principio de la certeza del derecho". Nuestro ordenamiento jurídico, estima mejor, que los particulares sepan desde un principio las normas ciertas que los van a regir, que por lo demás serán por lo general también justas, en lugar de atenerse a un incierto o probable acomodo de ellas a su caso, por parte del juez.[155]

Pero si bien el legislador chileno no permite usar la equidad para corregir las leyes, sí posibilita recurrir a ella como último elemento para interpretarlas, según se desprende del art. 24.

En consecuencia, si una ley puede tomarse en dos sentidos y conforme a las reglas de interpretación no se puede determinar cuál de ellos es el genuino, el juez se inclinará por el que más conforme parezca a la equidad natural.

En otros casos, por cierto excepcionales, el juez *debe* (y no sólo *puede*) recurrir a la equidad, cuando la ley así se lo ordena. Se trata de casos en que la ley se remite a la equidad natural, en forma explícita o implícita (en este último caso, cuando alude a la "prudencia").[156] Así, por ejemplo, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, podemos mencionar los siguientes casos en nuestro Derecho:

i.- En el art. 147, inc. 1° del Código Civil, en cuanto a la facultad que tiene el juez para "constituir *prudencialmente*", a favor del cónyuge no propietario, ciertos derechos reales sobre cosas muebles o inmuebles que previamente han sido declarados bienes familiares. En el inc. 2°, se agrega que al "El tribunal podrá, en estos casos, fijar otras obligaciones o modalidades si así pareciere *equitativo*".

ii.- En el art. 777, inc. 1°, en las reglas del usufructo: el usufructuario debe rendir caución para entrar en el goce de los bienes objeto de dicho usufructo, "dentro de un plazo *equitativo* señalado por el juez".

iii.- En el art. 1185 del Código Civil, referido al primer acervo imaginario, que ordena al juez partidor y a los herederos, actualizar "*prudencialmente*", es decir conforme a la equidad, a la época de la apertura de la sucesión, el valor de las cosas que el causante hubiere donado a un legitimario.

iv.- En el art. 1544, inc. 4° del Código Civil, a propósito de la "cláusula penal enorme". Tratándose de una pena convenida ante el incumplimiento de "obligaciones de valor inapreciable o indeterminado", se deja a la *prudencia* del juez moderar la cuantía de dicha pena, "cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme".

v.- En el art. 1734 del Código Civil, en las normas de la sociedad conyugal, respecto al pago de las recompensas, una vez disuelta aquella: "Todas las recompensas se pagarán en dinero, de manera que la suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la recompensa. / El partidor aplicará esta norma de acuerdo a la *equidad natural*".

vi.- En el art. 1744, inc. 2° del Código Civil, también en la sociedad conyugal. Se trata de las expensas ordinarias y extraordinarias de educación de un descendiente, y las que se hicieren para establecerle o casarle. Estas expensas, por regla general, serán de cargo de la sociedad conyugal. Si hubieren sido hechas por uno solo de los cónyuges, podrá pedir que el otro de los cónyuges le reembolse de sus bienes propios la mitad. Para tal efecto, "quedará a la *prudencia* del juez acceder a esta demanda en todo o parte, tomando en consideración las fuerzas y obligaciones de los dos patrimonios, y la discreción y moderación con que en dichas expensas hubiere procedido el cónyuge".

vii.- En el art. 1792-13, inc. 1°, del Código Civil, en las normas del régimen de participación en los gananciales, para los efectos de valorar por los cónyuges, por un

---

[155] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., p. 178.
[156] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., p. 178.

tercero designado por ellos o en subsidio por el juez, el activo y el pasivo de cada uno de aquellos. Para este efecto, el valor que tenían los bienes o el monto de las deudas, al inicio del régimen, deberá ser "*prudencialmente* actualizado" a la fecha de la terminación del régimen.

viii.- En el art. 1792-23 del Código Civil, también a propósito del régimen de participación en los gananciales, en cuanto dispone que "Para determinar los créditos de participación en los gananciales, las atribuciones de derechos sobre bienes familiares, efectuadas a uno de los cónyuges en conformidad con el artículo 147 del Código Civil, serán valoradas *prudencialmente* por el juez".

ix.- En el art. 2067, inc. 1° del Código Civil, a propósito del contrato de sociedad, en cuanto al reparto de los beneficios y de las pérdidas sociales: "Los contratantes pueden encomendar la división de los beneficios y pérdidas a ajeno arbitrio,[157] y no se podrá reclamar contra éste, sino cuando fuere manifiestamente *inicuo*". Lo "inicuo" es aquello "contrario a la equidad". Por tanto, el juez debe verificar que el tercero a quien se le confió por los socios dividir entre ellos los beneficios y las pérdidas, haya actuado efectivamente conforme a la equidad natural. Es decir, "la equidad debe regular dicho reparto".[158]

x.- En el art. 2173, inc. 3° del Código Civil, en las normas del contrato de mandato. El artículo discurre acerca del término del mandato, pero el mandatario, ignorando dicha expiración o incluso conociéndola, siguió actuando. En tales casos, los terceros de buena fe que contraten con el mandatario tendrán, en principio, acción en contra del mandante. Sin embargo, "Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere sido notificado al público por periódicos, y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero, podrá el juez en su *prudencia* absolver al mandante".

xi.- En el art. 2291, inc. 2°, en las normas del cuasicontrato de agencia oficiosa, al facultar al juez para fijar un plazo al interesado para pagarle al agente oficioso. El plazo será aquél que "… por las circunstancias del demandado parezca *equitativo*".

xii.- En el art. 2319, inc. 2°, del Código Civil, en las normas referidas a los delitos y cuasidelitos civiles. El inc. 1° dispone que no son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años ni los dementes. Del inc. 2° se desprende que tampoco son capaces los menores de dieciséis años. Sin embargo, el inc. 2° agrega que queda a la *prudencia* del juez determinar si el menor de dieciséis años ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento; y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior, es decir, responderá civilmente.

xiii.- En el art. 223, inc. 3° del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto dispone que el árbitro arbitrador debe fallar "obedeciendo a lo que su *prudencia* y la *equidad* le dictaren"; y en el art. 640, inc. 4° del Código de Procedimiento Civil, que establece que la sentencia del aludido árbitro debe contener "las razones de *prudencia* o de *equidad* que sirven de fundamento a la sentencia".[159]

xiv.- En el art. 48, inc. 3°, de la Ley N° 16.618, "Ley de Menores", al disponer que, cuando, por razones imputables a la persona a cuyo cuidado se encuentre el menor, se frustre, retarde o entorpezca de cualquier manera la relación directa y regular que ha de mantener con él el padre que no tenga el cuidado personal, en los términos en que ha sido establecida, el padre o madre a quien le corresponde ejercerla podrá solicitar la recuperación del tiempo no utilizado, lo que el tribunal dispondrá *prudencialmente*.

---

[157] Es decir, a la libre decisión de un tercero.

[158] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., p. 178.

[159] Nótese que el art. 223 del Código Orgánico de Tribunales alude a la "prudencia y la equidad", como si fueren cosas distintas; en cambio, el art. 640 del Código de Procedimiento Civil se refiere a las razones "de prudencia o de equidad", asimilándolas. Conforme a lo que expresamos *ut supra*, creemos que la fórmula correcta es la segunda.

xv.- En el art. 3, inc. 4°, de la Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. El art. 3 establece el monto mínimo de la pensión de alimentos, cuando quien la demande sea un hijo menor de edad. El inc. 3°, con todo, establece que si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios para pagar el monto mínimo establecido, el juez podrá rebajarlo *prudencialmente*.
xvi.- En el art. 62, inc. 2° de la Ley N° 19.947, de Matrimonio Civil, al disponer: "Si se decretare el divorcio en virtud del artículo 54, el juez podrá denegar la compensación económica que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal, o disminuir *prudencialmente* su valor".
xvii.- En el art. 459 del Código del Trabajo, al referirse al contenido de la sentencia. En su N° 5, se incluye, entre otros aspectos, "… los principios de derecho o de *equidad* en que el fallo se funda".

Aún más, como ya se afirmó, la equidad no sólo es un elemento supletorio de la *interpretación* de la ley o un elemento de *aplicación* de la ley en los casos en que ésta así lo disponga, sino que también opera, desempeñando un tercer rol, de *integración*, en los casos de lagunas legales: art 170, N° 5 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la integración de la ley.

De esta manera, la equidad natural podrá servir de factor determinante en tres casos:
1° Cuando un precepto legal presente "pasajes obscuros o contradictorios". En este caso, la equidad operará propiamente como un elemento de *interpretación* de la ley.
2° Cuando la ley se remite a la equidad natural. En este caso, la equidad no operará propiamente como un elemento de interpretación de la ley, sino que como elemento de *aplicación* de la ley, por mandato de la misma.
3° Cuando no exista precepto legal alguno que regule la materia que el juez debe resolver. En este caso, al igual que en el segundo, la equidad tampoco operará como un elemento de interpretación de la ley, pues ésta no existe, sino que más bien como elemento de *integración* de la ley, para suplir los vacíos o lagunas que presente el ordenamiento positivo.

La diferencia entre el primer y segundo caso, por una parte, y el tercer caso, por la otra, radica en que en los dos primeros, hay ley para el caso específico, mientras que en el tercero no la hay. En el primero, hay ley, pero ella presenta "pasajes obscuros o contradictorios". En el segundo, la ley específica ordena aplicar la equidad para el caso regulado por el legislador. En el tercero, no hay ley específica que resuelva la materia, siendo la ley general –art. 170 del Código de Procedimiento Civil-, la que faculta al juez para fallar conforme a la equidad.

En el tercer caso, relativo a la integración de la ley, podría todavía sostenerse que el recurso de la equidad debe emplearse siguiendo el siguiente orden:
i.- Resolver el asunto recurriendo a *la analogía*. Es decir, a falta de ley que resuelva de manera directa un asunto, el juez, fundándose en la equidad, podría recurrir a otro precepto legal, que regule otra materia, en la medida que sea la más semejante al primero que no posee regulación. Pero ello sería posible, advierte cierta doctrina, siempre que el precepto legal al que se recurre, no sea una *regla excepcional*. Así lo expresa Victorio Pescio: "El juez, en la hipótesis del vacío o laguna de la ley, deberá recurrir al método de la analogía, siempre que la disposición legal que se trata de ampliar al caso no previsto por el legislador, no sea de carácter excepcional, pues, en tal evento, no se admite la interpretación por extensión[160]: "Exceptio est strictissimae

[160] En realidad, la interpretación *por extensión* no debe confundirse con la interpretación *por analogía*, según se refirió al aludir a las *especies de interpretación*. En el primer caso, hay ley, sólo que su formulación fue más restrictiva de lo que pretendía el legislador, de manera que el intérprete debe ampliar su aplicación, en correspondencia con el espíritu o fin de la norma en cuestión. En el segundo caso, no hay ley que resuelva la cuestión, debiendo el intérprete recurrir a otro precepto legal, establecido para otra materia, pero que presenta semejanzas con la primera.

interpretationis" (…) Excluida esta limitación, cobran todo su vigor las máximas del método 'a pari' o por analogía que se expresan en fórmulas latinas: 'Ubi eadem est lagio ratio, ibi eadem est legis dispositio'; o 'ubi eadem ratio, ídem ius' o en el argumento 'a fortiori' que en síntesis, quiere decir que en donde existe la misma razón debe existir la misma disposición…".De esta manera, el método de analogía se aplica "como una demostración o expresión del sentido de la equidad".[161]

De esta forma, la analogía podría tener una segunda aplicación en nuestro Derecho. Como se observa, en este caso no en forma autónoma[162], sino que incluida en la equidad.[163]

Se trata en definitiva de la *analogía iuris*, a la que ya aludimos.

ii.- Resolver el asunto sin posibilidad de recurrir a la analogía. Ahora bien, en este caso, se pregunta Victorio Pescio: "¿en qué se inspirará el juez a falta de una disposición legal aplicable por analogía? ¿Deberá arreglar su fallo a los dictados de lo que él, subjetivamente, considere que es de equidad natural, con entera prescindencia del espíritu general de la legislación?".[164] La respuesta es clara: la *equidad natural* –aún a falta de una ley que regule un caso semejante-, debe llevar al juez a una conclusión justa, racional, fundada en razones jurídicas y con pretensión de generalidad. Se descarta por ende una conclusión subjetiva, ajena a estos cuatro parámetros. Y si nos encontramos ante una decisión que no cumpla con este estándar, que no se encuadre en estos cuatro presupuestos, tal sentencia debe ser impugnada, incluso mediante un recurso de casación en el fondo, pues el juez habría infringido la ley –en este caso, principalmente los arts. 24 del Código Civil y 170 N° 5 del Código de Procedimiento Civil-, y tal infracción ciertamente que puede haber influido sustancialmente en lo dispositivo de su fallo. La equidad natural o prudencia, entonces, nada tiene que ver con lo arbitrario, caprichoso o subjetivo. Tiene límites o presupuestos, que el juez debe respetar y seguir. En definitiva, el juez resolverá fundando su sentencia en el espíritu general de la legislación y en los principios fundamentales del ordenamiento jurídico (desempeñando estos últimos un rol *integrador*).

En síntesis, cualquiera sea el rol que desempeñe la equidad natural –sea para interpretar, aplicar o integrar la ley, y en esta última hipótesis recurriendo o no a la analogía-, debe cumplir con los siguientes presupuestos:

i.- Debe ser *justa*. Tal presupuesto es inmanente a la idea misma de equidad.

ii.- Debe ser *racional.* Es decir, debe ser objetiva, razonada.

iii.- Debe ser *jurídica*. Debe estar fundada en el espíritu general de la legislación (los fines más esenciales que el Derecho pretende alcanzar) y en los principios fundamentales del Derecho Civil (que constituyen un trasunto de tales fines esenciales).

---

[161] Pescio Vargas, Victorio (1948), *Manual de Derecho Civil. Título Preliminar del Código Civil*, I, Santiago de Chile, Nascimento, pp. 243 y 244.

[162] La primera aplicación de la analogía, según se indicó, opera tratándose de la llamada *analogía legis*, consagrada en el art. 22, inc. 2°.

[163] Debe considerarse que la analogía como elemento en virtud del cual el juez pudiere resolver el asunto, estaba considerada en el citado art. 4 del Proyecto de Código Civil del año 1853, ya citado. Como señala Pescio, este precepto se volcó a medias en el art. 24, "eliminando la costumbre, excluyendo el método por analogía, substituyendo el concepto de 'principios generales de derecho' por el de 'espíritu general de la legislación' y suprimiendo toda referencia a la falta de ley escrita": Pescio, Victorio, ob. cit., p. 242. En realidad, la costumbre no se eliminó, sino que se consagró en un artículo separado –el 2°-; la analogía por su parte debiéramos entenderla subsumida en la equidad; y los principios generales del derecho, si se trata de aquellos que se denominan "intrasistémicos", constituyen una derivación del espíritu general de la legislación. Asimismo, como ya se señaló, creemos que la analogía también está incorporada en el art. 22, inc. 2°, en su acepción de *analogía legis*. Por tanto, estos tres elementos –costumbre, analogía y principios-, no se excluyeron en definitiva, sino que se recogieron de otra forma a la que expresaba el art. 4 del Proyecto del año 1853.

[164] Pescio Vargas, Victorio (1948), ob. cit., p. 244.

iv.- Debe ser *general*. La solución, ha de ser susceptible de aplicarse a otros casos (ha de tener "vocación general").

g) *Principio de la especialidad*.

En el proceso interpretativo, el intérprete no debe olvidar que las leyes especiales prevalecen sobre las generales. Esta regla de carácter universal es de toda lógica. Si el legislador dicta una ley sobre una materia determinada quiere decir que desea sustraerla de la regulación general. Sería absurdo, entonces, hacer prevalecer ésta sobre aquella. Por otra parte, una ley particular supone un estudio expreso de la materia que regirá. Este principio de la especialidad lo reconoce el Código Civil en sus artículos 4 y 13. El primero se refiere a disposiciones contenidas en leyes distintas y el segundo a las contenidas en una misma ley.

h) *Determinación de la especie de interpretación que corresponda aplicar: declarativa, extensiva y restrictiva*.

Es el acatamiento de la regla de que lo favorable u odioso de una disposición no debe tomarse en cuenta para ampliar o restringir su interpretación: art. 23. Nos remitimos a lo expresado sobre el particular.

i) *Reglas prácticas de interpretación*.

Aparte de las normas del Código, existen para la interpretación de las leyes una serie de aforismos jurídicos, formados en la práctica del ejercicio profesional y que a menudo emplean la doctrina y la jurisprudencia. Suelen ser citados en fórmulas latinas, creadas por los antiguos juristas. En todo caso, ninguno de estos aforismos debe emplearse de modo exclusivo y no tienen un valor absoluto. Se utilizan para ilustrar el criterio del juez que fallará el litigio. Entre los más utilizados están:
i.- *Argumento de analogía* o *a pari*.

Alude a la interpretación por analogía y se expresa en el siguiente aforismo: "*donde existe la misma razón, debe existir o aplicarse la misma disposición o solución*" (*ubi eadem esto legis ratio, ibi eadem est legis dispositio*). De acuerdo con la doctrina predominante, la analogía consiste en resolver un asunto conforme a las leyes que rigen situaciones semejantes u análogas en casos no previstos por la ley.

Por ejemplo, antes de la vigencia del Derecho aeronáutico, muchos problemas que originaba la navegación aérea, se resolvían aplicando las normas del Derecho marítimo.

Cabe advertir que "Este argumento no es admisible cuando la disposición [a la que se recurre] es excepcional, es decir, que ella deroga a una regla general. Este, es el sentido de las fórmulas repetidas a menudo: 'la excepción es de derecho estricto (…) la excepción confirma la regla en los casos no exceptuados'".[165]

No se debe confundir la *analogía* con la *interpretación extensiva*. Por esta última, una norma se aplica a casos no comprendidos en su texto, pero sí en su espíritu, en su intención, en su razón de ser (*ratio legis*). Como esos casos corresponden al supuesto que se ha querido regular, se considera que el legislador por omisión u otra causa ha dicho menos de los que quería decir, estimándose natural y también lícito extender a esos hechos la aplicación de la norma. La analogía, en cambio, busca solucionar un caso concreto aplicando otras normas, porque aquella norma que lo regula es obscura (analogía *legis*), o porque el legislador no lo resolvió mediante una norma directa (analogía *iuris*). La analogía opera entonces ante una

[165] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 231, p. 127.

norma obscura o en ausencia de norma que resuelva la cuestión. En verdad, como ya expusimos, la analogía *iuris* es una forma de aplicar la equidad, en ausencia de norma que regule el asunto. Así, por ejemplo, encontramos algunos casos de aplicación por analogía de normas en las siguientes hipótesis:

i) Indemnización de los deterioros que hubiere causado en la cosa el poseedor vencido, que debe restituírsela al dueño: art. 906. Para saber de qué deterioros se responde, debemos distinguir entre el poseedor vencido de mala fe o de buena fe. Pero el art. 906 no señala en qué momento debe haber estado de buena o mala fe el poseedor. Aplicando por analogía el art. 913, que se refiere a los frutos y a las mejoras, se ha entendido que es en el momento en que se produjeron los deterioros.

ii) El art. 998 está ubicado entre las reglas de la sucesión abintestato y comienza diciendo "en la sucesión abintestato de un extranjero..."; de acuerdo con la doctrina unánime, este precepto debe aplicarse por analogía a las sucesiones testamentarias en lo que respecta a las asignaciones forzosas de los sucesores chilenos, pues existen las mismas razones de protección en una y otra sucesión.

iii) En las normas del derecho de acrecimiento (arts. 1147 a 1155), no se aclara cuándo se entiende faltar uno de los asignatarios conjuntos llamados a un mismo objeto de la sucesión. Se ha entendido que por analogía, debe aplicarse lo dispuesto en el art. 1156, que sí lo indica para el derecho de sustitución.

iv) No admite modalidades la aceptación o renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal, prevista en el art. 1781 (aplicando por analogía el art. 1227 en relación al art. 956, inc. 1º).

v) No sería suficiente para celebrar la prenda el mandato que una persona tuviera para vender, aplicando por analogía el art. 2143, que excluye en tal caso la posibilidad de hipotecar.

vi) Podría ocurrir que una cosa sea enajenada por distintos contratos a distintas personas no relacionadas entre sí. ¿Cuál de los adquirentes será preferido? La ley resuelve la cuestión respecto de la compraventa y la permuta en el art. 1817. ¿Qué ocurre tratándose de una donación? A nuestro juicio, no habiendo normas que resuelvan el punto, parece razonable aplicar, por analogía, lo dispuesto acerca de los dos primeros contratos.

vii) La ley prohíbe que las capitulaciones matrimoniales contengan estipulaciones relativas a la vigencia de la sociedad conyugal (art. 1721, inc. 3º). No permite la ley adelantar o retrasar la vigencia de la sociedad conyugal o crear causales especiales de extinción, si los esposos optan por tal régimen. Lo mismo cabe señalar respecto del régimen de participación en los gananciales: aunque la ley no lo señale expresamente, entendemos que aquí se aplica el aforismo "donde existe la misma razón, rige la misma disposición", operando una interpretación por analogía.

ii.- *Argumento de contradicción* o *a contrario sensu*.

Se expresa en la fórmula siguiente: "Lo que se dice de unos se excluye de otros". Este argumento "parte de la voluntad expresada en el caso previsto por el legislador para suponerle en todos los otros una voluntad contraria. Se formula ordinariamente *qui dicit de uno negat de altero*, 'quien dice de unos niega de otros'".[166]

Por ejemplo:

i) Art. 1801, inc. 2° del Código Civil: si la ley exige escritura pública en ciertas compraventas, en las demás, el contrato es consensual.

ii) Art. 1465: la condonación del dolo futuro no vale; a contrario sensu, la del dolo ya acaecido, es válida.

iii) Art. 1814, inc. 3º: "El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe". *A contrario*

[166] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 231, p. 127.

sensu, si el vendedor vendió de buena fe o si el comprador compró de mala fe, no será procedente indemnizar perjuicios.
iv) Art. 1935: el arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto, para que las hiciese por su cuenta. A contrario sensu, tal obligación no pesa sobre el arrendador si las faenas no tuvieron el carácter de indispensables para el goce de la cosa.
v) Art. 1186: ordena acumular de manera contable o imaginaria al acervo líquido dejado por el causante, las donaciones *entre vivos* hecha a extraños. *A contrario sensu*, no deben acumularse las donaciones hechas *por causa de muerte*.

Se suele criticar este argumento afirmando que el silencio del legislador nada prueba. Dicho silencio puede ser explicado de muchas otras maneras. Si la ley es una declaración de voluntad, es necesario que el legislador se haya manifestado. Normalmente, el argumento no prueba sino cuando, partiendo de una disposición excepcional, permite volver al derecho común que recupera su imperio. Por esta razón, este argumento debe utilizarse con cautela y discreción.[167]

Así, por ejemplo, aunque en el art. 999 del Código Civil se exprese que el testador puede revocar las *disposiciones* del testamento y nada se diga respecto de que pueda también revocar sus *declaraciones*, debemos concluir que algunas de éstas sí pueden revocarse.
iii.- *Argumento a fortiori*.

En virtud del mismo, si a una situación se le aplica una solución jurídica determinada atendiendo a cierta razón, a otro caso se le debe aplicar la misma solución cuando concurre la misma razón con mayor claridad. Este argumento se sintetiza en dos formas:
i) Argumento *a mayore*: "Quien puede lo más puede lo menos". Si una persona puede vender un inmueble con mayor razón puede prometer venderlo o sólo arrendarlo.
ii) Argumento *a minore*, conforme al siguiente aforismo: "Al que le está prohibido lo menos con mayor razón le está prohibido lo más". Si alguien no puede arrendar o hipotecar un bien con mayor razón no puede venderlo.
iv.- *Argumento de no distinción*.

Decían los juristas romanos "*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemos*", fórmula que hoy se expresa como "Donde la ley no distingue tampoco cabe al interprete distinguir". Por ejemplo:
i) Si la ley no distingue, todos los hijos del causante, tanto matrimoniales como no matrimoniales, concurren en el primer orden sucesorio, con igualdad de derechos (art. 998).
ii) Toda compraventa de bienes inmuebles debe celebrarse por escritura pública (art. 1801, inc. 2º).
iii) Se prohíbe la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, cualquier sea el régimen patrimonial del matrimonio y la naturaleza de los bienes que se vendan (art. 1796).
iv) En las normas de la lesión enorme, si el comprador enajenare el inmueble, el vendedor no podrá ya demandar la rescisión de la compraventa celebrada con el primero (art. 1893). No distinguiendo la ley, debemos entender que la ley se refiere tanto a la enajenación voluntaria como a la forzada.
v) También en la lesión enorme, la ley prohíbe renunciar a la acción rescisoria por lesión enorme (art. 1892). No distinguiéndose, la prohibición rige tanto para la renuncia que se hiciere al momento de celebrar el contrato, cuanto para aquella que se hiciere después.

---

[167] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 231, pp. 127 y 128.

De cualquier manera, se debe aplicar con cautela este argumento de la no distinción. En efecto, este principio es cierto si la ley no distingue ni en su tenor ni en su espíritu, pero puede ocurrir que no distinga en el primero, pero si en el segundo.

v.- *Argumento del absurdo*.

Conforme a él, debe rechazarse una interpretación que conduzca al absurdo, a toda conclusión que pugne con la lógica o la racionalidad jurídica. Por ejemplo:

i) Una parte de la doctrina ha invocado este argumento, para los efectos del cómputo del plazo de prescripción de la acción destinada a perseguir la responsabilidad extracontractual por la comisión de delitos y cuasidelitos. Conforme al art. 2332, prescribe la acción "en cuatro años contados desde la perpetración del hecho". Sin embargo, en algunos casos el daño que sufre la víctima del delito o cuasidelito no se manifiesta en forma coetánea a la comisión del hecho ilícito, sino que meses o incluso años después. Siendo así, en tal caso no resulta lógico interpretar la frase "perpetración del hecho" como "ejecución del hecho", pues la víctima podría quedar sin acción, sino que se postula que el plazo debe computarse desde que se manifiesta el daño y no desde la comisión del hecho ilícito.

ii) El art. 2317, también en las normas de responsabilidad extracontractual, expresa en su inc. 1º que, si el delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del delito o cuasidelito (es decir, a cualquiera se le podrá demandar por el total de los perjuicios). Acto seguido, el inc. 2º agrega: "Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso". Si se entendiera que este inciso es nada más que una reiteración de lo señalado en el inc. 1º, llegaríamos a una conclusión absurda, pues estaríamos ante una norma inútil. Por ello, parte importante de la doctrina concluye que este inc. 2º, a pesar de ubicarse en las normas de la responsabilidad extracontractual, debe aplicarse a casos de responsabilidad contractual.

j) *Efectos en caso de infringirse los arts. 19 a 24 del Código Civil*.

Las normas que se han revisado son, por cierto, imperativas para el juez que conozca del asunto. No puede dejar de aplicarlas ni modificarlas. Si así ocurriere, y al interpretar un precepto legal sustantivo no se aplicaren correctamente las normas citadas, el afectado podrá llegar hasta la Corte Suprema, a través del recurso de casación en el fondo, cuando la infracción de la ley ha influido en la parte dispositiva del fallo. Sin embargo, como ha reiterado la jurisprudencia, las reglas de interpretación no son sustantivas, sino más bien de carácter procesal. En consecuencia, es necesario fundar el recurso, denunciando la infracción a la norma o a las normas *decisoria litis* que, a consecuencia de su equivocada interpretación, permiten solicitar la invalidación de la sentencia: "Las reglas contenidas en los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil sólo constituyen principios o normas generales destinados a orientar la labor de los tribunales de justicia en su función específica y primordial de averiguar y fijar el recto y genuino sentido de la ley, para aplicarla con acierto a la resolución de las controversias de que conocen, por lo que su infracción no puede ser aducida por sí sola, sin adicionarla a otras reglas, para fundamentar un recurso de casación en el fondo. Es requisito básico de esta vía procesal que la infracción invocada influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo, condición que no puede producirse sin relacionar aquellas reglas con una ley en que propiamente repose el fallo, es decir, que tenga el carácter de decisoria litis" (Corte Suprema, 11 de abril de 1955; Corte Suprema, 12 de mayo de 1992)[168]; "Los artículos 19 y 22 del Código Civil son

[168] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 124.

preceptos sólo de ordenamiento procesal, como quiera que junto a las demás disposiciones del párrafo 4º del Título Preliminar del señalado Código, constituyen sólo un medio auxiliar del juez para dar a cada disposición legal la interpretación que éste considere adecuada, de manera que, atendidas tal naturaleza y finalidad, no pueden ellas ser objeto de un recurso de casación en el fondo, por no investir en sí mismas el carácter de normas decisoria Litis" (Corte Suprema, 27 de mayo de 1992)[169]; "Las disposiciones sobre hermenéutica legal no tienen por sí solas el carácter de leyes decisoria Litis. Para que su violación permita acoger el recurso de casación en el fondo que se funda en ellas, es indispensable que se señalen también como violadas la o las disposiciones sustantivas que debieron o no aplicarse como consecuencia del acertado establecimiento de los hechos del juicio y de su correcta interpretación" (Corte Suprema, 15 de junio de 1992).[170]

11.- Integración de la ley.

11.1. Cuando debe integrarse la ley.

En un caso determinado, el juez puede encontrarse en la situación de que no exista una norma precisa del ordenamiento jurídico, que resuelva la materia de la que está conociendo. Frente a este vacío o laguna legal opera la integración, en cuya virtud el juez está obligado a dictar sentencia fundándose en el principio de que *puede existir un vacío en la ley, pero no en el Derecho*.

Como expresa Squella, destacando la diferencia entre la interpretación y la integración de la ley, "Tratándose en particular de la interpretación de la ley, y, más concretamente aún, de la interpretación judicial de la ley, el juez cuenta con un derecho preexistente al caso que debe conocer y fallar, esto es, se encuentra vinculado a un material normativo puesto previamente por otra autoridad normativa, y que es, precisamente, el que él tiene que identificar, interpretar y decidir finalmente su aplicación a los casos de la vida social que se le presenten. La interpretación judicial de la ley, en consecuencia, supone la existencia de un material jurídico dado al juez –las normas del derecho legislado o los textos que expresan ese derecho-, de modo que su labor interpretativa, ya sea que se entienda encausada directamente a las normas o a los textos, se desenvuelve siempre en un marco previamente establecido. Distinto es lo que pasa con la *integración* de la ley, puesto que se trata de una actividad a la que el intérprete de la ley, en especial los jueces, se ven compelidos a falta de ley, es decir, cuando teniendo que conocer y resolver un determinado asunto, se encuentran con que el derecho legislado ha callado acerca de él y, por tanto, no provee solución jurídica alguna para el mismo. El legislador puede advertir lagunas en las leyes y remediarlas o no. El jurista puede también detectarlas y proponer maneras de salvarlas, pero sus propuestas no resultan vinculantes desde un punto de vista jurídico. En cambio, los jueces advierten a veces lagunas en las leyes en relación con los casos de que conocen, aunque, a diferencia del legislador, están obligados a llenarlas y a fallar el caso de que se trate, no estándoles permitido omitir el fallo a pretexto de que no existe ley sobre la materia. Esto significa que en presencia de una laguna el juez no puede negarse a dar una solución al caso que no aparece regulado por la ley, ni puede tampoco diferir la solución hasta que el legislador colme o remedie la laguna de que se trate, ni puede, en fin, reenviar el problema al legislador e instarlo

---

[169] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 124.
[170] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 125.

a que corrija la insuficiencia detectada en el derecho legislado de que ese legislador es responsable".[171]

11.2. Normas que ordenan integrar la ley.

Las disposiciones que contemplan esta obligación son las siguientes:
a) Art. 76 de la Constitución Política, cuando establece que reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión.
b) Art. 10, inciso 2, del Código Orgánico de Tribunales, que reitera la norma constitucional.
c) Art. 170, N° 5, del Código de Procedimiento Civil, cuando dispone que toda sentencia definitiva debe contener la enumeración de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo.
d) Art. 459, inc. 5° del Código del Trabajo, al disponer que la sentencia que resuelva un litigio laboral, debe contener "los principios de derecho o de equidad en que el fallo se funda".

11.3. Cómo debe integrarse la ley.

En el Derecho civil, a falta de ley que resuelva el asunto, el juez, según se expuso, está facultado para recurrir a la *equidad natural*. Conforme a lo expuesto con antelación, al recurrir a la equidad natural el juez podrá resolver el asunto de dos maneras:
i.- Conforme a la analogía, si existiere una norma que regule un caso semejante.
ii.- Construyendo una solución para el caso concreto con prescindencia de alguna norma analógica. En este caso, fundará su sentencia en el espíritu general de la legislación y en los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

En el ámbito del Derecho comercial, a falta de ley rige *la costumbre* (costumbre en el silencio de la ley) y a falta de ésta operan las reglas generales de integración, es decir, el juez podrá fundar su sentencia en la equidad natural.

En el ámbito del Derecho penal, el problema de las lagunas legales no existe, ya que sin ley no hay delito ni pena, y, por lo tanto, sólo cabe absolver al formalizado o acusado.

12.- Efectos de la ley.

Los "efectos de la ley", como señala Claro Solar, dicen relación con "los derechos y obligaciones que ella crea".[172]

Los efectos de la ley pueden estudiarse desde cuatro puntos de vista: respecto a *las personas*, en cuanto al *tiempo*, en lo relativo al *territorio* y en cuanto a la *sanción*.

En consecuencia, se trata de estudiar:
i.- A quiénes se les aplica la ley.
ii.- Durante qué período de tiempo se aplica la ley.
iii.- Dónde se aplica la ley.
iv.- Cómo se sanciona la infracción de la ley.

---

[171] Squella Narducci, Agustín (2004), ob. cit., pp. 476 y 477.
[172] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 82, p. 51.

En lo que se refiere a los efectos de la ley en cuanto a la sanción, nos atenemos a lo señalado cuando hicimos referencia a las normas imperativas, prohibitivas y permisivas y a las sanciones que pueden sobrevenir de infringirse.

Desarrollaremos a continuación lo concerniente a los efectos de la ley en el tiempo y en el espacio o territorio, para más adelante revisar lo relativo a las personas.

12.1. Efectos de la ley en cuanto al tiempo.

a) *Promulgación y publicación de la ley*.

La ley, como sabemos, debe formarse **de acuerdo con el** procedimiento establecido en la Constitución. Con todo, para que la ley sea obligatoria, no basta el voto conforme de ambas cámaras, con el quórum requerido según la ley de que se trate, ni con la sanción o aprobación del Presidente de la República (es decir, el acto por el cual éste, en su calidad de poder colegislador, presta su adhesión al proyecto de ley aprobado en el Congreso). En efecto, para que la ley sea obligatoria, es necesario, además de lo precedentemente indicado, que se proceda a su *promulgación* y a su *publicación*.

El art. 6 del Código Civil establece las condiciones necesarias para que la ley sea obligatoria. Dos requisitos deben cumplirse:
i.- Que sea promulgada por el Presidente de la República.
ii.- Que sea publicada en el Diario Oficial o en otra forma dispuesta en la misma ley, según agrega el inc. 3º del art. 7.

Con la sanción o aprobación del Presidente de la República, termina la primera fase de la formación de la ley, en cuya elaboración tiene exclusiva injerencia el Poder Legislativo, porque si bien existe participación del Presidente de la República, éste la tiene a título de integrante de aquél poder y no como titular del Poder Ejecutivo.

Se define la *promulgación* como el acto por el cual el Presidente de la República atestigua o certifica a la comunidad la existencia de la ley y ordena su ejecución.[173] La promulgación, como dice un autor, es la partida de nacimiento de la ley, le da existencia cierta, auténtica, incontestable y la reviste de la fuerza coercitiva de que antes carecía.[174] "Consiste en que el poder ejecutivo reconozca que la ley encierra los requisitos esenciales puntualizados en la Constitución, y ordene que la ley se ejecute".[175] La promulgación se verifica mediante un Decreto Supremo, en el que se inserta el texto de la ley. Dicho Decreto Supremo lleva la firma del Presidente y del Ministro respectivo (o los Ministros respectivos, si la ley abarca materias de la responsabilidad de dos o más Ministros de Estado). Conforme al art. 75 de la Constitución Política, si el Presidente de la República no devolviere al Congreso Nacional el proyecto aprobado por éste, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que fue remitido al primero, se entenderá que lo aprueba y que se promulgará como ley. En tal caso, la promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días.

La *publicación* –o *divulgatio promulgationis*- es el medio que se emplea para hacer llegar la ley al conocimiento de los individuos.[176] Es el acto por el cual se notifica la existencia de una ley a todos los habitantes del Estado.[177] Es lógico que para exigir obediencia a la ley debe proporcionarse el medio para conocerla.[178] Como expresa

---

[173] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 70, p. 43; Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 210, p. 150.
[174] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 70, p. 43; Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 211, p. 151.
[175] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., pp. 79 y 80.
[176] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 215, p. 152.
[177] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 80.
[178] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 215, p. 152.

Claro Solar, "La promulgación es una orden de ejecución; y sería injusto que tal orden pudiera ser ejecutada contra aquéllos a los cuales se dirige, antes que éstos hubieren sido colocados en situación de conocerla".[179] La publicación persigue entonces difundir el contenido de una ley, darlo a conocer a todos los habitantes de la República. Dispone el art. 75 de la Constitución Política que la publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.

El art. 7 del Código Civil regula lo relativo a la publicación de la ley, estableciendo:

i.- Que la ley debe publicarse mediante su inserción en el Diario Oficial.
ii.- Que, desde la fecha de su publicación, se entenderá conocida por todos.
iii.- Que desde la fecha de su publicación será obligatoria.
iv.- Que, para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación.
v.- Que, no obstante lo anterior, en cualquier ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha en que la ley de que se trate entre en vigencia.

La regla general entonces, será que la ley se hace obligatoria, es decir entra en vigencia, desde la fecha de su publicación. Sin embargo, en cualquier ley podrá establecerse una fecha distinta de vigencia.

El espacio de tiempo que media entre la publicación de la ley y su vigencia, se denomina "vacancia de la ley". Algunas legislaciones la establecen para que todas las personas puedan conocer el texto legal y se calcula considerando que el periódico oficial en el cual se insertó la ley llegue a sus manos en dicho lapso[180]. En realidad, no es esa solamente la razón que explica la eventual vacancia legal. Ésta se justifica en nuestros días, más bien, por la trascendencia o por la complejidad que pueda tener la nueva ley, y especialmente cuando ella supone reformar en profundidad la legislación hasta ahora vigente. En tales circunstancias, es razonable que se espere un tiempo antes de que la ley entre en vigencia, pues de no mediar este plazo, podrían producirse numerosos trastornos y frecuentes incumplimientos.

Para el cómputo del plazo de la vigencia de una ley, hay dos sistemas: uno *sucesivo* o *gradual* y otro *simultáneo*. Por el sistema sucesivo o gradual, la ley entra en vigor en unas localidades o regiones y luego en otras, según la mayor distancia que medie entre las diversas regiones y el lugar en que se publica el periódico oficial. De acuerdo con el segundo, la ley comienza a regir en un mismo instante en todos los puntos del territorio de un país.[181] Uno y otro sistema tienen inconvenientes, como apunta Claro Solar: "El primero de estos sistemas tiene el grave inconveniente de que la ley obligará a unos ciudadanos y no obligará a otros y continuará siendo lícito o prohibido en una parte del territorio del Estado, lo que la ley nueva prohíbe o permite, de tal modo que aunque la ley sea conocida puede un particular sustraerse a ella y aun burlarla en otra parte del territorio. Tiene también este sistema el inconveniente de complicar los cálculos, porque hay que estar consultando el cuadro de distancias entre las cabeceras de departamento. Por su parte, el plazo uniforme tiene el inconveniente de que debe ser algo largo para que la presunción de publicidad no sea contraria a la realidad de las cosas y que la ley se haga obligatoria sin darla a conocer o permitir su conocimiento; pero igualmente resultará que, a pesar de ser conocida, el cumplimiento de la ley quedará en suspenso por un tiempo largo en los departamentos próximos al de la publicación y en éste mismo. Tienen, pues, uno y otro sistema sus inconvenientes prácticos y lo único que el legislador debe averiguar es cuál de los dos los presenta menores en su aplicación al país para el cual legisla, habida consideración

---

[179] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 70, p. 43.
[180] Vodanovic, H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 218 bis, p. 154. Así, dispone el art. 5 del Código Civil y Comercial argentino: "Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen".
[181] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 219, p. 154.

a la extensión del territorio y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones entre las diversas secciones del país. Creemos que al redactarse el Código Civil su autor hizo bien en dar preferencia al sistema progresivo, porque de otro modo habría tenido que fijar un plazo demasiado largo para la vigencia simultánea de la ley. Hoy que las comunicaciones se han facilitado enormemente y que la publicidad es tanto mayor que antes, sería preferible fijar un plazo único".[182]

El postulado de Claro Solar, sin embargo, demoró 50 años en concretarse. Chile, en efecto, siguió el sistema gradual hasta que la Ley Nº 9.400, de 1949, consagró la fórmula de que la ley empieza a regir simultáneamente desde su publicación en el Diario Oficial en todo el territorio de la República, salvo disposición expresa en contrario.[183] En Chile, por ende, no hay vacancia legal, *por regla general*. Se fundamenta lo anterior en el hecho de que la ley, antes de su promulgación y publicación, es susceptible de conocerse por todos, al menos en lo sustancial, ya que las sesiones del Congreso y la sanción del Presidente de la República tienen gran publicidad a través de los medios de comunicación, de manera que al publicarse en el Diario Oficial, ese conocimiento público sólo viene a "oficializarse".[184] Por otra parte, hoy es también posible consultar por cualquier ciudadano, en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional (www.bcn.cl), las últimas leyes publicadas.

Sin embargo, por excepción, cualquier ley puede establecer reglas diferentes, no sólo sobre su publicación, sino también sobre su fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia. Por tanto, una ley, si así lo dispone ella misma, puede entrar en vigencia un tiempo después de su publicación o puede disponer que en ciertas regiones del país entre a regir en una fecha y en otras regiones en una fecha distinta.[185] Incluso, puede disponerse que ciertos artículos de una ley entren en vigencia inmediatamente de publicada ésta y otros con posterioridad. Así aconteció, por ejemplo, con las últimas reformas del Código Civil, promulgadas por las leyes números 18.802, 19.335 y 19.585 de los años 1989, 1994 y 1998, respectivamente, y con la Ley Nº 19.947, segunda ley de Matrimonio Civil, del año 2004 (seis meses de vacancia legal).

Los plazos prolongados de vacancia legal, como ya se dijo, se justifican en nuestros días cuando se trata de leyes que introducen una profunda y extensa transformación del ordenamiento jurídico o cuando estamos ante leyes que por su complejidad, requieren tiempo para ser cabalmente conocidas por los ciudadanos y aplicadas[186] (así, por ejemplo, tratándose de la reforma procesal penal, cuyas normas tuvieron una vigencia gradual, iniciándose ésta en las regiones de La Araucanía y de Coquimbo en el año 2000 y culminando en el año 2005 en la Región Metropolitana).

b) *Presunción o ficción de conocimiento de la ley*.

El inc. 1 del art. 7 establece que, desde la fecha de su publicación, la ley se entenderá conocida de todos. A su vez, el art. 8 dispone que nadie podrá alegar ignorancia de la ley, después que ésta haya entrado en vigencia.

---

[182] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 76, pp. 46 y 47.

[183] En el Código Civil originario, la ley entraba en vigencia en el plazo de 6 días, contado desde su publicación, si se trataba del departamento en el que ella se promulgare (en la práctica, en Santiago); y en cualquier otro departamento, después de 6 días y uno más por cada 20 kilómetros de distancia entre las cabeceras de ambos departamentos (art. 7). Por ello, decía Claro Solar en 1898 que "En consecuencia, la ley no reviste el carácter de obligatoria en todo el territorio de la República al mismo tiempo: así, una ley publicada en el *Diario Oficial* el 1º de Enero, será obligatoria en Santiago el 7 de Enero a las doce de la noche, y en Valparaíso, el 16 de enero, porque la distancia entre Santiago y Valparaíso es de 183 kilómetros": Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 75, p. 46.

[184] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 220, p. 155.

[185] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 220, p. 155.

[186] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 220, p. 155.

Descansan estas disposiciones en el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, consecuencia a su vez del principio fundamental del Código Civil de la omnipotencia de la ley.

El secular principio de que la ley es de todos conocida, se basa en un poderoso interés social, que se hace patente con solo pensar, como ha dicho un autor, que "si para ser dispensado de conformarse a la ley, bastase alegar que se la ignora, ella a nadie obligaría".[187]

Como expresaba Claro Solar, desde su publicación (por regla general), "la ley obliga a todos. Nace entonces del interés social, que exige que la aplicación de la ley sea independiente de las negligencias o mala voluntad de los particulares, una presunción de que ellos conocen la ley, y esta presunción excluye (…) la prueba contraria. Es la misma cosa conocer realmente una ley, que haber podido o debido conocerla (…) La presunción de conocimiento de la ley está fundada en un interés social: no habría sociedad posible si las leyes no tuviesen una fuerza obligatoria, independiente de la ignorancia, del capricho o de la mala voluntad de aquéllos a quienes obligan".[188]

En consecuencia, a partir de un hecho conocido (publicación y vigencia de la ley), se deduce una consecuencia (inmediato conocimiento de la ley).

En la doctrina, se suele indicar que el conocimiento supuesto que todos tienen de la ley no es en verdad una *presunción*, porque la base de toda presunción es que el hecho que se presume corresponde a lo que normalmente sucede, y es innegable que lo que acontece normalmente es la ignorancia del Derecho por parte de la generalidad de los ciudadanos, los cuales, en el enorme laberinto de las leyes dictadas sin interrupción no pueden conocer ni siquiera una pequeña parte de ellas.[189]

De ahí que se hable más bien de una "*ficción legal*". Por la necesidad social de que nadie eluda el cumplimiento de la ley, se finge que con el hecho de su publicación y vigencia nadie ignora sus preceptos, impidiendo así que se alegue su ignorancia. De otro modo, sería imposible obtener el cumplimiento de la ley, pues todos se escudarían en el desconocimiento de la misma.[190]

En realidad, como decía Portalis, "la publicación tiene menos por objeto hacer conocer la ley, que fijar una época en que se repute conocida".[191]

En relación con lo anterior, también se ha señalado por algunos que la disposición del art. 706, inc. final, acerca de que "el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario" no tendría una aplicación general, sino circunscrita a la posesión. Igual cosa ocurriría, tratándose de lo dispuesto en el art. 1452, en cuanto a que "el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento". Tal posición doctrinaria nos parece sumamente discutible, considerando la fuerza del art. 8, respecto del cual los arts. 706 inciso final y 1452 no son sino aplicaciones. La referida presunción de mala fe tendría entonces, en nuestra opinión, un alcance general.

Se suelen señalar también diversos casos en los cuales el error de derecho puede alegarse, sobre la base de la buena fe, aun cuando no para excusarse del incumplimiento de la norma, sino para otros efectos. Así, por ejemplo:

i.- Tratándose de los arts. 2297 y 2299, en el ámbito del *cuasicontrato del pago de lo no debido*, casos en los cuales quién pagó una suma de dinero o entregó una cosa a otro creyendo que estaba legalmente obligado a ello, puede solicitar la repetición (o

---

[187] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 222, p. 156.
[188] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 80, p. 48.
[189] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 222, p. 156.
[190] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 71, p. 44; Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 222, pp. 156 y 157.
[191] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 71, p. 44.

sea, la devolución) de lo que pagó o entregó, amparándose incluso en el error de derecho.
ii.- Otro caso se contempla en el art. 1683, referido a la *nulidad absoluta*. Tal precepto establece que puede alegarse la nulidad absoluta por todo el que tiene interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Así, si la persona no tuvo conocimiento de la ley en virtud de la cual el acto o contrato es considerado nulo, le es permitido invocar la nulidad de dicho acto jurídico.
iii.- También creemos que existe otro caso en el art. 972, referido a la *indignidad para suceder* que afecta a la persona que "a sabiendas de la incapacidad", haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquier forma, a una persona incapaz para suceder al causante. Si la promesa se hizo desconociendo la ley el que prometió, no operaría en su perjuicio la causal de incapacidad (Ramón Domínguez Benavente y Ramón Domínguez Águila,[192] sin embargo, consideran que sólo podría tratarse de un error de hecho).
iv.- Una cuarta hipótesis encontramos en las reglas del *contrato de mandato*, al disponer el art. 2122 del Código Civil que "El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, se convierte en un agente oficioso". Si el mandato es nulo, no hay verdadero mandato, y por ende quien actuaba como mandatario no puede reclamar el pago del honorario que le habría correspondido por ejecutar la gestión que se le confió. Pero, dado que la ley lo considera al menos como un agente oficioso, podrá reclamar el reembolso de lo que hubiere invertido en la ejecución de dicha gestión. La circunstancia de que haya incurrido en un error de derecho (al ignorar la causal de nulidad), no obsta para obtener dicho reembolso.
v.- A juicio de algunos autores, otro caso encontraríamos en las *obligaciones naturales*, es decir, en aquellas que no dan al acreedor respectivo derecho o acción para exigir al deudor su cumplimiento, pero cumplidas por éste, autorizan al primero para retener lo dado o pagado en razón de ellas. Estas obligaciones están reguladas en los arts. 1470 a 1472 del Código Civil. Tienen un carácter excepcional. En cambio, las obligaciones civiles o perfectas, son aquellas que dan derecho o acción al acreedor para exigir de su deudor la prestación debida. Estas últimas constituyen la regla general. Ahora bien, el inc. final del art. 1470 advierte que, para que no pueda pedirse la restitución, "es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes". Esta frase se ha interpretado por algunos en orden a que el deudor, al pagar, debe haberlo hecho con el *conocimiento* de que satisfacía una obligación natural y no civil. Siendo así, si por error de Derecho el deudor pagó porque creía que de no hacerlo su acreedor podría compelerlo a ello, y después se entera que no era ello posible, podría exigir la devolución de lo pagado. Al estudiar estas obligaciones revisaremos dicha opinión, y también la doctrina contraria, en virtud de la cual se descarta este derecho a reclamar la restitución de lo pagado alegando el pretendido error de Derecho. Vodanovic, al referirse a este caso, admite que la segunda doctrina es la mayoritaria.[193]
vi.- Para algunos, habría un solo caso en que podría sostenerse la ignorancia de la ley para excusarse de su incumplimiento. Tal sería el caso del llamado "*matrimonio putativo*", establecido en el art. 51 de la Ley de Matrimonio Civil. En efecto, algunos sostienen que el error a que se alude en el citado precepto es tanto el error de hecho como el de derecho. Podría una persona afirmar entonces que ignoraba la ley que señala los impedimentos para contraer matrimonio y así quedar amparada en la

---

[192] Domínguez Benavente, Ramón y Domínguez Águila, Ramón (2011), *Derecho Sucesorio*, 3ª edición actualizada, Tomo I, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, p. 298.
[193] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 222, p. 157.

putatividad, siempre que concurra la buena fe y la justa causa de error. El punto es sumamente discutible. Desde ya, Enrique Rossel concluye que no estaríamos ante tal caso excepcional. Afirma este autor que el error de derecho no puede ser considerado "justa causa de error", pues la ley se presume conocida de todos, de manera que quien yerra en derecho, yerra a sabiendas. Por lo demás, agrega el autor citado, ignorar la ley en un acto de la trascendencia del matrimonio importa una falta de diligencia y de acuciosidad incompatible con el concepto de "error justificable", que es el que inspira el art. 51 de la Ley de Matrimonio Civil. En consecuencia, si se declara nulo un matrimonio viciado de error de derecho, tal matrimonio no puede ser putativo y no genera efectos válidos. El error, en este caso, entonces, sólo puede ser el de hecho (por ejemplo, uno de los contrayentes ignoraba que el otro tenía un vínculo matrimonial no disuelto).[194] Distinta es la opinión de Manuel Somarriva. Admitiendo que el punto es discutible, considerando lo dispuesto en la posesión, agrega: "Sin embargo, se acepta comúnmente que aun el error de derecho puede traer consigo, como consecuencia, un matrimonio putativo, más que todo con el fin de darle mayor campo de aplicación a esta institución". Luego, después de aludir a varios casos en el Código Civil en los que se admite error de derecho (arts. 1683, 2297 y 1470), concluye: "Si el legislador acepta en estos casos el error de derecho, se dice también que lo puede aceptar en el caso del artículo 122,[195] porque la equidad así lo aconseja. Vemos, pues, que el asunto es muy discutible".[196]

c) *Derogación de las leyes*.

c.1) Concepto.

Consiste la derogación en la cesación de la eficacia de una ley en virtud de otra ley posterior. Se priva a la primera de su fuerza obligatoria, reemplazando o no sus disposiciones por otras.[197] En similares términos la define Ducci: "La derogación es la supresión de la fuerza obligatoria de una disposición legal, ya sea por su reemplazo por otra o por su simple eliminación".[198]

El fundamento de la derogación de la ley lo encontramos en la permanente evolución de la sociedad, la que exige constantemente nuevas formas jurídicas, de acuerdo al momento histórico en que se vive.[199]

Refiere Claro Solar que los romanos designaban con la palabra *derogación* la abolición parcial de la ley, mientras que reservaban la voz *abrogación* para designar la supresión completa de la ley. Hablaban a su vez de *obrogación* para referirse a la simple modificación de la ley y de *subrogación* para aludir a la agregación o complementación de una ley.[200]

En similares términos, Coviello expresa que "La cesación de la eficacia de la ley por fuerza extrínseca no es más que abolición, llamada abrogación, si es total, y derogación, si es parcial".[201]

Como advierte Ducci, "La derogación de la ley corresponde al legislador. Quien tiene la facultad para dictar leyes tiene también la facultad de dejarlas sin efecto. Los particulares no tienen facultad para derogar las leyes. Incluso la no aplicación de una

---

[194] Rossel Saavedra, Enrique (1994), *Manual de Derecho de Familia*, 7ª edición actualizada, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, Nº 78, pp. 58 y 59.
[195] Hoy, art. 51 de la Ley de Matrimonio Civil.
[196] Somarriva Undurraga, Manuel (1936), *Derecho de Familia*, Santiago de Chile, Editorial Nascimento, pp. 103 y 104.
[197] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 269, p. 190.
[198] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 56, p. 59.
[199] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 269, p. 190.
[200] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 308, p. 167.
[201] Coviello, Nicolás (2007), ob. cit., Nº 31, p. 97.

ley por todo el cuerpo social y durante un largo espacio de tiempo, el desuso de la ley, no implican su derogación".[202]

Cabe considerar, con todo, dos casos en el que la derogación o el cese extrínseco de eficacia de una ley no opera en virtud de otra ley que así lo disponga:

i.- Cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de un precepto legal. En este caso, y a pesar de que la propia Constitución señala en su art. 94, inc. 3°, que "el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 o 7 del artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo", a juicio de algunos no estaríamos en rigor ante un caso de derogación, sino de invalidación de una ley, que opera con efectos generales. Aludiremos a este punto en el literal que sigue.

ii.- Cuando se suscriba y ratifique un tratado internacional, que contenga normas inconciliables con alguna ley. Hemos visto que los tratados tienen rango legal, por regla general. Por ende, necesariamente deberá prevalecer la norma posterior por sobre la anterior. Ello, sin perjuicio de que la derogación pueda ser sólo parcial y no total, según se dirá.

Cabe advertir, además, que las categorías de ley *anterior* y de ley *posterior*, no necesariamente remiten a la fecha de promulgación de una y otra, sino que a la de *vigencia* en el ordenamiento jurídico. Incluso, podría ocurrir que la norma anterior derogue a la posterior, en el caso de una convención internacional o tratado, que fuere anterior a la norma interna, pero entre en vigencia en Chile después de la última.

c.2) Clases de derogación.

i.- Derogación expresa, tácita y orgánica.

Esta primera clasificación atiende *a la forma* en que opera.

La derogación puede ser expresa o tácita, conforme lo disponen los arts. 52 y 53 del Código Civil. A las anteriores, la doctrina agrega la derogación orgánica.

La derogación es *expresa*, cuando la nueva ley dice explícitamente que deroga la antigua (por ejemplo, el artículo final del Código Civil).

Es *tácita*, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Se funda en que, existiendo dos leyes contradictorias de diferentes épocas, debe entenderse que la más nueva ha sido dictada por el legislador con el propósito de modificar o corregir la ley más antigua. Con todo, como no debe llevarse esta presunción más allá de su razón y objeto, la derogación tácita, de acuerdo al art. 53, deja vigente todo aquello de las leyes anteriores que no pugne con las disposiciones de la nueva ley.[203] Como previene Ducci, la incompatibilidad entre la ley antigua y la ley nueva debe ser *absoluta*, cuestión que en ocasiones origina dificultades para el intérprete: "En efecto, el artículo 53 del Código Civil dice que la derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. Lo anterior determina la dificultad de establecer a veces si ha existido derogación tácita, porque para ello debe existir incompatibilidad entre preceptos cuyos presupuestos coinciden, es decir, es necesario determinar si existe contradicción entre ellos y no una simple discrepancia".[204]

De inmediato se observa una diferencia radical entre la derogación expresa y la tácita: la primera es declarada por *el legislador*, mientras que la segunda lo será por *el juez* que conozca de un asunto susceptible de resolverse con la ley antigua o con la nueva. Lo anterior, aunque tanto la expresa como la tácita se originan obviamente por la función legislativa. Por eso, expresa Miriam Henríquez Viñas, citando a su vez a

---

[202] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 56, p. 59.
[203] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 272, p. 192.
[204] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 58, p. 60.

Aníbal Bascuñán Rodríguez, que "… la derogación tácita se produce cuando el órgano que debe resolver un caso, y debe fundar su decisión sujetándose al derecho vigente, constata que éste contiene dos soluciones distintas para ese caso, incompatibles entre sí. En opinión del mismo autor, la derogación tácita de la ley anterior no es el efecto de un acto realizado en ejercicio de una potestad normativa, sino los efectos de un complejo de reglas que gobiernan el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Estas reglas obligan al órgano adjudicador a seleccionar de una manera determinada la norma aplicable al caso. Por tal motivo, la derogación tácita de la ley es constatada y declarada por el tribunal en la fundamentación de su sentencia. Por eso supone un acto interpretativo de la norma anterior y la posterior, que identifique sus respectivos sentidos y constate su incompatibilidad entre sí".[205]

Derogación *orgánica* es la que se produce cuando una ley, disciplina toda la materia, que está regulada por una o varias leyes precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de la ley antigua y la nueva. Si el legislador ha reordenado toda la materia, es forzoso suponer que ha partido de otros principios directivos, los cuales, en sus variadas y posibles aplicaciones, podrían llevar a consecuencias diversas y aun opuestas a las que se pretenden si se introdujera un precepto de la ley antigua, aunque no fuera incompatible con las normas de la nueva ley.[206]

Para que tenga lugar la derogación orgánica, es menester que la nueva ley reglamente en forma completa una materia o un organismo dado. El determinar si una materia está o no enteramente regulada por la nueva ley, depende no del mayor o menor número de disposiciones que contiene la ley nueva en relación con la antigua, sino de la intención, revelada por el legislador, de abarcar con las nuevas disposiciones toda una materia.[207]

Muchos autores consideran la derogación orgánica como una especie de derogación tácita, porque dicen que toda ley que viene a reglamentar totalmente una materia regida por otra ley anterior, contiene en sus preceptos una incompatibilidad implícita con cualesquiera otras que versen sobre el mismo asunto.[208]

En todo caso, nuestros tribunales han reconocido, en diversos fallos, la existencia de la derogación orgánica, señalándose que "tratándose de una ley general la posterior deroga a la ley general anterior dictada sobre la misma materia".

En efecto, expresa Carlos Ducci, "Nuestra Corte Suprema ha aceptado la derogación orgánica en ciertas ocasiones. En una sentencia, dictaminó que la ley de municipalidades de 1891 había derogado totalmente la de 1887, respecto de la cual no existía derogación expresa. En otra sentencia resolvió que el Decreto-Ley Nº 790, sobre nombramiento y remoción de los empleados municipales, había derogado el Decreto-Ley Nº 498, pues se trataba de un nuevo cuerpo de leyes, de carácter general como el anterior, dictado sobre la misma materia, reglamentada en su totalidad. Por último, en una sentencia de 4 de octubre de 1938, en que analiza la derogación de las leyes, acepta la existencia de la derogación orgánica, que considera una forma de la derogación tácita, que se va diversificando con el progreso de las instituciones, pero exige que la nueva ley reglamente toda la materia de que se ocupaba la ley anterior".[209]

ii.- Derogación total o parcial.

---

[205] Henríquez Viñas, Miriam (2017), "¿Derogación tácita o inaplicabilidad de preceptos preconstitucionales?", en *Estudios Constitucionales*, año 15, N° 1, 2017, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, p. 310.
[206] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 274, p. 193; Ducci Claro, Carlos, ob. cit., Nº 59, p. 60.
[207] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 274, p. 193.
[208] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 274, p. 193; Corral Talciani, Hernán, ob. cit., p. 96.
[209] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 59, p. 61.

La derogación, en cuanto *a su alcance*, puede ser total o parcial. La derogación total suprime por completo la ley antigua, sea que se limite a establecer la supresión, sea que la reemplace por otras disposiciones. Por la derogación parcial se suprime uno o más preceptos de la ley antigua, sustituyéndolos o no por otros, quedando el resto de las disposiciones vigentes.[210]

Relacionando esta segunda clasificación con la primera, puede concluirse que la derogación expresa puede ser total o parcial. La derogación tácita por regla general es parcial, pero nada obsta a que fuere total. La derogación orgánica sólo podría ser total.

iii.- Derogación o inaplicabilidad a consecuencia de entrar en vigencia una norma de rango superior.

Las clasificaciones anteriores se plantean bajo el entendido que la ley derogada y aquella que la deroga, son normas de la misma jerarquía. ¿Qué ocurre si la nueva norma fuere de rango constitucional, y sus términos son inconciliables con aquellos de una ley precedente? Se comprende que ésta no podría subsistir, habida cuenta de lo preceptuado en una norma de superior jerarquía. Pero la cuestión no es tan simple. Desde ya, tres cuestiones fundamentales se han debatido en la doctrina:[211]

1° ¿Cuál es el *criterio* para solucionar la incompatibilidad entre normas de distinta jerarquía, siendo la norma superior posterior a la norma inferior? Al efecto, las posibles respuestas serían: aplicando un *criterio jerárquico* o aplicando un *criterio cronológico*.

2° ¿Cuál es el *efecto* de aplicar uno u otro criterio? Si se aplica el criterio jerárquico, el efecto será la *inaplicabilidad o inconstitucionalidad* de la norma inferior. Si se aplica el criterio cronológico, el efecto será la *derogación* de la norma inferior.

3° ¿Cuál es el *órgano competente* para resolver el conflicto normativo? Algunos sostienen que la *declaración de inaplicabilidad o de inconstitucionalidad* sólo le compete al *Tribunal Constitucional*. Otros consideran que corresponde a los *tribunales de justicia* declarar la *derogación tácita* de los preceptos preconstitucionales (es decir, de aquellos que encontrándose vigentes al momento de entrar en vigencia la Constitución de 1980 o alguna de sus reformas, quedaron derogados tácitamente por contener normas contrarias al ordenamiento constitucional).

Particularmente complejo es este problema, en lo que respecta a la tercera de estas cuestiones, esto es, en cuanto al órgano competente. En efecto, la Corte Suprema ha dictado varias sentencias, en las que ha declarado tácitamente derogados preceptos legales anteriores a la vigencia de normas constitucionales incompatibles con las primeras. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha reclamado competencia exclusiva y excluyente en la materia, sobre la base que sólo a dicho Tribunal le compete declarar la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de los preceptos legales, ya sean preconstitucionales o postconstitucionales.

Para un sector de la doctrina, el conflicto entre la norma legal anterior y la norma constitucional posterior se resuelve mediante la declaración de inaplicabilidad o inconstitucionalidad de la norma legal por aplicación del criterio jerárquico, siendo competente sólo el *Tribunal Constitucional*. Ello, porque tras la reforma a la Constitución del año 2005, el control de la constitucionalidad quedó concentrado en el Tribunal Constitucional.

Otro sector de la doctrina, postula la posibilidad de que los *tribunales ordinarios* declaren la derogación tácita de los preceptos preconstitucionales. En el marco de esta segunda doctrina, se formula un distingo: si se trata de preceptos *preconstitucionales*, es procede que se declare su derogación tácita por los tribunales ordinarios de justicia. En cambio, si se trata de preceptos *postconstitucionales*, corresponde al tribunal Constitucional declarar su inaplicabilidad. Expresa al efecto Eduardo Cordero: "Así, si la norma es previa [a la vigencia de la Constitución] y ha devenido en inconstitucional, es

---

[210] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 275, p. 194.

[211] Seguimos a continuación el trabajo de la profesora Miriam Henríquez Viñas (2017), ob. cit., pp. 307-328.

claro que la solución será la derogación de la misma, cuya declaración corresponde a todo órgano llamado a aplicar el derecho, como son los jueces de la instancia, en la medida que constatan una consecuencia jurídica que ya se ha producido. En cambio, si la norma es postconstitucional esta posibilidad se ve fuertemente restringida, en la medida que la competencia al efecto queda radicada en el Tribunal Constitucional, tanto para constatar la derogación como para inaplicar la norma legal o anularla, en su caso".[212]

También en el marco de esta segunda doctrina, Julio Rojas sostiene la posibilidad de que se declare la derogación tácita de preceptos preconstitucionales por la jurisdicción ordinaria, conforme a los siguientes argumentos:

1° Procede la aplicación del criterio cronológico por sobre el criterio jerárquico.

2° Es necesario distinguir entre *vigencia* y *validez* de la norma. La norma legal anterior que contradice materialmente a la Constitución debe declararse derogada –y no invalidada-, pues antes que entrare en vigencia la segunda, era vigente y también válida. Mal podría operar una invalidez sobreviniente. La invalidez o la validez sólo pueden ser originarias, nunca sobrevinientes.

3° La fuerza normativa de la Constitución, que obliga a todos los órganos del Estado, y entre ellos a los tribunales ordinarios de justicia, a cumplir y aplicar directamente la Carta Fundamental.

4° La Constitución, como toda norma jurídica, tiene la capacidad de derogar normas jurídicas anteriores de igual o inferior rango, en el caso que la contradigan.[213]

Aún más, en lo que podríamos calificar como la tesis más extrema de la segunda doctrina, Eduardo Aldunate considera que la facultad de los tribunales ordinarios de justicia se extiende también a los preceptos postconstitucionales. Con ello, en lugar de existir un *control concentrado* de la constitucionalidad, este sería un *control difuso*, porque en realidad no sería privativo del Tribunal Constitucional: "No se observa una razón para afirmar que el mismo juez que puede resolver la antinomia en el caso de derogación tácita [de un precepto preconstitucional] no puede realizar la misma operación cuando la misma antinomia opera respecto de la misma Constitución, sólo que respecto de un precepto posterior a la entrada en vigencia de la misma. El argumento que señala que ello se debe al sistema de concentración de control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional pasa por alto que esta magistratura no resuelve, para la respectiva gestión judicial, la antinomia entre Constitución y precepto legal, sino que la elimina, al retirar del universo de fuentes que deberá considerar el juez del fondo, al resolver, el precepto legal cuya aplicación se impugna por inconstitucional. De este modo no se le ha otorgado al Tribunal Constitucional la facultad de resolver estas antinomias y mal podría sostenerse entonces que los jueces del fondo carecen de una atribución, porque ésta se alega entregada al Tribunal [Constitucional], cuando efectivamente no se le ha entregado. Esta solución es precisamente el argumento que tiende a reforzar la idea de que el predicado de fuerza normativa de la Constitución como eficacia directa incluye al derecho constitucional en el sistema de fuentes que debe considerar y resolver cualquier juez, de acuerdo a la idea de control difuso examinado arriba".[214]

Miriam Henríquez, por su parte, señala las siguientes consecuencias, que derivan del hecho que la Constitución sea fuente del Derecho con eficacia directa, y

---

[212] Cordero Quinzacara, Eduardo (2009), "Los principios y reglas que estructuran el ordenamiento jurídico chileno", en *Revista Ius et Praxis*, año 15, N° 2, p. 27, citado a su vez por Henríquez Viñas, Miriam (2017), ob. cit., p. 313.

[213] Rojas Chamaca, Julio (2013), *La derogación tácita de preceptos preconstitucionales por la jurisdicción ordinaria. Análisis jurisprudencial después de la reforma constitucional de 2005*, Santiago de Chile, Editorial Metropolitana, pp. 157-162, citado a su vez por Henríquez Viñas, Miriam (2017), ob. cit., p. 313.

[214] Aldunate Lizana, Eduardo (2009), "La fuerza normativa de la Constitución y el sistema de fuentes del derecho", en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, XXXII, p. 455, citado a su vez por Henríquez Viñas, Miriam (2017), ob. cit., p. 314.

que su garantía jurisdiccional se encuentre, desde la reforma del año 2005, concentrada en el Tribunal Constitucional:
1° Los tribunales de justicia, al decidir el Derecho aplicable, tienen la facultad de declarar derogado un precepto legal *preconstitucional* por su incompatibilidad con la Constitución, aplicando directamente la norma constitucional posterior. Se trataría de un problema de vigencia de normas, resoluble mediante la aplicación del criterio cronológico.
2° El tribunal Constitucional está facultado para verificar la conformidad del precepto legal *postconstitucional* con la norma constitucional superior, ya por la vía de la acción de inaplicabilidad o de la acción de inconstitucionalidad, siendo esta una cuestión de aplicabilidad/validez/constitucionalidad de normas, resoluble conforme al criterio jerárquico, más particularmente de la supremacía constitucional.
3° En ambos supuestos –es decir, sea que se trate de normas anteriores o posteriores a la Constitución-, la norma aplicable con preferencia a la otra es la norma constitucional posterior y superior.
4° Los tribunales de justicia carecen de la potestad para declarar la inaplicabilidad de las normas legales pre y postconstitucionales que contravinieren la Constitución. En un sistema de control concentrado de constitucionalidad como el chileno, la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o de inconstitucionalidad sólo le corresponde al Tribunal Constitucional.
5º Nada obsta a que las partes o el juez de la gestión pendiente requieran al Tribunal Constitucional para que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal preconstitucional, aplicable y decisivo en un caso concreto.[215]

Un ejemplo de la discusión expuesta, encontramos a propósito de algunas de las normas del Decreto Ley Nº 2.695, del año 1979, que "Fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella". Algunas de sus normas, se han considerado, en determinadas circunstancias, como contrarias a la Constitución Política de 1980.

c.3) La derogación en relación con la ley general y la ley especial.

Si con posterioridad a la promulgación de una ley general se dicta una ley especial sobre la misma materia, es indudable que ésta prevalece sobre la primera en todo lo que sean incompatibles. La ley especial deroga las disposiciones de otras leyes generales que no pueden coexistir con las normas de la primera. Lo anterior resulta de la aplicación del principio de la especialidad así como también de los principios de la derogación tácita.[216] Sin embargo, la ley especial no derogará las normas de la ley general, si éstas no son inconciliables con la primera. En tal caso, las normas generales se aplicarán supletoriamente, en lo no regulado por la ley especial (por ejemplo, las normas del Código Civil relativas al contrato de arrendamiento, tendrán aplicación supletoria, para las materias no resueltas en la Ley N° 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos o en el Decreto Ley N° 993 sobre arrendamiento de predios rústicos).

El problema es más complicado cuando a una ley especial sucede una ley general. La mayor parte de la doctrina, apoyándose en el aforismo "la ley posterior general no deroga la ley anterior especial", sostiene que las disposiciones especiales deben ser derogadas expresamente por la ley general posterior. Pero algunos autores (Ruggiero, Coviello), no piensan de la misma manera y estiman que esta es una cuestión de interpretación que se resuelve por el examen, en cada caso, de la intención del legislador. Es posible, sostienen, que la ley general posterior deje en evidencia la determinación de someter a su imperio los casos que se encontraban regidos por la ley especial.[217]

---

[215] Henríquez Viñas, Miriam (2017), ob. cit., pp. 314 y 315.
[216] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 277, p. 195; Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 58, p. 60.
[217] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 277, p. 195.

Como puede observarse, el problema expuesto se plantea en el ámbito de la derogación tácita y de la derogación orgánica.

Refiere Coviello sobre la materia que la abolición indirecta o tácita puede realizarse de dos modos:

i.- "El primero tiene lugar cuando una ley posterior contiene normas jurídicas incompatibles en todo o en parte con las contenidas en una ley anterior; esto es, cuando la aplicación contemporánea de las normas establecidas por las dos leyes es imposible por la contradicción que de allí se seguiría. La ley posterior, por lo demás, es la que ha sido promulgada después de otra (…). La abolición de la ley anterior tiene lugar dentro de los límites de la incompatibilidad, no más allá de éstos. Por lo tanto, la máxima ("*lex posterior derogat priori*") se entiende dentro de ciertos límites que la hacen conciliable con la otra que le es opuesta: "*leges posteriores ad priores pertinent*". Para tal fin, es necesario distinguir cuidadosamente la hipótesis en que una norma de índole general es posterior a otra también general, de aquella en que una ley especial sucede a una ley general y, finalmente, de aquella en que una ley general viene después de la especial. Si a una ley general sucede otra ley también general, la incompatibilidad resulta fácilmente. Pero si a una ley general sucede una de índole especial, no hay incompatibilidad, siendo posible la coexistencia de las excepciones con la regla; sólo que la que antes era regla absoluta se convierte en regla limitada por excepciones. En fin, aun en la hipótesis inversa en que a una ley de índole especial sucede una ley de índole general, se debe creer por la misma razón que no hay incompatibilidad y que la ley antigua continúa rigiendo al lado de la nueva. Pero cuando la nueva regla general esté concebida de modo de excluir cualquier excepción o enumere en forma taxativa las únicas excepciones de que es susceptible, surge evidente la incompatibilidad de la ley especial. Todo depende, pues, del examen de la intención del legislador, por lo cual no siempre es verdadera la máxima '*lex posterior generalis non derogat priori speciali*'".

ii.- "Se tiene el segundo modo cuando una nueva ley disciplina toda la materia regulada por una ley precedente, aunque no haya incompatibilidad entre las normas contenidas en ellas. Y esto por la razón de que si el legislador ha reordenado toda la materia, es necesario suponer que haya partido de otros principios directivos, los cuales en sus variadas y posibles aplicaciones pueden llevar a consecuencias diversas o aun opuestas a las derivadas de la ley anterior: existe siempre por eso una especie de incompatibilidad implícita".[218]

Como puede observarse, en el segundo modo al que alude Coviello, se comprende la "derogación orgánica", que él incluye como una especie de derogación tácita o indirecta.

c.4) Efectos de la derogación de la ley derogatoria.

Una ley derogada no revive por el solo hecho de derogarse la ley derogatoria. Ello, porque:

i.- La nueva ley nada puede haber dispuesto respecto a las situaciones jurídicas disciplinadas por las leyes anteriores, con lo cual lisa y llanamente queda abolida la correspondiente institución jurídica o ésta queda gobernada por normas o principios generales; o

ii.- Si la nueva ley algo dispuso, significa que se aplican sus disposiciones, aun cuando sean idénticas a las disposiciones que a su vez fueron suprimidas por la ley derogatoria, también abolida ahora.

Es necesario, por tanto, que una ley devuelva expresamente su vigor a una ley derogada; la simple abrogación de la ley derogatoria no puede por sí sola dar vida a lo que ya no existe. Y es lógico que así sea, teniendo presente que la ley es una declaración positiva y actual del legislador. En realidad, en este caso se tratará de una

[218] Coviello, Nicolás (2007), ob. cit., Nº 31, pp. 98 y 99.

nueva ley sobre la materia, con un contenido remitido al contenido de la ley que en su oportunidad fue derogada.

Las leyes que vuelven a poner en vigor una ley derogada, reciben el nombre de "restauradoras" o "restablecedoras".[219]

c.5) La derogación indirecta.

Puede ocurrir que se produzca esta especie de derogación, que Corral expresa de la siguiente manera: "La ley Nº 1 se remite para producir efectos a la ley Nº 2, y la ley Nº 3 deroga la ley Nº 2, ¿queda por esto derogada la ley Nº 1? La respuesta nuevamente debe ser negativa: el acto de autoridad sólo se ha producido para la ley expresamente derogada y no para aquella que no ha sido objeto de derogación. Esta seguirá vigente, aunque puede perder eficacia si sus disposiciones no pueden ser aplicadas por falta de contenido que le suministraba, por referencia, la ley derogada".[220]

En realidad, más que un problema de derogación, como lo deja en claro Corral al señalar que la ley en cuestión seguirá vigente, probablemente lo que ocurrirá en el caso descrito es uno de interpretación o de integración de la ley. Así, por ejemplo, el art. 1800 del Código Civil expresa: "Los mandatarios, los síndicos de los concursos,[221] y los albaceas, están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo dispuesto en el artículo 2144". Esta última disposición, está en las normas del contrato de mandato. Si se derogare el último precepto, sería necesario recurrir a otras normas semejantes (interpretación por analogía) o resolver conforme a la equidad natural (integración de la laguna legal "sobreviniente").

d) *Causas intrínsecas que producen la cesación de la eficacia de una ley*.

Si bien la derogación constituye la causa más frecuente de cesación de la eficacia legal, existen otras causas llamadas intrínsecas, porque van implícitas en la misma ley. En estos casos, no es un acto externo –una nueva ley- la que produce el cese de eficacia de la ley, sino que una causa que dimana de los mismos términos de la ley. En algunos casos, dicha causa operará de manera automática, sin necesidad de ningún hecho posterior, y en otros casos se requerirá precisamente de la ocurrencia de un hecho sobreviniente.

Tales causas intrínsecas son:[222]

d.1) *El transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley o el cumplimiento de una condición*. Así, por ejemplo, respecto del plazo, una ley que otorgue ciertos beneficios aduaneros a las empresas que se instalen en zonas extremas del país durante un determinado período. O aquella ley que condone las multas, para quienes regularicen ante la respectiva Dirección de Obras, dentro de un cierto plazo, las construcciones erigidas en sus viviendas, sin haber obtenido previamente el pertinente permiso de edificación. Pero también puede tratarse de una condición. Así, por ejemplo, una ley de emergencia que se dicta y entra en vigencia mientras subsista una pandemia; o aquella ley que se dicta y aplica mientras persista un estado de guerra y que se extinguirá cuando cese el mismo.

d.2) *La consecución del fin que la ley se propuso alcanzar*. Así, por ejemplo, la ley que dispuso una pensión de gracia a los veteranos de la Guerra del Pacífico y a sus hijas solteras, cesó su eficacia al fallecer la última de tales hijas; o una ley que autoriza una

---

[219] Coviello, Nicolás (2007), ob. cit., Nº 31, pp. 100 y 101; Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 278, pp. 195 y 196; Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 60, p. 61; Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 97.

[220] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 97.

[221] Hoy, los "liquidadores" a cargo del respectivo procedimiento concursal, conforme a la Ley Nº 20.720.

[222] Coviello, Nicolás (2007), ob. cit., Nº 31, p. 99.

expropiación por causa de utilidad pública, pierde su vigencia una vez materializada dicha expropiación. El fin para el cual fue dictada esa ley ya se cumplió.
d.3) *La desaparición de una institución jurídica, o la imposibilidad de un hecho que era presupuesto necesario de la ley*.[223] Así, por ejemplo, habiendo sido derogada la pena de muerte (salvo para el ámbito del Derecho penal militar), todos los preceptos que partían de la base de su existencia, dejaron por esa sola circunstancia de producir efecto. O en un futuro no muy lejano, es dable suponer que cesará la eficacia de las normas contemplas en la Ley del Tránsito, que se refieren a quienes conducen carruajes arrastrados por animales en vías urbanas. También ocurriría lo anterior en el caso de que se eliminare el régimen de sociedad conyugal, caso en el cual todas las normas que la regulan, cesarán en su eficacia.[224]

e) *Efecto inmediato, efecto retroactivo y ultra-actividad de la ley*.[225]

e.1) Aspectos generales.

Respecto a la vigencia y obligatoriedad de la ley, pueden distinguirse tres períodos:
i.- El período que media entre la entrada en vigor de la ley y la derogación de la misma.
ii.- El período anterior a la entrada en vigor de la ley; y
iii.- El período posterior a su derogación.[226]

Normalmente, una ley es obligatoria desde el día en que se publica o desde una fecha posterior que la misma ley establece y su vigencia se extiende hasta que es derogada por otra ley o transcurre el plazo o acaece el hecho que fija su extinción. La ley rige todos los hechos y actos que se realizan durante el período determinado.[227]

Los hechos, relaciones o situaciones jurídicas que han surgido y producido todos sus efectos bajo el imperio de la ley antigua, no son, naturalmente, alcanzados por la nueva norma. Pero el problema se presenta con respecto a los hechos, relaciones o situaciones jurídicas que han surgido al amparo de una ley y que por cualquiera razón vienen a desarrollarse o a producir todos o algunos de sus efectos cuando dicha norma ya no rige y tiene imperio otra. En estos casos, cabe preguntarse entonces qué ley debe aplicarse, si la antigua o la nueva.[228]

Refería Claro Solar sobre la materia: "Una ley nueva reemplaza a otra relativa al mismo asunto. La ley antigua rige sola, naturalmente, los actos jurídicos que se han realizado definitivamente con todos sus efectos bajo su imperio, sin que la nueva ley pueda afectarlos en ningún sentido. Del mismo modo esta última ley regirá con exclusión de la antigua los actos que no estaban comenzados bajo el imperio de ésta y que, por consiguiente, se cumplen en su totalidad bajo el imperio de la ley nueva. Pero como un acto jurídico realizado bajo el imperio de la antigua ley puede producir consecuencias que vengan a desarrollarse bajo el imperio de la ley nueva, se presenta la duda sobre qué ley regirá esas consecuencias. Si desde el instante en que la nueva ley se hace obligatoria debieran cesar todos los efectos de la ley antigua; si la demarcación entre el imperio de la antigua y de la nueva ley fuera tan clara y deslindada como el muro divisorio de dos predios colindantes, nada más sencillo que la aplicación de las leyes. Pero los actos que han nacido a la vida civil bajo una legislación no desaparecen con ella, quedan vivos y produciendo efectos y consecuencias que es

---

[223] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 279, p. 196.
[224] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 61, pp. 61 y 62.
[225] Cfr. Vodanovic, Antonio (1990), ob. cit., p. 214; y Figueroa Yáñez, Gonzalo (2015), *Curso de Derecho Civil*. Tomo I, 5ª edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, p. 168.
[226] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 311, p. 213.
[227] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 312, p. 213.
[228] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 313, p. 213.

importante saber por qué ley deberán regirse en este conflicto de dos leyes sucesivas que pretenden imperar sobre ellos".[229]

El art. 9 del Código Civil contiene al respecto un precepto universalmente aceptado: la ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo.

Dos reglas, contiene el precepto:

i.- La ley dispone para el porvenir: rige todos los actos y situaciones que se produzcan con posterioridad a su vigencia;

ii.- La ley nada dispone sobre los hechos pasados, realizados con anterioridad a su vigencia: esta segunda regla, constituye el principio de la no retroactividad de la ley.

Cuando la ley nueva alcanza con sus efectos al tiempo anterior a su vigencia, internándose en el dominio de la norma antigua, se dice que tiene *efecto retroactivo*, porque una ley vuelve sobre el pasado.[230]

Cuando la ley nueva rige ella sola, exclusivamente, desde el día en que entra en vigor, todos los actos y situaciones que se produzcan en el futuro, hablamos de *efecto inmediato* de la ley. En dicho contexto, la ley nueva no permite la subsistencia de la ley antigua, ni siquiera para las situaciones jurídicas nacidas en el tiempo en que ésta última regía. Los efectos de tales relaciones jurídicas, que se produzcan después de entrar en vigencia la nueva ley, se regirán por ésta, en virtud del señalado efecto inmediato.[231] Las leyes procesales, suelen tener efecto inmediato.

La regla general es el efecto inmediato de la ley. Lo excepcional es el efecto retroactivo.

Sin embargo, la ley antigua, a pesar de haber sido derogada, continúa rigiendo aquellos contratos celebrados bajo su vigencia. En este caso, entonces, no hay efecto inmediato de la ley nueva, sino que *ultra-actividad*[232] de la ley antigua.

En relación a la ultra-actividad y al efecto inmediato de la ley, cabe destacar la Ley Nº 5.001, publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 1931, que dispuso en su art. 1º que la renta de arrendamiento de los predios urbanos y rústicos debía ser pagada, durante su vigencia, con una rebaja del 20% con relación a la que el mismo arrendatario pagaba el 1º de enero de 1931. Esta ley, afirma Vodanovic, operó con efecto retroactivo, pues la situación establecida por los contratos de arrendamiento, con anterioridad a la promulgación de la ley, vino a ser modificada.[233] Disentimos de esta conclusión de Vodanovic. A nuestro juicio, esta ley no tuvo un efecto *retroactivo*, pues no afectó las rentas devengadas entre el 1º de enero de 1931 y el 13 de noviembre del mismo año, sino que más bien, a partir de esta última fecha, tuvo efecto *inmediato*, desconociendo la *ultra-actividad* de la ley que regía al momento en que se celebraron los respectivos contratos de arrendamiento. Una norma de esta índole con seguridad sería tachada en nuestros días de inconstitucional, pero debemos entenderla en el contexto de la época, cuando nuestro país fue severamente golpeado, con dos años de desfase, por la crisis del año 1929, ocasionando a la postre la caída del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo el 26 de julio de 1931.

e.2) Justificación de la irretroactividad.

Las razones que han determinado el establecimiento de este principio se relacionan directamente con la *seguridad jurídica*. Ninguna seguridad y confianza tendrían los particulares si su patrimonio, su condición personal y los efectos de sus actos y contratos fueran a cada instante puestos en discusión, modificados o suprimidos por un cambio de parecer del legislador. El interés general, exige que lo

---

[229] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 107, pp. 60 y 61.
[230] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 314, p. 214.
[231] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 314, p. 214.
[232] En la literatura jurídica, se habla de "ultractividad" o de "ultraactividad" de la ley. Hemos optado por emplear una tercera fórmula, "ultra-actividad", que nos parece más precisa.
[233] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 319, p. 216.

hecho regularmente bajo una ley, sea considerado válido e inamovible, no obstante la mudanza de legislación.[234]

El principio de la irretroactividad, destaca Corral, se aplica también a las normas de la potestad reglamentaria dictadas por el Poder Ejecutivo. Conforme a la Ley Nº 19.880 de 2003, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, "salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros" (art. 52).[235]

e.3) Justificación del efecto inmediato de la ley.

Como expresa Vodanovic, éste es un tema más controvertido. Algunos justifican este efecto bajo la premisa de que la ley nueva debe considerarse mejor que la antigua. Si el legislador modifica las normas y las reemplaza por otras, es porque considera que las nuevas darán una mejor solución a la materia por ellas regulada. Ello explica que se ejecuten en forma inmediata. Para otros, se trata simplemente de que prevalezca la voluntad legislativa, conforme a la delegación de facultades que le ha hecho la nación y que se consagra en la Constitución. Paul Roubier proporciona la siguiente explicación, que a juicio de Vodanovic parece la más acertada: "Nosotros vivimos bajo el régimen de la unidad de legislación y no se concibe que leyes diferentes puedan regir simultáneamente situaciones jurídicas de la misma naturaleza, porque ello constituiría un peligro para el comercio jurídico. El efecto inmediato se justifica también, pues, por una necesidad de seguridad jurídica".[236]

e.4) Justificación y límites de la ultra-actividad de la ley y dudas que ella genera.

Como se ha señalado, la ultra-actividad de la ley se produce cuando no obstante derogarse o modificarse un precepto legal, y usualmente entrar en vigencia un nuevo cuerpo legal, continuará rigiendo el que fue derogado o fue modificado, para aquellos contratos celebrados con antelación a la derogación o reforma legal, cuyos efectos en todo o en parte, se producen bajo el imperio de la nueva legislación. El fundamento de la ultra-actividad de la ley es la *seguridad jurídica*, considerando que las partes, al momento de contratar, lo hicieron teniendo presente un determinado estatuto jurídico que la ley establecía para la relación jurídica que originan. Se contrapone a la seguridad jurídica, la supuesta mayor justicia que se entiende ínsita en la nueva regulación legal.

Como es evidente, la aplicación de la normativa antigua ira extinguiéndose progresivamente, a medida que los contratos celebrados bajo su vigencia, se vayan terminando. Así, llegará un momento en que prevalecerá sólo la ley nueva, para aquellos contratos acordados durante su vigencia. Pero cuando ésta a su vez sea derogada o reformada, volverá a aplicarse la ultra-actividad para estos otros contratos.

Como expresa Beatriz Escudero de Quintana, "Siempre que se produce una modificación legislativa, se encuentran en pugna dos valores jurídicos: la justicia y la seguridad, que deben ponderarse en forma prudente y equilibrada para brindar la mejor solución de derecho transitorio. Por un lado, parece en cierta forma injusto aplicar los nuevos preceptos a relaciones jurídicas originadas antes de la vigencia de la ley, en atención a que los interesados no pudieron haber ajustado su conducta a una norma no existente. Pero, por otro, debe presumirse siempre la mayor justicia de la nueva norma, su mayor adecuación a las nuevas relaciones sociales, su mayor eficiencia y eficacia para regular la vida en comunidad, por lo que ella debe ser aplicada con la mayor extensión posible".[237]

---

[234] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 315, pp. 214 y 215.
[235] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., pp. 128 y 129.
[236] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 316, p. 215.
[237] Escudero de Quintana, Beatriz (2016), "La ultraactividad de las leyes en materia contractual. Análisis del último párrafo del artículo 7 del Código Civil y Comercial", en *Cuadernos Universitarios*, Publicaciones Académicas de la Universidad Católica de Salta (Argentina), núm. 9, 2016, p. 54.

En efecto, refiriéndose Escudero a la sustitución en la República Argentina del "Código de Vélez" por el nuevo "Código Civil y Comercial", acaecida en 2015, expresa: "Cuando se opera un cambio legislativo, especialmente de la trascendencia del acaecido el 1 de agosto de 2015 (…) surge la necesidad de determinar: a) hasta cuándo rige la ley vieja; b) desde cuándo rige la nueva disposición legal; c) qué norma regula las relaciones y situaciones jurídicas en curso".[238]

El problema de la ultra-actividad, dice relación a la tercera de las cuestiones formuladas: ¿qué ley debe regir las relaciones y situaciones en curso, y especialmente, los contratos celebrados antes de la mudanza legislativa?

En el Código de Vélez, la cuestión se regulaba en su art. 3 (que había sido modificado por la Ley Nº 17.771), del siguiente tenor: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. / A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias".

En el actual Código Civil y Comercial argentino, se mantuvo la norma, en su art. 7, pero con una limitación referida a los contratos de consumo: "Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. / Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. / Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".

En la doctrina argentina, tradicionalmente se ha entendido que las "leyes supletorias" corresponden a las "leyes disponibles", es decir, a las que los contratantes, conforme a la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, pueden modificar o incluso excluir de su relación contractual. Por oposición, están las "leyes imperativas" o "leyes indisponibles", es decir, aquellas que se imponen por sobre la voluntad de los contratantes y que éstos no pueden dejar de cumplir en su relación contractual. Sin embargo, debe tenerse presente lo expuesto por Guillermo A. Borda, en cuanto distingue entre leyes *supletorias* y leyes *dispositivas*. Por lo tanto, para éste autor, lo dispuesto en el inc. 3º del art. 7, sólo rige para la primera clase de leyes y no para la segunda clase de leyes. Nos remitimos a lo que señalamos a propósito de la clasificación de las leyes.

Revisemos precisamente los comentarios de Borda, a la norma del antiguo Código Civil trasandino, que, en lo esencial, se replicó en el actual Código Civil y Comercial, de manera que lo expresado respecto del antiguo art. 3, es perfectamente aplicable al actual art. 7. En nuestra opinión, estas reflexiones, también son perfectamente aplicables al Derecho chileno, conforme a lo que más adelante se dirá: "El primer párrafo sienta el principio de que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes deben aplicarse con la máxima extensión. No sólo ya a los hechos y relaciones futuros, sino también a los que hayan nacido al amparo de la ley anterior y se encuentren en plena vigencia al dictarse la nueva ley". Se trata por ende del efecto inmediato de la ley.

La norma, agrega Borda, alude a dos hipótesis: "a) En primer lugar, las llamadas *situaciones jurídicas generales*, es decir, aquellos derechos que son regulados por la ley (y no por la voluntad de las partes) y que son uniformes para todos. Como ejemplos más importantes podemos citar los derechos reales, los derechos de familia, las leyes administrativas. En su contenido, el derecho de propiedad, el derecho de

[238] Escudero de Quintana, Beatriz (1993), ob. cit., p. 54.

patria potestad, los derechos conyugales, son iguales para todos. La nueva ley se aplica a todos esos derechos y a todos los modifica desde su entrada en vigencia. b) "En segundo lugar, las *relaciones particulares* derivadas de los contratos (…). La regla general, sentada en el primer párrafo del artículo 3º, es que también los contratos caen bajo el imperio de la nueva ley, desde su entrada en vigencia. Pero esta regla es sólo aplicable a las leyes imperativas; si, por el contrario, la ley es supletoria, sólo se aplica a los contratos acordados con posterioridad a la vigencia de la ley, pero no los que se encuentran en curso de ejecución (último párrafo, art. 3º). Es razonable que así sea: las leyes supletorias tienen la misión de suplir la voluntad de las partes, cuando éstas no la han manifestado; pero los contratantes pueden apartarse de sus disposiciones, modificarlas y derogarlas. En caso de que los contratantes callen es cuando estas normas tienen vigencia. Es evidente, por tanto, que ellas forman parte del contrato; que las partes han callado porque la ley preveía lo que ellas querían estipular y porque acordarlo en el contrato, hubiera sido una estipulación sobreabundante e inútil. Por consiguiente, si una reforma legislativa altera los preceptos supletorios de un contrato dado, los contratos en curso deben ser juzgados por la vieja ley, que forma parte de ellos; en realidad, lo que se respeta no es la vieja ley, sino la voluntad de las partes. Es claro que si la nueva ley da carácter imperativo a las normas que sustituyen los viejos preceptos supletorios, debe aplicarse de inmediato a los contratos en ejecución, porque en tal caso la nueva ley no permite el libre juego de la autonomía de la voluntad, allí donde la anterior lo permitía. Es dentro del campo en el que la nueva ley sigue respetando la voluntad de las partes y precisamente por eso, por integrar el acuerdo de voluntades, que la ley supletoria anterior sigue en pie. Es necesario puntualizar, empero, que el último apartado del artículo 3º se aplica sólo a las leyes supletorias propiamente dichas, pero no a las *dispositivas*, es decir, a aquellas que no obstante ser derogables por las partes, se dictan teniendo principalmente en mira los intereses generales (…). Por no haber formulado esta distinción con el debido rigor, algunos tribunales han caído en el error de aplicar la vieja ley en materia de mora o de pacto comisorio que son casos típicos de leyes dispositivas que se dictan teniendo en mira el interés general y deben por tanto aplicarse de inmediato".[239]

Luego, se hace cargo Borda del aspecto más complejo de la ultra-actividad de la ley, como es el respeto a las *garantías constitucionales*. El punto tiene la mayor importancia, pues la Constitución (tanto la argentina como la chilena), consagra la inviolabilidad del derecho de propiedad, y éste puede recaer sobre las cosas incorporales, y entre ellas, sobre los derechos que un contrato confiere a las partes contratantes (en la Constitución argentina, en el art. 17, en términos generales; en la Constitución chilena en el art. 19, Nº 24, en forma explícita). ¿Tales derechos son *intangibles*, de manera que la nueva ley no podría afectarlos en ningún sentido? ¿Pueden ser afectados *en algún grado* por la nueva ley? La respuesta no es tan sencilla. Expresa el autor: "El tercer párrafo del artículo 3º dispone que la retroactividad establecida por ley, en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Este principio se vincula con la jurisprudencia de la Corte Suprema, según la cual las nuevas leyes no pueden afectar derechos adquiridos de orden patrimonial. La nueva disposición acoge en lo sustancial la jurisprudencia de la Corte, pero le introduce dos variantes importantes: prescinde del concepto equívoco y erróneo de derechos adquiridos y extiende el alcance de la excepción a todo derecho amparado por garantías constitucionales. Advirtamos que el artículo 3º se limita a establecer que no podrá afectarse retroactivamente un derecho amparado por la Constitución. En verdad, el concepto es más amplio. Un derecho protegido por la Constitución no puede ser afectado ni por leyes retroactivas ni por leyes que dispongan

[239] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., ob. cit., Nºs. 149-150 bis, pp. 161-163.

para lo futuro. Ello no significa que tales derechos deban mantenerse impolutos y que la ley no pueda modificarlos. Los puede modificar siempre que no los desnaturalice, que mantenga su esencia, que es lo que interesa conservar".[240]

Como puede observarse, en el planteamiento de Borda, la protección a las garantías constitucionales se extiende a lo *esencial*, pero no al derecho en su integridad, pues *lo no esencial* del derecho puede verse afectado por la mudanza legislativa. La dificultad, como es visible, dice relación a definir qué es aquello que no resulta esencial al derecho garantido por la Carta Fundamental.

Refiriéndose luego a la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina acerca de los derechos adquiridos de orden patrimonial, señala: "Dijimos ya que la Corte Suprema ha declarado que el Congreso no puede dictar leyes que afecten derechos adquiridos de orden patrimonial, porque, en tal caso, se vería afectada la garantía constitucional de la propiedad. Se trata, como se ve, de una importante limitación a las atribuciones del Poder Legislativo, ya que le está vedado legislar retroactivamente en un vasto sector jurídico, como es el patrimonial. Esta jurisprudencia se presta a serios reparos; aplicada rigurosamente hubiera trabado totalmente el progreso y la evolución del derecho en materia patrimonial, puesto que, según lo hemos dicho, toda ley nueva afecta derechos nacidos o adquiridos al amparo de la anterior. Por eso se ha dado la curiosa situación de que, mientras la Corte insiste constantemente en su declaración de que las leyes no pueden afectar derechos adquiridos patrimoniales, ha debido reconocer la constitucionalidad de numerosas leyes, no obstante la circunstancia de que los afectaban claramente (…). La Corte no ha precisado qué entiende por derecho adquirido (…). No obstante, en algunos fallos ha resuelto que debe considerarse que hay derecho adquirido siempre que esté reconocido en un contrato o en una sentencia firme. Pese a tan enfática declaración, el Alto Tribunal hubo de reconocer la constitucionalidad de leyes que afectaban derechos nacidos de un contrato y aun de una sentencia firme".[241]

Entre tales casos, Borda menciona:

i.- Las leyes de emergencia, es decir, "aquellas dictadas en circunstancias económicas o sociales excepcionales, que hicieran necesaria la adopción de medidas extraordinarias". Borda critica esta hipótesis, pues "Si la Corte considera que una determinada ley viola una norma constitucional, como es la garantía de la propiedad, debe declararla inválida, no obstante cualesquiera sean las circunstancias económicas o sociales".

ii.- La Corte Suprema debió declarar la constitucionalidad de leyes que afectaban derechos adquiridos contractualmente y que no tenían el carácter de leyes de emergencia: "Por lo pronto, era difícil calificar a la legislación sobre arrendamientos agrícolas como de emergencia, pues no había tal estado de emergencia, sino la prórroga lisa y llana de los contratos por motivos sociales que el legislador reputó suficientes. Y no obstante que afectaba los derechos de los propietarios, adquiridos contractualmente, la Corte la declaró válida. Lo mismo ha ocurrido con importantísimas y muy numerosas leyes obreras. Toda nueva ley obrera, aplicada a los contratos de trabajo en curso de ejecución en el momento en que aquélla se pone en vigencia, afecta evidentemente los derechos adquiridos de los patrones o de los obreros, al modificar las condiciones del contrato en sentido más gravoso para ellos. Y sin embargo, como no podía ser de otra manera, se las ha declarado constitucionales. Finalmente, la Corte declaró válida la ley de alquileres que autorizó la suspensión del lanzamiento aun después que exista sentencia definitiva de desalojo, lo que implica afectar radicalmente un derecho patrimonial adquirido por sentencia firme. Pero salvo este caso excepcional, prevalece en la jurisprudencia de la Corte el criterio de que sólo

---

[240] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., ob. cit., Nº 152, p. 165.
[241] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., ob. cit., Nºs. 157 y 158, pp. 168 y 169.

cuando no hay sentencia definitiva puede aplicarse una nueva ley al caso, sin vulnerar la garantía constitucional de la propiedad".[242]

Concluye Borda expresando que más que recurrir a la teoría de los derechos adquiridos, que sólo tiene rango legal, lo que debe hacerse es invocar la protección constitucional de la propiedad. De esta manera, en lugar de fundar la sentencia respectiva en el art. 3 del antiguo Código –hoy art. 7 del nuevo Código-, debe invocarse la norma constitucional de la inviolabilidad del derecho de propiedad. Sin embargo, de sus planteamientos se desprende que esta protección no es absoluta, sino que circunscrita a lo esencial del derecho de propiedad: "Es indudable que el derecho de propiedad que la Constitución protege, no se ve lesionado porque *cualquier* derecho adquirido al amparo de la legislación anterior sea afectado por la nueva. Al garantizar la propiedad, sin duda no ha sido el propósito cristalizarla, momificarla, conservarla indiferente a todo cambio y toda evolución. Lo que ha querido es proteger ese derecho frente a toda ley que lo afecte sustancialmente, lo desnaturalice. Y los jueces deben estar atentos contra estos ataques, pues son ellos los custodios de ese derecho –como de todos los otros garantizados por la Constitución- que es uno de los pilares de nuestra organización social y política. Cuando la propiedad se vea realmente afectada, la Corte debe declarar inconstitucional la ley, sin preocuparse de que tenga efectos retroactivos o disponga sólo para el futuro. No era, por consiguiente, necesario que la Corte Suprema recurriera a la vieja teoría de los derechos adquiridos para proteger la propiedad; bastaba con atenerse a la garantía constitucional, para mantener en su integridad aquel derecho".[243]

En lo que concierne al Derecho chileno, la primera norma que debemos destacar es la del art. 19, Nº 24 de la Constitución: "La Constitución asegura a todas las personas: (…) 24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. (…) Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador".

Queda en claro que la garantía constitucional protege también el dominio sobre derechos, es decir sobre "cosas incorporales". De esta manera, las partes que han celebrado un contrato, han adquirido el dominio de los derechos personales o créditos que de él emanan.

Ahora bien, la norma transcrita garantiza el derecho de propiedad en tres sentidos:

i.- Nadie, en caso alguno, puede ser privado de *su derecho* de propiedad.

ii.- Nadie, en caso alguno, puede ser privado *del bien* sobre el que recae su derecho de propiedad.

iii.- Nadie, en caso alguno, puede ser privado de alguno *de los atributos o facultades esenciales* del dominio.

Todo lo anterior, a menos que se apruebe una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. Caso en el cual el sujeto pasivo de la expropiación tendrá derecho a indemnización por "el daño patrimonial efectivamente causado".

Luego, en un rango legal, debemos tener presente el art. 22, inc. 1º de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, al que más adelante haremos referencia: "En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración".

---

[242] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., ob. cit., Nº 158, pp. 169 y 170.
[243] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., ob. cit., Nº 182, pp. 187 y 188.

Tal es entonces el marco constitucional y legal que permite la ultra-actividad de la ley, respecto de los contratos celebrados bajo la vigencia de una ley que más tarde es derogada o modificada. Ahora bien, en el Código Civil chileno, no existe, tratándose de contratos actualmente en curso, ninguna norma semejante a la del art. 7 del Código Civil y Comercial argentino, que distinga entre normas *supletorias* y normas *imperativas*. O lo que sería lo mismo: entre normas de *orden privado* y normas de *orden público*.

Pero como se ha señalado, el art. 19, Nº 24 de la Constitución, sí alude a "los atributos o facultades *esenciales* del dominio". A contrario sensu, la garantía constitucional del derecho de propiedad no ampara los atributos o facultades *accidentales* del dominio. Aquí radica, precisamente, la cuestión medular del problema: es decir, discernir cuándo una ley afecta *esencialmente* un derecho, y con ello vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad, y cuándo lo afecta de manera *accidental*, y en tal caso no transgrede dicha garantía. En otras palabras: cuándo la nueva ley *no desnaturaliza* o por el contrario *sí desnaturaliza* el derecho.

¿Qué podríamos entender como "atributos o facultades esenciales" del dominio? Lo esencial, es aquello más importante, lo principal. Es lo fundamental, en oposición a lo que es accesorio o accidental. Ahora bien, la cuestión fue tratada entre los integrantes de la "Comisión de Estudios de la Nueva Constitución". La conclusión fue que la esencia del derecho de propiedad está constituida por las facultades que este confiere, es decir las facultades de *uso*, de *goce* y de *disposición* material y jurídica.

Adicionalmente, debe tenerse presente lo dispuesto en el art. 19, Nº 26 de la Constitución Política, que establece: "La constitución asegura a todas las personas: (…) 26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".

De esta manera, la Constitución reitera que un derecho garantido por ella no puede afectarse "en su esencia", al regularlo un precepto legal.

Conforme a lo expuesto, podemos afirmar lo siguiente: todo derecho, como el de propiedad, se escinde o despliega en un conjunto de facultades. De éstas, las tres que son esenciales al dominio son la de uso, goce y disposición. Tales facultades articulan la *esencia* del derecho. Por lo tanto, una ley posterior que afecte alguna de estas facultades y por ende la esencia del derecho, ya incorporado en el patrimonio de su titular, debe ser objetada por vulnerar la Constitución.

Esta doctrina, por lo demás, ya había quedado asentada bajo la vigencia de la Constitución Política de 1925. En ella, la garantía constitucional del dominio se consagraba en el art. 10, Nº 10, en el que se declaraba que se aseguraba a todos los habitantes de la República "el derecho de propiedad en sus diversas especies" (texto fijado por la Ley Nº 16.615 de 20 de enero de 1967): "En la discusión del Proyecto, don Romualdo Silva Cortés dejó testimonio que la disposición del artículo 10 Nº 10 comprende 'el concepto de dominio y de otros derechos reales y personales respecto de una cosa, mueble o raíz, corporal o incorporal … la garantía se extiende a todos'". Esto fue ratificado por la Corte Suprema en diversas oportunidades. Así, por sentencia de 6 de mayo de 1964, se declaró que la garantía constitucional se refiere tanto a los derechos reales como a los personales. En otro fallo, de la misma Corte, de 9 de enero de 1952, se puntualizó que la garantía constitucional del dominio abarca todos los poderes o facultades que integran este derecho, sin que exista razón para restringirla a la nuda propiedad solamente, esto es, a un dominio que conservaría como único atributo el de disposición de la cosa, despojado de las facultades de goce.[244]

---

[244] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 76.

Se trata pues de una doctrina firmemente asentada en nuestra tradición constitucional, y es de esperar que el Constituyente la conserve, en la Constitución que reemplazará a la vigente de 1980/2005.

Revisemos un ejemplo: Juan es titular de un crédito en contra de Pedro, por diez millones de pesos. Dicho capital devenga intereses a una tasa del 1% mensual. Las facultades esenciales de este derecho personal o crédito se despliegan de la siguiente manera: la facultad de uso, consistirá aquí en cobrar el capital y los intereses y obtener con ello el pago. Al cobrar –supuesto que Juan tenga un título ejecutivo-, podrá solicitar el embargo de bienes de su deudor. Luego, podrá pedir la venta forzada de dichos bienes. Esta facultad, se vuelve a escindir entonces en tres facultades: persecución de los bienes, venta forzada y pago con el producto del remate (arts. 2465 y 2469, derecho de prenda o de garantía general). La facultad de goce, se concreta en el derecho que tiene el acreedor para cobrar los intereses que devengue este capital. Finalmente, la facultad de disposición consistirá en la cesión del crédito, o en renunciar a él (condonarlo) o en gravarlo con una prenda.

De esta manera, la secuencia sería: derecho personal (sobre el cual se tiene dominio) → facultades esenciales que definen el contenido del derecho (usar, gozar y disponer de este derecho personal) → facultades que definen el contenido de las facultades esenciales.

Si una ley afecta al derecho personal en cualquiera de estas facultades esenciales o en alguna de las facultades en que a su vez se dividen tales facultades esenciales, vulnerará la garantía constitucional amparada por los números 24 y 26 del art. 19. Tal ocurriría, por ejemplo, si una ley dispone que el acreedor no podrá embargar bienes de su deudor, no obstante tener título ejecutivo, o que no podrá solicitar, después del embargo, la venta forzada de dichos bienes en pública subasta. O si dispusiere que el acreedor sólo podrá cobrar un interés mensual del 0,5% mensual y no del 1% mensual, o si prohibiere enajenar el crédito.

En cambio, la ley posterior sí podría afectar facultades accidentales del derecho, es decir no esenciales. Así, por ejemplo, puede modificarse el plazo de prescripción de la acción para cobrar el crédito (cuestión resuelta, como veremos, en el art. 25 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes) o las reglas atinentes a las formalidades del procedimiento judicial, por ejemplo, al aumentar de 4 a 10 días el plazo del ejecutado para oponer excepciones (cuestión resuelta en el art. 23 de la misma Ley).

En nuestra doctrina, Vodanovic, basándose en la teoría de Paul Roubier, a la que nos referiremos más adelante, expresa que "El efecto inmediato es la regla; pero hay que considerar una excepción tradicional y muy importante, que Roubier justifica en virtud del mismo fundamento de la regla. El efecto inmediato de la ley, que tiende a asegurar la unidad de la legislación, no afecta a los contratos, los cuales constituyen, por su esencia, instrumentos de variedad jurídica. Las leyes nuevas no producen efectos sobre los contratos vigentes. Pero la excepción sólo tiene lugar en la medida en que los contratos representan instrumentos de diferenciación, o sea, en la medida en que su contenido queda entregado a la voluntad creadora de los individuos; los que no tienen otro efecto que provocar la aplicación de un estatuto legalmente establecido, quedan sometidos a la nueva ley desde su entrada en vigor. Así sucede con los contratos del Derecho de Familia: matrimonio, adopción, etc.; la ley nueva que modifica los efectos o los modos de disolución del matrimonio, se aplica inmediatamente a los matrimonios anteriormente celebrados".[245]

Volveremos más adelante sobre este problema.

e.5) El principio de la irretroactividad ante el legislador.

Entre nosotros, en materia civil, el principio de irretroactividad se halla consagrado en el Código Civil y no en la Constitución. Por lo tanto, no puede obligar al

[245] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 328, p. 222.

legislador, ya que éste sólo está subordinado a la Constitución.[246] Si el legislador puede derogar una ley, puede también dictar leyes retroactivas.[247] En otras palabras, "el Código, con toda su autoridad como libro jurídico, no tiene más fuerza ni jerarquía que una ley común. Si otra ley dispone que será retroactiva, se produce una derogación tácita o una ley especial que debe prevalecer por sobre la general del Código".[248]

Distinto es el caso en materia penal, conforme al Nº 3 del art. 19 de la Constitución, precepto que dispone que nadie puede ser juzgado sino por un tribunal establecido con anterioridad y que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. De tal forma, en materia penal la ley desfavorable al inculpado será inconstitucional si es retroactiva. A contrario sensu, la ley más favorable beneficiará tanto al inculpado como al condenado y podrá en consecuencia tener efecto retroactivo (art. 18 del Código Penal).[249]

En materia civil, existe sin embargo una prohibición indirecta a la retroactividad, de rango constitucional: es la norma del Nº 24 del art. 19 de la Constitución, que consagra la protección del derecho de propiedad. Reiterando lo dicho acerca de este precepto, nadie puede ser privado de su dominio, del bien sobre el que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales de ese derecho, sino por expropiación por causa de utilidad pública, y pagando al afectado la pertinente indemnización. En consecuencia, cualquiera ley que atentare contra el derecho de dominio habido bajo el imperio de una ley anterior, será inconstitucional. Cabe subrayar que esta protección no sólo se extiende a las cosas corporales, sino que también a las cosas incorporales, es decir a los derechos, sean estos reales o personales.[250] De esta manera, por ejemplo, si se publica y entra en vigencia una ley con fecha 1 de diciembre, y en ella se establece que las rentas anuales de arrendamiento de predios urbanos no podrán exceder del 11% del avalúo fiscal del inmueble, y que esta limitación se entenderá vigente desde el 1 de enero del mismo año (once meses antes por tanto), la ley será retroactiva y afectará el derecho adquirido del arrendador sobre las rentas que se le pagaron, por sobre el límite ahora establecido por la ley. Todavía más, la ley nueva tampoco podría aplicarse a los contratos actualmente en curso, es decir no es pertinente darle efecto inmediato, pues afectaría igualmente a un derecho adquirido. En efecto, el derecho del arrendador a percibir las rentas futuras del contrato, ya ha nacido, ya se ha radicado en su patrimonio, aunque por ahora no pueda ejercerlo. Pero son cosas distintas el reconocer la existencia de un derecho y la posibilidad de ejercerlo. La aplicación de la ley con efecto inmediato, también vulneraría un derecho adquirido y en consecuencia infringiría la garantía constitucional. Aún más, lo afirmado puede igualmente plantearse respecto a un derecho que al momento de entrar en vigencia estaba sujeto a condición suspensiva, y ésta se cumple posteriormente. En efecto, al cumplirse la condición, dicho cumplimiento se retrotrae al momento en que se celebró el acto o contrato. Por tanto, debe entenderse que el derecho ya existía y se había adquirido, en el momento en que entró en vigencia la nueva ley. Así, por ejemplo, la ley nueva podría disponer, modificando el Código Civil, que una persona jurídica no podrá adquirir el derecho real de usufructo por sucesión por causa de muerte. Sin embargo, al momento en que entra en vigencia dicha reforma, estaba pendiente el cumplimiento de una condición suspensiva, que una vez verificada, le permitiría a una corporación reclamar el usufructo testamentario, y tal condición se cumple en el plazo fijado por el causante. Siendo así, tiene derecho tal persona jurídica al amparo de la ley antigua, y conservará su usufructo por el plazo máximo de treinta

---

[246] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 317, p. 215.
[247] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 62, p. 62.
[248] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 129.
[249] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 317, p. 215.
[250] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 317, p. 215; Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 62, p. 63.

años que hoy establece el Código de Bello. En este caso no podemos aplicar el art. 22 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, que se refiere sólo a los contratos, sino que el art. 18 de la misma ley, en cuanto las disposiciones contenidas en el testamento, "estarán subordinadas a la ley vigente a la época en que fallezca el testador".

J. B. Duvergier señalaba en el mismo sentido: "Los *derechos adquiridos* son los que pueden ejercerse actualmente, esto es, que en caso de agresión o de resistencia, el poder público debe protegerlos (…) Las *expectativas*, al contrario, no son sino gérmenes de derecho, gérmenes que no se desarrollan sino en virtud de acontecimientos ulteriores. De donde resulta que entre el *derecho* y la *expectativa* hay dos diferencias: el uno deduce su eficacia solamente de lo pasado, la otra debe ser fecundada por lo porvenir; el derecho puede ejercerse inmediatamente, la expectativa no es susceptible de realización actual. Como hablamos a jurisconsultos, acaso sea innecesario decir que cuando el ejercicio de un derecho depende de un plazo, ese derecho tiene existencia cierta y actual; que cuando un derecho se subordina a una condición, cumplida ésta se retrotrae al tiempo en que principió el germen del derecho, y que la legislación entonces vigente es la que debe consultarse".[251]

En síntesis, el legislador tiene libertad para dictar leyes retroactivas, salvo en materia penal -a menos que la nueva ley sea más favorable- y en materia civil respecto al derecho de dominio.[252]

e.6) El principio de la irretroactividad ante el juez.

El art. 9 del Código Civil, como toda ley, es obligatorio para el juez. Este no puede aplicar una ley con efecto retroactivo, salvo que la misma ley así lo disponga, caso en el cual está obligado a aplicarla con ese efecto. El art. 9 contiene pues una prohibición para el juez, pero no para el legislador.[253] En consecuencia, el juez debe darle obligada primacía a los principios de la irretroactividad de las leyes y al carácter excepcional de la retroactividad, en su labor de interpretación y aplicación de la ley.[254]

e.7) La retroactividad debe ser expresa.

El juez no puede eludir la prohibición del art. 9, bajo el pretexto de una intención tácita del legislador. En otras palabras, no es posible aceptar una retroactividad implícita o "tácita".

Si se define la retroactividad en su sentido estricto, como la acción de volver sobre hechos consumados, el legislador sólo puede imponerla en forma expresa. Ello, porque dicha retroactividad es contraria a la función del juez, que es simplemente declarativa del derecho. La misión del juez es buscar y determinar los efectos jurídicos producidos en el pasado, lo que no puede hacer sino conforme a la ley vigente en el momento en que tales efectos se produjeron.

Así, nuestra jurisprudencia ha resuelto que la retroactividad es una regla de excepción, que debe interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, de acuerdo a sus propios términos.[255]

Efectivamente, "Como una ley de tal naturaleza contraría el principio general y afecta la seguridad jurídica, constituye un acto excepcional cuyo carácter, en consecuencia, no puede ser inferido, sino que tiene que estar expresamente manifestado en el texto legal. La retroactividad, en consecuencia, debe ser expresa. Además su carácter de excepción impone para tales preceptos una interpretación y aplicación restrictivas; son, usando una expresión consagrada, de derecho estricto".[256] En efecto, como señala una sentencia de la Corte Suprema de 20 de julio de 1989, "El

---

[251] Citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 136.
[252] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 317, p. 216.
[253] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 320, p. 216.
[254] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 62, p. 63.
[255] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nºs. 321 y 322, pp. 216 y 217.
[256] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 62, p. 62.

legislador para romper el principio de la irretroactividad de las leyes y establecer una situación excepcional, como lo es la retroactividad, debe hacerlo en forma explícita e inequívoca, empleando términos formales y claros".[257]

Un ejemplo de ley retroactiva, es la Ley N° 20.239, publicada en el Diario Oficial de fecha 8 de febrero de 2008, que liberó del pago de impuesto a la renta a las compensaciones económicas originadas al término del matrimonio. La Ley incorporó un N° 31 al art. 17 de la Ley de la Renta, que dice: "No constituye renta: (…) 31º.- Las compensaciones económicas convenidas por los cónyuges en escritura pública, acta de avenimiento o transacción y aquellas decretadas por sentencia judicial". Expresamente, se dio efecto retroactivo a la ley, fijándose su vigencia a partir del momento en que a su vez entró en vigencia la nueva Ley de Matrimonio Civil, es decir, el 18 de noviembre de 2004.

Otro ejemplo encontramos en la Ley Nº 16.455, que fijó "Normas para la terminación del contrato de trabajo". Se publicó y entró en vigencia el 6 de abril de 1966. Sin embargo, en su art. 6º transitorio, se dispuso que todo despido que ocurriere entre el 28 de febrero de 1966 y la fecha de promulgación de esta ley (lo que ocurrió el 5 de abril de 1966), daría derecho al trabajador a una indemnización extraordinaria de un mes de remuneraciones por año de servicios continuos o discontinuos prestados a la misma empresa. Por lo tanto, la ley tuvo efecto retroactivo, pues se aplicó a términos de contrato de trabajo acaecidos antes de que ella entrare en vigencia. Uno de los empleadores recurrió a la Corte Suprema, fundando su acción en la aludida retroactividad, que lo obligaba a pagar la indemnización. Su recurso no prosperó, declarando la sentencia que "el legislador puede dictar normas retroactivas, cuya justificación, oportunidad o conveniencia son materias que escapan a la jurisdicción de la Corte Suprema y exceden los límites del recurso de inaplicabilidad".[258] La verdad es que este fallo contraría los postulados de Paul Roubier, a los que aludiremos, pues se trataba de situaciones jurídicas extinguidas bajo la legislación anterior.

e.8) La teoría de los derechos adquiridos y de las simples expectativas.

Su origen se encuentra en los escritos de Savigny, de Merlin, como también en la teoría de Blondeau, expuesta en su obra "Ensayo sobre el llamado efecto retroactivo de las leyes", publicada en 1809. Antes, Portalis, uno de los principales redactores del Código Civil francés, había hecho ya la distinción entre derechos adquiridos y simples expectativas. El italiano Francisco Gabba, a fines del siglo XIX, desarrollará con mayor profundidad la teoría ("Teoría della retroattivita delle leggi").[259]

Esta teoría puede enunciarse así: una ley es retroactiva cuando lesiona intereses que para sus titulares constituyen *derechos adquiridos*, en virtud de la ley antigua; pero no lo es, cuando sólo vulnera *simples expectativas o meras facultades legales*.[260]

La cuestión de determinar cuándo nos encontramos ante un derecho adquirido ha suscitado diversas opiniones. Siguiendo a Borja, revisaremos a continuación algunos de estos planteamientos.

Savigny, refiriéndose a los derechos adquiridos, decía: "La fórmula relativa a la conservación de los derechos adquiridos debe expresarse en dos sentidos del todo diversos (…) Primeramente, cuando nuestra fórmula exige la conservación de los *derechos adquiridos*, se comprenden sólo los hechos jurídicos de una persona determinada, esto es, las partes constitutivas del dominio en que la voluntad individual

---

[257] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 71.
[258] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 74.
[259] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 325, p. 218.
[260] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 325, pp. 218 y 219.

ejerce su independencia; mas no facultades abstractas de todos los hombres o de una clase de la sociedad (…) En segundo lugar, no se confundan los *derechos adquiridos* con las meras expectativas que, puntualizadas por la ley antigua, la nueva ley extingue. Ese resultado en nada atañe al principio que garantiza los derechos adquiridos. Pero tampoco se confundan las meras *expectativas* con los *derechos*, que sujetos a condición o a plazo, no pueden por lo pronto ejercerse. Tales derechos lo son en realidad. La diferencia consiste en que la *expectativa*, en cuanto a su resultado, depende sólo de la voluntad de otra persona; lo cual no es aplicable tratándose de la condición o del plazo".[261]

Borja advierte, sin embargo, que la regla planteada por Savigny no es del todo exacta, "porque los derechos adquiridos no sólo provienen del ejercicio de las facultades que la ley concede. Si bien ciertos derechos dependen de la voluntad individual; otros se adquieren por el ministerio de la ley, y entonces son tan inviolables como los provenientes del ejercicio de las facultades legales. Un individuo muere abintestato, y la ley declara que la herencia pertenece a ciertos parientes. ¿No habría un derecho adquirido, tan inviolable como el que naciese de un contrato?".[262]

Chabot, por su parte, expresa que "el problema de los *derechos adquiridos* es el del *efecto retroactivo* de la ley; y añade: 'Son *derechos adquiridos* los conferidos irrevocable y definitivamente antes del hecho, el acto o la ley que quiere oponerse para impedir el pleno e íntegro goce de tales derechos. Evidente es que un derecho revocable *ad nutum*[263] por la persona que lo confirió, no constituye derecho adquirido, porque no pasa de esperanza, de mera expectativa. La ley nueva que lo halla en tal estado puede apoderarse de él para alterarlo a su voluntad: puede revocarlo o modificarlo, porque es revocable por naturaleza, y el dominio de la ley se extiende a todo lo que no estaba irrevocablemente terminado antes de su promulgación. No hay efecto retroactivo sino cuando se lastiman derechos definitivamente adquiridos".[264]

Laurent, a su vez, decía: "¿Cómo se puede saber si un *derecho es adquirido*? (…) Deben distinguirse los derechos que nacen de los contratos de los provenientes de la herencia abintestato o testamentaria. Tratándose de sucesión, el derecho no es adquirido sino cuando ella se abre (…) Los contratos son irrevocables tan luego como se perfeccionan; los derechos que de ellos provienen son esencialmente *derechos adquiridos*".[265]

Baudry-Lacantinerie, afirmaba al respecto: "Por *derechos adquiridos* deben entenderse las *facultades legales regularmente ejercidas*, y por *expectativas* las que no se habían ejercido aún cuando se alteró la legislación. Bajo la denominación de derechos, la ley nos reconoce aptitudes, nos confiere facultades, cuyo uso depende de la voluntad. Mientras no hemos utilizado las aptitudes, tenemos un derecho en el sentido de que somos aptos para adquirirlo conforme a la ley; y nuestra aptitud se manifiesta por el acto necesario para utilizarla. El ejercicio de la facultad legal que, por decirlo, así, se ha materializado en ese acto, traducido exteriormente por él, constituye el *derecho adquirido*".[266]

Pero haciendo abstracción de estos distintos pareceres, lo cierto es que el principio fundamental, es el siguiente: el juez no debe, en una controversia que incide sobre un derecho adquirido bajo la ley precedente, aplicar una ley nueva; pero puede hacerlo si el juicio versa sobre un hecho que bajo la ley antigua sólo constituía una mera facultad legal o una simple expectativa.[267]

---

[261] Citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., pp. 107 y 108.
[262] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 108.
[263] Es decir, a voluntad.
[264] Citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 109.
[265] Citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 109.
[266] Citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., pp. 109 y 110.
[267] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 325, p. 219.

Las *simples expectativas* son las esperanzas de adquisición de un derecho fundadas en la ley vigente y aún no convertidas en derecho por falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley. Por ejemplo, la expectativa a la sucesión del patrimonio de una persona viva; o la expectativa de adquirir por prescripción el dominio.[268]

Las *facultades legales* constituyen el supuesto para la adquisición de derechos y la posibilidad de tenerlos y ejercerlos. Por ejemplo, la capacidad para adquirir cierto bien; o la facultad para testar.[269] En otras palabras, y como se desprende de la doctrina citada, una vez ejercida la facultad legal correspondiente, se incorporará el derecho al patrimonio.

Se entiende por *derechos adquiridos*, conforme a la célebre definición de Francisco Gabba, todos aquellos derechos que son consecuencia de un hecho idóneo para producirlos en virtud de la ley vigente al tiempo en que se realizó el hecho, y que inmediatamente han llegado a ser parte del patrimonio de la persona, aunque la ocasión de hacerlos valer no se presente sino bajo el imperio de una ley nueva.[270]

De esta manera, la secuencia sería la siguiente: meras expectativas → ejercicio de una facultad legal → derecho adquirido.

Los derechos adquiridos entran al patrimonio por un hecho o acto del hombre o directamente por el ministerio de la ley.

Ahora bien, la ley nueva no puede lesionar, si el legislador le ha dado efecto retroactivo, los derechos adquiridos; pero sí puede vulnerar las facultades legales y las simples expectativas, porque ni aquellas ni éstas constituyen derechos que hayan entrado definitivamente a formar parte del patrimonio de una persona. De lo anterior se deriva una consecuencia importante: puesto que en el patrimonio no entran sino los derechos privados, toda una serie de derechos se sustrae al principio de la irretroactividad, como son los que derivan de normas de Derecho público, que no pueden dar lugar a derechos adquiridos.[271]

Frente a la teoría anterior, que se ha definido como "clásica", cabe aludir a la teoría de Paul Roubier, expuesta en su obra "Los conflictos de las leyes en el tiempo" (París, dos tomos, 1929-1933). Distingue este autor entre el "efecto retroactivo" y el "efecto inmediato" de la ley. El efecto retroactivo, según expresamos, consiste en la aplicación de la ley en el pasado. El efecto inmediato, a su aplicación en el presente. Alude seguidamente a las *"situaciones jurídicas"*, que pueden definirse como "la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica determinada".[272]

Plantea que esta noción de "situación jurídica" es superior a la de "derecho adquirido", porque no necesariamente tiene, como ésta, un carácter subjetivo, pudiendo aplicarse a situaciones como las del menor, el interdicto, el pródigo, etc. Respecto a estos estados, no podemos hablar de "derechos adquiridos", pero sí de una "situación jurídica". También es superior esta noción a la de "relación jurídica", pues ésta presupone una relación directa entre dos personas, lo que no ocurre en la "situación jurídica", que puede ser unilateral y oponible a todos.[273]

El número de situaciones jurídicas es infinito, siendo papel de las diversas ramas del Derecho definir y determinar sus efectos. Así, en el derecho de las personas, encontramos, por ejemplo, la situación de cónyuge, la de cónyuge separado, la de divorciado, la de hijo matrimonial o no matrimonial o de adoptado, la que corresponde a diversas incapacidades, la de tutor o curador, etc. En el derecho de bienes, la de

---

[268] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 325, p. 219.
[269] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 325, p. 219.
[270] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 75.
[271] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 325, p. 219.
[272] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 328, p. 221.
[273] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 328, p. 221.

propietario, o de usufructuario, o de titular activo o pasivo de una servidumbre, o de acreedor hipotecario, etc. En el derecho de las obligaciones, la de acreedor o deudor, de vendedor o comprador, de arrendador o arrendatario, de autor o víctima del daño, etc. En el derecho de sucesiones, la de heredero legitimario, de legatario, de heredero beneficiario, etc.[274]

Ahora bien, toda "situación jurídica" puede verse afectada por una nueva ley en lo concerniente a su *constitución*, a *sus efectos* o a *su extinción*. La nueva ley tendrá efecto retroactivo, cuando afecte a las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas. Por consiguiente, una ley relativa a la constitución o a la extinción de una situación jurídica, no puede volver a poner en tela de juicio la eficacia o ineficacia jurídica de un hecho pasado. En cambio, si la nueva ley sólo afecta *los efecto*s de una situación jurídica nacida con antelación, pero que se produzcan bajo la vigencia de la nueva ley, no habrá efecto retroactivo, sino que efecto inmediato. Pero ello, reiteramos, bajo el entendido que los efectos producidos por dicha situación jurídica antes de entrar en vigencia la nueva ley, ya quedaron regulados y fijados por la ley primitiva; en cambio, la ley nueva regirá los efectos de esta situación jurídica, cuando ellos se generen durante la vigencia de las nuevas normas.[275]

Dicho efecto inmediato también regirá para la constitución, para los efectos y para la extinción de *situaciones jurídicas nuevas*, es decir, nacidas después que la nueva ley haya entrado en vigencia.

Pero el efecto inmediato con que opera la nueva ley, tiene una importante excepción: no afectará a los contratos vigentes al momento en que aquella entre en vigencia, pero siempre que se trate de contratos cuyo contenido quede entregado a la voluntad creadora de los individuos (como ocurre usualmente con los *contratos patrimoniales*). En cambio, los contratos cuyo contenido es fijado imperativamente por la ley (como ocurre con los *contratos de familia*), quedarán sometidos, en cuanto a sus efectos, a la nueva ley.[276] Dicho de otra forma: cuando estamos ante un contrato cuyo íntegro estatuto puede quedar determinado por las partes, es decir, cuando sólo está regulado por normas de orden privado, no se aplicará el efecto retroactivo ni tampoco el efecto inmediato de la ley, sino que se respetará en su totalidad el contrato oportunamente convenido por las partes, bajo el amparo de una ley que ahora puede no existir o puede haberse modificado; en cambio, si el contrato está regulado por normas de orden público, las modificaciones a la legislación aplicable al mismo, afectarán al contrato aunque éste se hubiere celebrado con antelación a tales reformas, es decir, la nueva ley se aplicará con efecto inmediato. Tal ocurre, por ejemplo, con el contrato de matrimonio. Su estatuto lo fija la ley de manera imperativa, de manera que las modificaciones que el legislador haga a este contrato, regirán tanto para los que se celebren en el futuro, como también para los actualmente vigentes. Otro tanto ocurre con el contrato de trabajo. Si en él se estipuló, por ejemplo, que la jornada semanal sería de 45 horas, y más tarde la ley establece que la jornada semanal no podrá extenderse por más de 40 horas, regirá la nueva ley, aunque el contrato se haya celebrado antes de la reforma.

De esta manera, sintetizando los planteamientos de Roubier acerca de una situación jurídica:

i.- *En cuanto a su constitución*: rige la ley antigua. Los requisitos adicionales que pueda exigir la ley nueva para que se constituya una situación jurídica, no pueden aplicarse para la situación jurídica que quedó legalmente constituida bajo la vigencia de la ley antigua.

ii.- *En cuanto a sus efectos*:

---

[274] Figueroa Yáñez, Gonzalo (2015), ob. cit., p. 172.
[275] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 328, p. 222.
[276] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., pp. 221 y 222.

i) Los ya acaecidos: ley antigua.
ii) Los que se produzcan a partir de la vigencia de la ley nueva: debemos distinguir entre contratos regidos por normas de orden público o por normas de orden privado:
ii.a) Contratos regidos por normas de orden privado: continuarán rigiéndose los efectos del contrato por la ley antigua.
ii.b) Contratos regidos por normas de orden público: se regirán los efectos del contrato por las normas de la ley nueva.
iii.- *En cuanto a su extinción*:
i) Si se produjo bajo la vigencia de la ley antigua: no puede alterarse por la ley nueva. Rige sólo ley antigua.
ii) Si se produce a partir de la vigencia de la ley nueva: debemos distinguir entre contratos regidos por normas de orden público o por normas de orden privado:
ii.a) Contratos regidos por normas de orden privado: su extinción se regirá por la ley antigua.
ii.b) Contratos regidos por normas de orden público: su extinción se regirá por la ley nueva.

f) *Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes*.

f.1) Finalidad y contenido de la ley.

La ley, promulgada en 1861, tiene por objeto, como lo dice su art. 1, decidir los conflictos que resulten de la aplicación de leyes dictadas en diversas épocas. Abarca por ello diversas materias.

Se funda la ley en la teoría de los derechos adquiridos y en las meras expectativas, pero en algunos puntos se aparta de sus soluciones y establece otras que han parecido más justas y adecuadas al legislador.[277]

La ley, en los arts. 2 a 9, se ocupa de las personas naturales (aunque varios de sus artículos han quedado tácitamente derogados con la promulgación de la Ley Nº 19.585 de 1998); el art. 10, de las personas jurídicas; los arts. 12 a 17, de los bienes; los arts. 18 a 21, de las sucesiones; los arts. 22 y 23, de los contratos; el art. 24, de las normas de procedimiento; y los arts. 25 y 26, de la prescripción.

Vale decir, en sus 26 artículos, cubre prácticamente todas las materias de que trata en sus cuatro libros el Código Civil.

El art. 11, ratifica la abolición de la restitución "*in integrum*", que el art. 1686 del Código Civil había establecido. Esta figura "era un privilegio concedido a ciertas personas para que, en caso de lesión, se invalidasen sus actos o contratos, aunque éstos se hubiesen ejecutado o celebrado conforme a la ley. El Código Civil abolió, con razón, tal privilegio; pues, además de la inseguridad en las transacciones sociales, él perjudicaba aún más a las personas a quienes se pretendía favorecer".[278]

Establece el art. 11: "las personas naturales o jurídicas que bajo una legislación anterior gozaban del privilegio de la restitución "in integrum", no podrán invocarlo ni transmitirlo bajo el imperio de una legislación posterior que lo haya abolido". Dispone el art. 1686: "Los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararse nulos ni rescindirse, sino por las causas en que gozarán de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes". En el párrafo XXXVI del Mensaje del Código Civil, que alude a los contratos y cuasicontratos, Bello alude a esta figura y a las razones por las cuales se la expulsa del ordenamiento jurídico: "La novedad de mayor bulto que en esta parte hallaréis, es la abolición del privilegio de los menores, y de otras personas naturales y jurídicas, asimiladas a ellos, para ser restituidos *in integrum* contra sus actos y

[277] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 333, p. 225.
[278] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 141.

contratos. Se ha mirado semejante privilegio no sólo como perniciosísimo al crédito sino como contrario al verdadero interés de los mismos privilegiados. Con él, como ha dicho un sabio jurisconsulto de nuestros días, se rompen todos los contratos, se invalidan todas las obligaciones, se desvanecen los más legítimos derechos. 'Esta restitución, añade, es un semillero inagotable de pleitos injustos, y un pretexto fácil para burlas la buena fe de los contratos'. Todas las restricciones que se ha querido ponerles no bastan para salvar el más grave de sus inconvenientes, a saber: que inutiliza los contratos celebrados guardando todos los requisitos legales, deja inseguro el dominio, y dificulta las transacciones con los huérfanos, que no suelen tener menos necesidad que los otros hombres de celebrar contratos para la conservación y fomento de sus intereses. Lo dispuesto sobre esta materia en el código francés, en el de las Dos Sicilias, en el Sardo y en otros es mucho más conforme con la justicia y aún más favorable a los mismos pupilos. Según estos códigos, el contrato celebrado por un menor sin el consentimiento de un guardador no es nulo *ipso iure*, aunque puede rescindirse; pero el celebrado con las solemnidades de la ley, se sujeta a las mismas condiciones que los celebrados por personas mayores de edad. Decía el jurisconsulto Jaubert, explicando los motivos de esta disposición: 'Es indispensable asegurar completamente los derechos de los que tratan con los menores, observando las formalidades de la ley, y si esta precaución no fuese necesaria sería cuando menos útil, a causa de las prevenciones inveteradas que se tienen contra los pupilos, creyéndose, y con razón, que no hay seguridad en contratar con ellos".

f.2) Leyes sobre el estado civil.

El art. 304 del Código Civil define el estado civil como "la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles".

Se trata de un concepto defectuoso, más parecido al de capacidad de ejercicio, y que no explica la naturaleza del estado civil.

Más apropiadamente, puede definirse como la calidad permanente que ocupa un individuo en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia, que lo habilita para ejercer ciertos derechos y le impone un conjunto de deberes y obligaciones.

En términos similares, Claro Solar define el estado civil como "la calidad permanente del individuo en sus relaciones sociales o de familia que le confiere por el solo ministerio de la ley un conjunto de derechos y obligaciones inherentes a su persona, y que no se pueden, por lo tanto, transferir ni transmitir".[279]

En el marco de la ley que estamos analizando, se distingue entre el estado civil adquirido y el que aún no lo ha sido.

i.- *Adquisición del estado civil*: art. 2.

Establece esta norma: "Las leyes que establecieren para la adquisición de un estado civil, condiciones diferentes de las que exigía una ley anterior, prevalecerán sobre ésta desde la fecha en que comiencen a regir".

La posibilidad de adquirir un estado civil es una mera expectativa y mientras no se adquiera e incorpore a una persona, quedará dicha expectativa regida por la ley nueva. Vale decir, sólo se podrá adquirir un estado civil conforme a las leyes vigentes Así, por ejemplo, si un menor adulto de 15 años pretendía casarse bajo la vigencia de la antigua Ley de Matrimonio Civil, al entrar en vigencia la actual, el 18 de noviembre del año 2004, y exigirle tener cumplidos 16 años, forzosamente debió esperar a cumplir tal edad. De igual forma, si se modificare la Ley de Matrimonio Civil y se dispusiere que no podrán contraer matrimonio los colaterales por consanguinidad en el tercer grado, quienes tengan dicho parentesco no podrán celebrar el mencionado contrato, a partir de la reforma legal, aunque lo hayan podido hacer mientras regía la ley antigua.

---

[279] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 176, p. 97.

ii.- *Mantención del estado civil*: arts. 3, 5 y 6.

Conforme al art. 3º, inc. 1º, el estado civil se mantiene, aunque la ley en virtud del cual se contrajo, se modifique: "El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá aunque ésta pierda después su fuerza; pero los derechos y obligaciones anexos a él, se subordinarán a la ley posterior, sea que ésta constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos".

Así, por ejemplo, si un menor de 16 años hubiere contraído matrimonio antes del 18 de noviembre de 2004, conservará su estado civil de casado, aunque a partir de esa fecha, la ley exija tener 16 años cumplidos para contraer matrimonio; o, por ejemplo, si se modificare la Ley de Matrimonio Civil estableciéndose en ella que no podrán casarse los cuñados (parientes por afinidad en la línea colateral en 2º grado) o los primos hermanos (parientes por consanguinidad en la línea colateral en el 4º grado), quienes tengan dichos parentescos y hubieren celebrado el contrato de matrimonio antes de la reforma, conservarán su estado civil de casados.

El art. 5 aplica el principio anterior al estado civil de "hijo natural", expresión que hoy debemos entender referida al hijo no matrimonial: "Las personas que bajo el imperio de una ley hubiesen adquirido en conformidad a ella el estado de hijos naturales, gozarán de todas las ventajas y estarán sujetas a todas las obligaciones que les impusiere una ley posterior".

El art. 6, que hacía referencia a los hijos simplemente ilegítimos, debemos entenderlo derogado, pues si bien esta clase de filiación es asimilable hoy día al hijo de filiación indeterminada, la ley ya no le confiere derecho a pedir alimentos, como acontecía antes de la reforma hecha por la Ley Nº 19.585 al Código Civil. Dispone la norma: "El hijo ilegítimo que hubiere adquirido derecho a alimentos bajo el imperio de una antigua ley, seguirá gozando de ellos bajo la que posteriormente se dictare, pero en cuanto al goce y extinción de este derecho se seguirán las reglas de esta última".

En este punto, algunos autores advertían una contradicción entre lo que dispone el artículo inicialmente y lo que establece al final. El Código Civil asimilaba el derecho de alimentos al estado civil del hijo simplemente ilegítimo (antiguo art. 280). El único derecho que caracterizaba al estado civil de hijo simplemente ilegítimo era el derecho de alimentos. En consecuencia, se sostenía que este único derecho no podía quedar supeditado, como un mero "efecto" del estado civil, a una ley posterior, porque podría extinguirse el propio estado civil. Habría en efecto contradicción, por cuanto se reconocía por un lado al estado civil de hijo ilegítimo, amparándolo contra la retroactividad, y por otro lado se le desconocía, al permitirse que la nueva ley extinguiera el único efecto del mismo: el derecho de alimentos (tal habría ocurrido, si la nueva ley hubiere establecido que el hijo simplemente ilegítimo carecería de tal derecho. Como no tenía otro, en los hechos habría desaparecido todo efecto práctico de dicho estado civil).

iii.- *Efectos del estado civil*: se rigen por las disposiciones de la nueva ley.

El art. 3, inc. 2º, se refiere a los efectos del estado civil en general: "En consecuencia, las reglas de subordinación y dependencia entre cónyuges, entre padres e hijos, entre guardadores y pupilos, establecidas por la nueva ley, serán obligatorias desde que ella empiece a regir, sin perjuicio del pleno efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior".

El art. 4, alude a los efectos del derecho legal de goce y de administración que el padre y la madre tienen en los bienes del hijo no emancipado: "Los derechos de usufructo legal y de administración que el padre de familia tuviere en los bienes del hijo, y que hubieren sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán, en cuanto a su ejercicio y duración, a las reglas dictadas por una ley posterior". La expresión "padre de familia", aludía al "padre legítimo". Hoy, la patria potestad está radicada en el padre y la madre de todo hijo menor de edad (sea de filiación matrimonial o no matrimonial),

de manera que la norma debe entenderse que alude a los dos progenitores y respecto de todo hijo no emancipado.

Por ejemplo, si la ley nueva dispone que los padres deberán obtener autorización judicial, para gravar o enajenar los bienes muebles preciosos o con valor de afección del hijo no emancipado (exigencia que hoy no se contempla en la ley vigente), habrá que cumplir con aquélla.

f.3) Leyes sobre las personas jurídicas.

El art. 10, se remite en esta materia al art. 3; las personas jurídicas reciben igual tratamiento que las personas naturales. Dispone el primero de estos preceptos: "La existencia y los derechos de las personas jurídicas se sujetarán a las mismas reglas que respecto del estado civil de las personas naturales prescribe el artículo 3 de la presente ley".

Por ende, si bien no se puede desconocer por una nueva ley la existencia de las personas jurídicas constituidas con anterioridad, bajo el imperio de una ley antigua, en cuanto a sus derechos y obligaciones, ellas quedarán supeditadas a lo que disponga la nueva ley. Por ejemplo, la nueva ley dispone que para constituirse una hipoteca por una sociedad anónima, aún para garantizar obligaciones propias, se requerirá aprobación de junta extraordinaria de accionistas (hoy sólo se exige para caucionar obligaciones ajenas). Tal exigencia regirá para las sociedades constituidas antes y después de entrar en vigencia el precepto legal que así lo disponga.

f.4) Leyes acerca de la capacidad.

Debemos distinguir al respecto entre la capacidad de goce y la de ejercicio.

La capacidad es la aptitud legal de una persona para adquirir derechos o contraer obligaciones y poder ejercerlos y cumplirlas por sí misma.

La capacidad de goce es la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad de ejercicio es la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, y poder ejercerlos y cumplirlas, respectivamente, sin el ministerio o autorización de otra persona.

El art. 7 se refiere a la *capacidad de goce,* aunque en forma indirecta, bajo la formulación de un ejemplo: "Las meras expectativas no forman derecho. / En consecuencia, la capacidad que una ley confiera a los hijos ilegítimos de poder ser legitimados por el nuevo matrimonio de sus padres, no les da derecho a la legitimidad, siempre que el matrimonio se contrajere bajo el imperio de una ley posterior, que exija nuevos requisitos o formalidades para la adquisición de ese derecho, a menos que al tiempo de celebrarlo se cumpla con ellos".

El ejemplo se refiere a la capacidad para contraer el estado civil de hijo matrimonial, en el evento de que los padres que habían reconocido a dicho hijo, contrajeren posteriormente matrimonio. Hoy, por el solo hecho del matrimonio dicho hijo obtiene el mencionado estado civil. Pero si la ley nueva exigiere una formalidad adicional –como por ejemplo una declaración formulada por escritura pública-, será necesario cumplir con este requisito. En todo caso, el ejemplo ha perdido relevancia, después de la reforma hecha al Código Civil por la Ley Nº 19.585 de 1998 (que igualó los derechos de los hijos matrimoniales y no matrimoniales).

Conforme a lo expuesto, la capacidad de goce queda sometida a las nuevas leyes. Si una persona, bajo el imperio de una ley, tiene aptitud para adquirir *ciertos derechos*, la pierde *para esos derechos* si se dicta otra ley que le niega esa aptitud o exige otras condiciones para adquirirlos. Lo anterior, debido a que la capacidad de goce constituye una abstracta facultad legal, es decir, un supuesto para la adquisición de un derecho. La capacidad de goce no es en sí un derecho adquirido, sino un supuesto que habilita para llegar a tener tal derecho. Naturalmente que la regulación de la capacidad de goce por una ley nueva debemos entenderla en el contexto de la adquisición de derechos particulares (por ejemplo, el derecho del hijo de filiación no matrimonial de adquirir el estado civil de hijo de filiación matrimonial, con el

matrimonio posterior de sus padres; o la posibilidad que tenemos de comprar un bien raíz en tal región o zona del país). En otras palabras, bajo ningún respecto una ley nueva podría desconocer por completo la capacidad de goce de una persona, pues ello equivaldría a desconocerle su carácter de persona, habida cuenta que la capacidad de goce es inherente a la personalidad, es un atributo de la personalidad. Además, tal norma sería inconstitucional, atendido el principio de la igualdad de todas las personas frente a la ley. Nada obsta sin embargo a que la ley, para casos concretos y particulares, limite tal capacidad de goce (por ejemplo, si se dispone que ningún habitante de la República podrá comprar inmuebles en tal zona del país, por razones de seguridad nacional).

El art. 8 se refiere a la *capacidad de ejercicio*. Dispone el precepto: "El que bajo el imperio de una ley hubiese adquirido el derecho de administrar sus bienes, no lo perderá bajo el de otra aunque la última exija nuevas condiciones para adquirirlo; pero en el ejercicio y continuación de este derecho, se sujetarán a las reglas establecidas por la ley posterior".

En estricto rigor, siendo la capacidad una facultad legal, y no un derecho adquirido (a pesar de los términos del artículo), podría perderse si se modifica la ley y se establecen mayores exigencias para obtenerla. Sin embargo, otra es la solución en el art. 8: tal capacidad no se puede perder por una ley nueva. En otras palabras, el artículo trata a la capacidad de ejercicio como si fuere un derecho adquirido, no obstante que sólo es una facultad legal. Así, por ejemplo, si una nueva ley establece que la mayoría de edad se alcanzará nuevamente a los 21 años (retornando a la situación imperante hasta el año 1993), aquellos que la hubieren adquirido a los 18 años en conformidad a la ley antigua, no pierden su capacidad de ejercicio, aunque no tengan los 21 años al tiempo de promulgarse la nueva ley. La capacidad de ejercicio, por tanto, subsiste bajo el imperio de una nueva ley, aunque ésta exija condiciones diversas para su adquisición. Con todo, en la práctica la capacidad de ejercicio, aunque no se pierda, se verá limitada por la nueva ley, pues en cuanto a su ejercicio, a sus efectos, rigen las disposiciones de la nueva ley. Entendemos que éstas disposiciones, serán sin embargo las que se apliquen a todas las personas a quienes se les reconoce capacidad de ejercicio. No podría ser de otra manera, pues de lo contrario existirían dos categorías de plenamente capaces, situación que pugnaría con la lógica jurídica. En todo caso, estas limitaciones no alcanzan a los actos jurídicos ejecutados con anterioridad, aunque al otorgarlos o celebrarlos, la persona no haya alcanzado la edad que ahora exija la ley para ser plenamente capaz. En rigor, se producirá una situación anómala: en el ejemplo citado, hoy habría personas con 18, 19 o 20 años que serán considerados incapaces, y otras que habiendo tenido las mismas edades cuando alcanzaron plena capacidad, serán considerados capaces, pues lo hicieron antes de la reforma legal.

El art. 9, referido a los guardadores (tutores y curadores), es una aplicación del art. 8: "Los guardadores válidamente constituidos bajo una legislación anterior, seguirán ejerciendo sus cargos en conformidad a la legislación posterior, aunque según ésta hubieran sido incapaces de asumirlos; pero en cuanto a sus funciones, a su remuneración y a las incapacidades o excusas supervinientes estarán sujetos a la legislación posterior. / En cuanto a la pena en que, por descuidada o torcida administración hubiesen incurrido, se les sujetará a las reglas de aquella de las dos legislaciones que fuere menos rigurosa a este respecto; las faltas cometidas bajo la nueva ley se castigarán en conformidad a ésta".

De esta manera, la designación como tutor o curador subsistirá, aunque de conformidad a la ley nueva la persona designada en el cargo no habría podido serlo en la actualidad. Sin embargo, en todos los efectos de la guarda, regirá la ley nueva, salvo si la pena que deba imponerse fuere más rigurosa, pues en tal caso se aplicará la ley antigua.

f.5) Leyes relativas a los bienes.

Se refiere a la materia el art. 12: "Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley, sin perjuicio de lo que respecto de mayorazgos o vinculaciones se hubiese ordenado o se ordenare por leyes especiales".

La referencia a los mayorazgos y vinculaciones ha perdido relevancia, pues se trata de instituciones que desaparecieron durante el siglo XIX, como ya hemos dado cuenta en esta obra.

Dispone este precepto dos reglas:

i.- Los derechos reales *adquiridos* bajo una ley, subsistirán bajo el imperio de otra.

La nueva ley no puede desconocer el derecho real regularmente adquirido bajo el imperio de la ley antigua, aunque la ley nueva no permita ya dicha adquisición o establezca requisitos adicionales para hacerlo. Por lo demás, si la nueva ley desconociere el derecho real, sería inconstitucional.

ii.- En lo que se refiere a *los efectos* de tales derechos, es decir en cuanto al *goce*, *cargas* y *extinción*, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. Así las cosas:

i.-) En lo que concierne al *goce* del derecho real, debemos entender que ello se refiere a las facultades que el derecho real confiere a su titular. Más precisamente, se aludiría aquí a las facultades de uso y de goce (en el sistema del Código Civil, es usual que bajo la denominación de "goce", se incluya también el "uso", como acontece en los arts. 582, 764 y 1915). Por ende, tal uso y goce, quedaría regido por la ley nueva. Así, por ejemplo, en cuanto al *uso*, si la ley nueva prohíbe darle a ciertos inmuebles un uso industrial o comercial, el propietario no podrá abocarlos a tales fines, aunque al momento de adquirir el dominio, no hayan existido tales restricciones. Otro tanto ocurriría con un vehículo motorizado, si se prohibiere al dueño su uso en ciertos días, a consecuencia de episodios de contaminación ambiental. En lo que respecta al *goce*, es decir a la facultad de obtener los frutos que la cosa pueda reportar, la ley nueva podría disponer que si el propietario de un inmueble lo arrendare, no podrá percibir una renta anual superior al 11% del avalúo fiscal del inmueble. Otro ejemplo sería aquél en que se modifican las normas de urbanismo y construcción, de manera que el terreno que se adquirió bajo la vigencia de la antigua ley, quedará regido por la ley nueva en lo concerniente al coeficiente de constructibilidad, altura de lo que se edifique, destino de lo edificado, etc. Sin embargo, tal como lo hemos señalado recurriendo al primer ejemplo, si respecto de este inmueble existiere un contrato de arrendamiento *en curso*, la ley nueva no puede aplicarse a dicha relación contractual, porque de ocurrir tal cosa, se vulneraría la garantía constitucional de la propiedad, en este caso, porque el derecho del arrendador a percibir ciertas rentas ya había nacido, antes de la eventual reforma legal. La ultra-actividad de la ley, se fundaría entonces en las normas protectoras del dominio de la Constitución Política.

ii.-) En lo que respecta a las *cargas* que afecten al derecho real, también operará la ley nueva. Así, por ejemplo, si bajo la vigencia de la ley antigua, al momento de adquirirse el dominio de un inmueble este no estaba afecto al pago de contribuciones o impuesto territorial, y conforme a la ley nueva sí queda afecto a dicho tributo, se aplicará la ley nueva.

iii.-) En lo atinente a la *extinción* del derecho real, el asunto se ha discutido en la doctrina. Así, por ejemplo, el art. 770, inc. 2° del Código Civil, dispone que si en la constitución de un usufructo no se fija tiempo alguno para su duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. Si con posterioridad se modificare esta norma, y se dispusiere que el usufructo no podrá pasar de treinta años, ¿se aplicará esta limitación a los usufructos vigentes, que se hubieren constituido con el carácter de vitalicios bajo la vigencia de la ley antigua? La pregunta es válida, porque en cuanto a su "extinción", rige la ley nueva. La respuesta, sin embargo, no es tan simple. Si

aplicamos el tenor literal del art. 12, pareciera que la conclusión es positiva: la nueva ley afectará el plazo de vigencia de los usufructos constituidos antes de que aquella entre en vigencia. Pero ello equivaldría a desconocer la noción de derecho adquirido, como en su época José Clemente Fabres y Luis Claro Solar lo hacían notar. Afirmaba al respecto Luis Claro Solar: "Sin la palabra *extinción* nada tendríamos que observar a este artículo. Si el derecho real, adquirido bajo el imperio de una ley subsiste bajo el imperio de otra que estableciere nuevos requisitos para su adquisición, es porque esta última ley tendría efecto retroactivo si lo sometiera a su imperio. ¿Cómo pueden entonces prevalecer *en lo tocante a su extinción* las disposiciones de la nueva ley? La extinción del derecho ¿no es precisamente lo contrario de su subsistencia? En éste como en otros artículos la ley se ha apartado, pues, de los principios que ella misma consagra".[280] Habría pues un buen argumento para concluir en términos negativos: como expresa Hernán Corral, "… si se llegara a la conclusión de que el art. 12 permitiera al legislador imponer nuevas causas de extinción del derecho constituido en virtud de una ley anterior, devendría, en esa parte, en un precepto contrario al art. 19 N° 24 de la Constitución, que impide que las leyes afecten retroactivamente al derecho de propiedad".[281]

De cualquier forma, aquí se aprecia claramente la aplicación del principio de los derechos adquiridos. El *derecho en sí mismo*, permanece intangible, porque incorporado al patrimonio por un *título propio*, es decir, por la actividad de una persona, constituye derecho adquirido; pero no ocurre lo mismo en lo tocante a *las facultades anexas al derecho*, pues éstas entran al patrimonio por un *título general*, la ley. Por ello, la nueva ley puede, sin caer en retroactividad, someter dichas facultades anexas a su imperio.[282]

En otras palabras, "El derecho real es inviolable; pero las facultades que de él nacen no constituyen derecho adquirido mientras en realidad no se ejerzan".[283]

Otro tanto señalaba Claro Solar: "Una nueva ley no puede afectar a un derecho de propiedad o, más generalmente, a un derecho real ya existente, sin que se despoje al titular de un derecho adquirido, de una aptitud ya ejercida. Pero no debe confundirse con el derecho mismo lo que no constituye más que su ejercicio, su manera de usarlo o su modo de conservarlo. Estas no son sino meras aptitudes que emanan del derecho mismo, y naturalmente, quedan regidas por la nueva ley. Todo lo que exige el principio de la no retroactividad es que la nueva ley respete, en este último caso, los actos de goce ya cumplidos y que, como tales, son constitutivos de derechos adquiridos. Se puede tener interés en ejercitar el derecho de la misma manera; pero este interés no se transformará en derecho adquirido sino cuando la facultad de usarlo así, se ha traducido en un acto de ejercicio".[284]

Se desprende entonces de esta Ley que las facultades que nos confiere un derecho real no están protegidas ante la ley nueva. Sin embargo, como ya lo hemos señalado y volvemos a reiterarlo, *la protección de estas facultades tiene hoy rango constitucional*, conforme a lo dispuesto en el art. 19, Nº 24 de la Constitución Política, y lo que hemos dicho acerca de las "facultades esenciales" del derecho de propiedad. Tales facultades esenciales, están en nuestro ordenamiento jurídico protegidas tanto del efecto retroactivo cuanto del efecto inmediato de la ley.

Nótese, al efecto, la dispar redacción que tenía la Constitución Política de 1833 (que regía cuando se dictó la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes en 1861) y la que hoy tiene el art. 19, Nº 24, de la Constitución Política vigente, que ya hemos citado. Expresaba el art. 10, Nº 5 de la Constitución Política de 1833: "La Constitución

---

[280] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., tomo I, Nº 133, p. 75.
[281] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 139.
[282] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 346, p. 233.
[283] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 145.
[284] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 134, p. 75.

asegura a todos los habitantes de la República: (…) 5.º La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades, y sin que nadie pueda ser privado de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial; salvo el caso en que la utilidad del Estado, calificada por una ley, exija el uso o enajenación de alguna; lo que tendrá lugar dándose previamente al dueño la indemnización que se ajustare con él, o se avaluare a juicio de hombres buenos". En cambio, el art. 19, Nº 24, como se ha referido, no sólo alude a la propiedad o al derecho, sino que también a "los atributos o facultades esenciales del dominio".

Hay quienes advierten en el art. 12 la misma contradicción apuntada a propósito del art. 6. Se sostiene que bajo la apariencia de irretroactividad, el art. 12 otorga a las nuevas leyes efectos retroactivos, pues al decir que un derecho adquirido en conformidad a una ley se extinguirá por los medios que señale una ley posterior, afecta directamente al derecho.

Para otros autores, siguiendo la teoría de Paul Roubier (que en lugar de hablar de derechos adquiridos, como se refirió, alude a "situaciones jurídicas constituidas"), no habría retroactividad. Al ordenar la ley que "un derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra", se está refiriendo al caso que una nueva ley imponga nuevos requisitos para la constitución del derecho real, la que no recibirá aplicación tratándose de un derecho anteriormente constituido; pero el legislador no ha querido indicar que este derecho sea perpetuo; la circunstancia de aplicarse la nueva ley en lo tocante a la extinción del derecho no produce retroactividad, porque no se ataca a una situación constituida o extinguida, sino a una que se halla en curso, que está desarrollando sus efectos.

Los arts. 16 y 17, referidos al derecho real de servidumbre (art. 820 del Código Civil), reafirman el principio del art. 12. Disponen:

i.- Art. 16: "Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el imperio de una antigua ley, se sujetarán en su ejercicio y conservación a las reglas que estableciere otra nueva".

De esta manera, las servidumbres *naturales* y las *voluntarias* que se hubieren constituido bajo el imperio de una ley, subsistirán bajo el imperio de la ley nueva, pero en lo tocante a su ejercicio y conservación, se regirán por esta última.

Expresa Claro Solar al efecto: "Este artículo ha tratado de consagrar, en materia de servidumbres, el principio de no retroactividad; pero no lo ha hecho con felicidad. Desde luego, se refiere a las servidumbres naturales y *voluntarias*, omitiendo las servidumbres *legales*. La palabra *voluntarias* está, evidentemente, demás. Las servidumbres voluntarias son establecidas en virtud de un contrato y, naturalmente, quedan fuera del alcance de la ley que en esta materia deja a los particulares en entera libertad de constituir las servidumbres que quieran. No sucede lo mismo con las servidumbres *legales* que son obligatorias, lo mismo que las naturales. Si éstas existen en virtud de la situación natural de los lugares y se imponen necesariamente, aquéllas sólo tienen su fundamento obligatorio en la ley que limita la propiedad, consultando un interés general. Establecida hoy una servidumbre legal, no podría desconocerla mañana la nueva ley que declarara que tal servidumbre no es obligatoria. Es esto tal vez lo que ha querido decir el artículo 16 y ello sería conforme a los principios".[285]

En relación a la palabra "conservación" que emplea el art. 16, Claro Solar previene que "Esta última palabra es algo vaga y si se ha querido indicar la idea opuesta a *extinción*, de tal manera que la nueva ley pudiera extinguir una servidumbre ya constituida, se le daría una aplicación retroactiva".[286]

---

[285] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 135, p. 77.
[286] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 135, pp. 77 y 78.

ii.- Art. 17: "Cualquiera tendrá derecho de aprovecharse de las servidumbres naturales que autorizare a imponer una nueva ley; pero para hacerlo tendrá que abonar al dueño del predio sirviente los perjuicios que la constitución de la servidumbre le irrogare, renunciando éste por su parte las utilidades que de la reciprocidad de la servidumbre pudieran resultarle; a las cuales podrá recobrar su derecho siempre que restituya la indemnización antedicha".

Como señala Claro Solar, "Tal como está redactado este artículo, no se presenta con claridad la utilidad que pueda resultar de él para el conflicto de dos leyes diversas. La Comisión de la Cámara de Diputados, de que formaba parte don José Eugenio Vergara, había propuesto su redacción en estos términos: 'las servidumbres *legales*, que autorizare a imponer una nueva ley, podrán ejercerse aún en contradicción de las servidumbres establecidas bajo el imperio de una ley anterior; pero el que quiera aprovecharse de ellas deberá abonar al dueño del predio sirviente todos los perjuicios que le resulten, tanto de la constitución de la nueva servidumbre como de la extinción de la antigua. Si el dueño del predio sirviente quisiere aprovecharse de la reciprocidad de ventajas que le proporcione la nueva servidumbre, tendrá derecho a aquello con tal que devuelva al dueño del predio dominante la parte proporcional de la indemnización que este dió al imponerla'. En esta redacción, que no fue tomada en cuenta por la Cámara, se ve con más precisión la idea que se trataba de consultar, a saber: que no es un obstáculo para el establecimiento de una servidumbre que una nueva ley autorice el hecho de que exista establecida anteriormente otra servidumbre con arreglo a una ley anterior, pues esto no es sino una limitación de la propiedad que el legislador establece para el porvenir. La palabra *legales* que esta redacción empleaba es la que corresponde a la disposición y no la palabra *naturales* que emplea el artículo 17".[287]

Vodanovic reitera lo que Claro Solar ya había advertido acerca del art. 17 transcrito: "Hay aquí un error manifiesto: el artículo habla de servidumbres naturales; pero la verdad es que resulta claro que se refiere a las servidumbres legales. Servidumbres naturales son, según el artículo 831 del Código Civil, las que provienen de la natural situación de los lugares. Entonces, es lógico, que el legislador no haya tenido en la mente referirse a estas servidumbres, porque ellas no son impuestas por la ley; dependen de factores naturales. La misma redacción del precepto confirma esta inteligencia al decir: '… servidumbres naturales *que autoriza a imponer una nueva ley'*".[288]

De esta manera, si bajo el imperio de una ley nueva puede reclamarse la constitución de una servidumbre *legal* –y no *natural*, como dice la norma- (que no podía reclamarse bajo la vigencia de la ley antigua), quien lo haga deberá abonar al dueño del predio sirviente los perjuicios que la constitución de la servidumbre le irrogare. En otras palabras, la circunstancia de que bajo la vigencia de la ley antigua no era posible reclamar la constitución de la servidumbre legal ("natural" según el artículo), no es obstáculo para que ahora se reclame, si la ley nueva lo permite. Pero si se reclama, quien lo haga debe indemnizar al dueño del predio que resulta gravado.

f.6) Leyes relativas a la posesión.

El art. 13 alude a ella: "La posesión constituida bajo una ley anterior no se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios o con los requisitos señalados en ésta".

La posesión se define en el art. 700 del Código Civil: "La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a

[287] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 135, pp. 77 y 78.
[288] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 352, pp. 236 y 237.

nombre de él. / El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo".

Según se estudiará en la materia concerniente a los Bienes y los Derechos Reales, una persona puede encontrarse en tres situaciones, en relación a una cosa: puede ser su dueño, su poseedor o su mero tenedor. Si se es dueño, la cosa forma parte del activo de su patrimonio. Se tiene respecto de ella un *derecho adquirido*. Si se es poseedor, se tiene la *mera expectativa* de llegar a ser dueño, a través de la prescripción, cumpliéndose los requisitos previstos en la ley. No hay por ende todavía un derecho adquirido. Aunque se detente la cosa como dueño, en realidad no se tiene aún dicha calidad. Si se es mero tenedor, se detenta una cosa no como dueño, sino que en lugar y nombre del dueño, es decir, reconociendo dominio ajeno.

La misma crítica que se hace al art. 12, se suele formular respecto al art. 13: la irretroactividad de las leyes sobre la posesión sólo sería ilusoria. Si constituida la posesión de una cosa bajo el imperio de una ley, no puede conservarse bajo otra posterior, sino por los medios que esta última establece, es indudable que no puede hablarse de irretroactividad.

Pero la crítica en este caso es injustificada, pues existe una diferencia sustancial entre la naturaleza jurídica de un derecho real y la posesión. Esta última no es un derecho, sino un hecho, jurídicamente protegido, que, a través de la prescripción adquisitiva, puede conducir a un derecho. En consecuencia, mal podría tratarse de un derecho adquirido. Se trata, como está dicho, de una mera expectativa.

Este distingo se observa en el propio tenor del art. 13, donde se alude a la *constitución* de la posesión y no a la *adquisición* de la misma. El matiz es relevante, pues siendo la posesión un hecho, es correcto hablar que se constituye, más no que se adquiere, pues sólo los derechos pueden adquirirse.

El art. 13 se vincula con el art. 26, que, como se verá, se refiere a la prescripción adquisitiva. Dicha prescripción, se podría decir, constituye la *meta* a la que aspira llegar un poseedor. Pero ello ocurrirá en la medida en que la ley que así lo permite, no sea modificada antes de alcanzar tal objetivo.

f.7) Derechos deferidos bajo una condición.

El art. 14 se refiere a esta materia: "Los derechos deferidos bajo una condición que, atendidas las disposiciones de una ley posterior, debe reputarse fallida si no se realiza dentro de cierto plazo, subsistirán bajo el imperio de ésta y por el tiempo que señalare la ley precedente, a menos que este tiempo excediese del plazo señalado por la ley posterior contado desde la fecha en que ésta empiece a regir; pues en tal caso si dentro de él no se cumpliere la condición, se mirará como fallida".

Se entiende por condición aquél hecho futuro e incierto, del cual pende el nacimiento o la extinción de un derecho. Conforme a esta definición, la condición puede ser *suspensiva* o *resolutoria*. La primera, cuando está pendiente el nacimiento de un derecho. La segunda, cuando está pendiente la extinción de un derecho.

Por ejemplo, se deja una cuantiosa herencia a María, que actualmente cursa cuarto año de la carrera de Derecho, pero imponiéndole la condición, para recibirla, de que obtenga el título de abogado, en el plazo de cinco años, contados desde el fallecimiento del causante. Supongamos también que el plazo de cinco años, es el plazo máximo previsto en la ley al momento de otorgarse el testamento, para cumplir la condición. En este caso, se trata de una condición suspensiva.

Se pone el art. 14 en la hipótesis que una ley nueva, modifique el plazo dentro del cual deba cumplirse una condición, para adquirir un derecho. Si la nueva ley establece que la condición se entenderá fallida de no cumplirse dentro de cierto plazo (y por ende no se adquirirá el derecho), debemos distinguir:

i.- El derecho subsistirá bajo el imperio de la nueva ley, por el tiempo que señale la ley precedente;

ii.- Pero si el tiempo señalado por la ley precedente para cumplir la condición fuere mayor que el plazo señalado por la nueva ley, contado tal plazo desde la fecha en que la última ley empiece a regir, la condición deberá cumplirse dentro del referido plazo, so pena de tenerse por fallida.

Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo propuesto, podría ocurrir que se modificare la ley y se estableciere que la condición para reclamar una herencia deberá cumplirse en el plazo máximo de dos años, contados desde el fallecimiento del causante. Ahora bien, si hubieren transcurrido dos años desde el fallecimiento del testador, en principio, le quedaría a María el plazo de tres años para cumplir la condición que se le impuso. Sin embargo, conforme a la regla transcrita, le quedarán ahora sólo dos años.

Veamos otro ejemplo similar: para el cumplimiento de una condición de la que depende la *restitución* de un fideicomiso (es decir, cuando el dominio pasa del propietario fiduciario al fideicomisario), el Código Civil fija hoy como plazo máximo 5 años, contados desde la delación de la propiedad fiduciaria al propietario fiduciario (art. 739). Por ende, si se dejó un legado a Juan, consistente en un inmueble, pero sujetando su dominio al gravamen de pasar a Isabel, si ésta jura como abogado, ella debe cumplir con esta condición en el expresado plazo de cinco años. Ahora bien, si el Código Civil fuere modificado cuando había transcurrido un año, y se estableciera en el nuevo texto legal que la condición debe cumplirse en el plazo de 3 años, a Isabel sólo le restará para jurar como abogado el plazo de 3 años, y no de 4, de haber continuado rigiendo la norma antigua.

f.8) Prohibición de usufructos, usos, habitaciones y fideicomisos sucesivos.

Dispone el art. 15: "Siempre que una nueva ley prohíba la constitución de varios usufructos sucesivos, y expirado el primero antes de que ella empiece a regir, hubiese empezado a disfrutar la cosa alguno de los usufructuarios subsiguientes, continuará éste disfrutándola bajo el imperio de la nueva ley por todo el tiempo a que le autorizare su título; pero caducará el derecho de los usufructuarios posteriores si los hubiere. / La misma regla se aplicará a los derechos de uso o habitación sucesivos, y a los fideicomisos; sin perjuicio de lo que se haya dispuesto o se dispusiere por leyes especiales relativas a mayorazgos y vinculaciones".

La norma no hace sino reiterar las prohibiciones contenidas en los arts. 745 (sobre fideicomisos sucesivos) y 769 (sobre usufructos sucesivos y alternativos), y se justificó al promulgarse la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, para aquellos usufructos, fideicomisos sucesivos, etc., que se encontraban vigentes en aquel momento y que se habían constituido antes del 1 de enero de 1857.

f.9) Leyes relativas a la sucesión por causa de muerte.

Los arts. 18 y 19 se refieren a la sucesión testada. El art. 20, inciso 1º, a la sucesión intestada y el art. 21 a la partición de bienes.

Las sucesiones se rigen por la ley vigente al tiempo de su apertura, esto es, por la ley que impera en el momento de la muerte del causante (art. 955). Por consiguiente, dicha norma determina la capacidad e incapacidad de los asignatarios, todo lo relativo al desheredamiento, a la partición de bienes, al derecho de transmisión y al de representación, etc.

i.- *Sucesión testamentaria*.

Es preciso distinguir en todo testamento entre los requisitos externos, los requisitos internos y las disposiciones testamentarias:

i) *Requisitos externos o solemnidades que la ley exige para la validez del testamento y para su prueba*: se rigen por la *ley vigente al otorgamiento del testamento.* Dispone el art. 18, en su primera parte: "Las solemnidades externas de los testamentos se regirán por la ley coetánea a su otorgamiento".

En consecuencia, aunque en el lapso que media entre el otorgamiento del testamento y la muerte del testador se modifique la ley en lo concerniente a la forma

de otorgamiento del testamento, dicha reforma legal no afectará a los testamentos otorgados antes de tal reforma, en lo que concierne a las solemnidades del testamento.

ii) *Requisitos internos, que dicen relación con la capacidad y la libre y espontánea voluntad del testador*: el art. 18 nada dice al respecto. Los autores dan soluciones contradictorias.

José clemente Fabres afirma que la capacidad y libre voluntad del testador se rigen por la ley vigente al tiempo de la muerte del mismo. Ello, porque el testamento es un simple proyecto que no cobra eficacia sino con la muerte del testador y si el legislador cree que no está perfecta la voluntad sino cumpliendo con los requisitos que impone una nueva ley, es natural que lo exija para todos aquellos que mueren después de promulgada la ley que lo establece. La ley, corrobora otro autor, dice expresamente que las *"disposiciones"* contenidas en el testamento están subordinadas a la ley vigente a la época en que fallece el testador. Ahora bien, las disposiciones del testamento no son sino el efecto de la capacidad y de la libre voluntad del testador; luego, es necesario que tal capacidad y voluntad hayan existido a la fecha en que esas disposiciones se entienden dictadas, y para decidir si efectivamente han existido o no, debe atenderse a las precauciones que esa misma ley establecía para garantizar la perfección de la voluntad.[289]

Una opinión similar es la que plantea Luis Claro Solar: "Los *requisitos internos* del testamento, esto es, la capacidad y libre voluntad del testador, afectan a la validez del testamento en el día de su confección y en el día de la muerte del testador; es necesario, por lo tanto, que éste sea capaz, según la ley en vigor a la fecha del testamento, y además según la ley que existía cuando ha muerto. Hasta esta última fecha el testamento era un simple proyecto que una ley nueva puede reducir a la nada, quitando a su autor la capacidad que le pertenecía hasta entonces. Pero al mismo tiempo es indispensable que este proyecto haya sido regularmente formado el día de su confección, porque la nueva ley no podría validar un acto nulo en su origen".[290]

A juicio de Alessandri, lo más aceptable es que los requisitos internos del testamento se deban cumplir conforme a la ley vigente al tiempo de su otorgamiento. Si bien la Ley sobre efecto retroactivo no es clara, el texto del art. 18 opone las "solemnidades externas" a las "disposiciones", siendo claro, en su opinión, que se quiso incluir en la primera expresión todo lo relacionado con el otorgamiento del testamento. Y si alguna duda cabe, agrega Alessandri, ella desaparece ante el tenor de los arts. 1005 y 1006. El último precepto daría la pauta para conocer la intención del legislador, al establecer que la capacidad del testador, es decir uno de los requisitos internos del testamento, se rige por la ley vigente al tiempo de otorgarse.[291]

iii) *Disposiciones testamentarias (herencias y legados que se instituyen en el testamento)*: el contenido del testamento, está sujeto a *la ley vigente al tiempo de la muerte del testador*. Dispone el art. 18, después del primer punto y coma: "pero las disposiciones contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley vigente a la época en que fallezca el testador. / En consecuencia, prevalecerán sobre las leyes anteriores a su muerte, las que reglan la incapacidad o indignidad de los herederos o asignatarios, las legítimas, mejoras, porción conyugal[292] y desheredamientos".

Obedece lo anterior a que las disposiciones del testador se reputan dictadas inmediatamente antes de su muerte, ya que el testamento es esencialmente revocable y sólo produce sus efectos al fallecer el testador. El derecho del heredero o legatario nace con la muerte del testador y es entonces cuando debe ser capaz y digno de recoger su asignación. Si lo era, una ley nueva no puede quitarle su derecho, que ya

---

[289] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 354, p. 238.
[290] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 137, p. 79.
[291] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 354, pp. 238 y 239.
[292] La "porción conyugal" desapareció con la reforma de la Ley Nº 19.585, de 1998.

se ha incorporado a su patrimonio y por ende puede transmitir a su vez a sus propios herederos, junto con sus demás bienes; pero si la nueva ley se ha dictado antes de la muerte del testador, ella afectará al asignatario, sin que por ello tenga efecto retroactivo, porque sólo destruye una mera expectativa, no un derecho adquirido (por ejemplo, si una nueva ley dispone, antes del fallecimiento del testador, que será incapaz de suceder el abogado que hubiera redactado el testamento).

El art. 19 es una consecuencia del principio anterior: "Si el testamento contuviere disposiciones que según la ley bajo la cual se otorgó no debían llevarse a efecto, lo tendrán sin embargo, siempre que ellas no se hallen en oposición con la ley vigente al tiempo de morir el testador".

Así, por ejemplo, si hoy un testador deja todos sus bienes a un extraño y no respeta por lo tanto las asignaciones forzosas (es decir, las que está obligado a hacer a ciertas personas por mandato de la ley) y si antes de su fallecimiento se dicta una ley que suprime tales asignaciones forzosas, sus disposiciones testamentarias tendrán pleno efecto. Podríamos decir que, en este caso, las disposiciones testamentarias cobran eficacia con posterioridad al otorgamiento del testamento.

ii.- *Sucesión intestada*.

La misma regla que el art. 18 establece sobre las disposiciones testamentarias, se aplica a la sucesión intestada. *Debemos estar a las normas vigentes a la muerte del causante*. De tal forma, el que era incapaz según la antigua ley, puede recibir la asignación si a la apertura de la sucesión la nueva ley lo considera capaz. Por el contrario, el que era capaz de suceder bajo la antigua ley no podrá recoger la herencia si en el instante de su delación, es incapaz con arreglo a la nueva ley.

Lo mismo cabe decir respecto de las normas que regulan los órdenes sucesorios (arts. 988 y siguientes del Código Civil). Regirán en la sucesión intestada del causante, las normas vigentes a la época de su muerte.

iii.- *El derecho de representación*.

El art. 20 se refiere a este derecho, definido a su vez en el art. 984, inc. 2º del Código Civil en los siguientes términos: "La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder".

El caso más usual de representación en materia sucesoria, opera cuando fallece el heredero directo antes que el causante, pero el primero deja a su vez hijos. Por ejemplo, el hijo del causante fallece antes que éste, pero le sobreviven sus propios hijos, nietos por ende del causante, que "representan" a su padre en la sucesión del abuelo, y llevan la cuota que le habría correspondido al hijo. Los nietos serán herederos "indirectos" y sucederán "por estirpe", es decir colectivamente, repartiéndose la cuota que le habría correspondido al hijo del causante, si hubiere vivido al tiempo de abrirse la sucesión del causante.

Dispone el inc. 1º del art. 20 que tal derecho se regirá por la ley vigente a la apertura de la sucesión: "En las sucesiones forzosas o intestadas el derecho de representación de los llamados a ella, se regirá por la ley bajo la cual se hubiere verificado su apertura".

Ejemplo: si mañana se estableciera por una ley que el derecho de representación sólo tiene cabida hasta el segundo grado de parentesco en línea recta y no sin limitaciones, como ocurre ahora, y si la sucesión se abre bajo el imperio de la nueva ley, los bisnietos del causante, que en conformidad a la ley antigua podían heredar por derecho de representación, ahora no lo podrían hacer, porque son parientes en tercer grado del causante.

Establece por su parte el inciso 2º del art. 20 lo que sucede ante un cambio de legislación, si en el testamento se había llamado a suceder según las normas del derecho de representación: "Pero si la sucesión se abre bajo el imperio de una ley, y

en el testamento otorgado bajo el imperio de otra se hubiese llamado voluntariamente a una persona que, faltando el asignatario directo, suceda en el todo o parte de la herencia por derecho de representación, se determinará esta persona por las reglas a que estaba sujeto ese derecho en la ley bajo la cual se otorgó el testamento".

En este caso, el testador ha instituido heredero a una persona determinada y de llegar a faltar, dispone que deben ser llamadas las personas que tienen derecho a representar al primer heredero (sin indicar quiénes son). En esta hipótesis, dice la ley, para la determinación de esas personas se atenderá a la ley vigente a la fecha en que se otorgó el testamento. En otras palabras, si la nueva ley dispone que otros serán los llamados a representar al primer heredero, se preferirá a los que podrían haber concurrido bajo el imperio de la ley antigua. Lo anterior se explica, porque el testador tuvo en vista, para referirse al derecho de representación, la ley vigente a la época en que otorgó el testamento. Cabe señalar que en este caso no hay en realidad sucesión por derecho de representación, puesto que tal derecho no tiene lugar en la sucesión testada. Lo que ocurre es que el testador manifiesta su voluntad, en orden a indicar quienes heredarán, remitiéndose al derecho de representación que la ley consagra para las sucesiones intestadas.

iv.- *Partición y adjudicación*.

El art. 21 regula la materia: "En la adjudicación y partición de una herencia o legado se observarán las reglas que regían al tiempo de la delación".

Para que opere la partición, es necesario que hallan dos o más herederos, o que la cosa legada se haya dejado a dos o más legatarios conjuntamente.

De esta forma, establece el precepto que en la partición y adjudicación subsecuente de una herencia o legado, regirán las normas vigentes a la época de la delación de la herencia. Es decir, *las vigentes al momento del fallecimiento del causante*.

La "delación de la herencia" está definida en el art. 956, inc. 1º del Código Civil: "La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla". Agrega el inc. 2º que "La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional". Este llamamiento se producirá, entonces, por regla general, inmediatamente después de la muerte del causante. Sin embargo, si la herencia o legado quedare sujeta al cumplimiento de una condición suspensiva, la delación sólo se producirá al cumplirse dicha condición.

No debe creerse que en el caso de una herencia o legado dejados bajo condición suspensiva, la partición se regirá por la ley vigente al momento en que se cumpla la condición. No es así. Siempre se regirá dicha partición por la ley vigente al fallecimiento del causante. Lo anterior, porque cumplida que sea la condición, sus efectos se retrotraen al momento en que se produjo la muerte del causante, como si la delación (es decir el llamamiento) hubiere sido pura y simple y no sujeta a condición.

Así, por ejemplo, hasta el 26 de octubre de 1999, antes de entrar en vigencia la reforma introducida al Código Civil por la Ley Nº 19.585 (llamada "Ley de Filiación"), los hijos "naturales" (nacidos fuera del matrimonio pero reconocidos), recibían la mitad de lo que correspondía a un hijo "legítimo" y en su conjunto, los primeros no podían llevar más de una cuarta parte de la herencia intestada. A partir del 27 de octubre de 1999, tienen idénticos derechos en la herencia de su padre o madre. Ahora bien, supongamos que el causante hubiere muerto el 25 de octubre del año 1999, pero sus tres únicos herederos –un "hijo legítimo" y dos hijos "naturales"-, se mantienen aún en comunidad. Si la partición se lleva a cabo hoy día y en el marco de la misma el Juez Partidor dispone la venta en pública subasta de los bienes indivisos, el primero recibirá un setenta y cinco por ciento y los otros dos, en conjunto, un veinticinco por ciento del precio que se obtenga por la venta de los bienes comunes, es decir cada uno un doce

coma cinco por ciento. En cambio, si el causante hubiere fallecido el 28 de octubre del año 1999, lo obtenido con la venta de los bienes se debe repartir en tres partes iguales, correspondiendo a cada hijo un tercio del precio de venta.

f.10) Leyes relativas a los contratos.

Dispone el art. 22 que "En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración".

Como expresaba George Antoine Chabot, "Los contratos, puros o condicionales, deben regirse siempre, en todos sus efectos, por la ley vigente cuando su celebración, aunque se cumplan las condiciones, los efectos se verifiquen y la ejecución se realice bajo el imperio de la ley posterior".[293]

En realidad, como expresa Borja, la regla no es tan amplia como pareciere conforme a su tenor literal: "No es cierto que en los contratos se supongan incorporadas *todas las leyes* vigentes cuando su celebración; pues no se incorporan sino las *leyes sustantivas civiles*".[294]

En consecuencia, dichas leyes sustantivas determinan tanto los requisitos necesarios para la validez del contrato como el alcance de los derechos y obligaciones por él generados. Por ende, todo lo relativo a los requisitos internos o de fondo de un contrato -consentimiento exento de vicios, capacidad, objeto lícito y causa lícita-, así como lo concerniente a sus requisitos de forma o solemnidades, han de entenderse cumplidos conforme a la ley vigente a la época de su celebración. De la misma forma, lo concerniente a los efectos del contrato –derechos y obligaciones por él generados-, se regirán por la ley que se encontraba vigente al momento en que aquél se celebró. Tal contrato, fundado en lo expresamente estipulado y en la legislación vigente que le sea aplicable, incorporada en el contrato como un estatuto jurídico residual o supletorio de la voluntad, será una ley para los contratantes (art. 1545).

De esta manera, como señala Hernán Corral, el contenido de un contrato no podrá verse alterado por una ley posterior a su celebración. Dicho contenido invariable del contrato estará compuesto por:

i.- Las estipulaciones expresas de las partes (art. 1545).

ii.- Las disposiciones legales supletorias (art. 1546).

iii.- Las leyes imperativas que se imponían a la voluntad de las partes (art. 1546). En este punto, surge sin embargo una pregunta: no habría duda que Corral se refiere a las leyes imperativas vigentes al momento en que se celebró el contrato. Pero la interrogante surge respecto de las normas imperativas que disponga la nueva ley. ¿Se aplican ellas al contrato celebrado con antelación a su vigencia? Nos referiremos a ello seguidamente.

iv.- Las costumbres supletorias vigentes en esa época (art. 1546).

Borja señalaba que "De la regla que en todo contrato se consideran incorporadas las *leyes sustanciales civiles* vigentes cuando su celebración se deducen, entre otras, las siguientes:

1ª. Aun cuando el contrato dependa de una condición, y ésta se cumpla cuando rige una ley posterior, la ley vigente cuando fue celebrado es la única aplicable al contrato mismo y a todos sus resultados;

2ª. La rescisión por lesión enorme se juzga según la ley vigente cuando [se celebra] el contrato;

3ª. Si la ley coetánea a la celebración declara que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse lo pactado, la propia ley se aplicaría aunque la posterior aboliese esta causa de resolución;

---

[293] Citado por Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 169.

[294] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 167.

4ª. La ley aplicable al contrato de arrendamiento, es la que determina si el comprador debe o no respetarlo;[295]
5ª. Si una ley posterior altera el máximum del interés que puede estipularse, o los intereses legales de la mora, los intereses se exigen conforme a la ley vigente cuando el contrato fue celebrado".[296] En el mismo caso, un criterio semejante expresa Claro Solar: "Una ley que limita el tipo de interés convencional del dinero, no puede afectar a las estipulaciones hechas bajo una ley que admitía la libertad de interés; ni una ley que admita la libertad de interés puede ser aplicada a las estipulaciones hechas bajo una ley que limitaba el tipo de interés".[297]

Así las cosas, el contenido del contrato habrá quedado irrevocablemente fijado de conformidad a los arts. 1545 y 1546 del Código Civil, en relación al 22 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes.

Con todo, no obstante los términos generales que tiene el art. 22, es necesario formular algunos distingos, conforme expresa Claro Solar: "En todo contrato se distinguen los requisitos internos o condiciones de fondo requeridas para su validez y los efectos, o sea los derechos y obligaciones a que el contrato da origen. Los primeros figuran entre las condiciones *esenciales* de un contrato; los segundos constituyen las cosas que son de la naturaleza del contrato o puramente accidentales, según el tecnicismo del artículo 1444 del Código Civil".[298]

Debemos considerar entonces, por una parte los *requisitos esenciales* del contrato, y por la otra, los *efectos* del mismo:

i.- *En cuanto a los requisitos de existencia y de validez del contrato*.

Regirá la ley vigente a la época de su celebración, sea que se trate de un contrato cuyo contenido pueden pactar íntegramente las partes o de un contrato dirigido, cuyo estatuto es fijado mayoritariamente por el legislador en forma imperativa.

Claro Solar señala al respecto que "En lo que concierne a las condiciones de fondo requeridas para su validez, los contratos son regidos por la ley existente a la época de su celebración. Un contrato, en efecto, crea derechos, adquiridos desde el momento de su perfeccionamiento, puesto que la aptitud que la ley concede para celebrarlo así, ha sido ejercida y estos derechos no deben, por consiguiente, recibir ataque alguno de una ley nueva que cambiara las condiciones de validez, requeridas por la ley que regía al tiempo de su celebración".[299]

ii.- *En cuanto a los efectos del contrato*.

Afirma Claro Solar que "Del mismo modo, los efectos del contrato son regidos por la ley en vigencia a la época de su perfeccionamiento, y están al abrigo de un cambio de legislación. Ellos dependen exclusivamente de la voluntad de los contratantes, aunque esta voluntad no se haya manifestado expresamente, pues la ley la suple o interpreta, en el sentido de que cuando las partes no han determinado completamente los efectos que el contrato debe producir, se considera que han querido referirse a la ley en este punto y no podría ser a otra ley que aquella que existía a la época del contrato. Hacerlos regir por una nueva ley, que los contratantes no han podido tener en vista al contratar, sería substituir una nueva convención a la que las partes han celebrado, y despojarlas, al mismo tiempo, de derechos adquiridos. La aplicación en esta forma del principio de la no retroactividad tiene una importancia

---

[295] Esto se debe relacionar con el art. 1962 del Código Civil.
[296] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., pp. 165 y 166. Aquí, me parece que el ilustre jurista ecuatoriano cometió un error: es correcto lo que señala respecto de los intereses *convencionales*, pero no lo es en lo que atañe a los intereses *legales*, habida cuenta de lo que dispone el art. 22 Nº 2, de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, según revisaremos.
[297] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 146, p. 84.
[298] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 143, p. 81.
[299] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 143, p. 81.

práctica considerable, pues sólo ella puede dar una confianza absoluta en la eficacia de los contratos, confianza indispensable para la seguridad de las transacciones civiles, a que está vinculado el progreso y el perfeccionamiento social. Estas son las ideas que expresa el artículo 22, al decir que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Forman un solo cuerpo con el contrato, porque ellas determinan tanto los requisitos necesarios a la validez del contrato como el alcance de los derechos y obligaciones a que el contrato da lugar. La nueva ley no puede aplicarse a ellos sin producir efecto retroactivo. (…) El alcance y significación que damos al artículo 22 están conformes con la historia de su establecimiento. En el mensaje del Presidente de la República se decía: 'El que contrata no lo hace por lo regular, tomando en cuenta sólo el momento en que ajusta su convención, sus cálculos abrazan además el porvenir y trata de asegurarse al amparo de la ley una posición que, en cuanto se pueda, esté a salvo de eventualidades caprichosas. Sería, pues, contrariar hasta un punto muy peligroso la confianza en las especulaciones, si hubiera de verse expuesto en el curso de su desarrollo a sufrir los cambios más o menos radicales que se originasen de la promulgación de una nueva ley. Para evitar estos inconvenientes, el proyecto sienta el principio de considerar incorporadas en un contrato las leyes que eran aplicables al tiempo de su celebración'".[300]

Sin embargo, a nuestro juicio el planteamiento de Claro Solar, si bien correcto como principio general aplicable en la materia, debe matizarse, siendo necesario subdistinguir, según si se trata:

i) De un contrato *cuyo contenido principal pueden pactar íntegramente las partes*. Se trata de los contratos exclusivamente patrimoniales, regidos por normas que mayoritariamente son de orden privado, y por ende, cuyo principal contenido pueden fijar los contratantes libremente, según ya se expuso: estos contratos se regirán, en cuanto a sus efectos, por la ley vigente a la época de su celebración. Operará aquí en plenitud la ultra-actividad de la ley.

ii) De un *contrato dirigido,* es decir, *cuyo estatuto es fijado mayoritariamente por el legislador en forma imperativa*: se regirán sus efectos por la ley vigente a la época en que éstos se produzcan. No habrá en tal caso ultra-actividad de la ley, sino efecto inmediato de la ley. Así, por ejemplo, tratándose de los contratos de familia, como el contrato de matrimonio, o el contrato de trabajo, o a juicio de algunos el contrato de arrendamiento de predios urbanos. En todos estos casos, si se modifica la legislación que regula estos contratos, dicha reforma afectará tanto a los contratos celebrados antes de la reforma, como a los que se convengan después de la mutación legal. Veamos algunos ejemplos:

1° *Respecto del contrato de matrimonio*, una ley nueva, que modificare el art. 1749 del Código Civil y agregare otra limitación a la administración del marido de los bienes sociales, habiendo régimen de sociedad conyugal: por ejemplo, estableciere que el marido deberá obtener autorización de la mujer o de la justicia en subsidio, para enajenar bienes muebles cuyo valor supere las 10 unidades de fomento. En tal caso, el marido no podría aducir que tal limitación no se le aplica, habida cuenta que al contraer matrimonio, la ley no la contemplaba.

2° *Respecto del contrato de trabajo*, una ley nueva, que dispusiere que la jornada semanal de trabajo no podrá exceder de cuarenta horas. El empleador que hubiere celebrado con el trabajador el contrato antes de la reforma (hoy puede llegar a cuarenta y cinco horas semanales), no podrá sostener que la limitación no rige para ese contrato.

3° *Respecto del contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos*, la cuestión es discutible en realidad. Supongamos que una ley nueva, estableciere, por ejemplo, que la renta anual de arrendamiento de predios urbanos cuyo avalúo fiscal no exceda de

[300] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 143-145, pp. 82 y 83.

cincuenta millones de pesos, no podrá superar el 11% anual de dicho avalúo. El arrendador que hubiere dado en arrendamiento el inmueble bajo la vigencia de la ley antigua (que hoy no establece ninguna limitación), ¿podrá pretender que la limitación no rige para dicho contrato? Se podría responder negativamente, sobre la base de encontrarnos ante un contrato dirigido. Ello, porque conforme al art. 19 de la Ley N° 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, los derechos que esta ley confiere a los arrendatarios son irrenunciables. Adicionalmente, podría considerarse que no puede pretenderse por el arrendador que no se le aplique la reforma legal, pues la ley no se está aplicando con efecto retroactivo sino con efecto inmediato. Es decir, no se afectará al arrendador en lo que concierne a las rentas ya percibidas o devengadas, sino sólo a las que se devenguen en el futuro. Sin embargo, esta conclusión *pro arrendatario* podría discutirse, sobre la base de atentar la ley nueva contra el derecho de propiedad del arrendador, en este caso, consistente en percibir la renta pactada por todo el período de vigencia del contrato. Aunque su crédito esté sujeto a plazo suspensivo, y no pueda cobrar por ahora las rentas futuras, se trata de un derecho ya incorporado al patrimonio del arrendador. Es decir, tiene propiedad sobre ese crédito, aunque no sea actualmente exigible. En otras palabras, y tal como ya lo hemos señalado, la ultra-actividad de la ley anterior debiera prevalecer sobre el efecto inmediato de la nueva ley, fundando esta conclusión en la garantía constitucional del derecho de propiedad sobre toda clase de cosas, corporales como incorporales.

Dos excepciones, establece sin embargo, el citado art. 22:

i.- En lo relativo a *las leyes procesales*: se aplicarán las leyes vigentes al momento de promoverse la contienda judicial. Ello, porque las leyes procesales rigen *in actum*. No hay ultra-actividad respecto de ellas. Establece el art. 22, Nº 1, que se exceptúan de la regla inicial del precepto: "Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de ellos".

En todo caso, *en materia de prueba*, debemos distinguir conforme lo dispone el art. 23, entre las leyes procesales sustantivas -*qué medios de prueba se admiten*- y las leyes procesales adjetivas -*cómo debe rendirse la prueba*.

En cuanto a los *medios de prueba admisibles*, rige la ley vigente al celebrarse el contrato. En efecto, "Que los actos o contratos deban probarse conforme a la ley vigente cuando su ejecución o celebración, es del todo conforme a los principios; porque la ley garantiza los derechos adquiridos, y derecho adquirido es el de rendir, a suscitarse controversia, las pruebas puntuales por la ley vigente cuando la ejecución del acto o celebración del contrato. Las partes no podían prever que una ley posterior exigiría otras pruebas que las determinadas por la ley a que se sujetaron cuando la ejecución del acto o celebración del contrato".[301] Así, por ejemplo, hoy se desprende del art. 1709 del Código Civil, interpretado *a contrario sensu*, que será admisible la prueba de testigos para un acto o contrato que contenga la promesa o entrega de una cosa que valga *menos* de dos unidades tributarias (mensuales). Si se modificare este artículo y se estableciere que dicha prueba no se admitirá cuando el contrato contenga la promesa o entrega de una cosa que valga *menos* de una unidad tributaria mensual, dicha restricción no podrá aplicarse a los contratos celebrados con antelación a la reforma.

Con todo, refiere Claro Solar, "El artículo 23 no habla, sin embargo, de que los actos o contratos *deberán* probarse, sino que *podrán* probarse en conformidad a la ley de su otorgamiento, lo que quiere decir que en concepto del legislador es admisible valerse de un medio de prueba que la antigua ley no reconocía o prohibía".[302] En otras palabras, el precepto sería facultativo para la parte que quiera recurrir a los medios de

[301] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 171.
[302] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 151, p. 85.

prueba que consagraba la ley antigua, pero ello no le impediría valerse de los medios de prueba que establezca la ley nueva.

En cuanto *a la forma de rendir la prueba*, rige la nueva ley. Dispone el art. 23: "Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquélla establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere". Así, por ejemplo, conforme al art. 320 del Código de Procedimiento Civil, si no se ha presentado recurso de reposición contra la resolución que recibe la causa a prueba, cada parte deberá presentar una minuta de los puntos sobre los que piense rendir prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad y precisión y una nómina de los testigos de que piensa valerse, dentro de los cinco días siguientes desde la última notificación de dicha resolución. Si se modificare tal norma, y se estableciere que el plazo sólo será de tres días, regirá la ley nueva. Lo mismo cabe señalar respecto de la forma en que se interrogará a dichos testigos.

ii.- En lo relativo a *las penas que por la infracción del contrato impongan las leyes*: el incumplimiento se castigará conforme a la ley vigente a la época de la infracción, y no por aquélla que regía al tiempo de la celebración del contrato. Establece el Nº 2 del art. 22 que se exceptúan de la regla inicial del artículo, "Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellos; pues ésta será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido".

Cabe precisar que la norma se refiere a las penas que impone la ley, no a las penas estipuladas por las partes en caso de incumplimiento. Estas últimas quedan sujetas a las leyes vigentes al tiempo de celebrar el contrato. Así, por ejemplo, si por la ley vigente al tiempo de la celebración del contrato se castiga la infracción con la indemnización de perjuicios, comprendiéndose en éstos tanto el daño emergente como el lucro cesante (art. 1556) y con posterioridad una ley establece que la indemnización se limitará al daño emergente, las infracciones verificadas bajo la vigencia de esta nueva ley sólo obligarán a responder por este único perjuicio y no por el lucro cesante. En cambio, la pena estipulada por las partes (cláusula penal) se mantendrá inalterable. Se ha dicho, a propósito de esta excepción, que ella se referiría exclusivamente a las leyes penales, y no a las civiles.[303] Nos parece que ambas clases de normas quedarían comprendidas bajo la expresión "penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellos" (en los contratos), pues la "pena" operaría al infringir lo estipulado en el contrato, no al infringir lo estipulado en la ley (donde podría configurarse una eventual responsabilidad penal). Lo mismo refería Borja, refiriéndose a esta norma: "Las cláusulas penales forman parte de la convención, y confieren derechos adquiridos, que a modificarse por las leyes posteriores surtirían éstas efecto retroactivo".[304]

El art. 22 nada dice acerca de las restantes fuentes de las obligaciones. Borja, después de aludir al art. 1437 del Código Civil, que señala las fuentes de las obligaciones, considera que debe aplicárseles la misma regla: a las obligaciones que deriven de las demás fuentes, también debe aplicárseles la ley vigente al tiempo en que se verifica el cuasicontrato, el delito o el cuasidelito: "El artículo que comentamos no habla sino de los contratos, y silencia las demás fuentes de las obligaciones (…) Ahora bien, ¿qué leyes serán aplicables a las obligaciones que nacen de los cuasicontratos, delitos y cuasidelitos? Inconcuso nos parece que también se incorporan las *leyes sustantivas civiles* vigentes cuando la ejecución del acto lícito de donde la obligación nace. No hay razón alguna para distinguir, en cuanto a la ley aplicable, entre los contratos y cuasicontratos; pues aquéllos no se diferencian de éstos sino en que el consentimiento se manifiesta, ya expresa o tácitamente, ya de una manera

[303] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 140.
[304] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., p. 168.

presunta. De los cuasicontratos nacen derechos; éstos constituyen *derechos adquiridos*, y la nueva ley no puede alterarlos. Lo mismo opinamos en cuanto a las obligaciones provenientes de los delitos o cuasidelitos; pues si tan luego como ellos se cometen hay un derecho adquirido, la ley posterior debe respetarlo. De manera que, como ya lo hemos insinuado, la regla hubiera sido completa y exacta diciéndose: *todo lo concerniente a las obligaciones que nacen de un hecho voluntario, lícito o ilícito, se determina por las leyes sustantivas civiles vigentes cuando la obligación se contrajo*".[305]

Concordamos con lo señalado por Borja. Así, por ejemplo, tratándose del cuasicontrato de agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, el art. 2290 del Código Civil dispone que, si el negocio ha sido bien administrado, el interesado le reembolsará al agente oficioso "las expensas útiles o necesarias", que el segundo haya invertido al ejecutar la gestión. Supongamos que después de realizada ésta, se modificare el precepto, de manera que el agente oficioso sólo podrá reclamarle al interesado el reembolso de las expensas necesarias, más no de las útiles. Tal reforma, no puede afectar al agente cuya gestión fue realizada bajo la vigencia de la ley antigua. Más claro es todavía el principio, si se trata de la comisión de un delito o cuasidelito civil, tanto desde el punto de vista de quienes los cometen, cuanto desde la perspectiva de la víctima de estos hechos ilícitos. Desde el punto de vista de quienes cometen el delito o cuasidelito, cabe considerar la regla del art. 19 Nº 3, inc. 8º de la Constitución Política, en virtud de la cual: "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado". Desde la perspectiva de la víctima, nace para ésta el derecho a ser indemnizado, en los términos que establecía la ley al momento en que se perpetra el hecho ilícito. Así, el art. 2317 del Código Civil dispone que si dos o más personas participan en la comisión de un delito, responderán solidariamente por el daño causado a la víctima. Si el precepto se reformare y se suprimiere dicha responsabilidad solidaria y se estableciere que la responsabilidad será simplemente conjunta (es decir cada uno por su cuota), ello no puede afectar a quien fue víctima del delito bajo la vigencia de la antigua ley.

f.11) Leyes relativas al procedimiento.

Regula la materia el art. 24: "Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar regir. Pero los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación".

De esta manera, como lo habíamos señalado, las leyes de procedimiento rigen *in actum*, tienen efecto inmediato, desde su promulgación. Frente a tales normas, no cabe hablar de derechos adquiridos.

Excepcionalmente, los plazos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Así, por ejemplo, el término para contestar la demanda en un juicio ordinario, se rige por la ley antigua, si tal plazo estuviere pendiente al dictarse una nueva ley.

f.12) Leyes relativas a la prescripción.

El art. 25 se refiere tanto a la *prescripción adquisitiva como extintiva*: "La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que aquélla hubiese empezado a regir".

---

[305] Borja, Luis F. (1899), ob. cit., pp. 166 y 167.

El Mensaje del Presidente de la República, expresaba respecto de este artículo: "Dándose al prescribiente la facultad de elegir entre el término señalado por la ley antigua y el que prefija la nueva, él verá por cuál de ellos más le convenga decidirse. Si prefiere la antigua ley, ninguna innovación se producirá en su condición ni en la de los derechos de la persona contra la cual está prescribiendo. Si, por el contrario, elige la nueva, ningún ataque se infligirá a los derechos de esta última, desde que todos los requisitos constitutivos de la prescripción deben realizarse después de que dicha ley haya sido promulgada".[306]

La prescripción es un modo de adquirir el dominio o de extinguir los derechos y acciones que emanan de las obligaciones (art. 2492). Conforme al art. 25, es el prescribiente quien elige la ley que debe regir la prescripción alegada. A veces, puede resultarle más ventajoso someterse a la ley nueva y en otras ocasiones, a la ley antigua. Así, por ejemplo, si la ley antigua requería 15 años para adquirir por prescripción y la nueva ley sólo 10 años, y al ser promulgada la última habían transcurrido 7 años, le conviene optar por la primera, pues le faltarían sólo 8 años; si escoge la segunda, debe esperar 10 años, contados desde la promulgación de la nueva ley. Desde el punto de vista de la prescripción extintiva, si la ley antigua establecía que la acción cambiaria emanada del pagaré a la orden prescribía en 4 años contados desde el vencimiento de la obligación, y la nueva ley rebaja a un año tal plazo, pero al promulgarse la última habían transcurrido 3 años 6 meses y el acreedor notifica la demanda 9 meses después de haber sido promulgada la nueva ley, no le convendrá al prescribiente elegir la nueva ley, sino la antigua. En el marco de la antigua ley, la acción cambiaria prescribió tres meses antes de la notificación; en el marco de la nueva ley, faltarían tres meses para que dicha acción prescribiera.

El art. 26 sólo se refiere a la *prescripción adquisitiva*: "Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiese principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción".

La norma se pone en el caso de que una persona entre en posesión de una cosa, de manera que más adelante, transcurrido el plazo previsto en la ley, pueda adquirir su dominio. Sin embargo, si en el lapso intermedio una ley declara que la cosa en cuestión no puede adquirirse por prescripción, el propósito del poseedor no podrá alcanzarse. Regirá la ley nueva, y no la vigente al entrar en posesión de la cosa. Esto, no es sino una aplicación del principio de que la posesión, presupuesto de la prescripción, no es un derecho adquirido sino una mera expectativa.

Así, por ejemplo, el Código Civil actual permite adquirir por prescripción un derecho real de servidumbre, siempre que ésta sea *continua* y *aparente*, como por ejemplo la servidumbre de acueducto superficial. En tal caso, transcurrido que sea un plazo de cinco años, podrá adquirirse esta clase de servidumbre (arts. 882, inc. 2º y 2512 del Código Civil). Ahora bien, supongamos que habían transcurrido tres años, desde que se cavó el acueducto y fluyó el agua por el predio sirviente, para que las recibiera el predio dominante (de manera que faltaban dos años para adquirir el derecho de servidumbre por prescripción), cuando se modifica el Código Civil, y se establece que ninguna servidumbre podrá adquirirse mediante la prescripción, estableciéndose que "ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas" (como dice el inc. 1º del art. 882 para excluir la prescripción en el caso de las servidumbres discontinuas y las inaparentes), no podrá ya alegarse prescripción.

12.2.- Efectos de la ley en cuanto al territorio.

a) *Territorialidad y extraterritorialidad de las leyes*.

---

[306] Citado por Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 155, p. 87,

Los problemas que origina el conflicto de leyes en el espacio, giran en torno a dos principios contrapuestos: el territorial y el personal o extraterritorial. Según el principio territorial, las leyes se dictan para un territorio y tienen su límite dentro del mismo. Según el principio personal, las leyes se dictan para las personas o nacionales de un Estado y siguen a éstas fuera del territorio nacional.[307]

Como expresa Claro Solar, refiriéndose al primero de estos principios, "Siendo cada Estado independiente de los demás, posee y ejerce solo y exclusivamente la soberanía y la jurisdicción en toda la extensión de su territorio. Las leyes de cada Estado, por consiguiente, obligan y rigen a todas las personas que habitan su territorio, aunque no hayan nacido en él, lo mismo que a todas las propiedades muebles o inmuebles que se encuentren en el territorio y a todos los actos o contratos que en él se ejecuten o celebren. (…) Pero si esto sucede dentro del territorio, en virtud de la independencia de los Estados, esta misma independencia es un obstáculo para que la ley pueda, traspasando sus fronteras, afectar directamente o reglamentar objetos que se encuentran fuera de él, u obligar a personas que en él no residen, sea que estén o no sometidas al Estado, por el hecho de su nacimiento. El territorio del Estado viene a ser, de este modo, un límite del imperio de la ley".[308]

Si el primero de los principios se aplicara estrictamente, el Estado podría exigir el reconocimiento exclusivo de su derecho sobre el territorio que le pertenece, pero no podría pretender que sus normas fueren reconocidas más allá de las fronteras. Si se aplicara en términos absolutos el principio personal, el Estado sólo podría legislar para sus nacionales y no podría hacer valer autoridad alguna sobre los extranjeros que residieran en su territorio.[309]

Se visualiza por tanto que la aplicación extrema de uno o de otro principio, generaría graves dificultades. Por eso, cuando las relaciones sociales y comerciales entre las naciones se hicieron más continuas y regulares, se comprendió que la ley no podía ser absolutamente personal ni absolutamente territorial y que resultaba necesario buscar fórmulas de armonía y conciliación entre ambos principios contrapuestos. Esta ha sido la constante aspiración de los sistemas de Derecho Internacional Privado.[310]

b) *Territorialidad de la ley*.

b.1) Normas que lo establecen.

En cuanto a *las personas*, el art. 14 del Código Civil consagra en nuestro Derecho el principio territorial, al disponer que "La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros".

Conforme a lo anterior, en principio, salvas las excepciones que se indicarán, todos los individuos que habitan en el territorio nacional, sean chilenos o extranjeros, quedan sometidos a la ley chilena desde el punto de vista de sus personas, sus bienes y sus actos jurídicos.

Dicho principio, respecto de *los bienes*, también está consagrado en el inc. 1º del art. 16: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile".

El principio de la territorialidad absoluta está presente también en varias disposiciones legales:

i.- En lo que se refiere al matrimonio: art. 80 de la Ley de Matrimonio Civil, que impone a los que se casaron en el extranjero, el cumplimiento de las normas relativas

---

[307] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 385, p. 261.
[308] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nºs. 158 y 159, pp. 87 y 88.
[309] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 385, p. 262.
[310] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 386, p. 262.

a los impedimentos dirimentes o causales de incapacidad (arts. 5 a 7 de la citada ley). Lo mismo ocurre con el art. 12 de la Ley N° 20.830, sobre Acuerdo de Unión Civil: podrá declararse nulo el contrato celebrado en el extranjero, en contravención a lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la citada Ley (por ejemplo, porque los contrayentes no eran mayores de edad).
ii.- En lo relativo a la sucesión abintestato: art. 997, los extranjeros son llamados de la misma manera que los chilenos.
iii.- En el ámbito del Derecho Penal, dispone el art. 5 del Código del ramo que la ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros.[311]
b.2) Excepciones al principio de la territorialidad consagrado en el art. 14.

Dicho principio no tiene más excepciones que las siguientes, admitidas por el Derecho Internacional:
i.- Los soberanos de un Estado quedan sometidos a sus leyes, dondequiera se encuentren;
ii.- Los agentes diplomáticos acreditados ante un país, están sometidos a las leyes del Estado al cual representan; y
iii.- Los barcos de guerra de nación extranjera, aun los surtos en aguas territoriales chilenas, y las aeronaves militares extranjeras autorizadas para volar en el espacio aéreo chileno, están sometidos a las leyes del Estado al cual pertenecen, tratándose de aquellos actos realizados al interior de las naves o aeronaves (por ende, si por ejemplo los tripulantes de un barco de guerra extranjero protagonizan un delito estando desembarcados en un puerto, quedarán sujetos a la ley chilena). Igual principio rige para los barcos y aeronaves militares chilenos, en el extranjero.[312]
b.3) Equiparación de los chilenos y extranjeros.

En compensación a las obligaciones que el art. 14 impone a los extranjeros al someterlos a las leyes chilenas, se les otorga en el art. 57 una franquicia, al establecerse que en lo relativo a la adquisición y goce de los derechos civiles, la ley no reconoce diferencias entre los chilenos y los extranjeros.[313] "De modo que la ley es perfectamente justa –señala Claro Solar- porque, al mismo tiempo que impone las obligaciones, acuerda al extranjero los derechos establecidos por la ley chilena, sin tomar en cuenta la reciprocidad con que las otras naciones pudieran o no tratar a los chilenos".[314]

Hay algunas excepciones a la regla anterior, fundadas más bien en el domicilio antes que en la nacionalidad, como se verá a propósito de esta última.

c) *Extraterritorialidad de la ley*.

Los casos en que la ley produce efectos fuera del territorio del Estado que las dicta, son excepcionales, porque la regla general es que no produzca efectos sino dentro de sus límites. No obstante, hay casos en que la ley chilena produce efectos fuera del territorio nacional, hipótesis en la cual hablamos de extraterritorialidad de la ley chilena.

Para abordar este tema, debemos distinguir entre tres tipos de leyes:
c.1) Leyes personales.
c.2) Leyes reales.
c.3) Leyes relativas a los contratos.[315]

---

[311] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 392, p. 265.
[312] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 394, p. 266.
[313] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 396, p. 267.
[314] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 169, p. 96.
[315] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 398, p. 268.

Este distingo tiene su origen en la teoría de los *estatutos*. Se funda esta teoría, refería Claro Solar, "en la distinción de las leyes según su objeto en *reales* y *personales*, designándose con la denominación de *Estatuto real*, *Statuta realia*, el conjunto de leyes reales y de *Estatuto personal*, *Statuta personalia*, el conjunto de leyes personales, y se había establecido por el uso y la convención tácita de las naciones, como regla general, que las leyes *personales* viajan con el individuo y lo siguen a donde quiera que traslade su residencia, *sicut umbra corpore*,[316] y que, al contrario, las leyes *reales* no ejercen sus efectos sino dentro del territorio. (…) El hombre está sometido a la ley bajo el triple punto de vista de su persona, de sus bienes y de sus actos (…). Según el objeto primordial que la ley tenga en vista será, por consiguiente, *real, personal o relativa a los actos*. (…) Según la doctrina comúnmente admitida, son leyes *personales* aquéllas cuyas disposiciones afectan directa y exclusivamente el estado de la persona, es decir, la universalidad de su condición, de su capacidad o incapacidad para proceder a los actos de la vida civil y que si tienen relación con las cosas es sólo accesoriamente y por una consecuencia del estado y de la calidad del hombre, objeto principal del legislador. Así son personales: la ley que determina si el individuo es nacional o extranjero, la que fija la mayor edad, las condiciones para el matrimonio y la legitimidad, la que somete la mujer a la potestad del marido, el hijo de familia a la patria potestad, la que establece la capacidad de obligarse o de testar, etc. Son leyes *reales* las que se refieren directamente a las cosas para determinar su naturaleza y el modo de poseerlas o adquirirlas, transmitirlas y transferirlas, sin tener relación con el estado o la capacidad general de la persona si no es de un modo incidental y accesorio. A esta clase pertenecen las leyes que dividen los bienes en cosas corporales e incorporales, muebles e inmuebles; las que determinan el derecho de suceder *ab intestato* o por testamento, las que fijan la cuota de libre disposición, etc.".[317]

c.1) Leyes personales.

i.- Consagración en el Código Civil.

La extraterritorialidad de la ley chilena, en lo que respecta a las leyes personales, está determinada por el art. 15 del Código Civil. Similar fundamento tiene el art. 80 de la Ley de Matrimonio Civil.

Dispone el art. 15: "A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero.

1º. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile;

2º. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos".

Debemos precisar que la norma del art. 15 no implica una inconsecuencia con respecto al art. 14. En principio, pareciera haberla, porque mientras el art. 14 declara que en Chile rige solamente la ley chilena (lo que equivale a decir que no se acepta la ley personal del extranjero), en el art. 15 se dispone que la ley personal del chileno rige más allá de las fronteras de nuestro país. Sin embargo, examinando la cuestión a fondo, se ve que no hay tal inconsecuencia:

i) En primer lugar, porque la ley chilena sólo rige en el extranjero para los actos que han de tener efecto en Chile. Ello ocurrirá "cuando los derechos que nacen de dicho acto han de ejercitarse y las obligaciones que producen han de cumplirse en Chile".[318]

ii) En segundo lugar, no se exige ni se pide a las autoridades extranjeras amparo para la ley chilena, para los referidos actos que han de tener efectos en Chile. De tal forma,

---

[316] Es decir, como sombra que sigue al cuerpo.

[317] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nºs. 161 a 163, pp. 89-91.

[318] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 176, p. 98.

en caso alguno se pretende que la ley chilena sea aplicada por tribunales extranjeros.[319]

ii.- Fundamento del art. 15.

El legislador chileno quiere evitar que, mediante un subterfugio, se burlen las leyes nacionales relativas al estado y capacidad de las personas y a las relaciones de familia, todas de orden público, ligadas a la constitución misma de la sociedad, y en especial a la familia, su núcleo básico.[320]

¿Qué alcance tiene la palabra "estado" empleada en el art. 15? No cabe duda que ella encierra el estado civil, pero ello no quiere decir que éste sea su alcance preciso y exclusivo. Nuestra doctrina, sin embargo, ha restringido la palabra al estado civil.[321] Pero a diferencia de lo que suele ocurrir a lo largo del Código, donde la expresión "estado", cuando alude al estado civil, va precisamente seguida de la voz "civil", tal cosa no acontece en el Nº 1 del art. 15.

Revisemos lo que expresa Guillermo A. Borda: "El estado de las personas es la posición jurídica que ellas ocupan en la sociedad; o, para decirlo con más propiedad, es el conjunto de calidades que configuran la capacidad de una persona y sirven de base para la atribución de deberes y derechos jurídicos". Agrega Borda: "Creemos carente de todo fundamento legal y doctrinario, la opinión de quienes limitan la noción de estado al estado de familia (…) De esta manera, resulta trunco y confuso un concepto perfectamente claro; por estado debe entenderse el conjunto de calidades que fijan los derechos y obligaciones de una persona. ¿Por qué limitarlo al estado de familia, si también las calidades propias de la persona y las relativas a la sociedad influyen en sus derechos y obligaciones? Aceptar esa opinión implica introducir confusión en una idea que era clara ya en el derecho romano". Considerando lo expuesto, afirma Borda que "El estado se puede apreciar desde tres puntos de vista: a) Con relación a las personas consideradas en sí mismas: se puede ser mayor o menor de edad, hombre o mujer, sano o demente, médico, militar u obrero; en estos casos, la edad, el sexo, la salud mental, la profesión, hacen surgir distintos derechos y obligaciones. b) Con relación a la familia: una persona puede ser casada o soltera, viuda o divorciada, padre o hijo de familia, pariente, etc. c) Con relación a la sociedad en que vive: puede ser nacional o extranjero".[322]

En rigor, la palabra "estado" es el género, y el estado civil y la capacidad son especies de estados. El numeral pudo aludir sólo al "estado de las personas", y de igual manera se habría comprendido en él lo concerniente a la capacidad. Se explica sin embargo la redacción del precepto, pues se replicó lo que señalaba el art. 3 del Código francés, del siguiente tenor: "Las leyes concernientes al estado y a la capacidad de las personas rigen a los franceses, aunque residan en nación extranjera".

iii.- Aplicación restrictiva del art. 15.

Constituyendo esta norma una excepción al principio general de la territorialidad, debe aplicarse restrictivamente, sólo en los casos que ella contempla. Su carácter excepcional queda de manifiesto teniendo presente:

i) Que sólo se refiere a los chilenos.

ii) Sólo hace obligatorias para el chileno que está fuera del país las leyes chilenas relativas al *estado* de las personas y a su *capacidad* para ejecutar actos que hayan de tener efectos en Chile, y a las obligaciones y derechos que nacen de *relaciones de familia*. Las demás leyes chilenas, aunque sean personales, no obligan al chileno que se halla en el extranjero.

---

[319] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nºs. 399 y 400, p. 269; Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 172, p. 96.

[320] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 401, p. 269.

[321] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 176, p. 97.

[322] Borda, Guillermo A. (2007), ob. cit., Nº 414, pp. 360 y 361.

iii) Sólo se refiere a los actos que hayan de tener efectos en Chile y sólo respecto al cónyuge y parientes chilenos.[323]

iv.- Análisis del Nº 1 del art. 15.

El acto ejecutado por un chileno en el extranjero está sujeto a la ley chilena, en cuanto a su estado y capacidad, si ese acto va a producir efectos en Chile. Si los produce, queda sujeto a las leyes chilenas; en caso contrario, se rige por las leyes del país en que el acto se realiza. Un acto produce efectos en Chile cuando los derechos y obligaciones que origina, se hacen valer o intentar cumplir en Chile.[324] Así lo expresa una sentencia de la Corte de Santiago de fecha 13 de enero de 1931.[325]

Así, por ejemplo, en cuanto a la capacidad, si un chileno de 17 años, domiciliado en Panamá, donde la mayoría de edad fuere adquirida a los 16 años, vende un bien raíz ubicado en Chile, tal compraventa adolecerá en nuestro país de nulidad relativa, a menos que el vendedor hubiere actuado representado o autorizado. En Panamá en todo caso, el acto es válido.

De igual forma, en cuanto al estado de una persona, si por ejemplo un chileno de sólo 13 años contrae matrimonio en Arabia Saudita, donde los varones pueden celebrar tal contrato a partir de los 12 años, el matrimonio adolecerá de nulidad en Chile. El mismo principio se recoge en la Ley de Matrimonio Civil, art. 80 en relación a los arts. 4 a 7.

v.- Análisis del Nº 2 del art. 15.

Esta disposición tiene por objeto proteger a la familia chilena. Los chilenos domiciliados o residentes en el extranjero quedan sometidos a la ley chilena en lo que respecta a sus relaciones de familia; los derechos que emanen de tales relaciones de familia, sólo pueden reclamarse por los parientes y el cónyuge chilenos.[326]

Como expresa Claro Solar, "Esta disposición se presta, desde luego, a la observación de que las obligaciones y derechos a que se refiere, son obligaciones y derechos inherentes al estado civil, que precisamente fija la situación o calidad permanente del individuo, en cuanto depende de sus relaciones de familia. Pero el legislador la ha consignado, porque su propósito era limitar su alcance a los cónyuges y parientes chilenos. Nuestro Código no toma en cuenta, respecto del cónyuge y parientes extranjeros, otros derechos y obligaciones que los determinados por la ley extranjera. De este modo, el número segundo viene a ser una limitación de lo establecido en el número primero; y es como si hubiera dicho que el chileno, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, continúa sujeto a la ley chilena en lo relativo al estado de las personas, menos en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, relativamente a su cónyuge y parientes extranjeros".[327]

Directamente ligada con esta disposición, está la norma del art. 998. La regla general respecto a las sucesiones (art. 955) es que éstas se reglan por las leyes del último domicilio del causante; pero como las leyes chilenas protegen siempre a los parientes chilenos, han establecido que si en una sucesión abierta en el extranjero tiene el causante bienes en Chile, en éstos deberá adjudicarse el total de lo que corresponda a los herederos chilenos, quienes tendrán los mismos derechos que las leyes chilenas les acuerdan en las sucesiones abiertas en Chile. Regirá al respecto el art. 149 del Código Orgánico de Tribunales, que dispone que cuando una sucesión se abra en el extranjero y comprenda bienes situados en Chile, la posesión efectiva de la

---

[323] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 402, p. 270; Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 71, pp. 71 y 72.

[324] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 403, p. 270.

[325] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 111.

[326] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 404, p. 271.

[327] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 177, p. 98.

herencia deberá pedirse ante el juez del lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del que la pida si aquél no lo hubiere tenido (art. 833 del Código de Procedimiento Civil); este juez será también competente para conocer de la apertura y publicación del testamento (art. 1009 del Código Civil). El art. 998 está ubicado entre las reglas de la sucesión abintestato y comienza diciendo "en la sucesión abintestato de un extranjero...". Pero de acuerdo con la doctrina unánime, este precepto debe aplicarse por analogía a las sucesiones testamentarias en lo que respecta a las asignaciones forzosas de los sucesores chilenos, pues existen las mismas razones de protección en una y otra sucesión. Así, por ejemplo, si un inglés muere en Londres, en donde existe libertad absoluta para testar, y dicho inglés tenía dos hijos, uno inglés y otro chileno, y al morir el causante deja un testamento en el cual instituye como único heredero a su hijo inglés, y ha dejado bienes en Chile, el hijo chileno tiene derecho a pedir que se le adjudique en esos bienes, todo lo que según la ley chilena debiera percibir a título de legítima, dado su carácter de asignatario forzoso (arts. 1167 y 1182 Nº 1).[328]

c.2) Leyes reales.

i.- Consagración en el Código Civil.

Son las que se refieren directamente a los bienes, y sólo de un modo accidental o accesorio a las personas. El principio general, basado en la territorialidad, es que los bienes situados en Chile, se rigen por la ley chilena. Así lo establece el art. 16: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile". El precepto consagra el principio *"lex loci rei sitae"* en su más amplia expresión.[329]

No se toma en consideración para determinar cuál es la ley aplicable a un bien situado en Chile, la nacionalidad del propietario, sino que exclusivamente el lugar de su ubicación.

A contrario sensu, se desprende del art. 16, inc. 1º, que los bienes situados en el extranjero no están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean chilenos y residan en el territorio nacional.[330]

Cabe advertir que el art. 16, inc. 1º sólo se refiere a los bienes corporales. Muebles e inmuebles, pues sólo ellos pueden encontrarse "situados" en Chile.[331] Se podría entender que se aplica a los derechos reales que se tengan sobre tales bienes. En cambio, los derechos personales y las obligaciones correlativas, se regirán por el inc. 2º del mismo artículo.

ii.- Excepciones al principio anterior.

i) *La del art. 16, inc. 2º*. En efecto, la regla del art. 16, inc. 1º, se entiende, sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en el extranjero. Esto implica que no obstante estar situados los bienes en Chile, las estipulaciones contractuales que a ellos se refieren, otorgadas válidamente en el extranjero, tienen pleno valor y efecto en Chile (el art. 16, inc. 3º, contiene una contra-excepción, que nos devuelve al principio general del inciso 1º, como veremos). Previene Claro Solar que, "Esta excepción no importa, como pudiera creerse, que el Código acepta que, por medio de un contrato otorgado válidamente en país extranjero, se pueda contrariar o infringir todas las leyes reales chilenas. Ello sería sencillamente absurdo. La intención del legislador no ha podido ser, por ejemplo, declarar lícitas las estipulaciones contrarias al orden público chileno o a las buenas costumbres, porque ello habría sido una abdicación de los más sagrados deberes que el interés social le impone".[332]

---

[328] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 404, p. 271.
[329] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 180, p. 99.
[330] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 405, p. 272.
[331] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 149.
[332] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 192, p. 107.

ii) *La del art. 955*: en efecto, de acuerdo al inc. 1º del art. 16, dado que los bienes situados en Chile están sujetos a la ley chilena, la manera de adquirir dichos bienes también ha de ser conforme a nuestra ley. Sin embargo, según el art. 955, la sucesión -que es un modo de adquirir- se regla por la ley del último domicilio del causante; de suerte que si éste fallece teniendo su último domicilio en el extranjero, se regirá por la ley del país en el cual tenía su último domicilio (sin perjuicio que en lo relativo a los bienes que se encuentran en Chile, regirá el art. 149 del Código Orgánico de Tribunales). Aquí, también opera una contra-excepción, que nos devuelve al principio general del art. 16, inc. 1º: la contenida en el art. 998, ya visto, respecto del cónyuge y parientes chilenos.[333] Como refiere Claro Solar, "Siendo la sucesión por causa de muerte, un modo de adquirir el dominio y los derechos reales, excepto los intransmisibles, debería rigorosamente regirse por la ley chilena en cuanto a los bienes situados en Chile, desde que son evidentemente reales todas las leyes que reglan los modos de adquirir las cosas y los derechos constituidos en ellas. El artículo 955 sanciona, sin embargo, un principio contrario y dispone que la sucesión se rija por la ley del domicilio".[334]

Visualicemos lo anterior con un ejemplo: si un alemán fallecido en Colonia y teniendo su último domicilio en dicha ciudad deja bienes en Chile, en principio, según la regla general del art. 16, inc. 1º, la sucesión de sus bienes deberá regirse por la ley chilena; pero en virtud del art. 955, correspondería aplicar la ley alemana (la del último domicilio); con todo, si hay chilenos con derecho a herencia o alimentos, sus derechos se reglan por las leyes chilenas y podrán solicitar que se les adjudique el total de lo que les corresponda en los bienes situados en Chile, solicitando incluso en nuestro país la posesión efectiva de la herencia, en lo tocante a esos bienes (art. 998 del Código Civil y art. 149 del Código Orgánico de Tribunales).

Que se desprenda del art. 955 que debe aplicarse la ley extranjera a una sucesión en la que existan bienes en Chile, no quiere decir que los tribunales chilenos no sean competentes para conocer de un litigio que se origine en razón de ellos, como lo precisa una sentencia de la Corte Suprema de 27 de diciembre de 1918: "La excepción contemplada en el artículo 955 del Código Civil, según la cual la sucesión de bienes por causa de muerte queda sometida a las leyes del último domicilio de la persona difunta, se refiere al dominio de esos bienes y a los derechos que sobre ellos puedan establecerse; pero no tiene influencia sobre la jurisdicción de las autoridades chilenas para juzgar y resolver sobre los derechos de cada cual en una sucesión abierta en el extranjero respecto de los bienes situados en Chile".[335] De esta manera, un juez chileno conocerá del litigio, pero en caso de no existir herederos chilenos que invoquen el art. 998, deberá fallarse conforme al Derecho extranjero, operando la excepción al art. 16, inc. 1º, prevista en el art. 955.

c.3) Leyes relativas a los actos y contratos.

Para determinar la ley por la que se rige un acto jurídico otorgado o celebrado en el extranjero y que se hará valer en Chile, debemos distinguir entre:

c.3.1) Los requisitos externos o de forma;
c.3.2) Los requisitos internos o de fondo;
c.3.3) La prueba del mismo; y
c.3.4) Sus efectos.[336]

Los revisamos en el mismo orden:

c.3.1) Ley que rige los requisitos externos o de forma de los actos.

i.- Principios generales.

---

[333] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 407, p. 273.
[334] Claro Solar, Luis (1898), ob. cit., Nº 191, p. 107.
[335] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 113.
[336] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 149.

Son requisitos externos o de forma los que se relacionan con la manera de hacer constar fehacientemente la existencia del acto jurídico. Se trata de los requisitos externos que la ley exige para otorgar o celebrar un acto o contrato. Por ejemplo, la ley chilena exige escritura pública en la compraventa de bienes raíces; o, tratándose del otorgamiento de un testamento abierto, la presencia de al menos tres testigos y notario público o, si no concurre un notario público, la presencia de al menos cinco testigos.

El principio aquí es el siguiente: los actos jurídicos se rigen por *la ley del lugar en que han sido otorgados o celebrados*, cualquiera que sea la legislación del país en que han de producir sus efectos, según el principio *"Lex locus regit actum"*, principio universal de Derecho, consagrado entre nosotros en los arts. 17 (norma general) y 1027 (respecto de los testamentos) del Código Civil y en el art. 80 de la Ley de Matrimonio Civil.

El art. 17, inc. 1°, dispone: "La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados". Agrega acto seguido en su inc. 2°: "La forma se refiere a las solemnidades externas…".

Cabe considerar que si bien el precepto alude a la "forma de los instrumentos públicos", debiéramos entender que el principio también rige para los instrumentos privados. En ambos casos, se aplicarán las formalidades previstas en la ley del lugar en que se otorgue el instrumento. Se trata de un caso de interpretación extensiva de la norma. Así lo ha entendido por lo demás la doctrina y la jurisprudencia.[337]

Sobre el particular, refiere Claro Solar que "Esta disposición es deficiente porque sólo se refiere a las solemnidades o formas de los *instrumentos públicos*; pero se completa con la del inciso 2º del artículo 16 que da valor en Chile a los contratos *otorgados válidamente* en país extranjero y con otras disposiciones del Código, como el artículo 119 [hoy 135], que reconoce la validez del matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad a las leyes del mismo país, y el artículo 1027, que reconoce la validez del testamento otorgado en el extranjero si se han observado en él las solemnidades prescritas por la ley del otorgamiento, sin otra limitación que la de que sea escrito".[338]

Nuestra Corte Suprema ha declarado que este principio es de carácter general, se refiere a todo acto o contrato, a todo instrumento, sea público o privado.

De esta manera, si la ley extranjera acepta cierta forma de una acto jurídico que se otorga en el territorio en el que aquella se aplica, y la ley chilena no, prevalecerá la ley extranjera, atendido el lugar en que el acto se otorgó. Así, por ejemplo, el Código Civil no admite el testamento ológrafo, es decir, aquél escrito, fechado y firmado de puño y letra por el testador, sin intervención de testigos ni de un ministro de fe. Inicialmente, la Corte Suprema consideró que no valía en Chile el testamento ológrafo otorgado en el extranjero en conformidad a las leyes del país en que se otorgó (sentencia de 27 de junio de 1864). Posteriormente, consideró que vale en Chile un testamento ológrafo otorgado en Francia, con las solemnidades que exigen sus leyes, aunque se refiera a bienes situados en nuestro país (sentencia de 14 de enero de 1927).[339] Nos parece que la doctrina correcta es la segunda, pues se trata de formalidades del acto.

Con todo, el citado principio no es obligatorio en la legislación chilena, sino *facultativo*. Es decir, los chilenos en el extranjero pueden optar por sujetarse a las leyes del país en que se otorga o celebra el acto o contrato o por actuar conforme a las chilenas, para realizar actos que hayan de surtir efecto en Chile. Si optan por la segunda alternativa, deberán acudir a los funcionarios diplomáticos o consulares

---

[337] Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), ob. cit., pp. 69 y 70.
[338] Claro Solar, Luis (1898), Nº 205, p. 114.
[339] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 118.

chilenos, que estén autorizados para desempeñar en estos casos funciones de ministro de fe. Entre otros actos, pueden otorgarse ante el Cónsul escrituras públicas o privadas y testamentos. En estos casos, de conformidad a las normas del Decreto Supremo Nº 172 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 29 de julio de 1977, que establece el "Reglamento Consular".

De tal forma, en cada caso concreto, los chilenos residentes en el extranjero decidirán ajustarse a las leyes extranjeras o a las chilenas, según más les convenga.

ii.- Requisitos necesarios para que un instrumento público otorgado en el extranjero conforme a la ley extranjera, tenga validez en Chile:

i) Se requiere que haya sido extendido con las formalidades prescritas por la ley del país en que se otorgó;

ii) Que se pruebe su autenticidad conforme a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. La autenticidad de los documentos públicos se refiere al hecho de:

1. Haber sido realmente otorgados por las personas que figuren en el instrumento; y
2. Haber sido realmente autorizados por las personas y de la manera que en los respectivos instrumentos se exprese (art. 17, inc. 2º).

La autenticidad de los instrumentos públicos se prueba en la forma que establecen los arts. 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil: se trata del trámite de "legalización" de los documentos.

iii.- Excepciones al principio *"Lex locus regit actum"*.

Son las siguientes:

i) El art. 1027, tratándose del otorgamiento de un *testamento*: "Valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la formas ordinaria". Esto supone que sólo se reconoce validez en Chile a los testamentos otorgados en país extranjero cuando fueren escritos. No se reconoce validez, en cambio, a un testamento verbal otorgado en otro país, cualquiera que sea el valor que las leyes de ese país le atribuyan.[340]

ii) El art. 2411, en las normas de la *hipoteca*: "Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero darán hipoteca sobre los bienes situados en Chile, con tal que se inscriban en el competente registro". Esto implica que, en la práctica, la hipoteca debe constar por *escritura pública*, porque si no, el Conservador de Bienes Raíces no la inscribirá, aunque la ley extranjera acepte un instrumento privado.

c.3.2) Ley que rige los requisitos internos o de fondo del acto o contrato.

Son requisitos internos o de fondo los contemplados en el art. 1445 del Código Civil, a saber:

i.- La *voluntad* (debe existir y además no debe estar viciada) y la *capacidad* de quienes otorgan o celebran el acto o contrato.

ii.- El *objeto* (debe existir y ser lícito) y la *causa* (debe existir y ser lícita) de dicho acto o contrato.

Como puede observarse, los dos primeros son requisitos personales o subjetivos, mientras que los dos últimos son requisitos objetivos, del acto jurídico de que se trate.

Por regla general, los requisitos internos, al igual que los externos, se rigen por la ley del país en que el acto o contrato se ejecuta o celebra. Así se desprende del art. 16, que después de aplicar la ley chilena a los bienes situados en Chile, agrega en su inc. 2: "Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño".

---

[340] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 415, p. 278.

Aunque la norma recién transcrita se refiera a "los contratos", se ha entendido que también se comprenden en ella los actos jurídicos unilaterales.[341]

Sin embargo, esta regla que se remite a la ley extranjera, debe matizarse. En efecto, al menos cuatro limitaciones pueden señalarse:

i) En cuanto a la *capacidad*: regirá la ley chilena y no la extranjera, si se trata de un chileno que otorga o celebra el acto o contrato. Lo anterior, conforme a lo que se establece en el art. 15, inc. 1°. En cambio, si se trata de un extranjero, se mantiene en pie la aplicación de la ley extranjera, pues en este caso no corresponde aplicar el art. 15.

ii) Tratándose del *contrato de matrimonio*: desde ya, sólo se reconocerá como tal al celebrado entre un hombre y una mujer (art. 80, Ley de Matrimonio Civil). Además, se aplicarán a los contrayentes las normas que se refieren a las incapacidades para contraer matrimonio y las que regulan los vicios de que puede adolecer la voluntad, contempladas en los arts. 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Matrimonio Civil.

iii) En el caso del *contrato de acuerdo de unión civil, o semejante celebrado en el extranjero*: deberá cumplirse con las normas que regulan los impedimentos de parentesco y los vicios de la voluntad (error y fuerza), contemplados en la Ley N° 20.830. En efecto, dispone el art. 12 de este cuerpo legal:

"Los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes, no constitutivos de matrimonio, que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el extranjero, serán reconocidos en Chile, en conformidad con las siguientes reglas:

1ª. Los requisitos de forma y fondo del acuerdo se regirán por la ley del país en que haya sido celebrado.

2ª. Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el acuerdo celebrado en territorio extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 7°, 8° y 9° de esta ley".

Los arts. 7 y 9, se refieren a impedimentos para celebrar el acuerdo de unión civil. El art. 9, a los vicios de la voluntad.

iv) En general, se ha estimado que otro límite a la eficacia en Chile de los actos otorgados en el extranjero, consistiría en la *eventual ilicitud del objeto o de la causa* de que estos pudieren adolecer. Lo anterior contravendría el orden público nacional. Así, por ejemplo, si se tratare de un contrato de compraventa de cocaína, celebrado en un país en el que tal acto estuviere permitido.[342]

c.3.3) Ley que rige la prueba de los actos jurídicos.

Dado que el acto o contrato otorgado o celebrado en el extranjero será presentado en Chile, su prueba deberá regirse por la ley chilena. En otros términos, la prueba será la misma, sea que el acto jurídico se otorgó en Chile o en el extranjero.

Así lo deja en claro el art. 18, en lo que se refiere a la prueba de instrumento público: "En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas".

Sobre este particular, Bello decía que "Los requisitos probatorios son materia de derecho público, contra el cual nada valen ni las leyes de un país extranjero, ni las convenciones privadas".[343]

El art. 18 guarda armonía con el art. 1701, que dispone en su inc. 1°: "La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiera esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun

---

[341] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 150.

[342] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 151.

[343] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 120.

cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno".

De esta manera, aunque la ley extranjera hubiere admitido probar el acto por instrumento privado, dicha prueba no se admitirá en Chile, cuando nuestra legislación exige que el acto se otorgue o celebre mediante instrumento público.

Cabe tener presente que tratándose de actos solemnes, la ley considera que no hay manifestación de voluntad si no se cumplen las formalidades por ella exigidas. Así, el contrato de compraventa de bienes raíces es solemne, porque debe otorgarse por escritura pública (art. 1801, inc. 2º). Igual cosa respecto de la hipoteca (art. 2409). Estos actos *no existen jurídicamente* mientras no se realice la solemnidad, y siendo así, es evidente que no podrá probarse su existencia por medio alguno que no sea la escritura pública.

Se entiende así la conexión existente entre los arts. 1701 y 18. Cabe señalar que el último, se aplica a chilenos y extranjeros, porque se refiere a los actos que van a producir efectos en Chile y en nuestro país sólo rige la ley chilena. Todo extranjero que fuera de Chile ejecute un acto que haya de tener efecto en nuestro país y que según nuestras leyes deba otorgarse por escritura pública, debe tener en claro que su acto no valdrá en Chile si no se cumple este requisito, aun cuando las leyes del país en que el acto se realiza no exijan dicha solemnidad.

Lo anterior puede parecer contradictorio con el principio "*Lex locus regit actum*" reconocido en el art. 17, pero en verdad no hay tal contradicción, atendido lo dispuesto en el inciso final del art. 16, que establece que los efectos de un contrato celebrado en el extranjero para cumplirse en Chile, deben sujetarse a nuestras leyes (en general, entendemos por efectos de un contrato los derechos y obligaciones originados por el mismo). Y en tal contexto, uno de los efectos de un contrato es su prueba (en este caso, por escritura pública), de manera que el art. 18 es una consecuencia del inciso final del art. 16.

c.3.4) Ley que rige los efectos de los actos jurídicos.

Los efectos de un acto jurídico corresponden a los derechos y las obligaciones que se crean, modifican, transfieren, transmiten o extinguen por aquél.

Dichos efectos deberán regirse por la ley chilena, conforme se desprende del art. 16, inc. 3°: "Los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas".

De esta manera, dice Ducci, "aunque se reconoce validez al contrato otorgado en el extranjero, los derechos y obligaciones emanados de él están sujetos a la ley chilena".[344]

Vodanovic plantea que los "efectos" a que alude el precepto corresponderían a los elementos de la naturaleza y a los accidentales del acto o contrato, y no a los de la esencia, porque estos últimos no son efectos del acto, sino el acto mismo, es decir, corresponden a sus elementos constitutivos. Siendo así, "la norma se refiere a los derechos y obligaciones que produce, y estos derechos y obligaciones pueden ser cosas de la naturaleza del contrato o cosas accidentales del mismo. Luego, que los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a la ley chilena, quiere decir que los derechos y obligaciones que de ellos emanan, sea por la naturaleza de esos contratos, sea por virtud de las cláusulas especiales que les agregaron las partes, serán los mismos que establece la legislación chilena o los que ella permite estipular a los contratantes".[345]

Comentando Corral esta tesis, que se explica "para así evitar que puedan ejecutarse en Chile contratos que vayan contra nuestro orden público o leyes imperativas chilenas", agrega que "quizás, eso deba ser controlado a través de los

---

[344] Ducci Claro, Carlos (1984), ob. cit., Nº 70, p. 71.
[345] Vodanovic H., Antonio (1990), ob. cit., Nº 418, p. 281.

requisitos internos (objeto ilícito o causa ilícita), o a través de la noción de orden público que es clave en todo el Derecho Internacional Privado. El artículo 16.3 no controla el contenido de los efectos, sino únicamente la forma de cumplimiento de ellos, es decir, su realización práctica o su reclamación en juicio".[346]

En todo caso, el precepto no dice que *todos* los efectos del contrato celebrado en el extranjero se regirán por la ley chilena, sino *sólo aquellos que deban cumplirse en Chile*. Lo precisa una sentencia de la Corte de Santiago de 2 de noviembre de 1953: "Los efectos de los contratos celebrados en país extranjero y que no deben cumplirse en Chile no están sujetos a la ley chilena. Los contratos celebrados en país extraño, aun cuando se refieran a bienes situados en Chile, ha de entenderse que, tanto en sus requisitos como en sus efectos, deben someterse a la ley del lugar en que se otorgaron; sólo precisan arreglarse a la ley chilena, en lo que a sus efectos toca, en caso de que deba dárseles cumplimiento en nuestro país".[347] Así, por ejemplo, si se celebra en el extranjero una compraventa de un inmueble situado en Chile, la tradición deberá efectuarse en nuestro país de conformidad al art. 686 del Código Civil, inscribiéndose el título en el Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Pero si en dicho contrato quedó pendiente de pago un saldo de precio, que debe pagarse en el extranjero, y que devenga una tasa de interés que podría exceder de la tasa máxima convencional prevista en la Ley Nº 18.010, pero se ajusta en cambio a lo dispuesto en la ley extranjera, se aplicará ésta última en lo que respecta a dicho pago y no la ley chilena, pues no se trata de un efecto que deba cumplirse en Chile. A contrario sensu, si de los términos del contrato se desprende que el pago de este saldo de precio debía hacerse en Chile, el comprador podría invocar en su favor la Ley Nº 18.010 y obtener que se rebaje el interés excesivo a la tasa de interés corriente. Ello sería así, porque se trataría de un efecto del contrato que debe cumplirse en Chile.

En ocasiones, puede ser dudoso si la cuestión que se litiga pertenece a la esfera de los requisitos internos o de fondo del contrato (en cuyo caso se aplica la ley extranjera, inc. 2º del art. 16) o al ámbito de los efectos del contrato que han de aplicarse en Chile (en cuyo caso se aplica la ley chilena, inc. 3º del art. 216). Así, por ejemplo, una sentencia de la Corte Suprema de 10 de agosto de 1906, concluye que "No puede admitirse la acción rescisoria por lesión enorme en la venta de unos derechos hereditarios celebrada en España y que recae sobre bienes situados en Chile, porque de acuerdo con la legislación de ese país no procede y, en conformidad al inciso 2º del artículo 16 de nuestro Código, en el punto cuestionado, es a aquella legislación a la cual hay que atenerse para resolver el caso". En voto disidente, dos ministros "sostienen que si la lesión enorme que da origen a la acción rescisoria afecta a los requisitos, a la esencia del contrato, la cuestión debe resolverse por la ley del lugar de la celebración de éste, porque todo lo que se relaciona con la esencia de la convención obedece a esa ley; si no afecta a tales requisitos, la cuestión sale de los dominios de ella. Pues bien, la acción rescisoria en referencia, a juicio de los citados Ministros, se deriva de un efecto del contrato, de la obligación particular que crea para los interesados. En consecuencia, el caso controvertido debe resolverse, no por las disposiciones legales españolas, sino de acuerdo con el inciso 3º del artículo 16 de nuestro Código Civil, por los preceptos de las leyes chilenas. Y estas también excluyen la acción rescisoria por lesión enorme en la venta de los derechos hereditarios".[348] Como puede observarse, sea que correspondiere resolver conforme al inc. 2º o al inc. 3º del art. 16, lo cierto es que la acción no podía prosperar, porque tanto en el Derecho español como en el Derecho chileno, la jurisprudencia ha entendido que no

---

[346] Corral Talciani, Hernán (2018), ob. cit., p. 153.
[347] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 114.
[348] *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), ob. cit., p. 117.

puede haber lesión enorme en la compraventa de un derecho real de herencia (hubo sin embargo un voto de minoría que estimó que sí debía declararse la rescisión del contrato por lesión enorme).

Bibliografía.

- Aftalión, Enrique R. (1956), García Olano, Fernando y Vilanova, José, *Introducción al Derecho*, 7ª edición, Buenos Aires, Editorial "La Ley".
- Aldunate Lizana, Eduardo (2009), "La fuerza normativa de la Constitución y el sistema de fuentes del derecho", en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, XXXII.
- Andreucci Aguilera, Rodrigo (2008), "Los conceptos de la Corte Suprema sobre interpretación de la ley a través de sus sentencias", *Nomos*, Universidad de Viña del Mar, Nº 1 (2008).
- Barillas, José (1967), "Las fuentes formales del ordenamiento jurídico", tesis doctoral, Universidad de El Salvador, Corte Suprema de Justicia, Biblioteca Judicial "Dr. Ricardo Gallardo", disponible en www.csj.gob.sv.
- Bascuñán Valdés, Antonio (1964), *Introducción al estudio de las ciencias jurídicas y sociales*, 2ª edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.
- Bascuñán Rodríguez, Antonio (2013), "El mito de Domat", en Fernando Atria y otros (Editores), *Una vida en la Universidad de Chile. Celebrando al profesor Antonio Bascuñán Valdés*, Thomson Reuters.
- Bello, Andrés (1981), *Principios de Derecho Internacional*, p. 180, en *Obras Completas*, Caracas, La Casa de Bello.
- Bello, Andrés, "Necesidad de fundar las sentencias", en *Obras Completas*, VII, Opúsculos jurídicos.
- Bermúdez Soto, Jorge (2010), "Estado actual del control de legalidad de los actos administrativos. ¿Qué queda de la nulidad de derecho público?", en *Revista de Derecho*, Vol. XXIII, Nº 1 – Julio 2010.
- Borda, Guillermo A. (2007), *Tratado de Derecho Civil. Parte General*, Tomo I, 12ª edición actualizada, Buenos Aires, Abeledo-Perrot.
- Borja, Luis F. (1899), *Estudios sobre el Código Civil Chileno*, Tomo Primero, Quito, Tip. De la Escuela de Artes y Oficios.
- Brebbia, Roberto H. (2000), *Instituciones de Derecho Civil*, I, Rosario, Editorial Juris.
- Claro Solar, Luis (1898), *Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, De las Personas*, Tomo Primero, Santiago de Chile, Establecimiento Poligráfico Roma.
- Cordero Quinzacara, Eduardo (2009), "Los principios y reglas que estructuran el ordenamiento jurídico chileno", en *Revista Ius et Praxis*, año 15, N° 2.
- Corral Talciani, Hernán (2018), *Curso de Derecho civil. Parte General*, Santiago de Chile, Thomson Reuters.
- Couture, Eduardo (1960), *Vocabulario Jurídico*, Montevideo, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La República.
- Coviello, Nicolás (2007), *Doctrina General del Derecho Civil*, Buenos Aires, Valletta Ediciones.
- Domínguez Benavente, Ramón y Domínguez Águila, Ramón (2011), *Derecho Sucesorio*, 3ª edición actualizada, Tomo I, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.
- Ducci Claro, Carlos (1984), *Derecho Civil. Parte general*, 2ª edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.

- Escudero de Quintana, Beatriz (2016), "La ultraactividad de las leyes en materia contractual. Análisis del último párrafo del artículo 7 del Código Civil y Comercial", en *Cuadernos Universitarios*, Publicaciones Académicas de la Universidad Católica de Salta (Argentina), núm. 9, 2016.
- Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier (2006), *La argumentación interpretativa de la justicia electoral mexicana*, México D.F., Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Fernández Concha, Rafael (1877), *Filosofía del Derecho o Derecho Natural*, Santiago de Chile, Imprenta de "El Correo", de R. Varela.
- Figueroa Yáñez, Gonzalo (2015), *Curso de Derecho Civil*. Tomo I, 5ª edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.
- Gómez Moreno, Ángel, y otros (2012), *Antología comentada de la literatura española. Edad Media*, dirigida por Andrés Amorós, Barcelona, Castalia Ediciones.
- Guzmán Brito Alejandro (2005), "El significado histórico de las expresiones 'equidad natural' y 'principios de equidad' en el Derecho Chileno", en *Estudios dogmáticos de derecho civil*, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- Guzmán Brito, Alejandro (2007), *Las Reglas del "Código Civil" de Chile sobre interpretación de las leyes*, Santiago de Chile, LexisNexis.
- Henríquez Viñas, Miriam (2017), "¿Derogación tácita o inaplicabilidad de preceptos preconstitucionales?", en *Estudios Constitucionales*, año 15, N° 1, 2017, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca.
- Mijangos Borja, María de la Luz (1995), "La naturaleza jurídica del presupuesto", en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Nº 82.
- Navarro Beltrán, Enrique (2018), *Las acciones constitucionales económicas ante los tribunales de justicia*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Finis Terrae.
- Paul, Jacques (2003), *Historia intelectual del occidente medieval*, España, Ediciones Cátedra.
- Pedrals García de Cortázar, Antonio (2010), en su trabajo "Sobre la 'abstracta y difusa' noción de equidad natural", publicado en *Estudios de Derecho Civil V*, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Concepción, 2009, AbeledoPerrot-LegalPublishing.
- Pescio Vargas, Victorio (1948), *Manual de Derecho Civil. Título Preliminar del Código Civil*, I, Santiago de Chile, Nascimento.
- Portalis, Jean-Etienn Marie, "Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de la commission du gouvernement", en Fenet, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil*, t. I.
- Ramos Núñez, Carlos (2009), "Consideración de la costumbre en la doctrina jurídica virreinal. De la valoración clásica a su impugnación moderna", en *La tradición clásica en el Perú Virreinal*, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- *Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias* (1996), Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, tomo I.
- Rodríguez Grez, Pablo (1990), *Teoría de la interpretación jurídica*, Santiago de Chile, edición privada.
- Rodríguez Grez, Pablo, "Sobre la interpretación jurídica", en *El Mercurio*, cuerpo A, edición del 27 de enero de 2013.
- Rojas Chamaca, Julio (2013), *La derogación tácita de preceptos preconstitucionales por la jurisdicción ordinaria. Análisis jurisprudencial después de la reforma constitucional de 2005*, Santiago de Chile, Editorial Metropolitana.
- Rossel Saavedra, Enrique (1994), *Manual de Derecho de Familia*, 7ª edición actualizada, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.

- Ruz Lártiga, Gonzalo (2011), *Explicaciones de Derecho Civil. Parte general y acto jurídico*, Tomo I, Santiago de Chile, AbeledoPerrot Legal Publishing Chile.
- Serrano, Enrique, "La Teoría Aristotélica de la Justicia", en *Isonomía* Nº 22/Abril 2005, México.
- Somarriva Undurraga, Manuel (1936), *Derecho de Familia*, Santiago de Chile, Editorial Nascimento.
- Squella Narducci, Agustín (2004), *Introducción al Derecho*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.
- Vodanovic H., Antonio (1990), *Derecho Civil. Parte Preliminar y Parte General, Explicaciones basadas en las versiones de clases de los profesores de la Universidad de Chile Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva U., redactadas, ampliadas y actualizadas por Antonio Vodanovic H.*, Santiago de Chile, Ediar Conosur Ltda., Tomo 1º, 5ª edición.
- Williams Benavente, Jaime (1999), *Lecciones de Introducción al Derecho*, Santiago de Chile, Ediciones Fundación de Ciencias Humanas, 3ª edición, actualizada.
- www.expansiom.com/diccionario-juridico/interpretacion-teleologica-o-finalista.

Cuestionario:

1.- A) ¿Cómo define la ley el art. 1º del Código Civil? B) ¿Qué críticas se han formulado a esta definición?
2.- Proporcione una definición doctrinaria de ley.
3.- ¿Cuáles son los requisitos externos de la ley? Explíquelos brevemente.
4.- ¿Qué quórum se exige para aprobar, modificar o derogar las distintas clases de leyes? En cada caso, ¿qué fracción de diputados y senadores siempre debe asistir a la respectiva sesión?
5.- ¿A qué se atiende con los requisitos internos de la ley?
6.- A) ¿Qué se entiende por ley imperativa? B) ¿De qué clases pueden ser?
7.- A) ¿Qué se entiende por leyes imperativas propiamente tales? B) Proporcione tres ejemplos –de los revisados en la cátedra-, de leyes imperativas propiamente tales.
8.- A) ¿Qué se entiende por leyes imperativas de requisito? B) Proporcione tres ejemplos –de los revisados en la cátedra-, de leyes imperativas de requisito.
9.- A) ¿Qué se entiende por leyes prohibitivas? B) Proporcione tres ejemplos –de los revisados en la cátedra-, de leyes prohibitivas.
10.- ¿Qué se entiende por leyes permisivas? Proporcione un ejemplo.
11.- Refiérase a la sanción, en caso de infringir una ley imperativa. Al efecto, explique lo postulado por Carlos Ducci.
12.- Refiérase a la sanción, en caso de infringir una ley prohibitiva. Indique cuál es la regla general y los casos excepcionales.
13.- Refiérase a la sanción de una ley permisiva.
14.- ¿Cómo se clasifican las leyes?
15.- ¿Qué causas determinan al legislador a dictar leyes prohibitivas e imperativas?
16.- ¿Qué se entiende por leyes dispositivas? Proporcione uno de los ejemplos revisados en la cátedra.
17.- Explique el distingo entre leyes materiales y leyes formales.
18.- Explique el distingo entre leyes perfectas, más que perfectas, menos perfectas e imperfectas.
19.- Indique los distintos escalones en que se ordenan jerárquicamente las normas jurídicas, y en cada uno qué normas se contemplan.

20.- A) ¿Qué opiniones se han formulado, acerca de la jerarquía de los tratados que consagra derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana? B) ¿Qué precepto de la Constitución Política ha originado esta discusión?
21.- A) ¿Qué controles operan en la escala jerárquica de normas jurídicas? B) ¿Qué órganos ejercen estos controles?
22.- A) ¿A qué órgano administrativo corresponde el control de legalidad? B) ¿Cómo opera este control?
23.- ¿Por qué afirmamos que, en la práctica, el control de la constitucionalidad también corresponde a los tribunales ordinarios de justicia?
24.- ¿En virtud de qué factores se jerarquizan las normas jurídicas? Explíquelos brevemente.
25.- A) ¿Qué se entiende por constitucionalidad de fondo? B) ¿Qué se entiende por constitucionalidad de forma? C) Proporcione un ejemplo, de los revisados en la cátedra, de ley inconstitucional en el fondo y de ley inconstitucional en la forma.
26.- En el control de la constitucionalidad que corresponde al Tribunal Constitucional, enumere las atribuciones que tiene este órgano.
27.- A) ¿Qué objetivo tiene la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad? B) ¿Qué quórum se requiere para que el Tribunal Constitucional la acoja?
28.- A) ¿Qué objetivo tiene la acción de inconstitucionalidad? B) ¿Qué quórum se requiere para que el Tribunal Constitucional la acoja?
29.- ¿Qué diferencia se aprecia, según si el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de un decreto supremo, de un auto acordado, de un decreto con fuerza de ley o de una ley?
30.- ¿Qué diferencias se aprecian entre la acción de inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad?
31.- ¿Qué se ha planteado acerca de la clase de inconstitucionalidad que se puede atacar mediante el recurso de inaplicabilidad o mediante el recurso de inconstitucionalidad?
32.- A) ¿Cómo se define la potestad reglamentaria en sentido propio y estricto? B) ¿Cómo se la define en un sentido amplio? C) Considerada en toda su extensión, ¿en qué instrumentos se manifiesta?
33.- ¿Qué autoridades administrativas tienen potestad reglamentaria?
34.- A) ¿Qué comprende la potestad reglamentaria del Presidente de la República? B) Conforme a lo anterior, ¿qué denominaciones asume dicha potestad reglamentaria en uno u otro caso?
35.- ¿Qué se entiende por un reglamento de ejecución? Proporcione dos ejemplos, de los revisados en la cátedra.
36.- ¿Qué se entiende por reglamentos autónomos?
37.- A) ¿Cómo se define el decreto en general? B) ¿Cuándo recibe el nombre de decreto supremo? C) ¿Cómo se clasifican los decretos?
38.- A) ¿Qué se entiende por reglamento o decreto reglamentario? B) ¿Qué se entiende por simple decreto o decreto individual? C) ¿Qué firmas deben llevar los decretos?
39.- A) ¿Qué órgano ejerce el control de legalidad de los decretos? B) ¿Qué puede hacer el Presidente de la República si el aludido órgano no les diere curso?
40.- ¿Qué semejanzas se aprecian entre la ley y el decreto?
41.- ¿Por qué se afirma que la ley y el decreto no se diferencias necesariamente en su objeto o contenido ni en generalidad e impersonalidad?
42.- ¿En qué se diferencian, esencialmente, la ley y el decreto?
43.- ¿Qué clases de instrucciones o circulares existen? Explíquelas brevemente.
44.- ¿Qué clases de ordenanzas existen? Explíquelas brevemente.
45.- ¿Qué se entiende por decreto con fuerza de ley?
46.- ¿Por qué se ha discutido la constitucionalidad de los decretos con fuerzas de ley?

47.- El art. 64 de la Constitución Política, faculta al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley. ¿Qué limitaciones se establecen al respecto?
48.- La Constitución Política prohíbe dictar decretos con fuerzas de ley en diversas materias. Indique tres de ellas.
49.- A) ¿Por qué razones el Contralor General de la República puede negarse a tomar razón de un decreto con fuerza de ley? B) En tal caso, ¿de qué facultad carece el Presidente de la República? C) ¿Qué puede hacer el Presidente de la República y en qué plazo, para que se dirima el conflicto?
50.- ¿Qué se entiende por decreto ley?
51.- Aunque los decretos leyes se han dictado al margen del ordenamiento constitucional, ¿por qué razón la jurisprudencia terminó por aceptarlos?
52.- ¿En qué períodos de nuestra historia se han dictado decretos leyes?
53.- A) ¿Qué jerarquía tienen los decretos leyes? B) ¿Cómo pueden ser modificados o derogados?
54.- ¿Qué acepciones admite la palabra interpretación? Explíquelas brevemente.
55.- A) ¿Cómo se define la interpretación jurídica? B) ¿Cuándo corresponde que opere esta clase de interpretación?
56.- ¿Qué normas del Código Civil se refieren a la interpretación de la ley, de los contratos y de los testamentos?
57.- A) ¿Qué sistemas de interpretación existen? B) ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen?
58.- ¿De qué clases puede ser la interpretación de la ley? Cuando corresponda, formule la pertinente subdivisión.
59.- ¿Quiénes realizan la interpretación doctrinal o privada? Indique alguna de las normas legales que se refieren a ella.
60.- ¿Qué diferencia –conforme al art. 3 del Código Civil-, se aprecia entre la interpretación hecha por el legislador y aquella hecha por el juez?
61.- A) ¿Qué funcionario público está facultado para realizar una interpretación administrativa? B) ¿Qué puede hacer el particular a quien afecte dicha interpretación?
62.- ¿Qué elementos de interpretación de la ley señala Savigny? Explíquelos brevemente.
63.- A) ¿De qué especies puede ser la interpretación? B) ¿Atendiendo a qué se formula este distingo?
64.- ¿Cuándo corresponde hacer una interpretación declarativa? Proporcione uno de los ejemplos revisados en la cátedra.
65.- ¿Cuándo corresponde hacer una interpretación extensiva? Proporcione uno de los ejemplos revisados en la cátedra.
66.- ¿Cuándo corresponde hacer una interpretación restrictiva? Proporcione uno de los ejemplos revisados en la cátedra.
67.- Se ha sostenido que, respecto de ciertas leyes, su interpretación debiera ser siempre restrictiva. Mencione tres de estos casos. ¿Cuál fue la opinión de la cátedra al respecto?
68.- A) El art. 23 del Código Civil descartó el principio de "lo favorable y lo odioso". ¿Cómo se aplicaba dicho principio en el Derecho antiguo? Proporcione tres ejemplos en que se aplicaba el principio, proporcionados por Andrés Bello. B) ¿Por qué tal principio no se admitió en nuestro Código Civil? C) ¿Por qué se afirmó en la cátedra que no obstante lo expuesto por el art. 23, podría sin embargo aplicarse el principio de "lo favorable y lo odioso" en el marco de lo dispuesto en el art. 24?
69.- ¿Qué métodos de interpretación de la ley se revisaron en la cátedra?
70.- Resuma los planteamientos del método lógico tradicional de la interpretación de la ley e indique la principal crítica que se le ha formulado.
71.- Resuma los planteamientos del método histórico evolutivo de la interpretación de la ley e indique la principal crítica que se le ha formulado.

72.- Explique brevemente los planteamientos del método de la libre investigación científica de la interpretación de la ley.
73.- ¿Qué propone el método positivo teleológico de interpretación de la ley? ¿Qué críticas se le han formulado?
74.- Resuma los postulados del método de la escuela del Derecho libre de interpretación de la ley.
75.- Reuma los postulados de la teoría "creacionista", que postula el profesor Pablo Rodríguez Grez como método de interpretación de la ley.
76.- Respecto de la interpretación judicial, señale quién la realiza, qué fases la integran (y qué hace en cada una de ellas el intérprete) y qué elementos la integran.
77.- ¿Cuál es la interpretación legal o auténtica, de qué manera se realiza y a qué debe limitarse?
78.- ¿Qué ficción legal establece el art. 9 del Código Civil acerca de la interpretación legal o auténtica?
79.- ¿Quiénes pueden tener iniciativa para llevar a cabo la interpretación legal o auténtica?
80.- ¿Qué alcance tiene la interpretación legal o auténtica?
81.- ¿Qué se señala acerca de la retroactividad, con relación a las leyes interpretativas?
82.- ¿Cuáles son las limitaciones de la ley interpretativa?
83.- ¿A qué elemento de interpretación de la ley se refiere el inc. 1º del art. 19 del Código Civil y en qué términos?
84.- Conforme se desprende del art. 19 del Código Civil, para no desatender el tenor literal de la ley es necesario que el sentido de esta sea claro. Conforme a lo estudiado, ¿cuándo se entiende que dicho sentido es claro?
85.- A) ¿En qué sentidos pueden emplearse las palabras en un precepto legal? B) ¿En qué artículos del Título Preliminar del Código Civil se alude a dichos sentidos?
86.- A) ¿A qué corresponde el sentido "natural y obvio" de las palabras? B) ¿Dónde debe indagarse dicho sentido, conforme a la jurisprudencia tradicional? C) ¿Qué plantean postulados más modernos?
87.- ¿Cuándo debe recurrirse al sentido "legal" de las palabras?
88.- ¿Qué se entiende por sentido "técnico" de las palabras?
89.- Considerando los tres sentidos en que puede emplearse una palabra en la ley, ¿en qué orden deben operar?
90.- A) ¿En qué normas del Título Preliminar del Código Civil se alude al elemento lógico de interpretación de la ley? B) ¿Qué aspectos se comprenden en este elemento? Explíquelos brevemente.
91.- ¿En qué norma del Título Preliminar del Código Civil se alude al elemento histórico de interpretación de la ley y en qué consiste dicho elemento?
92.- ¿En qué norma del Título Preliminar del Código Civil se alude al elemento sistemático de interpretación de la ley y en qué consiste dicho elemento?
93.- A) ¿Qué presupuestos deben cumplirse para que opere el elemento sistemático en la interpretación de una ley? B) Si se cumplen dichos presupuestos, ¿en qué consistirá la labor del intérprete?
94.- A) La analogía puede emplearse por el intérprete en dos casos. ¿Cuáles son y qué función se cumple en uno y otro? B) ¿Cómo las denomina la doctrina, según la función que cumpla la analogía?
95.- A) ¿En qué norma del Título Preliminar del Código Civil se alude al espíritu general de la legislación? B) ¿Qué presupuestos deben cumplirse para que el juez pueda recurrir a dicho espíritu general de la legislación?
96.- A) ¿Qué consideró la doctrina tradicional respecto del espíritu general de la legislación? B) ¿Qué ha postulado la doctrina más reciente?

97.- ¿A qué corresponde el espíritu general de la legislación y en qué se diferencia de uno de los aspectos presentes en el elemento lógico de interpretación de la ley?
98.- A) ¿En qué se sistematiza el espíritu general de la legislación? B) ¿Qué relación se deriva de esta sistematización?
99.- El profesor Hernán Corral distingue entre principios "intrasistémicos" y "extrasistémicos". Explique brevemente dicho distingo.
100.- A) ¿Qué relación jerárquica se planteó por la cátedra, respecto al distingo entre principios "intrasistémicos" y "extrasistémicos"? B) ¿De qué precepto de la Constitución Política puede desprenderse dicha relación jerárquica? C) ¿Qué limitación al Derecho nacional se desprende de este precepto constitucional?
101.- A) ¿En qué norma del Título Preliminar del Código Civil se alude a la equidad natural? B) ¿Qué se ha entendido por ella por la doctrina nacional? C) ¿Con qué expresiones debe vincularse también la palabra equidad?
102.- ¿Autoriza el Código Civil al juez para fallar conforme a la equidad natural, cuando le parezca injusta la norma positiva?
103.- ¿Por qué se afirma que la equidad debe emplearse conforme a un criterio objetivo y no puramente subjetivo?
103.- ¿Con qué elemento de interpretación está o puede estar muy ligada la equidad natural? Explique brevemente esta relación.
105.- ¿En qué consiste el carácter "general" que debe contener la interpretación fundada en la equidad natural?
106.- A) ¿Qué doctrinas o criterios se han planteado para que el juez concrete y precise la interpretación fundada en la equidad natural? B) ¿Cuál de estas doctrinas o criterios debiera descartarse, conforme a la opinión de la cátedra, y por qué?
107.- ¿Por qué la equidad natural no puede servir para corregir la injusticia que pudiera resultar de la aplicación de la ley?
108.- ¿Qué rol puede desempeñar la equidad natural, si una ley puede interpretarse en dos sentidos?
109.- ¿En qué caso el juez no sólo puede, sino que debe recurrir a la equidad natural?
110.- Indique y explique brevemente cinco casos, de los revisados en la cátedra, en los cuales el Código Civil se remite explícitamente a la equidad o a la "prudencia" o a lo "equitativo", de manera que el juez debe aplicarla para resolver el conflicto o materia
111.- ¿En qué caso la equidad natural desempeña un rol integrador del Derecho?
112.- La equidad natural puede servir de factor determinante para resolver el conflicto o materia en tres casos. A) ¿Cuáles son y qué rol desempeña en cada uno de ellos la equidad natural? B) ¿Qué diferencia se aprecia además entre los dos primeros casos y el tercero?
113.- Si la equidad natural opera como factor de integración del Derecho, ¿en qué orden debe emplearse, conforme a lo estudiado en la cátedra?
114.- Si la equidad natural opera como factor de integración del Derecho y en el marco de la misma se recurre a la analogía, ¿qué preceptos legales no pueden aplicarse para resolver el conflicto o materia?
115.- Si la equidad natural como factor de integración del Derecho no puede fundarse en la analogía, ¿qué cabe exigir en el razonamiento del juez?
116.- Cualquiera fuere el rol que desempeñe la equidad natural, ¿con qué presupuestos debe cumplir?
117.- De lo estudiado a propósito de la interpretación de la ley, A) ¿Cuándo estamos ante la *analogía legis*? B) ¿Cuándo en cambio estamos ante la *analogía iuris*?
118.- A) ¿En qué consiste el principio de la especialidad? B) ¿En qué normas del Título Preliminar está contemplado?
119.- A) ¿En qué consisten las reglas prácticas de interpretación? B) ¿Cuáles se revisaron en la cátedra?

120.- A) ¿En qué consiste el argumento de analogía? B) ¿Bajo qué fórmula se enuncia? C) ¿En qué se diferencia la interpretación extensiva del argumento de analogía?
121.- Señale y explique brevemente tres casos, de los revisados en la cátedra, en los que la ley autoriza recurrir a la aplicación por analogía de una norma.
122.- A) ¿En qué consiste el argumento de contradicción? B) ¿Bajo qué fórmula se enuncia? C) Señale uno de los ejemplos revisados en la cátedra.
123.- A) ¿En qué consiste el argumento a fortiori? B) ¿Bajo qué fórmulas se enuncia? C) Proporcione el ejemplo revisado en la cátedra, en cada caso.
124.- A) ¿En qué consiste el argumento de no distinción? B) ¿Bajo qué fórmula se enuncia? C) Señale dos de los ejemplos revisados en la cátedra.
125.- ¿En qué consiste el argumento del absurdo? Proporcione uno de los ejemplos revisados en la cátedra.
126.- ¿Cuándo debe integrarse la ley?
127.- ¿Qué normas ordenan integrar la ley?
128.- A) ¿Cómo debe integrarse la ley? B) ¿Cuándo no corresponde integrar la ley?
129.- ¿Desde qué puntos de vista pueden estudiarse los efectos de la ley?
130.- Una vez que la ley es sancionada por el Presidente de la República, A) ¿qué condiciones son necesarias para que sea obligatoria? B) ¿Qué artículo del Título Preliminar del Código Civil establece dichas condiciones?
131.- A) ¿Qué se entiende por promulgación de la ley? B) ¿Cómo se verifica? C) ¿En qué plazo debe promulgarse, una vez aprobado el Proyecto?
132.- A) ¿Qué se entiende por publicación de la ley? B) ¿En qué plazo debe publicarse la ley?
133.- ¿Qué dispone el art. 7 del Código Civil, acerca de la publicación de la ley?
134.- A) ¿Cómo se denomina el espacio de tiempo existente entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley? B) ¿Con qué propósito puede establecerse dicho plazo? C) ¿Qué sistemas se establecen en el Derecho comparado? D) ¿Cuál es el que adopta nuestra Derecho?
135.- A) ¿Qué dispone el art. 8 del Código Civil? B) ¿Por qué se afirma que en dicho artículo se consagra una "ficción" y no una verdadera "presunción"?
136.- ¿Con qué normas se relaciona el art. 8 del Código Civil y por qué?
137.- Indique uno de los casos, de los revisados en la cátedra, en los que se admite error de derecho.
138.- A) ¿Qué se entiende por derogación de la ley? B) ¿Cuál es el fundamento de la derogación legal? C) ¿En qué caso la derogación de la ley opera de una manera distinta a la prevista en el Código Civil? D) ¿De qué clases puede ser la derogación de la ley según el Código Civil? E) ¿Qué artículos del Título Preliminar se refieren a ellas?
139.- A) ¿Qué se entiende por derogación expresa de la ley? B) ¿Qué se entiende por derogación tácita de la ley? C) ¿Qué diferencia radical se observa entre ambas?
140.- A) ¿Qué se entiende por derogación orgánica de la ley? B) ¿Qué es necesario para que opere? C) Para muchos autores la derogación orgánica no sería sino una especie de otra clase de derogación. ¿Cuál sería?
141.- ¿Cómo se clasifica la derogación de la ley en cuanto a su alcance?
142.- Cuando una nueva norma fuere de rango constitucional y sus términos son inconciliables con aquellos de una ley precedente, ¿qué cuestiones fundamentales se han planteado por la doctrina? Explíquelas brevemente.
143.- Para un sector de la doctrina, cuando una norma fuere de rango constitucional y sus términos son inconciliables con aquellos de una ley, ¿de qué dependerá para determinar cuál es el órgano llamado a resolver la cuestión?
144.- Para el profesor Julio Rojas, ¿en virtud de qué argumentos puede declararse la derogación tácita de preceptos preconstitucionales por la justicia ordinaria?

145.- A) ¿En qué consiste la doctrina del llamado control difuso de la constitucionalidad? B) Conforme a esta doctrina, ¿qué facultad se le reconocería a los tribunales ordinarios de justicia?
146.- ¿Qué consecuencias derivan –para la profesora Miriam Henríquez-, del hecho que la Constitución sea fuente del Derecho con eficacia directa y que su garantía jurisdiccional se encuentre concentrada desde la reforma del año 2005 en el Tribunal Constitucional?
147.- A) ¿Qué consecuencias se producen si con posterioridad a la promulgación de una ley general se dicta una ley especial sobre la misma materia? B) Por el contrario, ¿qué consecuencias se producen cuando a una ley especial sucede una ley general?
148.- ¿Qué efectos se producen si una ley derogatoria es posteriormente derogada? Fundamente su respuesta.
149.- ¿Qué es necesario para que una ley derogada recobre su vigencia?
150.- ¿Qué se entiende por leyes "restauradoras" o "restablecedoras"?
151.- ¿Qué causas intrínsecas pueden hacer cesar la eficacia de la ley? Proporcione un ejemplo en cada caso.
152.- Respecto de la vigencia y obligatoriedad de una ley, ¿qué períodos pueden distinguirse?
153.- Normalmente, ¿durante qué período una ley es obligatoria?
154.- ¿Qué reglas contiene el art. 9 del Código Civil?
155.- ¿Cuándo se entiende que una ley tiene efecto retroactivo?
156.- ¿Cuándo se entiende que una ley tiene efecto inmediato?
157.- ¿Cuándo nos encontramos ante ultractividad de una ley?
158.- ¿Qué justificación tiene la irretroactividad de la ley?
159.- ¿Cómo opera el principio de la irretroactividad de la ley, frente al legislador? Formule los distingos del caso.
160.- ¿Cómo opera el principio de la irretroactividad de la ley, frente al juez?
161.- En aquellos casos en que la ley puede tener efecto retroactivo, ¿cómo debe establecerse ésta? Fundamente su respuesta.
162.- Conforme a la teoría de Blondeau, ¿cuándo una ley es retroactiva?
163.- A) ¿Qué se entiende por simples expectativas? B) ¿Qué se entiende por facultades legales? C) ¿Cómo se definen los derechos adquiridos?
164.- A) De acuerdo a la teoría de Paul Roubier, ¿qué se entiende por una "situación jurídica"? B) ¿En qué aspectos puede verse afectada una situación jurídica por una ley nueva? C) Conforme a la misma teoría, ¿cuándo tendrá efecto retroactivo la ley nueva y cuándo tendrá efecto inmediato?
165.- ¿En el marco de la teoría de Paul Roubier, qué importante excepción puede tener el efecto inmediato de la ley nueva?
166.- ¿Cómo pueden sintetizarse los planteamientos de Paul Roubier acerca de una situación jurídica?
167.- ¿Qué finalidad tiene la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes?
168.- Indique seis materias reguladas por la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes.
169.- ¿Qué distingos cabe formular acerca del estado civil, en el marco de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes? Explique brevemente cada situación.
170.- ¿Qué establece el art. 10 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de las personas jurídicas?
171.- ¿Qué distingo cabe formular, en el marco de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de la capacidad? Explique brevemente cada situación.
172.- ¿Qué reglas contiene el art. 12 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de los bienes?
173.- ¿Qué regla contiene el art. 13 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de la posesión?

174.- ¿Qué reglas contiene el art. 14 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de los derechos deferidos bajo una condición?
175.- ¿Qué reglas contienen los arts. 18 y 19 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de la sucesión testada?
176.- ¿Qué regla contiene el art. 20 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de la sucesión intestada?
177.- ¿Qué regla contiene el art. 21 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de la partición y adjudicación?
178.- ¿Qué regla contiene el art. 22 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de los contratos?
179.- De acuerdo al profesor Hernán Corral, ¿qué compone el "contenido invariable" de un contrato?
180.- De acuerdo a la cátedra, ¿qué distingos cabe formular en relación a los contratos celebrados bajo la vigencia de la ley antigua?
181.- ¿Qué excepciones se establecen en los arts. 22 y 23 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de la regla general aplicable a los contratos?
182.- A) ¿Qué regla contiene el art. 24 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de las normas relativas al procedimiento? B) ¿Qué salvedades se contemplan en el mismo precepto?
183.- ¿Qué regla contiene el art. 25 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva?
184.- ¿Qué regla contiene el art. 26 de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, acerca de la prescripción adquisitiva?
185.- A) ¿En qué consiste el principio territorial de la ley? B) ¿En qué consiste el principio personal de la ley? C) ¿Qué dificultades se observan si se aplica uno u otro en términos absolutos?
186.- ¿Qué normas del Código Civil consagran el principio de territorialidad de la ley y en qué aspectos?
187.- ¿En qué normas de nuestra legislación está presente el principio de la territorialidad absoluta de la ley chilena?
188.- Señale las excepciones al principio de la territorialidad consagrado en el art. 14 del Código Civil.
189.- A) ¿Qué beneficio consagra el art. 57 del Código Civil? B) ¿Qué compensa dicho artículo?
190.- El art. 15 del Código Civil consagra casos de extraterritorialidad de la ley chilena. ¿Por qué puede sostenerse que este precepto no supone una inconsecuencia en relación con lo dispuesto en el art. 14 del mismo Código?
191.- ¿Cuál es el fundamento de los casos de extraterritorialidad contemplados en el art. 15 del Código Civil?
192.- ¿Por qué se afirma que el art. 15 del Código Civil tiene aplicación restrictiva?
193.- ¿Cuál es el caso de extraterritorialidad consagrado en el Nº 1 del art. 15 del Código Civil? Proporcione un ejemplo.
194.- ¿Cuál es el caso de extraterritorialidad consagrado en el Nº 2 del art. 15 del Código Civil? ¿Qué otra norma del Código Civil está directamente ligada con la primera?
195.- ¿Qué dispone el art. 16, inc. 1º del Código Civil, acerca de las "leyes reales"?
196.- ¿Qué excepciones se contemplan en nuestro Código Civil, a la regla general del art. 16, inc. 1º, del Código Civil, acerca de las "leyes reales"?
197.- ¿Qué distingos cabe formular, en cuanto a la ley aplicable, respecto de las leyes relativas a los actos y contratos otorgados o celebrados en el extranjero y que vayan a tener efectos en Chile?
198.- A) ¿Qué se entiende por requisitos externos o de forma de un acto? B) ¿Qué ley rige los requisitos externos o de forma de los actos jurídicos otorgados en el extranjero

y que producirán efectos en Chile? C) ¿Qué preceptos del Código Civil resuelven esta interrogante? D) ¿Por qué se afirma que lo anterior es facultativo y no obligatorio para los chilenos?
199- ¿Qué requisitos deben cumplirse para que un instrumento público otorgado en el extranjero tenga validez en Chile?
200.- ¿Qué excepciones se indicaron al principio *lex locus regit actum*?
201.- ¿Cuáles son los requisitos internos o de fondo de un acto o contrato?
202.- A) ¿Qué ley rige, por regla general, los requisitos internos del acto otorgado en el extranjero? B) ¿Qué precepto del Código Civil dispone dicha regla general? C) ¿Qué limitaciones deben señalarse a esta regla general?
203.- Respecto de la prueba de un acto o contrato otorgado o celebrado en el extranjero, ¿qué se desprende de los arts. 18 y 1701 del Código Civil?
204.- A) ¿Qué ley rige los efectos de un acto o contrato? B) ¿Qué precepto del Código Civil resuelve esta materia?

_____******_____